بغية المحتاج

إلى مواطن الاختلاف

بين نصوص الشافعي والمنهاج

تأليف

أبي عبد الباري الصومالي

د. محمود بن محمد الشبلي

المجلد الثاني

بغية المحتاج

إلى مواطن الاختلاف

بين نصوص الشافعي والمنهاج

تأليف

أبي عبد الباري الصومالي

د. محمود بن محمد الشبلي

عنوان الكتاب: بغية المحتاج إلى مواطن الاختلاف بين نصوص الشافعي والمنهاج

تأليف: أبي عبد الباري الصومالي | د. محمود بن محمد الشبلي

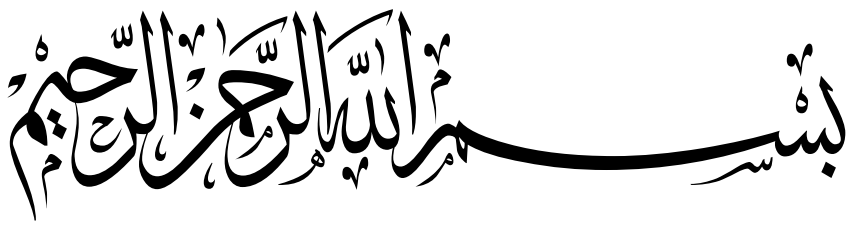
المجلد: الثاني

عدد الصفحات: ٤٢١

سنة الطباعة: ١٤٤٧هـ - ٢٠٢٦م

الطبعة: الأولى

جميع الحقوق الملكية محفوظة لمؤلف الكتاب
يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب


بسم الله الرحمن الرحيم



كتاب الجراح

باب كيفية القصاص

[٦٤] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٠٩ ط. الحداد): «ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما، فإن ألحقه القائف بالآخر اقتص، وإلا فلا».

ما جزم به النووي هنا من وجوب القصاص علىٰ القاتل إذا ألحق القائف بعد القتل بغيره، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٢٩٠) ولفظه: «ولو تداعىٰ اثنان ولدا مجهولا، ثم قتله أحدهما، لم يقتص في الحال، فإن ألحقه القائف بعد ذلك بالقاتل فلا قصاص، وإن ألحقه بالآخر اقتص منه».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ١٦٧): «وإن ألحقه بالآخر، اقتص من القاتل، وكذا لو ألحقه بغيرهما»، وتبعه النووي في الروضة (٩/ ١٥٣).

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحه الشيخان هنا مخالف لنص الشافعي، فإنه نص علىٰ أنه يدرأ عنه القود للشبهة.

قال الشافعي الأم (٧/ ٨٨ ط. د. رفعت فوزي) في الرجل يقتل ابنه: «وإذا تداعىٰ الرجلان ولدا، فقتله أحدهما قبل يبلغ، فينتسب إلىٰ أحدهما، أو يراه

القافة، درأت عنه القود للشبهة، وجعلت الدية في ماله، وكذلك لو قتلاه جميعا.

قال: وإذا أكذبا أنفسهما إذا كانا قاتلاه بالدعوة لم أقتلهما؛ لأني ألزمه أحدهما، وإن أكذب أحدهما نفسه بالدعوة قتلته به؛ لأن ثم أبا أنسبه إليه إذا كان قبل يختاره، أو يلحقه القافة بأحدهما».

فقوله «أو يراه القافة» أي قتله قبل أن يراه القافة فيلحقوا به، ثم ذكر الشافعي بعد ذلك أنه لا يقتل به إذا أكذبا أنفسهما في دعوىٰ الولد، فلا قصاص ما لم يبلغ، أو تلحقه القافة بأحدهما.

وعلىٰ هذا فالمنصوص المعتمد أنه لا قصاص في هذه المسألة إلا بشرطين:

الأول: ألا يبلغ فينتسب لغير القاتل، وإلا وجب القصاص علىٰ القاتل الذي لم ينتسب إليه بعد بلوغه.

الثاني: أن يكون القتل بعد إلحاق القافة بأحدهما، فإن كان قبل ذلك فلا قصاص للشبهة.

قال الماوردي في الحاوي (١٢/ ٢٤): «وإن قتله أحدهما قبل البيان فلا قود عليه سواء لحق بالقاتل أو بالآخر؛ لثبوت الشبهة فيه عند قتله».

وقال فيه أيضا (١٢/ ٢٥): «وإن قتل قبل البيان فلا قود علىٰ واحد منهما،

سواء بان من بعدُ أنه أبٌ أو غير أبٍ؛ لثبوت الشبهة حال القتل».

وتبعه الروياني في بحر المذهب (١٢/ ٢٢، ٢٣).

وحكاه الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ١٦٧) وجها للقاضي ابن كج فقال: «وحكىٰ القاضي ابن كج وجها: أنه لا يقتص من الآخر أيضا، ووجهه بأن إلحاق القائف، مبني علىٰ الإمارات وهو ضعيف، فلا يناط به القصاص الذي يسقط بالشبهات، بخلاف الإلحاق بالفراش» وتبعه الدميري في النجم (٨/ ٣٦٦) .

وقال الأذرعي في القوت (٨/ ٦٩، ٧٠) عن ابن القطان والدارمي والبغوي في التعليق والماوردي والزبيلي، ثم قال: «وذكر في متن الروضة (٩/ ١٥٣) أنه وجه شاذ، وهو قوي، لأن النسب يلحق بالإمكان، والقود يدرأ بكل شبهة، وخطأ القائف في الإلحاق محتمل، وفي أدب القضاء للزبيلي: فإن ألحقته القافة بأحدهما فقتله الملحق به أو الآخر فظاهر المذهب أنه لا قود عليه للشبهة».

والظاهر من صنيعه أنه لم يطلع علىٰ نص الشافعي المذكور وإلا لاستدل به علىٰ ما رجحه من عدم القود.

وفي التدريب للبلقيني (٤/ ٥٩): «وإذا تداعىٰ رجلان مجهولا، ثم قتله أحدهما، أو قتلاه، فلا قصاص في الحال، فإن ألحقه القائف بأحدهما، وكانا

مشتركين في القتل، فلا قصاص علىٰ الذي ألحق به، ولا يقتص من الآخر بمجرد إلحاق بغير القائف -خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله-، سواء كان القائف لم ير الولد إلا بعد القتل، أو كان رآه قبل القتل، كما هو ظاهر نص الشافعي في «الأم» في ترجمة ما جاء في الرجل يقتل ابنه، وبه جزم الماوردي، وهو المعتمد».

ثم ذكر نص الشافعي، ثم قال: «فقد درأ الشافعي عنه القود مطلقا من غير توقف علىٰ قول القائف؛ لأن قوله حجة علىٰ خلاف القياس، فيقتصر بها علىٰ مجرد إلحاق النسب بشروطه من غير إيجاب قصاص علىٰ القاتل، كما إذا أثبتنا هلال رمضان بواحد، لا يحكم بحلول الدين المؤجل، ولا بإيقاع الطلاق المعلق علىٰ مجيء رمضان قبل الثبوت، وعدم القتل أولىٰ».

وذكر نحوه في التحرير للعراقي (٣/ ٢٥) عن شيخه السرج البلقيني.

[٦٥] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١١٢ ط. الحداد): «ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص، والمذهب وجوب دية مسلم مخففة علىٰ العاقلة».

ما ذكره النووي من وجوب الدية مخففة علىٰ العاقلة تبع فيه الرافعي في

المحرر (ص ١٢٩٥) ولفظه: «ولو رمىٰ إلىٰ مرتد أو حربي، فأسلم ثم أصابه ومات فلا قصاص، لكن تجب الدية علىٰ الأصح، والدية الواجبة دية مسلم مخففة مضروبة علىٰ العاقلة».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ١٩٠): «إذا قلنا بوجوب الضمان فيما إذا جرح حربيا فأسلم، ثم مات، وفيما إذا جرح عبد نفسه، ثم أعتقه، فمات، فالواجب دية حر مسلم، وكذلك في مثلهما من صورة الرمي ثم الذي رأىٰ الإمام القطع به، وجرىٰ عليه صاحب الكتاب: أن الدية فيما إذا طرأ الإسلام أو العتق بعد الجرح تكون مخففة مضروبة علىٰ العاقلة، وتكون الجناية ملحقة فالخطأ المحض منزلة منزلة ما إذا رمىٰ إلىٰ صيد، فأصاب إنسانا، ويكون عروض عصمة الإسلام، كاعتراض الآدمي في مورد السهم إلىٰ الصيد»، ونحوه فيه (١٠/ ١٨٨، ٣١٧). وتبعه النووي في الروضة (٩/ ١٦٧-١٦٨).

وعبر عن هذه المسألة في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٠٣) بالأشهر الأصح.

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحاه من وجوب دية مخففة علىٰ العاقلة مخالف لنص الشافعي، فقد نص علىٰ وجوب الدية حالة في مال الجاني، فتكون دية مغلظة.

قال الشافعي في الأم (٧/ ١٢٤ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فرماه رجل، ولم تقع الرمية به حتىٰ أسلم، فمات منها، أو جرحه بالرمية، فلا قصاص علىٰ الرامي؛ لأن الرمية كانت وهو ممن لا عقل له ولا قود، وعليه الدية في ماله حالَّة إن مات، وأرش الجرح إن لم يمت حالا؛ لأنه عمد».

وهذا نص صريح في أن الدية علىٰ مال الجاني حالة، وأنها دية عمد فتكون علىٰ هذا مغلظة.

قال الإسنوي في المهمات (٨/ ٢١٣): «فانظر إلىٰ أمثال هذه النصوص الصريحة الواضحة، كيف يغفلون عنها، ويتحيلون في ترجيح ضعيف مستند إلىٰ مقالة بعض المتأخرين المعدودين من المصنفين».

وقال الأذرعي في قوت المحتاج (٨/ ٨٨-٨٩): اعلم أن ما تضمنه نص «الأم» هو قضية نص «المختصر» وكلام الجماهير من الطريقين، وأن قول المصنف «والمذهب وجوب دية مسلم مخففة علىٰ العاقلة» ممنوع، بل المذهب وجوب دية العمد عليه، وإنما أخذ من قال ذلك من إطلاق نص «المختصر»[(١)]،

---

(١) في مختصر المزني (٢/ ٣٥٢ ط. الداغستاني):« ولو أرسل سهما، فلم يقع علىٰ نصراني حتىٰ أسلم، أو علىٰ عبد فلم يقع حتىٰ أعتق لم يكن عليه قصاص؛ لأن تخلية السهم كانت ولا قصاص، وفيه دية حر مسلم والكفارة، وكذلك المرتد يسلم قبل وقوع السهم؛ لتحول الحال قبل وقوع الرمية».

وإذا تصفحت أكثر الكتب المشهورة لن ترىٰ فيها إلا ذكر وجوب الدية من غير وصف بتخفيف، ولا بكونها علىٰ العاقلة».

وفي التدريب للبلقيني (٤/ ٦٣): والمذهب المنصوص وجوب دية مسلم أو حر، وتكون في ماله حالة، كما نص عليه الشافعي ﷺ في «الأم» في المرتد، وإذا كان الشافعي أوجب الدية حالة في مال الجاني في صورة المرتد، فإيجاب دية حر حالة في مال السيد في صورة عبد نفسه أولىٰ، وأما الحربي فقد صححوا التسوية بينه وبين المرتد في إيجاب الدية، وقضية إلحاقه بالمرتد أن تكون الدية في مال الجاني».

ونحوه في تحرير الولي العراقي (٣/ ٢٩، ٣٠) عن شيخه البلقيني.

[٦٦] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١١٨ ط. الحداد): «والسمع كالبصر، يجب القصاص فيه بالسراية».

ما ذكره النووي من وجوب القصاص في السمع، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٣٠٤) ولفظه: «والسمع كالبصر، يجب القصاص فيه بالسراية».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٢١٨): «وإذا أوجبنا القصاص في

فلم يذكر نوع الدية الواجبة، ولا علىٰ من تجب، لكن نصه في الأم أوضح أنها دية عمد حالة في مال الجاني.

ضوء البصر بالسراية، فالذي صححه الإمام رواية ونقلا أن السمع كالبصر».

وقال في الروضة بعد تقرير النص في القصاص في ذهاب الضوء (٩/ ١٨٦): «وإذا أوجبنا القصاص في الضوء بالسراية، فالذي صححه الإمام نقلا ومعنىٰ أن السمع كالبصر».

○ قال أبو عبد الباري:

وما صححاه مخالف لنص الشافعي علىٰ أن في السمع دية ، ولا قود فيه.

قال الشافعي في الأم (٧/ ١٦٩-١٧٠ ط. د. رفعت فوزي): «ولا قود في ذهاب السمع؛ لأنه لا يوصل إلىٰ القود فيه، فإذا ذهب السمع كله ففيه الدية كاملة ... والأذنان غير السمع، فإذا قطعتا ففيهما القود، وفي السمع إذا ذهب الدية، وكل واحد منهما غير صاحبه».

وهذا النص صريح في أنه لا قصاص في السمع للعلة المذكورة، وجزم به غير واحد.

قال الماوردي في الحاوي الكبير (١٢/ ١٦٠): «ولو قطع أذنه فذهب منها سمعه اقتص من أذنه، ولم يقتص من سمعه لتعذره».

وقال الشيرازي في المهذب (٣/ ١٨٣): «وإن جنىٰ علىٰ رأسه فذهب عقله،

أو علىٰ أنفه فذهب شمه، أو علىٰ أذنه فذهب سمعه، لم يجب القصاص في العقل والشم والسمع، لأن هذه المعاني في غير محل الجناية فلم يمكن القصاص فيها».

وقال ابن الرفعة في الكفاية (١٥/ ٣٩١ بعد قول الشيرازي السابق): «وقد وافق الشيخ - علىٰ ما ادعاه من الحكم في الصور الثلاثة - البندنيجي، وطرده في غيرها؛ حيث قال: كل جناية سرت إلىٰ ما دون النفس، لا قصاص في السراية، إلا في مسألة العين.

وكذلك القاضي الحسين؛ حيث قال: كل قصاص يجري في النفس يجري في الطرف إلا في شيئين:

أحدهما: القود في النفس يجب بالسراية، وفي الطرف لا يجب بالسراية، وإنما يجب بإتلاف عينه إلا في إذهاب البصر».

وقال الأذرعي في قوت المحتاج (٨/ ١١٨): وقد تصفحت ما رأيته من كتب الطريقين علىٰ كثرتها، فرأيتها مقتصرة هنا علىٰ ذكر البصر ...، وقوة كلام الجميع في الديات يقتضي أن الواجب فيه الدية دون القصاص ... وفي جمل «العمد»: وأما الرافعي فلم يعرج علىٰ غير كلام الإمام، وإلا ما حكاه عن

المهذب، وكأنه رآه كالمنفرد لما نقله الإمام».

وقال الزركشي في الخادم (ص ٣٤٩-٣٥١ تحقيق إبراهيم بن فريهد العنزي) تعقيبا علىٰ كلام الرافعي: «ما نسبه للإمام حكاه عن الأصحاب، ولم يحك سواه، وجزم به الرافعي في المحرر، وهو خلاف مذهب الشافعي؛ فقد نص في الأم علىٰ أنه: (لا قود في ذهاب السمع؛ لأنه لا يُوصِّل إلىٰ القود فيه)، وفي هذا رد لقول الرافعي بعد ذلك في كلامه علىٰ ألفاظ الوجيز: أنه ليس في السمع نص.

ودعوىٰ الإمام: أن الأصحاب علىٰ أنه كالبصر مردود ؛ فقد جزم العراقيون وغيرهم: أنه لا قود فيه، وممن جزم بأنه لا قود فيه الماوردي في باب الديات، والشيخ في المهذب، وصاحب البيان هنا، وكذلك البندنيجي وقال: كل جناية سرت إلىٰ ما دون النفس لا قصاص في السراية إلا في مسألة العين، وكذا صرح به الصيدلاني في شرح المختصر، والقاضي الحسين في التعليقة، وعبارته: وفي الطرف لا يجب بالسراية، وإنما بإتلاف عينه، إلا في إذهاب البصر، وقال الشيخ أبو محمد الجويني في مختصره: والقود بسبب السراية لا يجب في سوىٰ العين، وقال الجرجاني في الشافي: أما الأعراض فلا يقتص في شيء منها إلا في ضوء

البصر، وكذا قال في التحرير، وكلام الأصحاب جميعهم في الديات صريح فيه؛ حيث أوجبوا فيه الدية دون القصاص.

وقد ظهر بذلك التعجب من الإمام والغزالي؛ حيث نسبا للأصحاب: إلحاق السمع بالبصر، مع تصريح الأصحاب وإمامهم بخلافه، وأعجب منه: عدم تصريح الرافعي عن كلام الإمام».

وقال فيه أيضا (ص ٣٥٥): «وما ذكره من أنه ليس في السمع نص مردود، فقد بينا أن الشافعي نص في الأم علىٰ المنع، وبذلك يتجه الاعتراض علىٰ الغزالي في نقله عن النص الوجوب؛ إذ لا يعرف ذلك أصلا».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٧٢): «وما صححه في «المنهاج» تبعا لأصله من وجوب القصاص ليس بمعتمد، وما نص عليه صاحب المذهب هو المعتمد».

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في الغرر البهية (٥/ ٣٨): «ما تقرر من وجوب القود في السمع، هو ما جزم به الشيخان، ونقلاه عن تصحيح الإمام.

قال ابن الرفعة وغيره: والمذهب فيه المنع، إذ هو قول الجمهور، ونص عليه في الأم فقال: «ولا قود في ذهاب السمع؛ لأنه لا يتوصل إلىٰ القود فيه»، بل

قضية كلام ابن الرفعة وغيره: أن المعتمد من حيث النقل أن لا قود في سائر المعاني إلا في الضوء؛ لأنه ألطفها وأحراها بأن تؤثر النكايات فيه».

وبهذا يتبين أن المعتمد المنصوص أنه لا قود في السمع، وأن جمهور الأصحاب علىٰ هذا.

[٦٧] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١١٩ ط. الحداد): «وكذا زائد في الأصح».

صحح النووي هنا أنه لا يضر تفاوت العضوين في الكبر والطول والقوة والبطش في العضو الزائد، وهو تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٣٠٥) فإنه لما ذكر أن ذلك التفاوت لا يؤثر في العضوين الأصليين، قال ما نصه: «وكذلك لو كانا زائدين في أظهر الوجهين».

ولم يرجح في الشرح الكبير (١٠/ ٢٢٢) ورجح النووي في الروضة (٩/ ١٨٩) ما رجحه في «المنهاج».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي تبعا للرافعي هنا مخالف لما ذكره الشافعي في السن الزائدة ونحوها.

قال الشافعي في الأم (٧/ ١٤١-١٤٢ ط. د. رفعت فوزي): وإن قلع رجل لرجل سنا زائدة، أو قطع له أصبعا زائدة، أو كانت له زنمة تحت أذنه زائدة، فقطعها رجل فسأل القود فلا قود، وفيها حكومة، وإن كان للقاطع في موضع من هذا مثله ففيه القود سنا كان أو غير سن، أو أصبع، أو زنمة، وهكذا لو خلقت له أصبع لها طرفان، فقطع أحد الطرفين فلا قود، وفيها حكومة، إلا أن يكون له أصبع مثلها فيقاد منه ... وإن كان للقاطع مثلها وليست شلاء أقيد، ولا حكومة، ولو كانت لأصبع القاطع طرفان، وليس ذلك لأصبع المقطوع، فلا قود؛ لأن أصبع القاطع كانت أكبر من أصبع المقطوع».

وهذا النص صريح في أن التفاوت بين العضوين من سن أو أصبع ونحوهما يؤثر في القصاص، وأنه لابد من استوائهما في الموضع والكيفية.

ونحوه في مختصر المزني (٢/ ٣٧٤ ط. الداغستاني) ولفظه: «ولو قلع له سنا زائدة .. ففيها حكومة، إلا أن يكون للقالع مثلها، فيقاد منه».

قال الماوردي في الحاوي (١٢/ ١٩٢):«وإن كان للجاني سن زائدة لم يخل من أن تكون في مثل محلها من المجني عليه أو غير محلها، فإن كانت في غير محلها منه مثل أن تكون الزائدة من الجاني مع الأسنان العليا ومن المجني عليه

مع الأسنان السفلىٰ أو تكون من الجاني يمنىٰ ومن المجني عليه يسرىٰ، أو تكون من الجاني مقترنة بالناب ومن المجني عليه مقترنة بالثنية فلا قصاص فيها، لأن اختلاف محلهما يمنع من تماثلهما فإن كانت من الجاني في مثل محلها من المجني عليه ففيها القصاص، لثماثلهما في المحل، وسواء اتفقا في القدر والمنفعة أو تفاضلا، لتساويهما في الاسم الخاص كما قلناه فيما كان من أصل الخلقة المعهودة».

ولهذا قال العمراني في البيان (١١/ ٣٧٦): «وإن كان له سن زائد في ذلك الموضع، إلا أنه أكبر من سن المجني عليه.. ففيه وجهان:

أحدهما: - وهو قول أكثر أصحابنا -: لا يجب فيها القصاص؛ لأن القصاص في العضو الزائد إنما يجب بالاجتهاد، فإذا كانت سن الجاني أزيد كانت حكومتها أكثر، فلم يجب قلعها بالتي هي أنقص منها، بخلاف السن الأصلية، فإن القصاص فيها ثبت بالنص، فلا يعتبر فيها التساوي.

والثاني: حكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد، واختاره: أنه يجب فيها القصاص؛ لأن ما ثبت بالاجتهاد يجب اعتباره بما ثبت بالنص، والأول هو المنصوص».

فقوله (والأول هو المنصوص) يريد به نص الشافعي المذكور.

ولهذا قال الأذرعي في قوت المحتاج (٨/ ١٢٦): «فإذن هو المذهب لا كما رجحاه، والظاهر أن العضو كالسن»، ثم ذكر نص الشافعي.

[٦٨] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٢٠ط. الحداد): «والصحيح أن الاختيار في موضعه إلىٰ الجاني».

صحح النووي هنا إن كان رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج أن الجاني يختار موضع الأخذ للقصاص دون المجني عليه، وكذلك قال في الروضة (٩/ ١٩٠).

والنووي تبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٠٦) ولفظه: «وإن كان رأس الشاج أكبر لم يوضح المشجوج جميع رأسه، بل قدر ما أوضح، والأظهر: أن الاختيار في موضعه له»، وكذلك قال في الشرح الكبير (١٠/ ٢٢٤).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكراه من أن الاختيار في موضع القصاص للجاني مخالف لمنصوص الشافعي.

قال الشافعي في الأم (٧/ ١٣٠ ط. د. رفعت فوزي): «وإن شج رجل رجلا

موضحة أخذت ما بين منتهىٰ منابت رأس المشجوج من قبل وجهه، إلىٰ منتهىٰ منابت رأسه من قفاه، وهي نصف ذلك من الشاج، أخذ له نصف رأسه، وخُيِّر المشجوجُ، فبدئ له إن شاء من قبل وجهه، وإن شاء فمن قبل قفاه».

وهذا صريح في أن الاختيار للمجني عليه خلافا لما في المحرر والمنهاج، وما في النص المذكور عن الشافعي هو الذي حكاه الماوردي في الحاوي الكبير (١٢/ ١٥٢) عن جمهور الأصحاب فقال في تماثل رأس الجاني والمجني عليه: «والوجه الثاني: وهو أصح، وبه قال جمهور أصحابنا: أن المستوفىٰ له القصاص مخير في الابتداء بأي الموضعين شاء، لأن له أن يقتص من بعضها في أي الموضعين شاء».

ثم لما تكلم عن حالتنا هذه، وهي ما إذا كان رأس الجاني أكبر من رأس المجني عليه: «وإن قيل: بالوجه الثاني الذي هو أصح إن المقتص له مخير في الابتداء بأي الموضعين شاء، كان بالخيار بين ثلاثة أحوال...» ثم ذكرها.

وقال الشيرازي في المهذب (٣/ ١٨٠): «فإن أوضح جميع رأسه، ورأس الجاني أكبر فللمجني عليه أن يبتدئ بالقصاص من أي جانب شاء من رأس الجاني، لأن الجميع محل للجناية».

وبه قال الروياني في البحر (١٢/ ١٣٨) والبغوي في التهذيب (٧/ ٩٧) والشاشي في الحلية (٧/ ٤٧٣).

وقال الأذرعي في قوت المحتاج (٨/ ١٣٠): «والذي أورده العراقيون والمراوزة خلا الإمام ومن تبعه أو أخذ من كلامه: أن الخيرة إلىٰ المستحق، وهو المنصوص في الأم صريحا، وهو الصواب معنىٰ ونقلا»، ثم ذكر قول الإمام، ثم قال: «أما المعنىٰ: فما علله به يقتضي تخيير المشجوج لا الشاج، والمرعي جانب المستحق في القود، وهو الذي جميع رأسه محل الجناية، فأي موضع طلبه من رأس الشاج فقد جنىٰ عليه مثله من رأسه، فلا وجه لمنعه أصلا، إذ لم يطلب أزيد من حقه فتعين إجابته، ... وأما النقل فكما تقدم».

ثم قال: «وممن جزم بتخيير المشجوج: الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وسليم الرازي، وابن الصباغ، والقاضي أبو الطيب الطبري في «المجرد»، ونقله عن نص الشافعي ....، وبه أجاب الشيخ المقدسي في «تهذيبه»، وأصحاب «البيان» و«الانتصار» و«التهذيب» و«الكافي»، والبغوي في «تعليقه»أيضا.

وقال في «الاستقصاء»: إنه المذهب، وفي «البسيط»: إنه الظاهر من المذهب، ولم أر نقل تخيير الجاني وجها إلا في «النهاية» وفروعها».

وقال الزركشي في المنثور (١/ ٢٦٠-٢٦١): «والصحيح عند الإمام والرافعي أن الاختيار في موضعه إلىٰ الجاني، ولكن المنصوص وعليه الجمهور: أن الاختيار للمستحق». وهكذا قال ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٤/ ٥٠).

وقال مصفطىٰ سميط في مختصر تحفة المحتاج (٤/ ٣٧): «المعتمد مقابل الصحيح، وهو أن الاختيار في ذلك للمجني عليه إن لم يطلب أزيد من حقه».

[٦٩] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٢٢ ط. الحداد): «وفي قلع السن قصاص، لا في كسرها».

جزم النووي هنا أنه لا قصاص في كسر السن، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٠٩) ولفظه: «وفي السنّ القصاص، ولكن عند القلع دون الكسر».

وقال النووي في شرح مسلم (١١/ ١٦٤) في فوائد حديث الربيع: «ومنها وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه إذا أقلعها كلها، فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء، والأكثرون علىٰ أنه لا قصاص». وهو قول البغوي في التهذيب (٧/ ١٠٤).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي تبعا للرافعي من أنه لا قصاص في كسر السن مخالف لنص الإمام الشافعي، فإنه أجاز القصاص في الكسر إذا أمكن.

قال الشافعي في الأم (٧/ ١٥٩ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كسر الرجل سن الرجل من نصفها، سألت أهل العلم، فإن قالوا: نقدر علىٰ كسرها من نصفها بلا إتلاف لبقيتها ولا صدع، أقدته، وإن قالوا: لا نقدر علىٰ ذلك لم نقده لتفتتها».

وهذا صريح في جواز القصاص في كسر السن إذا كان ممكنا بقول أهل الخبرة.

وفي النجم الوهاج (٨/ ٤٠١): «وفي قول نص عليه في الأم، وقطع به في المهذب (٣/ ١٨٣) والحاوي (١٢/ ١٦٠) أنه يراجع أهل الخبرة، فإن قالوا: تمكن فيه المساواة اقتص، واحتج الماوردي بحديث الرُّبَيِّع، لكن حمله الشيخ أبو حامد علىٰ القلع من أصله، وهو خلاف الظاهر» وتبعه في البحر (١٢/ ١٤٦).

وفي بداية المحتاج (٤/ ٥٦) عن البلقيني أنه قال: إنه المذهب، وفي الكفاية (١٥/ ٣٩٥) أن القاضي ابن كج عزا ذلك لنص الشافعي».

وفي التدريب للبلقيني (٤/ ٧٠): «وفيه دلالة واضحة علىٰ إيجاب القصاص

في كسر السن، وهو محمول علىٰ إمكان المماثلة، وحمل الحديث علىٰ أنها قلعتها بعيد من الظاهر، فإنه لا يقال في ذلك كسرتها، بل يقال قلعتها».

وقال الهيتمي في التحفة (٨/ ٤٢٦): «المعتمد أنه إن أمكن استيفاء مثله بلا زيادة ولا صدع في الباقي فعل، ومن ثم صح فيمن كسرت سنّ غيرها «كتاب الله القصاص»، ونحوه في المغني (٥/ ٢٦٨) والنهاية (٧/ ٢٩٢) وغيرها.

[٧٠] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٢٤ ط. الحداد): قدَّ ملفوفا وزعم موته صُدِّق الوليُّ بيمينه في الأظهر».

ما ذكره النووي هنا من تصديق ولي الدم بيمينه تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٣١٣) ولفظه: «لو قدّ ملفوفا في ثوب بنصفين، وقال: «إنه كان ميتا»، وقال وليه: «بل كان حيا فقتله» فأيهما المصدق بيمينه؟ فيه قولان: أظهرهما أن المُصدَّق وليُّ الملفوف».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٢٤٨): «وأظهرهما: ويحكىٰ عن رواية الربيع: أن المصدق ولي المجني عليه؛ لأن الأصل استمرار الحياة».

وتبعه النووي في الروضة (٩/ ٢٠٩) فقال: «قد ملفوفا في ثوب نصفين وقال: كان ميتا، وقال الولي: كان حيا، فأيهما يصدق؟ قولان، أظهرهما: الولي».

○ قال أبو عبد الباري:

هذا الذي رجحه النووي وجعله الأظهر مخالف لصريح قوله في «الأم» وأكثر كتبه، ومن ذلك:

قال الشافعي في الأم (٧/ ٤٨-٤٩ ط. د. رفعت فوزي): «وهكذا لو قالوا: نشهد أنه ضربه وهو ملفف، فقطعه باثنين، أو جرحه هذا الجرح، ولم يبينوا أنه كان حيا حين ضربه، لم أجعله قاتلا، ولا جارحا، حتىٰ يقولوا: ضربه وهو حي، أو تثبت بينة أنه حين ضربه كان حيا، أو كانت فيه الحياة بعد ضربه إياه، فيعلم أن الضربة كانت وهو حي، وأقبل قول الجاني مع يمينه -إذا لم تقم بينة- بأن هذه الشجة لم تكن من فعله، وأنه ضربه ميتا، وهكذا لو شهدوا: أن قوما دخلوا بيتا فغابوا، ثم هدمه هذا عليهم فقال: هدمته بعد ما ماتوا، جعلت القول قوله حتىٰ تثبت البينة أن الحياة كانت فيهم حين هدم هذا البيت.

قال الربيع: وللشافعي[1] فيه قول ثان يشبه هذا: أن الملفوف بالثوب، والقوم الذين كانوا في البيت فهدمه عليهم علىٰ الحياة حتىٰ يعلم، أو تقوم بينة أنهم ماتوا

---

(١) وهذا التصريح من الربيع يرد ما زعمه الماوردي في الحاوي (١٣/ ٨٠) من أن هذا القول من تخريج الربيع، وما في البويطي يرد ما زعمه من تفرد الربيع به.

قبل أن يهدم البيت عليهم».

وقال في الأم (٧/ ٤٩ ط. د. رفعت فوزي): «وهكذا لو أقر فقال: ضربته فقطعته، وهدمت البيت علىٰ هؤلاء، وهم موتىٰ، أو ضربت فم هذا الرجل وأسنانه ساقطة، كان القول قوله مع يمينه حتىٰ تقوم بينة بخلاف ما قال».

وقال في الأم (٧/ ١٦٧-١٦٨ ط. د. رفعت فوزي): «وكذلك لو جاء رجل إلىٰ رجل مسجىٰ بثوب فقطعه باثنين، فقال: قطعته وهو ميت، أو جاء قوما في بيت فهدمه عليهم، فقال: هدمته عليهم وهم موتىٰ، كان القول قول الجاني مع يمينه، وعلىٰ أوليائهم البينة أن الحياة كانت فيهم قبل الجناية، فإذا أقاموها لم يقبل قول الجاني حتىٰ تثبت له بينة أنه قد حدث لهم موت قبل الجناية.

قال الربيع: وله قولان، أحدهما: هذا، والقول الثاني: أن الذين هدم عليهم البيت علىٰ الحياة التي قد عرفت منهم حتىٰ يقيم الذي هدم عليهم البيت أنهم ماتوا قبل أن يهدمه».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٢٦): ولو شهدا أنه ضربه ملففا فقطعه باثنين، ولم يثبتا أنه كان حيا .. لم أجعله قاتلا، وأحلفته: ما ضربه حيا».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٥٧، ٨٥٨): وإذا هدم الرجل علىٰ القوم البيت، أو ضرب رجلا ملفوفا، أو فقأ عينه فقال: كانوا أمواتا، وقال أولياؤهم: بل كانوا

أحياء، أو صحيح العين، فإن أقام البينة أنه دخل البيت وهو حي، أو دخل في الثوب حيا، والعين قائمة فعليه القود.

وقد قيل: لا شيء عليه إلا أن يقيموا البينة أنه في ساعة الهدم كانوا أصحاء».

وهذه النصوص عن الإمام صريحة في تصديق الجاني بيمينه، وليس في شيء منها تصديق الولي بيمينه، وإنما في «الأم» و«البويطي» أن القول قوله إن أقام البينة.

وهذا هو اختيار غير واحد من أئمة المذهب كالماوردي والشيرازي وغيرهما.

قال الماوردي في الحاوي (١٣/ ٨٠): «وهو الذي نقله المزني هاهنا، ونص عليه الشافعي في أكثر كتبه» وتبعه الروياني في البحر (١٤/ ٢٥٧) كعادته.

وقال الشيرازي في التنبيه (ص ٢٦٢): «فيه قولين: أصحهما: أن القول قول الضارب».

وقال ابن الرفعة في الكفاية (١٨/ ٤٧٩): وهذا ما نص عليه في الأم، في باب دعوى الدم، ورجحه الشيخ أبو حامد والقاضي الروياني وأبو الطيب وغيرهم».

وزاد في النجم الوهاج (٨/ ٤١١) ممن صححه: المحاملي، والروياني،

وصاحب المعتمد، والشيخ في التنبيه، وأن النووي أقره عليه في التصحيح».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٧٧): نص الشافعي: أن الجاني يصدق مطلقا بيمينه، وعلىٰ الولي البيان خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله».

وقال الولي العراقي في تحرير الفتاىٰ (٣/ ٤٣) عن البلقيني: «لم أجد في تصنيف من الطريقين تصحيح ما صححه الرافعي والنووي».

وعزاه ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٤/ ٥٨) للجمهور فقال: «وهو ما عليه الجمهور، وقال الماوردي: نص عليه الشافعي في أكثر كتبه».

وما رجحه الرافعي والنووي ليس هو القول الثاني الذي حكاه الربيع، وذلك لأمرين:

الأول: أنه ليس فيه تحليف الولي، فليس موافقا للقول الثاني في هذا.

الثاني: أن القول الثاني للشافعي صريح بوجوب القود عليه كما في البويطي، والذي قرره النووي في الروضة (٩/ ٢١٠) أنه لا قصاص فيه فقال: «قلت: وإذا صدقنا الولي بلا بينة، فالواجب الدية دون القصاص، ذكره المحاملي والبغوي، وقال المتولي: هو علىٰ الخلاف في استحقاق القود بالقسامة».

[٧١] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٢٦ ط. الحداد): «وليتفقوا علىٰ مستوف، وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب، وقيل: لا يدخل».

رجح النووي هنا دخول العاجز في القرعة، وتبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٣١٥) ولفظه: «والأظهر أنه يدخل في القرعة من يعجز عن الاستيفاء كالشيخ والمرأة، فإذا خرجت له استناب».

وعزاه في الشرح الكبير (١٠/ ٢٥٧) إلىٰ اختيار البغوي في التهذيب (٧/ ٢٨، ٢٩)، وتردد في الخلاف هل هو قولان أو وجهان، وتبعه النووي في الروضة (٩/ ٢١٥).

○ قال أبو عبد الباري:

الذي عليه الأكثرون، وهو المنصوص المعتمد عدم دخول العاجز في القرعة.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٥٠ ط. د. رفعت فوزي): «وإن تشاححتم أقرعنا بينكم، فأيكم خرجت قرعته خليناه وقتله، ولا يقرع لامرأة، ولا يدعها وقتله؛ لأن الأغلب أنها لا تقدر علىٰ قتله إلا بتعذيبه في القتل، وكذلك لو كان فيهم أشل اليمنىٰ، أو ضعيف، أو مريض لا يقدر علىٰ قتله إلا بتعذيبه، أقرع بين من يقدر علىٰ قتله، ولا يدع يعذبه بالقتل».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٥٨ ط. القره داغي): «وإذا تشاح الأولياء في القتل، وفيهم النساء لم يكن للنساء في ولاية القود بأيديهن شيء، فإن كان بعض

الأولياء أقوىٰ من بعض ولي القوي القتل، وإن استووا أقرع بينهم، فمن خرجت قرعته قتل».

وهذا هو الذي نقله النووي في الروضة (٩/ ٢١٥) عن الأكثرين، وعليه مشىٰ القزويني في الحاوي الصغير فقال (ص ٥٦٩): «ويقرع للقادرين».

وهو الذي رجحه التاج السبكي في التوشيح (٣/ ٢٣٦-٢٣٩) ونقل فيه نص الشافعي من الأم.

وفي النجم الوهاج (٨/ ٤١٨): «هذا هو الصحيح في الشرح والروضة، والمعتمد المنصوص في الأم، وعليه الأكثرون، بل قال الروياني في التجربة: إن الأول غلط».

ووهِمَ ابن الرفعة في المطلب (ص ٤٨٨ تحقيق خالد مشعان) فعزا دخول العاجز في القرعة إلىٰ نص الأم، ونبه عليه المحقق.

[٧٢] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٢٦ط. الحداد): «وإن بادر بعد عفو غيره لزمه القصاص، وقيل: لا، إن لم يعلم، ويحكم قاض به».

ما ذكره النووي تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٣١٦) ولفظه: «فإن كانت المبادرة بعد عفو سائر الشركاء أو بعضهم، فالأظهر: وجوب القصاص».

تضمن كلام النووي هنا أمرين:

الأول: أن الراجح وجوب القصاص مطلقا سواء علم العفو، أم لم يعلم، وسواء حكم القاضي به أم لا.

الثاني: أن اشتراط العلم بالعفو وحكم القاضي وجه ضعيف في المذهب.

وقال النووي في الروضة (٩/ ٢١٦): «إن علم العفو، وحكم الحاكم بسقوط القصاص عن الجاني، لزمه القصاص قطعا، وإن لم يحكم به لزمه أيضا علىٰ المذهب، وقيل: لا، لشبهة اختلاف العلماء.

وإن جهله، فإن قلنا: لا قصاص إذا علمه، فهنا أولىٰ، وإلا فوجهان».

فلم يرجح في صورة الجهل بالعفو، لكنه رجح وجوب القصاص في «المنهاج»، ولهذا قال ابن قاضي شهبة في البداية (٤/ ٦٤): «وإطلاق الكتاب يقتضي: أن الأصح: وجوب القصاص»، ونحوه في المغني (٥/ ٢٧٧).

وهو تابع الرافعي في هذا الترجيح، فإنه قال في المحرر كما تقدم، وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٢٥٩) وجعل الأظهر وجوب القصاص، وسيأتي نص كلامه في آخر المسألة، لكن النووي حذف ترجيحه من الروضة.

○ قال أبو عبد الباري:

ما اختاره النووي من وجوب القصاص مطلقا هو أحد الأقوال التي حكاها الشافعي واختار منها العفو مطلقا، وما جعله وجها ضعيفا للأصحاب من اشتراط العلم وحكم القاضي هو المنصوص عند الشافعي أنه موجب للقصاص، وهذه بعض نصوصه.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣٨-٣٩ ط. د. رفعت فوزي): «ولو أن رجلا له وليان أو أولياء، فعفا أحد أوليائه القصاص، ثم عدا عليه أحد الأولياء فقتله، وقال: لم أعلم عفو من معي، ففيها قولان:

أحدهما: أن عليه القصاص، فإذا اقتص منه، فنصيبه من الدية في مال القاتل المقتول الذي اقتص منه.

والآخر: أن يحلف ما علم عفوه، ثم عوقب ولم يقتص منه، وأغرم ديته حالة في ماله، يرفع عنه منها بقدر نصيبه من دية المقتول الذي هو وارثه.

وإن لم يحلف، (حلف)[1] أولياء المقتول الآخر لقد علم، ثم في القصاص

---

(١) كلمة «حلف» سقطت من نسخة د. رفعت فوزي، وهي في نسخة دار الفكر، وبها يستقيم المعنى.

منه قولان: أحدهما: أن يقتص منه، والآخر: لا قصاص منه.

ومن قال: يقتص منه، جعل لورثة المقتول الأول في مال القاتل نصيبهم من الدية، وللذي قتل به حصته من الدية، لما أخذ منه القصاص».

ومثله في مختصر المزني (٢/ ٣٦٤-٣٦٥ ط. الداغستاني)فقال: قال الشافعي: ولو قتل أحد الوليين القاتل بغير أمر صاحبه .. ففيها قولان:

أحدهما: أن لا قصاص بحال؛ للشبهة، قال الله عز وجل {فقد جعلنا لوليه سلطانا}، يحتمل أي ولي قتل كان أحق بالقتل، وهو مذهب أكثر أهل المدينة، ينزلونه بمنزلة الحد لهم عن أبيهم، إن عفوا إلا واحدا كان له أن يحد، قال الشافعي: وإن كان ممن لا يجهل عزر، وقيل للولاة معه: لكم حصصكم... والقول الثاني: أن علىٰ من قتل من الأولياء قاتل أبيه القصاص حتىٰ يجتمعوا علىٰ القتل».

ثم قال المزني: «فقد أجاب فيه بثلاثة أقاويل، وأصل قوله: أن القاتل لو مات كانت الدية في ماله، قال المزني: وليس تعدي أخيه بمبطل حقه ولا مزيله عمن هو عليه، ولا قود للشبهة».

فذكر الشافعي هنا في الأم والمزني قولين في العفو والقصاص إذا ادعىٰ العلم ولم يرجح.

وقوله «ولا قود للشبهة» هو اختيار المزني، والأظهر عنده من الأقوال الثلاثة

التي حكاها، لكنه أخذه من قول الشافعي المتقدم والآتي.

وقال في مختصر البويطي (ص ٨٥٢ ط. القره داغي): «وإذا كان الوليان، فعفا أحدهما، فقتل الآخر قاتل أبيهما، فإنه يدرء القود عنه بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول عليه الدية، ويرجع ولي القتيل الأول بنصف الدية في مال القاتل الأول».

فجزم هنا وجوب الدية دون القصاص للشبهة، ولم يفرق بين العلم بالعفو وعدم العلم به، وهو ظاهر، موافقا لقول أكثر مفتي أهل المدينة.

وهذا القول هو الجاري علىٰ قاعدة الشافعي في غير موضع منها أنه حكىٰ قولين في وكيل القصاص يقتل بعد العفو وقبل العلم، واختار عدم القصاص.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٥٢ ط. د. رفعت فوزي): «فلو أن الوالي أذن لرجل أو امرأة بقتل رجل قضىٰ له عليه بالقصاص، فذهب ليقتله، ثم قال الولي: قد عفوت عنه قبل أن يقتله، فقتله قبل أن يعلم العفو عنه، ففيها قولان:

أحدهما: أن ليس علىٰ القاتل شيء إلا أن يحلف بالله ما علمه عفا عنه، ولا علىٰ الذي قال: قد عفوت عنه.

والقول الثاني: أنه يغرم الدية ويكفر إن حلف، وأقل حالاته أن يكون قد أخطأ بقتله، ومن قال هذا، قال: ولو وكل الولاة رجلا بقتل رجل لهم عليه قود،

فتنحىٰ به وكيلهم ليقتله، فعفا كلهم أو أحدهم، وأشهد علىٰ العفو قبل أن يقتل الذي عليه القود، ولم يصل العفو إلىٰ الوكيل حتىٰ قتل الذي عليه القود، لم يكن علىٰ الوكيل الذي قتل قصاص؛ لأنه قتله علىٰ أنه مباح له خاصة، وعليه الدية والكفارة، ولا يرجع بها علىٰ الولي الذي أمره؛ لأنه متطوع له بالقتل، ويحلف الوكيل ما علم العفو، فإن حلف لم يقتل، ووداه، وإلا حلف الولي لقد علمه وقتله.

قال الشافعي رحمة الله عليه: هذا القول أحسنهما؛ لأن المقتول صار ممنوعا بعفو الولي عنه القتل، وهذا أشبه بمعنىٰ العبد يعتق ولا يعلم الرجل بعتقه فيقتله، فيغرم دية حر، والكافر يسلم ولا يعلم الرجل بإسلامه فيقتله، فتكون ديته دية مسلم».

قلت: القولان متفقان علىٰ عدم القصاص، ووجوب التحليف، ثم بعد ذلك هل عليه دية، أم لا شيء عليه.

فبين الشافعي أن هاتين الصورتين في العبد يعتق، والكافر يسلم، يشبهان هذه الصورة من جهة عصمة دمه بالعفو مع قيام الشبهة في كل من ذلك، فتجب الدية والكفارة، لأنه تثبت مع الشبهة دون القصاص فيدرأ بالشبهة.

وإذا كان في الوكيل الذي ليس بصاحب دم، فمن باب أولىٰ صاحب الدم،

والشبهة المذكورة في النصين الأول والثاني.

وقد ذكر الرافعي أن مأخذ هذه المسائل واحد، فقال في الشرح الكبير (١٠/ ٢٥٩): «وإن كان جاهلا بالعفو، ترتب علىٰ ما إذا كان عالما، فإن لم نوجب القصاص عند العلم فعند الجهل أولىٰ، وإن أوجبناه عند العلم، فهاهنا وجهان، أو قولان، بناء علىٰ الخلاف فيما إذا قتل من عرفه مرتدا وظن أنه لم يسلم، فبان خلافه، وقد مر أن الأظهر الوجوب، ووجه الشبه بين الصورتين: أن المقتول معصوم، والقاتل جاهل بحاله، غير معذور في الإقدام عليه».

وهذه المسألة ذكرها الإسنوي في المهمات (٨/ ١٨٣) ولم يتعقب علىٰ الرافعي والنووي بنص الشافعي في «البويطي»، وكأنه لم يستحضرها.

وأما إذا علم بالعفو وحكم القاضي: فيجب القصاص لزوال الشبهة من جهة علمه بالعفو، ومن جهة حكم القاضي الذي يرفع الخصومة.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣٩ ط. د. رفعت فوزي) ولفظه: «فإذا عفا أحد الورثة القصاص، فحكم الحاكم لهم بالدية، فأيهم قتل القاتل قتل به، إلا أن يدع ذلك ورثته».

فنصَّ هنا علىٰ الشرطين، وأوجب القصاص في هذه الحالة.

[٧٣] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٢٧-١٢٨ ط. الحداد): «ويقتص علىٰ الفور، وفي الحرم، والحر والبرد والمرض».

جزم النووي هنا جواز استيفاء القصاص في الحرّ والبرد والمرض، وأطلق ذلك في النفس والطرف، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣١٨) ولفظه: «للمستحق القصاص علىٰ الفور، ولو التجأ الجاني إلىٰ الحرم فله الاستيفاء فيه، ولا يؤخر لشدة الحر والبرد والمرض».

وقد ذكر في الروضة أن هذا الحكم يعم النفس والطرف فقال (٩/ ٢٢٥): «لا يؤخر قصاص الطرف لشدة الحرّ والبرد، ولا بسبب المرض وإن كان مخطرا، وكذا لا يؤخر الجلد في القذف، بخلاف قطع السرقة والجلد في حدود الله تعالىٰ، لأن حقوق الله تعالىٰ مبنية علىٰ التخفيف، هكذا قطع به الغزالي والبغوي وغيرهما، وفي «جمع الجوامع» للروياني أنه نص في «الأم» علىٰ أنه يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب». وتبع في ذلك الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٢٧٠).

فصرح هنا بأن الروياني حكىٰ نص «الأم» بالتأخير، والظاهر أنه لم يقف عليه، وإلا نقله بنفسه.

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي تبعا للرافعي مخالف لنص الشافعي فيما دون النفس.

قال الشافعي في الأم (٧/ ١٤٥ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كان المستقاد منه مريضا ولا نفس عليه، لم يقتص منه فيما دون النفس حتىٰ يبرأ، فإذا برئ اقتص منه.

وكذلك كل حدٍّ وجب عليه لله ﷻ، أو أوجبه الله للآدميين، فإن كانت علىٰ المريض نفس، قتل مريضا أو صحيحا، وإن كان جرح، فمات المجروح من الجراح، أقيد منه من الجراح والنفس معا في مقام واحد؛ لأني إنما أؤخره فيما دون النفس لئلا يتلف بالقود مع المرض، وإذا كنت أقيد بالقتل لم أؤخره بالمرض، وهكذا إذا كان القود في بلاد باردة، وساعة باردة، أو بلاد حارة، وساعة حارة، فإذا كان ما دون النفس أُخِّر حتىٰ يذهب حدُّ البرد وحدُّ الحر، ويقتص منه في الحال التي ليست بحال تلف، ولا شديدة المباينة لما سواها من الأحوال، وكان حكم الحر والبرد حكم مرضه، يقتص منه في النفس، ولا يقتص منه فيما دونها».

وقال الشافعي في الأم (٧/ ١٤٦-١٤٧ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كان الذي يجب عليه جراحا لا يأتي علىٰ النفس، لم يؤخذ ذلك منه مريضا، ولا في حر شديد، ولا في برد شديد، وحبس حتىٰ تذهب تلك الحال، ثم يؤخذ منه».

قال الأذرعي في قوت المحتاج (٨/ ١٧٢): «هذا هو المذهب، إلا أن يثبت له نص بخلافه» ثم ذكر النصوص السابقة عن الإمام الشافعي.

وفي تحرير الفتاوي للولي العراقي (٣/ ٥٠) عن البلقيني أنه المعتمد»، وجزم به في التدريب (٤/ ١٧٢).

[٧٤] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٢٩ ط. الحداد): «ولو جوَّع كتجويعه فلم يمت زِيْدَ، وفي قول: السيف».

تبع النووي في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣١٩) ولفظه: «ولو جُوِّع مثل المدة التي جوَّع فلم يمت، فيزاد فيه، أو يعدل إلىٰ السيف؟ فيه قولان، رُجِّح منهما الأول».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٢٧٧، ٢٧٨): «وترجيح هذا قريب، أي في الاختيار وزيادة الجوع» وذكر أنه الأصح عند البغوي.

فتبعه النووي في الروضة (٩/ ٢٣٠) فقال: «وهذا أقرب».

○ قال أبو عبد الباري:

ما جعلاه قولا ضعيفا من لزوم السيف هو منصوص الشافعي ﷺ، فهو

المعتمد، وما رجحاه من زيادة التجويع ضعيف مخالف للنص.

قال الشافعي في الأم (٧/ ١٨ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا أقدته بما صنع به، حبسٌ ومنعٌ، كما حبسه ومنعه، فإن مات في تلك المدة، وإلا قتل بالسيف».

وقال في الأم أيضا (٧/ ١٥٦ ط. د. رفعت فوزي): «وما قلت: إني أقتص به من القاتل إذا صنعه بالمقتول، فلولاة المقتول أن يفعلوا بالقاتل مثله، وذلك مثل أن يشدخ رأسه بصخرة، فيخلىٰ بين ولي المقتول وبين صخرة مثلها، ويُصبَّرُ له القاتل حتىٰ يضربه بها عدد ما ضربه القاتل، إن كانت ضربة فلا يزيد عليها، وإن كانت اثنتين فاثنتين، وكذلك إن كان أكثر، فإذا بلغ ولي المقتول عدد الضرب الذي ناله القاتل من المقتول فلم يمت، خلىٰ بينه وبين أن يضرب عنقه بالسيف، ولم يترك وضربه بمثل ما ضربه به إن لم يكن له سيف، وذلك أن القصاص بغير السيف إنما يكون بمثل العدد، فإذا جاوز العدد كان تعديا من جهة أنه ليس من سنة القتل، وإنما أمكنته من قتله بالسيف؛ لأنه كانت له إفاتة نفسه مع ما ناله به من ضرب، فإذا لم تفت نفسه بعدد الضرب أفتها بالسيف الذي هو أوحىٰ القتل.

وهكذا إذا كان قتله بخشبة ثقيلة، أو ضربة شديدة علىٰ رأسه، وما أشبه هذا من الدامغ أو الشادخ أمكنت منه ولي القتيل ... »الخ كلامه.

وفي مختصر المزني (ص ٨٤٥، ٨٤٦): «قال الشافعي: والقصاص أن يفعل بالقاتل مثلما فعل بالمقتول، فإن مات مما فعل بالمقتول وإلا ضربت عنقه».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٤٥-٨٤٦ ط. القره داغي): « قال الشافعي: والقصاص أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل المقتول، فإن مات مما فعل بالمقتول، وإلا ضربت عنقه".

وفي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي(٣/ ٥٤) عن البلقيني: «ما صححه المنهاج في التجويع مخالف لنص «الأم» و«المختصر»، وإنما هو قول خرجه المزني، وتخريجه مرجوح، وعبارة الشافعي في منع الشراب: «فإن مات في تلك المدة، وإلا .. قتل بالسيف»، فقال المزني: «القياس علىٰ ما مضىٰ أول الباب: أن يمنعه الطعام والشراب حتىٰ يموت، كما قال في النار والحجر والخنق بالحبل: حتىٰ يموت».

قال شيخنا: وليس هذا بالقياس؛ فإن النار محرقة تتلفه بإسراع، وكذا الخنق بالحبل، وليس الجوع من المتلف بإسراع، وكم ممن يجوع أياماً كثيرة ولا يموت، لا سيما من ألفه؛ فالصواب كما قال الشافعي في صورة الجوع: أنه يقتل بالسيف».

وفي قوت المحتاج للأذرعي (٨/ ١٨١، ١٨٢) عن الشيخ إبراهيم المروزي

أنه قال في تعليقه: هذا ظاهر المذهب»، وعن القاضي حسين أن الشافعي لم يقبل بخلافه، ولم يختلف مذهبه فيه».

وقال الدميري في النجم (٨/ ٤٣٢): «والصواب: العدول إلىٰ السيف؛ فإنه منصوص الأم و البويطي، وقال القاضي حسين: لم يختلف مذهب الشافعي فيه، وجرىٰ عليه الجمهور؛ لظاهر قوله: فأحسنوا القتلة».

وبه قال ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٤/ ٦٩) والخطيب في المغني (٥/ ٢٨٣) والرملي في النهاية (٧/ ٣٠٦) والقليوبي في حاشيته (٤/ ١٢٥).

[٧٥] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٣٨ ط. الحداد): «ولو وجب قصاص عليها، فنكحها عليه جاز وسقط، فإن فارق قبل الوطء رجع بنصف الأرش، وفي قول: بنصف مهر مثل».

ما ذكره النووي هنا تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٣٢٩) ولفظه: «ولواستحق القصاص علىٰ امرأة، فنكحها عليه جاز، وسقط القصاص، فإن طلقها قبل الدخول فيرجع بنصف أرش الجناية، أو بنصف مهر المثل؟ فيه قولان، رُجِّح منهما الأول».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٣٠٨-٣٠٩) وتبعه النووي في الروضة (٩/ ٢٥١).

○ قال أبو عبد الباري:

ما سبق عن الرافعي والنووي يتضمن أمرين:

الأول: ترجيح الرجوع بنصف الأرش مطلقا، ومقتضاه صحة الصداق علىٰ كامل الأرش واستحقاقها له، وهذا إنما يصدق علىٰ بعض الحالات علىٰ أحد قولين.

الثاني: أن فيه قولا للشافعي بالرجوع عليها بنصف مهر مثل.

وفي كل منهما نظر.

• أما الأول: فنصوص الشافعي متطابقة في أن الصداق فاسد لا يصح، وفي قول صحتُه في العمد إذا عرفت إبل الدية، وهذه جملة من نصوص الإمام.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣١٨ ط. د. رفعت فوزي): وإذا شجت المرأة الرجل موضحة، أو جنت عليه جناية غير موضحة، عمدا أو خطأ، فتزوجها علىٰ الجناية، كان النكاح ثابتا، والمهر باطلا، ولها مهر مثلها، وعلىٰ عاقلتها أرشها في الخطأ، ولا يجوز المهر من جناية خطأ ولا عمد، من قبل أن جناية الخطأ تلزم العاقلة، وتقبل إبلهم منها، وإن اختلفت إبلهم، ويؤخذ منهم أسنان معلومة، فإذا

أدوا أعلىٰ منها في السن وما يصلح لما يصلح له ما عليهم قبل منهم، وهذا كله لا يجوز في البيع، والمهر لا يصلح إلا بما يجوز في البيع.

وكذلك إن كانت الجناية عمدا فنكحها عليها، جاز النكاح، وبطل المهر؛ لأنها إنما يلزمها بالجناية إبل، فأي إبل أدتها من إبل البلد بسن معلومة قبلت، وهذا لا يجوز في البيع، فإذا نكحت علىٰ الجناية في الخطأ والعمد فالنكاح ثابت، ولها مهر مثلها، طلقها قبل الدخول عليها أو لم يطلقها، وإذا نكحها علىٰ جناية عمد بطل القود؛ لأنه عفو عن القود، فلا سبيل إلىٰ قتلها، وإن صارت الجناية نفسا، ولا إلىٰ القود منها في شيء من الجراحة، وتؤخذ منها الدية في العمد حالَّة، ومن عاقلتها في الخطأ، ولها في ماله مهر مثلها».

وقال في مختصر البويطي (ص ٨٥٤ ط. القره داغي): «وإذا جنت امرأة علىٰ رجل موضحة خطأ فنكحته عليها، فالنكاح جائز، ولها صداق مثلها، ويرجع بأرش الموضحة علىٰ عاقلتها، وإن كانت عمدا فعرفت ما وجب فيها، فنكحته عليها فذلك صداقها.

قال الربيع: وفيها قول آخر: قيل: لها صداق مثلها، وإن عرفت ما وجب لها من الإبل، فالإبل غير محدودة موصوفة، كما لو اشترىٰ إبلا مسماة، لم يجز حتىٰ

يصفها بعينها كلها.

قال الشافعي: وإن زادت الجناية حتىٰ صارت نفسا لم يقدها به، لأنه قد عفا وصارت دية، ولها صداق مثلها».

وقال الشافعي في الأم (٧/ ٤٢-٤٣ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا جنت المرأة علىٰ الرجل موضحة عمدا أو خطأ، فنكحها علىٰ الموضحة، فالنكاح عليها عفو للجناية، ولا سبيل إلىٰ القود، والنكاح ثابت، وإن كانا قد علما أرش الجناية، كان مهرها أرش الجناية في العمد خاصة، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش الموضحة.

وإن نكحها علىٰ أرش موضحة خطأ، كان النكاح جائزا، وكان لها مهر مثلها، وله علىٰ عاقلتها أرش موضحة؛ لأنه إنما نكحها بدين له علىٰ غيرها، ولا يجوز صداق دين علىٰ غير المصدق».

فهذه النصوص تفيد أمورا:

أولها: أن الجناية إن كانت خطأ لم يصح الصداق مطلقا، لأنه صداق علىٰ دين له علىٰ غيرها، وذلك لا يجوز عند الإمام، فيكون لها صداق مثلها، فلو فارقها قبل الدخول رجعت عليه بنصف مهر المثل، وهو يرجع بأرش الجناية

علىٰ عاقلتها، وهذه ليست مسألة الكتاب، إذ البحث هنا في العمد.

ثانيها: أن الجناية إن كان عمدا سقط القصاص، لأن إصداقه يتضمن العفو عن القصاص، فيسقط القصاص، وهو كما قال النووي هنا.

ثالثها: أن الجناية إن كانت عمدا فهي علىٰ حالين:

• الأولىٰ: إذا لم تعرف صفات الإبل بأوصاف تميزها عن غيرها فلا يصح ذلك قولا واحدا، لأنها معاوضة لإبل الجناية عن الصداق، ومع الجهل بالصفات يفسد الصداق، وفي هذا يقول: «لأنها إنما يلزمها بالجناية إبل، فأي إبل أدتها من إبل البلد بسن معلومة قبلت، وهذا لا يجوز في البيع».

وهذه الحالة داخلة في إطلاق النووي مع مخالفة نص الشافعي لما يقتضيه هذا الإطلاق، فهذا موضع المؤاخذة الأولىٰ.

• الثانية: إذا عرفت الإبل بكامل صفاتها، ففيها قولان:

أولهما: صحة الصداق بها، وعليه فإذا طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الأرش، وفي هذا يقول الشافعي: «وإن كانا قد علما أرش الجناية، كان مهرها أرش الجناية في العمد خاصة، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش الموضحة».

ويقول: «وإن كانت عمدا فعرفت ما وجب فيها، فنكحته عليها فذلك صداقها».

ثانيهما: بطلان الصداق، ولها صداق مثلها، وعليه فيرجع عليها بالأرش سواء طلقها قبل الدخول أو بعده، وفي هذا يقول الربيع : «وفيها قول آخر: قيل: لها صداق مثلها، وإن عرفت ما وجب لها من الإبل، فالإبل غير محدودة موصوفة، كما لو اشترىٰ إبلا مسماة، لم يجز حتىٰ يصفها بعينها كلها».

قال الأذرعي في قوت المحتاج (٨/ ٢١٩) بعد ذكر نص المنهاج وشرحه: «إذا علمت هذا فاعلم أن نص «الأم» مصرح بعدم صحة الصداق في الصورتين، وأن الواجب مهر المثل»، ثم ذكر النصوص المتقدمة، وقال في التعليق علىٰ نص البويطي بعد النص الثاني من «الأم»: وهذا موافق لنص «الأم» في عدم صحة إصداق جناية العمد قولا واحدا».

ثم ذكر النص الآخر من «الأم» فقال: وهو مصرح أيضا بأن نفس الجناية عمدا لا يكون صداقا».

وأما الثاني: وهو حكاية قول عن الشافعي في الرجوع عليها بنصف مهر المثل، فقد ذكر الولي العراقي في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٦٦) إنكار البلقيني له، وأنه

قال: لم أقف عليه في شيء من كتب الطريقين إلا في تهذيب البغوي (٧/ ١٣٠) ومن تبعه، وهو شذوذ من البغوي مردود عليه، خارج عن قاعدة المذهب، وقد نص في الأم علىٰ المسألة، وصرح بأنه يرجع بنصف الأرش».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٨٩): «وشذ البغوي ومن تبعه بحكاية قول: أنه يرجع عليها بنصف مهر المثل؛ لأنه غريب خارج عن قاعدة المذهب، وذلك أن المستحق للزوج عند الفراق وقبل الدخول إنما هو بدل التالف لا بدل البضع، والمستحق لبدل البضع إنما هو الزوجة أو سيدها، وحينئذ فالجاري علىٰ القواعد القطع بأنه يرجع عليها بنصف الأرش».





كتاب الديات

[٧٦] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٣٨ ط. الحداد) في مواطن تغليظ الدية: «أو محرما ذا رحم فمثلثة».

اشترط النووي هنا لتغليظ الدية أن يكون ذا الرحم المجني عليه مَحرمًا، وهو تبع الرافعي في المحرر (ص ١٣٣١) وفيه في التغليظ: «أو يصادف محرما، فتجب مغلظة بالسنّ مثلثة».

وكذلك رجحه الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٣١٦) ووتبعه النووي في الروضة (٩/ ٢٥٥) أيضا، وهو قول الشيرازي في التنبيه (ص ٢٢٣) والمهذب (٣/ ٢١١) والقفال في الحلية (٧/ ٥٤٠) والماوردي في الحاوي الكبير (١٢/ ٢١٧) والجويني في نهاية المطلب (١٧/ ١٥٩) والعمراني في البيان (١١/ ٤٨٦)، وفي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ٦٩) أن القاضي حسين حكىٰ إجماع الأصحاب عليه.

○ قال أبو عبد الباري:

الذي نص عليه الشافعي في جميع كتبه التي وقفنا عليها اشتراط أن يكون

المجني عليه رحما، وليس في شيء منها أن يكون محرما، وهذه نصوصه:

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٧٨ ط. د. رفعت فوزي): «وتغليظ الدية في العمد، والعمد الخطأ، والقتل في الشهر الحرام، والبلد الحرام، وقتل ذي الرحم، كما تقدم في العمد غير الخطأ لا تختلف، ولا تغلظ فيما سوىٰ هؤلاء»

وفي مختصر المزني (٢/ ٣٧٨ ط. الداغستاني): «وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام، والبلد الحرام، وذي الرحم».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٧٥ ط. القره داغي): «وتغليظ الدية في أسنان الإبل في العمد، وفي شبه العمد، وقتل ذي الرحم، وفي الشهر الحرام والبلد الحرام».

وفي مختصر البوطي أيضا (ص ٨٨٣ ط. القره داغي): «والتغليظ في الشهر الحرام، والبلد الحرام، وقتل ذي الرحم عمدا كان ذلك أو شبه عمد أو خطأ».

وفي مختصر البويطي أيضا (ص ٨٨٥ ط. القره داغي): «كذلك إذا قتل ذا رحم خطأ، ألحقناه بدية التغليظ، وإذا قتله عمدا أو شبه عمد، لم يزد عليه أكثر من التغليظ».

وهذا صريح في الاقتصار علىٰ أن يكون ذا رحم، وهو أعم من المحرمية، فقد يكون رحما ليس بمحرم كما هو معلوم.

وقال الجويني في النهاية (١٦/ ٣١٣-٣١٤): «وكان شيخي يميل إلىٰ أن الرحم المجرد كاف في اقتضاء التغليظ، والأحاديث المستحثة علىٰ تعظيم الرحم ترِد مطلقة من غير تقييد بالمحرمية» ثم ذكر بعضها.

وذكر ابن الرفعة في الكفاية (١٦/ ٦٧) أن عدم اشتراط المحرمية هنا اختيار الشيخ أبي محمد الجويني، والقاضي الروياني، وزاد الولي العراقي في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٦٩) أنه قول الشيخ أبي حامد، وحكي عن القفال».

وقال ابن الرفعة في المطلب العالي (ص ٤٧٥ تحقيق سلطان بن مبارك السناني): « وجه اختيار الشيخ أبي محمد والقاضي الروياني أنه كالمحرم لما في قتله من قطع الرحم، وهذا ما دل عليه ظاهر النص الذي حكيناه عن «المختصر» و«الأم»، وأنه أناط التغليظ فيهما بقتل ذي الرحم».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٩٤): «أو قتل خطأ ذا رحم وإن لم يكن محرما كما نص عليه الشافعي في «الأم» حيث قال: «وتغليظ الدية في العمد، والعمد الخطأ، والقتل في الشهر الحرام، والبلد الحرام، وقتل ذي الرحم كما تقدم في العمد غير الخطأ لا تختلف). انتهىٰ. وهذا هو المعتمد خلافا لما في «المنهاج» تبعا لـ«لمحرر».

ومشىٰ عليه القزويني في الحاوي الصغير (ص ٥٥٣) فقال: «ولذي رحم» أي وإن لم يكن محرما.

[٧٧] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٤٤): «ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد، قيل: أو أحدهما، فموضحتان».

ذكر النووي هنا أن الموضحة في موضعين إذا كان الحاجز بينهما لحم فقط، أو جلد فقط كانت موضحة واحدة، وضعف القول بأنهما موضحتان، وجعله وجها للأصحاب فعبَّر عنه بـ(قيل)، وهو تابع الرافعي في المحرر (ص ١٣٣٩) ولفظه: «فإن أوضح في موضعين، وبقي بينهما الجلد واللحم فموضحتان، وإن بقي أحدهما دون الآخر، فالحاصل موضحة واحدة علىٰ الأصح».

وهكذا صححه الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٣٤٠) والنووي في الروضة (٩/ ٢٦٧).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكراه من أنه لا يكون موضحتين إلا ببقاء الجلد واللحم معا يشمل ما إذا بقي اللحم وحده، أو الجلد وحده، وظاهر نصوص الشافعي أنها موضحتان.

أما إذا بقي الجلد: ففي الأم (٧/ ١٩١ ط. د. رفعت فوزي): «ولو بقي من الجلد شيء قلَّ أو كثر لم ينخرق، وإن ورم فاخضر، وأوضح من موضعين،

والجلد الذي لم ينخرق حاجز بينهما، كان موضحتين، وكذلك لو كانت مواضح بينهما فصول لم تنخرق».

وهذا صريح في أنها موضحتان أو أكثر بحسب تعدد مواضعها ما لم ينخرق الجلد.

وأما اللحم: ففي مختصر المزني (٢/ ٣٨٠ ط. الداغستاني): «ولو كان وسطها ما لم ينخرق فهي موضحتان».

وهذا النص في المختصر يدل بعمومه علىٰ أنها موضحتان، وهو قياس قوله في الأم في التي قبلها.

وهو الوجه الثاني عند الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٣٤٠) والنووي في الروضة (٩/ ٢٦٧).

وقد ذكر الجويني في النهاية اضطراب الأصحاب في هاتين الصورتين (١٦/ ٣٢٩، ٣٣٠) وذكر وجوها أربعة، وتبعه عليه الغزالي في الوسيط (٦/ ٣٣٤) وأتباعهما.

الأول: لا يكون ذلك حاجزا، وتكون موضحة واحدة، وهو الذي صححه الرافعي وتبعه النووي.

الثاني: أن ذلك حاجز، وتكون موضحتان اعتبارا بالاسم.

الثالث: أن اللحم حائل فتكون موضحتان، دون الجلد فتبقىٰ موضحة واحدة.

الرابع: العكس، فتكون بوجود الجلد وحده موضحتان دون اللحم وحده، قال: «وهذا ليس بشيء».

فإن قيل: في الأم (٧/ ١٩٠-١٩١ ط. د. رفعت فوزي): «ولو ضرب رجل رجلا بشيء فشجه شجة موتصلة، فأُوضِح بعضُها، ولم يُوضح بعضٌ، كان فيها أرش موضحة فقط، وكذلك لو لم تزد علىٰ أن خرق الجلد من موضع، وبُضع من آخر، وأُوضح من آخر، ففيها أرش موضحة؛ لأن هذه الشجة موتصلة».

فالجواب: أن هذا ليس فيه موضحتان، وإنما فيه موضحة وباضعة وغيرهما، فأعطىٰ الحكم لأكثرها، وجعل الباقي داخلا فيها، والبحث هنا فيما إذا كانت في الجناية موضحتان بينهما حاجز والله أعلم.

[٧٨] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٤٨ ط. الحداد) في دية اللسان: «وقيل: شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاءٍ ومصٍّ».

أطلق النووي وجوب الدية في اللسان، وجعل اشتراط ظهور أثر النطق في الطفل وجها ضعيفا، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٤١) ولفظه:

«وكذا الطفل إن ظهر منه أثر النطق بمبادئه، وبالتحريك عند البكاء والامتصاص، وكذلك إن لم يظهر علىٰ الأظهر».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٣٦٥) وزاد: «والذي يوجد في كتب عامة الأصحاب وجوب الدية، أخذاً بظاهر السلامة، كما تجب الدية في يده ورجله، وهذا ما حكاه القاضي ابن كج عن أبي إسحاق، وذكر أن أبا الحسين نقل في المسألة قولين»، وتبعه النووي (٩/ ٢٧٥).

○ قال أبو عبد الباري:

الذي ضعفاه من اشتراط ظهور مخايل النطق في لسان الصبي الذي لم يبلغ النطق هو نص الشافعي ﷺ تعالىٰ.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٩٥ ط. د. رفعت فوزي): «وكذلك إذا جني علىٰ لسان الصبي، وقد حركه ببكاء، أو بشيء يعبره اللسان، فبلغ أن لا ينطق، ففيه الدية؛ لأن العام الأغلب أن الألسنة ناطقة حتىٰ يعلم أنها لا تنطق».

وفي مختصر المزني (٢/ ٣٨٣): «وفي لسان الصبي إذا حركه ببكاء أو بشيء يعبره اللسان الدية».

فاشترط الشافعي هنا ظهور مخايل النطق والكلام حتىٰ يحمل علىٰ الأغلب

وهو السلامة، ومفهومه عدم وجوب الدية إذا لم تظهر هذه المخايل والعلامات، وقد صرح بذلك الإمام والغزالي وغيرهما، بل حكىٰ الغزالي اتفاق الأصحاب عليه.

قال في نهاية المطلب (١٦/ ٣٧٤، ٣٧٥): ومما يتعلق بتمام الفصل القول في لسان الصبيان، فالذي ذكره الأصحاب فيه، أنه إذا بدا في لسان الصبي مخايل النطق، فكان يحركه تحريكا صحيحا بالضحك، والبكاء، والمصّ، فاللسان صحيح، والجاني عليه يلتزم الدية أو القصاص، كما يلتزم ذلك بالجناية علىٰ رجليه، قبل أن يستقل وينهض، إذا ثبتت علامة الصحة في رجليه.

فإن لم يبد في لسان الصبي مَخيلة النطق، لم نحكم بوجوب الدية حملاً علىٰ غالب الحال، وإن لم يتبين فيه مخيلة الخرس، وكان شيخي يقول: إن بانت مخيلة الخرس فالحكومة، وإن لم تبن علامة الخرس ولا علامة النطق، فالذي قطع به الأصحاب الحكومة، وإن لم تبن علامة الخرس».

وقال الغزالي في الوسيط (٦/ ٣٤١): «وفي لسان الناطق كمال الدية، وفي الأخرس حكومة، وفي الصبي الذي لم ينطق كمال الدية إن ظهرت أمارة القدرة بالتحريك والبكاء، ويجب بقطعه القصاص، وإن قطع كما ولد ولم تظهر أمارة فحكومة، إذ لم تتيقن القدرة، اتفق عليه الأصحاب».

وأما قول الرافعي بأن عامة الأصحاب ذكروا الدية، فيخالفه قطع الإمام ونسبته للأصحاب مطلقا وجوب الحكومة، وكذلك حكاية الغزالي اتفاق الأصحاب.

وفي تحرير الفتاوى (٣/ ٨١) عن البلقيني: «والذي يظهر من كلام كثير من أصحاب الطريقين، ترجيح إيجاب الحكومة في قطع لسان المولود عقب ولادته، قبل أن يتحرك لسانه ثم يسقط ذلك»(١).

والصواب المعتمد نص الإمام الشافعي المتقدم، ولم نعرف له نصا آخر يخالفه، وقد عرفت البحث مما تقدم والله أعلم.

[٧٩] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٥١ ط. الحداد) في موجبات الدية الكاملة: «وكذا سلخ جلد إن بقي حياة مستقرة».

جزم النووي هنا وجوب الدية بسلخ الجلد، وهو تبع في ذلك المحرر (ص ١٣٤٥) ولفظه: «وفي سلخ الجلد الدية، وإنما يظهر وجوب الدية إذا فرض بقاء حياة مستقرة، وحز غير السالخ رقبته».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٣٨٦) وتبعه النووي في

(١) وبذلك قال الماوردي في الحاوي (١٢/ ٢٦٨) والروياني في البحر (١٢/ ٢٤٤).

الروضة (٩/ ٢٨٨-٢٨٩).

○ قال أبو عبد الباري:

هذا الذي ذكراه ورجحاه من وجوب الدية في سلخ الجلد نقله الإمام في النهاية (١٦/ ٤٣٥) عن أبي علي السنجي وأنه مما تفرد به فقال: «ومما ذكره الشيخ أبو علي رضي الله عنه [نه لو سلخ الرَّجُلَ من قَرْنه إلىٰ قدمه، لوجبت الدية الكاملة، ثم قال: فلو فرض قطع اليدين بعد هذا مثلاً، فسلْخُ الجلد يوزع بالتقدير والمساحة علىٰ جميع اليدين حتىٰ يتبين مقدار كل عضو منه، فيحط حصته من اليدين، فنوجب الدية علىٰ قاطع اليدين إلا المقدار الذي يخص الجلد المسلوخ، هكذا ذكره رضي الله عنه، ولم أره إلا له».

وعلق عليه ابن الرفعة في المطلب (ص٣٧٢ تحقيق محمد بن ثابت بن محمد) فقال: « والإشارة يجوز أن تكون لجملة ما ذكر أبو علي، وأنا لم نر غير صرح بذلك، ويجوز أن تكون لتنقيص اليدين عند سلخ الجلد عليهما، وهذا هو الصحيح، لأني رأيت بعد ذلك في التلخيص لابن القاص أنه يجب في سلخ

جميع الجلد الدية في ماله إذا لم ينبت ولم يمكن القصاص فيه»(١).

وما ذكره أبو علي السنجي وتبعه الإمام وأتباعه مخالف لظاهر نصّ الشافعي الذي فيه وجوب الحكومة دون الدية.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٠٣ ط. د. رفعت فوزي): «ولو أن رجلا سلخ شيئا من جلد بدن رجل، فلم يبلغ أن يكون جائفة، وعاد الجلد فالتأم، أو سقط الجلد فنبت جلد غيره، فعليه حكومة، فإن كان عمدا فاستطيع الاقتصاص منه اقتص منه، وإلا فديته في ماله، وإذا برأ الجلد معيبا زيد في الحكومة بقدر عيب الجلد مع ما ناله من الألم، ولو كان هذا في رأسه، أو الجسد، أو فيهما معا، أو في بعضهما، فنبت الشعر، كانت فيه حكومة إن كان خطأ لا يبلغ بها دية، وإن لم ينبت الشعر، غير أنه إذا لم ينبت الشعر زيد في الحكومة بقدر الشين مع الألم».

تضمن كلام الشافعي هنا أمورا:

أولها: وجوب القصاص في سلخ شيء من الجلد إن أمكن.

ثانيها: وجوب الحكومة في سلخ شيء من الجلد إذا كانت الجناية خطأ، أو لم يمكن القصاص.

---

(١) التلخيص (ص ٥٨٦ تحقيق عادل أحمد وعلي محمد عوض).

الثالث: أن الجلد إذا برأ معيبا زيد في الحكومة بقدر الشين والألم.

الرابع: أن هذا يستوي في الرأس والجسد في السلخ.

الخامس: أن في الشعر حكومة، وإذا لم ينبت الشعر زيد في الحكومة بقدر الشين والألم.

وقد ذهب إلىٰ وجوب الحكومة في سلخ الجلد غير واحد من أئمة المذهب، ففي الحاوي الكبير للماوردي (١٢/ ٣٠٥): «ولو سلخ جلده، فضرره أعظم، وخوفه أكثر، وفيه حكومة لا تبلغ دية النفس، ويعتبر اندماله، فإن عاد جلده كانت حكومته أقل منها إذا لم يعده». وأقره الروياني في بحر المذهب (١٢/ ٢٨٠).

وعزاه الأذرعي في قوت المحتاج (٨/ ٢٩٤-٢٩٦) إلىٰ كفاية الصيمري، وفروع أبي الحسن القطان وأنه عزاه لنص الشافعي، قال: «وأكثر كتب الأصحاب التي رأيتها ساكتة عن ذلك».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ١٠٦): «وفي سلخ الجلد الحكومة علىٰ النص»، وحكىٰ عنه الولي العراقي في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٨٤) أنه جعله المعتمد».

وهذا هو الموافق لقاعدة الإمام الشافعي في أن كل جرح لم يرد فيه أرش معلوم، ولم يمكن فيه القصاص ففيه حكومة، وهذا ينطبق علىٰ سلخ الجلد.

ففي مختصر البويطي (ص ٨٨٢ ط. القره داغي): «وكل جرح دون الموضحة، أو كسر العظام مما لا يستطاع فيه القصاص، ولم يأت فيه أرش معلوم فبرأ، أو عاد لهيئته، أو لم يبرأ، ففيه حكومة علىٰ قدر الشين في البرء وغيره».

وقد قال الشافعي بمثل ذلك في نتف اللحية والشارب والرأس، وكذلك الحاجبان ولو تضمن ذلك قطع الجلد، تطبيقا لهذه القاعدة، ونصوصه في ذلك كثيرة نذكر شيئا منها.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣٠٣ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا نتف حاجبا الرجل عمدا فلا قود فيهما، فإن قطع جلدتهما حتىٰ يذهب الحاجبان، فكان يقدر علىٰ قطع الجلد كما قطع، ففيها القود، إلا أن يشاء المجني عليه العقل، فإن شاء فهو في مال الجاني، وكذلك إن كان قطعهما عمدا والقصاص لا يستطاع فيهما، ففيهما حكومة في مال الجاني، وفيهما حكومة إذا قطعهما خطأ إلا أن يكون حين قطع جلدهما أوضح عن العظم، فيكون فيهما الأكثر من موضحتين أوحكومة، وهكذا اللحية، والشاربان، والرأس ينتف، لا قود في النتف.

وقد قيل: فيه حكومة إذا نبت، وإن لم ينبت ففيه حكومة أكثر منها، وإن قطع من هذا شيء بجلدته كما وصفت في الحاجبين ففيه الأكثر من حكومة الشين وموضحة، أو مواضح إن أوضح موضحة، أو مواضح بينهن صحة من الرأس، أو اللحية لم توضح».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٧٩ ط. القره داغي): «قال الشافعي: وإذا قطع الحاجبان عمدا، فإن كان يستطاع القصاص ففيه القصاص، وإلا ففيها حكومة، وليس فيها دية، وهو في مال الجاني، وإن كان خطأ فالحكومة علىٰ العاقلة، إلا أن يكون أوضح عن العظم فيكون فيها الأكثر من أرش موضحتين أو الحكومة».

○ اعتراض وجوابه

فإن قيل: في نص الشافعي المتقدم ما يدل علىٰ أن فيه دية، وهو قوله «فديته في ماله»، ومنه أخذه صاحب التلخيص كما ذكر الأذرعي وقال: إنه محتمل جدا.

وقد أوضحه ابن الرفعة في المطلب العالي (ص ٣٧٣٧-٣٧٤ تحقيق محمد ثابت محمد) بأن قوله «لا يبلغ بها دية» يدل علىٰ أن في جميعه الدية فلذلك ينقص الواجب في البعض عنها، وأنه لا يشكل علىٰ هذا تسميتها بالحكومة وهي لا تطلق إلا علىٰ ما يثبت بالاجتهاد، لأن للاجتهاد فيما نحن فيه مجال في معرفة

المساحة والنسبة، فصح إطلاق الحكومة عليه علىٰ ما يقتضيه التوزيع، وأن قوله «فديته في ماله» عبر عن الواجب بالدية بعد أن عبر عنه أولا بالحكومة، فدل علىٰ أنه هو، بناء علىٰ قولنا: في اللسان إذا قطع ثم نبت أنه لا يسقط الواجب به.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن ابن الرفعة بين في أول كلامه علىٰ أن هذا فيه بُعدٌ فقال بعد ذكر نص الشافعي: «وهذا النص يجوز أن يأخذ منه ما قاله أبو علي - علىٰ بُعدٍ - وعكسه».

الثاني: أن الأصل إجراء اللفظ علىٰ ظاهره، ولا يطلق الحكومة إلا ما لا تقدير فيه عند الشافعي وغيره، قال ابن الرفعة في ذلك: «ألا تراه قال: إنها تزداد عند عدم نبات الشعر بسبب ذلك، وزيادة الألم ، والدية لا تزيد عند عدم نباته في المحل الذي فيه أرش مقدر كما سلف في الموضحة إذا زال الشعر بسببها ولم ينبت».

وقوله «فديته في ماله» أي أرش الجلد بدليل ما تقدم من التنصيص علىٰ أن عليه حكومة، وبه يتفق قول الشافعي فلا يصار إلىٰ اختلاف قوله في سياق واحد، وقد ذكر الأذرعي أن هذا محتمل والله أعلم.

[٨٠] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٥٨ ط. الحداد): «فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلىٰ الاندمال، وقيل: يقدره القاضي باجتهاده، وقيل: لا غرم».

رجح النووي وجوب الحكومة في الجناية التي ليس لها أرش مقدر ولم يبق لها أثر بعد الاندمال، وجعل عدم إيجاب الغرم علىٰ الجاني وجها ضعيفا.

وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٥٢-١٣٥٣) ولفظه: «فإن لم يبق نقصان، ولم تتأثر القيمة، فأحد الوجهين: أنه لا يجب شيء سوىٰ التعزير، وأظهرهما: أنه لابد من إيجاب مال.

وعلىٰ هذا فيقدر الحاكم شيئا باجتهاده، أو ينظر إلىٰ ما قبل الاندمال من الحالات المؤثرة في النقصان؟ فيه وجهان: أظهرهما الثاني، ويعتبر أقرب الحالات إليه».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٣٥١) وعزاه لأبي إسحاق وقال: «هو ظاهر النص»، وتبعه النووي في الروضة (٩/ ٣٠٩) وقال: «وأصحهما عند الأكثرين وبه قال أبو إسحاق، وهو ظاهر النص: أنه لا بد من وجوب شيء».

○ قال أبو عبد الباري:

ما جعله وجها ضعيفا بقوله (وقيل: لا غرم) هو منصوص الشافعي في الأم.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٠٤ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا ضرب رجل رجلا ضربا لم يذهب له شعرا، أو لم يغير له بشرا غير أنه آلمه، فلا حكومة عليه فيه، ويعزر الضارب».

وقال الشافعي في الأم أيضا (٧/ ٢٠٥ ط. د. رفعت فوزي): «ولو خنق رجل رجلا أو غمه، ثم أرسله ولا أثر به منه، لم يكن عليه فيه غرم، وعزر، ولو حبسه فقطع به في ضيقته، ولم ينله في يديه بشيء، ولم يمنعه طعاما ولا شرابا، فقد أثم، ويعزر، ولا غرم عليه، وكل ما ناله من خدش أو أثر في يديه يبقىٰ ففيه حكومة، وإن كان أثرا يذهب، مثل الخضرة من اللطمة فلا حكومة».

وقال أيضا بعده: «الجنايات التي فيها الحكومة، كل جناية كان لها أثر باق، جرح، أو خدش، أو كسر عظم، أو ورم باق، أو لون باق، فأما كل ضرب، ورم أو لم يورم، فلم يبق له أثر، فلا حكومة فيه».

وقال في الأم أيضا (٧/ ٢٠٧ ط. د. رفعت فوزي): «ومتىٰ أخذ له شيء مما وصفت، غير أثر الجرح الذي يعلم أنه لا يذهب أرشا، ثم ذهب رد الأرش الذي

أخذ له».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٧٧ ط. القره داغي): «وإذا ضرب الأنف ولم يكسر ولم يجرح، لم يكن فيه حكومة، لأنه ليس بجرح ولا كسر عظم».

وهذه النصوص صريحة في أنه لا شيء علىٰ الجاني ما لم يبق بعد الاندمال أثر، وهو المعتمد.

وفي مختصر المزني (٢/ ٣٨٨ ط. الداغستاني): «وفي الجراح في غير الوجه والرأس بقدر الشين الباقي بعد التئامه، لا يبلغ به الدية إن كان حرا، ولا ثمنه إن كان عبدا، ولأنه ليس في الجسد قدر معلوم سوىٰ الجائفة».

ومفهوم قوله «بقدر الشين الباقي بعد التئامه» أنه لا أرش إذا لم يكن شين بعد التئامه.

قلت: قال الإمام في النهاية (١٦/ ٤١٩): ولو كانت جراحة الحكومة بحيث لو اندملت لم تعقب شينا، ولم تترك نقصا، فهل تجب الحكومة والحالة هذه؟

اختلف أصحابنا في المسألة على وجهين:

أحدهما: أنه لا يجب شيء أصلا، وهو ظاهر القياس؛ لأن المعتمد في الحكومات اعتبار النقصان، وبناء النسبية عليه، فإذا لم يكن نقصان أصلا، فلا

معنىٰ لإيجاب شيء، مع انعدام الموجب».

وفي النجم الوهاج (٨/ ٥٢٧): واختاره ابن سريج، وقال الإمام: إنه القياس».

وأما ما حكاه عن أبي إسحاق المروزي وقال: إنه ظاهر النص، فالجواب عنه من وجهين:

الأول: أنه قول مخرج، ففي البيان للعمراني (١١/ ٥٦٦): «قال أبو إسحاق وأكثر أصحابنا: تجب عليه الحكومة، وهو المنصوص؛ لأن الشافعي ﷺ تعالىٰ قال: «وإن نتف لحية امرأة أو شاربها فعليه الحكومة أقل من حكومة في لحية الرجل؛ لأن الرجل له فيها جمال، ولا جمال للمرأة فيها».

وفي هذا ما يبين أن المنصوص المذكور إنما هو قول مخرج من مسألة لحية المرأة، ولهذا قال الزركشي في الخادم (ص ٣٦٦ تحقيق إبراهيم بن محمد الفراج): «ما نسبه لأبي إسحاق وقال: إنه ظاهر النص قد بيَّن البندنيجي مستند النص، فقال: «خرجه من قول الشافعي: لو نتف لحية امرأة كانت الحكومة فيها أقل من الحكومة في لحية رجل، لأن للرجل بها جمالا، ولا جمال لها فيها، لكن ابن الصباغ قال: إن ابن سريج أخذ مقابله من قول الشافعي: لو لطمه، فاسودّ

الموضع واحمرّ، ففيه حكومة، وإن لم يتغير فلا شيء».

الثاني: أن إيجاب الحكومة في نتف شعر لحية المرأة مبني علىٰ استهلاك بعض الخلقة التي توجب ضمان جملتها ضمان أجزائها، كما قال الماوردي في الحاوي (١٢/ ٣٠٣).

وقال البغوي في التهذيب (٧/ ١٦٧): «لأنه جزءٌ من جملةٍ مضمونة؛ فيكون مضمونـًا؛ كما لو بقي له شينٌ».

[٨١] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٦٠ ط. الحداد): «ومراهق متيقظ كبالغ».

كذا قال النووي في التفريق بين الصبي والمراهق، فجعل المراهق المتيقظ هنا كالبالغ في الحكم، وعلىٰ هذا يكون مناط الحكم التمييز، ففي مغني المحتاج (٥/ ٣٣٦) عن الزركشي أنه قال: «الأمر منوط بالتمييز وعدمه، لا بالبلوغ والمراهقة وعدمها، مع أن ظاهر كلام الشافعي والأصحاب أن الصبي لا يضمن ولو كان مراهقا، لأنه لم يكمل عقله».

والنووي تابع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٥٥) ولفظه: «والمراهق المتيقظ كالبالغ».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٤١٦) وتبعه النووي في الروضة (٩/ ٣١٤).

وهذا الذي ذكراه من التفريق بين المميز وغيره هو قول الإمام في النهاية (١٦/ ٤٤٧)، فإنه لما ذكر إطلاق الأصحاب عقَّب عليه بقوله: «وما ذكره الأصحاب في صبي لا يميز، أو كان ضعيف التمييز، بحيث يبعد منه أن يتماسك، فلو كان مراهقا، فهو في معنىٰ الكبير».

○ قال أبو عبد الباري:

ظاهر كلام الشافعي عدم التفريق بين المميز وغيره من الصبيان، وجعل مناط الضمان الصبا مطلقا.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٠٢ ط. د. رفعت فوزي): «ولو صاح عليه، أو ذعره بشيء فذهب عقله، لم يبن لي أن عليه شيئا، إذا كان المصيح عليه بالغا يعقل شيئا، وكذلك لو صاح عليه وهو راكب دابة أو جدارا فسقط فمات، أو أصابه شيء، لم يبن لي أن علىٰ الصائح شيئا، ولكن لو صاح علىٰ صبي، أو معتوه لا يعقل، أو فزعه، فسقط من صيحته ضمن ما أصابه.

وكذلك لو ذهب عقل الصبي ضمن ديته، والصياح في الصبي والمعتوه إذا

كانت منه جنايةٌ يضمنها الصائح؛ لأنهما لا يفرقان بين الصياح وغيره.

ولو عدا رجل علىٰ بالغ يعقل بسيف فلم يضربه به، وذعره ذعرا أذهب عقله، لم يبن لي أن عليه دية، من قبل أن هذا لم تقع به جناية؛ وأن الأغلب من البالغين أن مثل هذا لا يذهب العقل».

وفي مختصر المزني (٢/ ٣٩٠ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم أر عليه شيئا، ولو كان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته ضمن».

وهكذا أطلق كثير من الأصحاب ولم يفرقوا بين المراهق وغيره من الصبيان.

قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه (ص ٢٢٠): «وإن صاح علىٰ صبي فوقع من سطح، أو صاح علىٰ بالغٍ وهو غافل، فوقع فمات؛ وجبت الدية، وإن صاح علىٰ صبيٍّ فزال عقلُه وجبت الدية، وإن صاح علىٰ بالغٍ فزال عقله لم تجب».

وقال الماوردي في الحاوي الكبير (١٢/ ٣١٨): «قال الشافعي ﷺ: «ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم أر عليه شيئا، ولو كان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته ضمن».

قال الماوردي: وهو كما قال، إذا وقف إنسان علىٰ شفير بئر، أو حافة نهر، أو

قلة جبل، فصاح به صائح، فخر ساقطا، ووقع ميتا، لم يخل حال الواقع من أحد أمرين:

أحدهما: أن يكون رجلا، قوي النفس، ثابت الجأش، ثابت الجنان، فلا شيء علىٰ الصائح، لأن صيحته لا تسقط مثل هذا الواقع، فدل ذلك علىٰ وقوعه من غير صيحته.

والضرب الثاني: أن يكون صبيا أو مجنونا أو مريضا أو مضعوفا لا يثبت لمثل هذه الصيحة، فالصائح ضامن لديته، لأن صيحته تسقط مثله من المضعوفين، ولا قود عليه لعدم المباشرة، لكنه إن عمد الصيحة كانت الدية مغلظة، وإن لم يعمد كانت مخففة». وتبعه الروياني في بحر المذهب (١٢/ ٢٩٢).

وقال الشيخ أبو محمد الجويني في «الجمع والفرق» (٣/ ٤٤٠ مسألة (٦٤٧): قال الشافعي ﷺ: «لو صاح برجل، فسقط من صيحته عن حائط لم أر عليه شيئًا، ولو كان صبيا، أو معتوها، فسقط من صيحته ضمن».

والفرق بينهما: أن الصبي في غالب أمره لا يكاد يثبت ويضبط نفسه إذا فزعته بغتة بالصيحة الهائلة، والظاهر أن سقطته منسوبة إلىٰ صيحته، والغالب من

الرجل التثبت وضبط النفس، ومن النوادر أن يسمع البالغ المستجمع للعقل والرزانة صيحة، فتستفزه، كما تستفز الصبي والمجنون؛ فلذلك لم ينسب القتل إليه».

وقال الغزالي في الوسيط (٦/ ٣٥٥): «إذا صاح علىٰ صغير وهو علىٰ طرف سطح، فارتعد وسقط ومات، وجب الضمان، لأنه سبب ظاهر».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ١١٨): «وحكم المراهق حكم الصبي خلافا لمن جعله كالبالغ في حالة تيقظه؛ لأن الشافعي ﷺ أناط عدم الضمان بالبلوغ مع العقل، وأناط الضمان بالصبي، مع قيد أن يكون علىٰ حائط ونحوه بالنسبة إلىٰ غير زوال العقل، وصار الصبي وصفا ضابطا بحكمة، لا حكمة مجردة لعدم الانضباط، فلا يخرج عن صور الصبي أحد وإن كان مراهقا، لأنه لم يكمل عقله»، ونحوه في تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ١٠٥).

وتبين بما تقدم أن المراهق كسائر الصبيان لعدم كمال عقله، خلافا لما في «المنهاج»، وأن تقييد الصبي بغير التمييز خارج عن نصّ الشافعي.

[٨٢] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٦٤، ١٦٥ ط. الحداد): «ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق، وماتا أو أحدهما، فلا ضمان إن اتسع الطريق، وإلا فالمذهب إهدار قاعد ونائم لا عاثر بهما، وضمان واقف لا عاثر به».

ما ذكره النووي هنا تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٣٦١) ولفظه: «ولو تعثر بقاعد أو نائم في الطريق، أو بواقف وهلكا أو أحدهما، فلا ضمان إن كان الطرق واسعا، وإن كان ضيقا فالذي رجح وحكي عن النص: أن في التعثر بالقاعد والنائم يهدر دمهما، وعلىٰ عاقلتهما دية الماشي، وفي التعثر بالواقف يهدر دم الماشي، وعلىٰ عاقلته دية الواقف».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٤٣٣-٤٣٤) وتبعه النووي في الروضة (٩/ ٣٢٦).

○ قال أبو عبد الباري:

وما ذكراه هنا مخالف لنص الشافعي في أن الضمان علىٰ العاثر وعاقلته، سواء كان الطريق واسعا أو ضيقا، والظاهر من حكاية الرافعي للنص أنه لم يقف عليه، ولهذا قال «وحكي» بصيغة المجهول، وبالوقوف علىٰ نص الشافعي في الأم والمختصر كما سيأتي لفظهما يتبين أن الضمان علىٰ العاثر، وما أصابه هدر مطلقا.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢١١ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كان الفارس أو الراجل واقفا في ملكه أو غير ملكه، أو مضطجعا، أو راقدا، فصدمه رجل فقتله،

والمصدوم يبصر ويقدر علىٰ أن ينحرف، أو لا يبصر ولا يقدر علىٰ أن ينحرف، أو أعمىٰ لا يبصر فسواء، ودية المصدوم مغلظة علىٰ عاقلة الصادم.

قال الشافعي ﷺ: ولو مات الصادم كانت ديته هدرا؛ لأنه جنىٰ علىٰ نفسه».

وفي مختصر المزني (٢/ ٣٩٢ ط. الداغستاني): «وإذا كان أحدهما واقفا فصدمه الآخر فماتا فدية الصادم هدر، ودية صاحبه علىٰ عاقلة الصادم».

وهذا النص من الإمام مخالف لما في المنهاج.

قال الزركشي في الخادم (ص ٤٤٥ تحقيق إبراهيم بن محمد الفراج): «إن كان الطريق ضيقا فما رجحه من إهدار دم قاعد ونائم لا للعاثر بهما تابع فيه البغوي، وهو مخالف لنص الشافعي وجمهور الأصحاب، من أنه لا فرق بين اتساع الشارع وضيقه، وأنه يهدر الماشي ويضمن من سواه».

ووقال البلقيني في التدريب (٤/ ١٢٣): «وإن ضاق فصحح البغوي إهدار قاعد ونائم لا عاثرهما، وضمان واقف لا عاثر به، وإطلاق النص في «الأم» إهدار الماشي وضمان من سواه» ثم ذكر نصوص الشافعي السابقة.

وفي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ١١٦) عن البلقيني: «لم يصححه غير البغوي، قال: والذي يعتمد عليه في ذلك نصه في «الأم»، وهو: إهدار العاثر،

وضمان الواقف والقاعد والنائم، وأنه يستوي في ذلك اتساع الشارع وضيقه».

وذكر الزركشي في الخادم (ص ٤٤٦ تحقيق إبراهيم بن محمد الفراج) أن القول بضمان العاثر وإهدار النائم من القديم للشافعي فقال: «وقد بين أبو الفرج الزاز في تعليقه أنه نص في القديم، وأنه قال في موضع من القديم: «لو مات النائم كان هدرا، وإن مات العاثر كان مضمونا في مال عاقلة النائم»، وإذا كان هذا نصه في القديم، وقد نص في الجديد علىٰ خلافه فيتعين العمل بالجديد».

[٨٣] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٦٦ ط. الحداد): «ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما».

أطلق النووي ضمان الأجنبي، وتابع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٦٣) ولفظه: «وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما، لم يهدر شيء من ديتهما، ولا قيمة الدابتين، بل ضمان الكل علىٰ الفضولي».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٤٤٠، ٤٤٣) وتبعه النووي في الروضة (٩/ ٣٣٣).

○ قال أبو عبد الباري:

هذا الذي ذكره الرافعي والنووي وغيرهما، هو الذي نقل ابن المنذر

الإجماع عليه في الإشراف (٧/ ٤٥٢) فقال: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علىٰ أن من حمل صبيا لم يبلغ، أو مملوكا بغير إذن مواليه علىٰ دابة، فتلف أنه ضامن».

وهذا كما قالوه لكنه مقيّد بما إذا كان الصبيان لا يضبط مثلهما، وإلا فلا ضمان علىٰ الأجنبي عند الشافعي.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢١١ ط. د. رفعت فوزي): «فإن كان حملهما أجنبيان، ومثلهما لا يضبط الدابة، فدية من أصابا علىٰ عاقلة الذي حملهما؛ لأن حملهما عدوان عليهما، فيضمن ما أصابا في حمله».

فقيده بقوله «ومثلهما لا يضبط الدابة»، وظاهره أن الأجنبي لا يضمن إن كان الصبيان ممن يضبط الدابة.

ونقل النووي في الروضة (٩/ ٣٣٣) عن المتولي في التتمة أنه قال: «إن كان مثله لا يستمسك علىٰ الدابة ولم يشده؛ وجب الضمان؛ وإن كان يستمسك؛ فإن كان ينقله من موضع إلىٰ موضع فلا ضمان؛ سواء أركبه الولي أو غيره؛ لأنه لا يخاف منه الهلاك غالبا، وإن أركبه ليتعلم الفروسية؛ فهو كما لو تلف في يد السباح».

وهذا التفصيل قريب من نص الشافعي المتقدم، كما قال ابن الرفعة في

المطلب (ص ٥٤١ تحقيق محمد ثابت محمد): «وما ذكره المتولي من الإطلاق وهو ما يقتضيه مفهوم نص الشافعي ﷺ في «الأم»، وأقره الزركشي في الخادم (ص ٤٦٨ تحقيق إبراهيم بن محمد الفراج).

واعتمده البلقيني في التدريب (٤/ ١٢٥) فقال: «فإن كانا ممن يضبطها فهو كما لو ركبا بأنفسهما». ونحوه في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ١١٩).

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنىٰ المطالب (٤/ ٧٧) والغرر البهية (٥/ ٦٦): «قضية كلام الجمهور: أن ضمان المركب بذلك ثابت، وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب، وقضية نص الأم أنهما: إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهما، وبه جزم البلقيني أخذا من النص المشار إليه».

[٨٤] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٧٠ ط. الحداد): «ولا يعقل عتيق في الأظهر».

رجح النووي هنا أن المولىٰ من أسفل - وهو العتيق - لا يحمل عقل معتقه من أعلىٰ، لأنه لا يرثه فلم يحمل عقله، وهو تبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٦٧): «وأصح القولين: أن العتيق لا يتحمل عن المُعتِق».

وذكر الرافعي نحوه في الشرح الكبير (١٠/ ٤٧١) وتبعه في الروضة (٩/

(٣٥١).

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحاه مخالف لما وقفنا عليه من نصوص الشافعي في الأم والمزني والبويطي، والقول الآخر لم أجد أحدا ذكر مصدره، وسيأتي الكلام عليه.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٨٦-٢٨٧ ط. د. رفعت فوزي): «وكذلك لا تعقل الموالي المعتَقُون عن المولىٰ المعتِق، وللمولىٰ المعتق قرابة تحتمل العقل، فإن كانت له قرابة تحتمل بعض العقل بدئ بهم، فإن عجزوا عقل عنه مولاه الذي أعتقه، ثم أقرب الناس إليه كما يعقلون عن مولاه الذي أعتقه لو جنىٰ.

وهكذا إذا لم يكن لواحد من الجانين قرابة عقل عنه الموالي من أعلىٰ وأسفل علىٰ ما وصفت، وإن كان للمولىٰ المعتِق موال من فوق، وموال من أسفل، لم يعقل عنه مواليه من أسفل، وعقل عنه مواليه من فوق، فإن عجزوا، ولم تكن لهم عاقلة، عقل عنه مواليه من أسفل، وإنما جعلت مواليه من فوق يعقلون عنه، ومن فوقهم من مواليهم؛ لأنهم عصبته، وأهل ميراثه من دون مواليه من أسفل، ولم أجعل علىٰ الموالي من أسفل عقلا بحال حتىٰ لا يوجد نسب ولا

موال من فوق بحال، ثم يحملونه بأنه يعقل عنهم، لا لأنهم ورثة؛ ولكنهم يعقلون عنه كما يعقل عنهم».

وفي مختصر المزني (٢/ ٣٩٨ تحقيق الداغستاني)«ولا أحمل الموالي من أسفل عقلا حتىٰ لا أجد نسبا ولا مولىٰ من أعلىٰ، ثم يحملونه، لا أنهم ورثة، ولكنهم يعقلون عنه كما يعقل عنهم».

وفي مختصر البويطي (ص٨٧٦ ط. القره داغي): «وإن لم يكن لرجل مولىٰ من فوق يعقل عنه، وكان له موالي في أسفل عقلوا عنه، ولم أجعل العقل من قبل الميراث، ولكني جعلته لأنه يعقل عنهم فيعقلون عنه».

وهذا النصوص صريحة في أن العتيق يعقل عن معتقه إذا لم يوجد من يكفي في العقل عنه من قرابة ومولىٰ من أعلىٰ، قال: لا لأنهم ورثة؛ ولكنهم يعقلون عنه كما يعقل عنهم».

وهذا هو الذي نسبه ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ١٤٨) للشافعي.

وقال الزركشي في الخادم (ص ٥٠٥ تحقيق إبراهيم بن محمد الفراج): «وترجيح المنع خلاف نص الشافعي في الأم والمختصر والبويطي علىٰ أنه يتحمل، ولا يرث قاتله في كلام الشافعي، ولما ذكر الشيخ أبو حامد نص

المختصر قال: الذي نص عليه الشافعي ههنا أنهم يتحملون»، وحكىٰ أبو إسحاق في الشرح أن الشافعي قال في موضع آخر «لا يفعلون».

ورجح أبو حامد القول الذي حكاه أبو إسحاق مع قوله: إنه لا يعرف للشافعي، وجرىٰ علىٰ تصحيحه الشيخ في المهذب، ونقل أن القفال اختاره، ورجحه البغوي أيضا، وجزم ابن القاص في تلخيصه بالتقرير أنه يتحمل، ونقل القولين من غير ترجيح الماوردي وابن الصباغ وغيرهما، والصواب ما نص عليه، وليس تحمل العقل مبنيا علىٰ الإرث، إنما هو مبني علىٰ الموالاة والمناصرة».

وذكر البلقيني في التدريب (٤/ ١٣٠، ١٣١) نصوص الشافعي في الأم ومختصري المزني والبويطي ثم قال: «فهذه نصوصه في هذه الكتب، علىٰ تحمل الموالي من أسفل عند عدم المتحملين من جهة الولاء من أعلىٰ.

ولما ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه نص الشافعي في «مختصر المزني» قال: «الذي نص عليه ههنا أنهم يتحملون الدية، وحكىٰ أبو إسحاق في الشرح أن الشافعي قال في موضع آخر أنهم «لا يعقلون»، قال أبو حامد: ولست أدري أنه قال الشافعي هذا إلا أنه لا يختلف أصحابنا أن المسألة علىٰ قولين».

ونحوه في تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ١٢٦) عن البلقيني.

[٨٥] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٧٥ ط. الحداد) في جنايات أم الولد: «وجناياتها كواحدة في الأظهر».

كذا رجح النووي، وهو تابع الرافعي في المحرر (ص ١٣٧٢) ولفظه: «وإن جنت مرارا، فأصح القولين: أن جميع الجنايات كواحدة».

وذكر الرافعي نحوه في الشرح الكبير (١٠/ ٥٠١) وتبعه النووي في الروضة (٩/ ٣٦٤).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكراه مخالف لاختيار الشافعي في «الأم»، فإنه ذكر القولين فقال فيه (٧/ ٢٤٩ ط. د. رفعت فوزي): «والقول الثاني: أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية، فإذا عادت فجنت -وقد دفع جميع قيمتها- لم يرجع الآخر علىٰ الأول بشيء، ورجع الآخر علىٰ سيدها، فأخذ منه الأقل من قيمتها والجناية، وهكذا كلما جنت، وهذا قول يدخل من قبل أنه إن كان إنما ذهب إلىٰ العبد يجني فيعتقه سيده أنه يضمن الأقل من قيمته أو الجناية، فهذه لم يعتقها سيدها، وذلك إذا عاد عقلت عنه العاقلة، ولم يعقل هو عنه، وهو يجعله يعقل عن هذه.

قال الربيع: قال الشافعي: والقول الثاني أحب إلينا».

فقوله (والقول الثاني أحب إلينا) اختيار وترجيح من الإمام، فهو المعتمد.

وفي مختصر المزني (٢/ ٣٩١ ط. الداغستاني): «قال: ويقال لسيد أم الولد إذا جنت: افدها بالأقل من قيمتها أو جنايتها، ثم هكذا كلما جنت».

ثم قال المزني: «هذا أولىٰ بقوله من أحد قوليه، وهو أن السيد إذا غرم قيمتها ثم جنت، شرك المجني عليه الثاني المجني عليه الأول، فهذا عندي ليس بشيء؛ لأن المجني عليه الأول قد ملك الأرش بالجناية، فكيف تجني أمة غيره ويكون بعض الغرم عليه؟».

وذكره مطولا بذكر القولين في المختصر (٢/ ٧٧٥-٧٧٦ ط. الداغستاني) وفيه: «والثاني: أنه يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية، فإن عادت فجنت، وقد دفع رجع علىٰ السيد، وهكذا كلما جنت».

ثم قال المزني: «الثاني أشبه عندي بالحق؛ لأن إسلام قيمتها لو كان كإسلام بدنها، لوجب أن تكون الجناية الثانية علىٰ قيمتها وبطلت الشركة، وفي إجماعهم علىٰ إبطال ذلك إبطال هذا القول، وفي إبطاله ثبوت القول الآخر؛ إذ لا وجه لقول ثالث نعلمه عند جماعة العلماء ممن لا يبيع أمهات الأولاد، فإذا افتكها

ربها صارت بمعناها المقدم لا جناية عليها ولا علىٰ سيدها بها، فكيف إذا جنت لا يكون عليه مثل ذلك قياسا؟ وقد ملك المجني عليه الأرش بحق، فكيف يجني غيره وغير ملكه وغير من هو عاقلة له فيجب عليه غرمه أو غرم شيء منه؟».

قال الزركشي في الخادم (ص ١٢٨ تحقيق منصور بن عبد الوهاب الشقحاء): «واعلم أن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم علىٰ القولين، في باب الجناية علىٰ أم الولد بعد أبواب القسامة، ونقل الربيع عن الشافعي ما يقتضي ترجيح لزوم الفداء لكل جناية، وهو الذي اختاره البغوي في تعليقه».

وفي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ١٣٥) عن البلقيني: «واختاره المزني والربيع، وصححه البغوي والخوارزمي، قال: وهو المذهب الجاري علىٰ القواعد».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ١٣٧): «وليست جناية أم الولد التي لا تباع كواحدة علىٰ الذي أحبه الشافعي صاحب المذهب، بل تفرد كل جناية بحكمها، وتعتبر قيمتها وقت الجناية علىٰ الأصح».

[٨٦] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٧٦ ط. الحداد): «وكذا لحم قال القوابل: فيه صورة خفية».

كذا قال النووي في اعتبار قول القوابل في الصورة الخفية، وهو تابع الرافعي

في المحرر (ص ١٣٧٣) ولفظه: «وكذا لو لم يظهر، وقالت القوابل: إن الصورة فيه خفية لا يعرفها إلا أهل الخبرة».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٠/ ٥١٠): «ولو لم يظهر شيء من ذلك، ولكن شهدت القوابل بأن الصورة فيه خفية، يختص أهل الخبرة بمعرفتها، فكذلك في الغرة»، وتبعه النووي في الروضة (٩/ ٣٧٠).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكراه هنا مخالف لما نص عليه الشافعي في الأم والمزني والبويطي من أن الصورة الخفية لا توجب غرة.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٦٥ ط. د. رفعت فوزي): «وأقل ما يكون به السقط جنينا فيه غرة: أن يتبين من خلقه شيء يفارق المضغة أو العلقة، أصبع، أو ظفر، أو عين، أو ما بان من خلق ابن آدم سوىٰ هذا كله، ففيه غرة كاملة».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٠٣ ط. الداغستاني): «وأقل ما يكون به جنينا أن يفارق المضغة والعلقة، حتىٰ يبين فيه شيء من خلق آدمي، إصبع، أو ظفر، أو عين، أو ما أشبه ذلك، فإذا ألقته ميتا فسواء، ذكرا كان أو أنثىٰ».

ثم قال المزني: «هذا يدل علىٰ أن أمته إذا ألقت منه دما لا تكون به أم ولد؛ لأنه لم يجعله ههنا ولدا، وقد جعله في غير هذا المكان ولدا، وهذا عندي أولىٰ

من ذلك».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٧١ ط. القره داغي): «وأقل ما يكون السقط جنينا أن يتبين فيه شيء من خلق بني آدم، أصبع، أو ظفر، أو شيء يفارق المضغة أو العلقة، وإن لم يستبن فليس عليه عقله، وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثىٰ ففيه الغرة، لأن النبي ﷺ قضىٰ فيه بالغرة، ولم يسأل أذكر هوأو أنثىٰ».

وهذا صريح في اشتراط ظهور شيء من الخلقة لا في شيء خفي، وعليه مشىٰ القزويني في الحاوي الصغير (ص ٥٥٧) فقال: «بدا في بعضه التخطيط»، وقواه البلقيني وقال في قول المنهاج هنا: «إنه خلاف نص الشافعي في الأم في دية الجنين» كما في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ١٣٧).

وقال في التدريب (٤/ ١٤٠): «ولو ألقت لحما قال القوابل فيه صورة خفية فلا غرة فيه علىٰ النص، وفي قول: تجب غرة إذا قلن: لو بقي لتصور، والمعتمد عدم الوجوب».

وقول النووي: «وقيل: أو قلن: لو بقي لتصور» جعله وجها، وعند الشيرازي في التنبيه (ص ٢٢٣) أنه قول، وتبعه البلقيني كما تقدم.

وهذه المسألة تعود لما تنقضي به عدة الحامل، والقول المذكور هنا في

الجنايات مخرج من مفهوم قوله في العدة كما قال ابن الرفعة فقال في المطلب العالي (ص ٣٦٨ تحقيق عبد الهادي بن حسين الرشيدي): «وما يقابل الأصح قول مخرج من نصه علىٰ أن العدة ينقضي به».

وفي باب العدة بحث غير واحد من أصحابنا[١]، ففي النهاية للجويني (١٥/ ١٧٥): «وإن ألقت لحما، وقالت القوابل: إنها لحم ولد، فقد نص الشافعي علىٰ أن العدة تنقضي به، ونص في أمهات الأولاد علىٰ أن الجارية لا تصير به أم ولد، وقال في الجنايات: لا تجب الغرة بسببه»[٢].

ونص الشافعي المشار إليه هو ما جاء في الأم (٦/ ٥٦٠ ط. د. رفعت فوزي): «وأقل ما تخلو به المعتدة من الطلاق والوفاة من وضع الحمل، أن تضع سقطا قد بان له من خلق بني آدم شيء: عين، أو ظفر، أو أصبع، أو رأس، أو يد،

---

(١) قال ابن الرفعة في المطلب العالي (ص ٣٦٨ تحقيق عبد الهادي بن حسين الرشيدي): «وقد تعرض للفرق بينهما المصنف في كتاب العدة، وكذا غيره، لا جرم أحال الجمهور ما نحن فيه علىٰ كتاب العدد فلنقتد بهم».

(٢) ولما ذكر الجويني المسألة في الجنايات (١٦/ ٥٩٥) أحال علىٰ كلامه في العدة فقال: «ولو أسقطت المرأة لحما، ليس عليه تخطيط، وقالت القوابل: إنه ليس لحم ولد، فلا حكم له، وإن قال القوابل: إنه لحم ولد، فهذا فيه اختلاف النصوص، وقد ذكرتها في كتاب العدة، وذكرت اختلاف طرق الأصحاب فيها، فلا أعيد ما قدمته».

أو رجل، أو بدن، أو ما إذا رئي علم من رآه أنه لا يكون إلا خلق آدمي، لا يكون دما في بطن، ولا حشوة، ولا شيئا لا يبين خلقه، فإذا وضعت ما هو هكذا، حلت به من عدة الطلاق والوفاة.

قال: وإذا ألقت شيئا مجتمعا شك فيه أهل العدل من النساء أخلق هو أم لا، لم تحل به، ولا تخلو إلا بما لا يشككن فيه».

ويؤيده ما في مختصر المزني (٢/ ٢٦٥ ط. الداغستاني): «ولو طرحت ما تعلم أنه ولد مضغة أو غيرها حلت».

فذكر أن اللحم له حكم الجنين إذا اتفقت القوابل علىٰ أنه لحم ولد، ولم يشككن في ذلك، فخرج الأصحاب في الجنايات قولا، وتبين بذلك أن المنصوص في الجنايات هو أنه لا يوجب غرة، فليكن المعتمد، لأن المنصوص مقدم علىٰ المُخرَّج.

[٨٧] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٧٦ ط. الحداد) في الغرة: «وهي عبد أو أمة، مميز».

هكذا اشترط النووي التمييز ولم يذكر سنا معينا لازما، وتابع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٧٤) ولفظه: «ويشترط فيها السلامة من العيوب المثبتة للرد في المعاوضات، وبلوغ سنّ التمييز».

وهذا الذي رجحه الرافعي هنا لم يصرح بترجيحه في الشرح الكبير، وإنما ذكر أنه يحتمل أن يقال به، ولفظه (١٠/ ٥٢٢) بعد ذكر نص الشافعي الآتي في المزني واختلاف الأصحاب في تفسيره: «ويمكن أن يقال: المقصود أنه لا يقبل من هو دون سن التمييز، وسن التمييز سبع أو ثمان، ويختلف باختلاف حال الصبيان، ولا يجبر علىٰ قبول من بلغ سن التمييز، ولا تمييز له؛ لأنه معيب».

وتبعه النووي في الروضة (٩/ ٣٧٦) فقال: «وفي لفظ الشافعي ﷺ، لا يقبل دون سبع أو ثمان، فقيل: معناه ما ذكرنا، ويمكن أن المراد لا يقبل دون سن التمييز وهو سبع أو ثمان، ويختلف باختلاف الصبيان».

○ قال أبو عبد الباري:

نصوص الشافعي في الأم والمزني والبويطي متفقة علىٰ اشتراط بلوغ الغرة سبع سنين، وأنه لا يؤدىٰ بها دون هذا السن.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٦٩ ط. د. رفعت فوزي): «ولهم أن يؤدوا الغرة مستغنية بنت سبع سنين أو ثمان، ولا يؤدونها في سن دون هذا السن؛ لأنها لا تستغني بنفسها دون هذه السن، ولا يخير المولود بين الأبوين إلا في هذه السن، ولا يفرق بين الأمة وولدها في البيع؛ لأنها صغيرة إلا بهذه السن».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٠٣ ط. الداغستاني): «ولمن وجبت له الغرة أن

لا يقبلها دون سبع سنين أو ثمان؛ لأنها لا تستغني بنفسها دون هذه السنين، ولا يفرق بينها وبين أمها في البيع إلا في هاتين السنتين فأعلىٰ».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٧٣ ط. القره داغي): «والغرة مستغنية بنفسها، ابنة سبع أو ثمان، ولا يكون سنا دون هذا، وليس لهم أن يؤدوا هرمة ولا ضعيفة عن العمل، وإنما قلنا: ابنة سبع أو ثمان لأنه الوقت الذي يفرق بين الأم وولدها».

وتضمنت نصوص الشافعي التي ذكرناها التعليل بعلتين:

الأولىٰ: أن من كان دون ذلك لا يستغني بنفسه، فيما هو من ضروریاته.

الثانية: أن الشرع علق بعض الأحكام علىٰ هذا السنّ، لأن الغالب فيه التمييز والاستغناء بالنفس.

وهذا صريح في اشتراط سبع سنين للغرة، واعتمده الشيخ أبو إسحاق في التنبيه (ص ٢٢٣) والمهذب له (٣/ ٢١٤) فقال: «ولا يقبل في الغرة ما له دون سبع سنين».

ونحوه في الحاوي الكبير للماوردي (١٢/ ٣٩٢) والجمع والفرق لأبي محمد الجويني (٣/ ٤٤٨ مسألة رقم ٦٥٤) و الحلية للشاشي (٧/ ٥٤٧) والبيان للعمراني (١١/ ٥٠٠) والبحر للروياني (١٢/ ٣٥٩) والتهذيب للبغوي (٧/ ٢١٣) والغزالي في الوسيط (٦/ ٣٨٦).

وقال الولي العراقي في تحرير الفتاوي (٣/ ١٣٨) بعد ذكر ما في التنبيه: «خالفه «المنهاج» و«الحاوي» فاعتبرا التمييز، وقد يحصل قبل هذا السن، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه ليس بمعتمد، فلا بد من هذا السن مع التمييز، وقد نص عليه في «الأم» فقال ...» وذكر نص الشافعي في الأم.





كتاب دعوى الدم والقسامة

[٨٨] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٨٢ ط. الحداد): «وشهادة العدل لوث، وكذا عبيد أو نساء، وقيل: يشترط تفرقهم».

ظاهر عبارة النووي قبول شهادتهم لو جاءوا دفعة واحدة، وقد صرح بذلك في الروضة (١٠/ ١١) فقال: وكذا لو جاءوا دفعة علىٰ الأصح».

وهو تابع الرافعي في المحرر ولفظه (ص ١٣٧٩): «وقول جماعة تقبل روايتهم كالعبيد والنسوة كذلك، وفي وجه: إن جاءوا دفعة واحدة لم يكن لوثا».

ورجح في الشرح الكبير (١١/ ١٦) أن ذلك لوث، فقال: «وإن جاؤوا دفعة واحدة، فوجهان:

أشهرهما: المنع؛ لاحتمال أنهم تواطؤوا أو لقنوا.

وأقواهما: أنه لوث؛ لأنه يثير نوع الظن، واحتمال التواطؤ كاحتمال الكذب في شهادة العدل الواحد، وهذا ما يوافقه إطلاق صاحب الكتاب، وكذلك أطلق الشيخ أبو حامد».

فتبعه النووي ورجح عدم اشتراط تفرقهم الذي يفيده كلام الرافعي فقال:

«وقيل: يشترط تفرقهم»، وجعله وجها ضعيفا.

○ قال أبو عبد الباري:

والمعتمد المنصوص في الأم والمزني اشتراط تفرقهم، وأنهم إذا جاءوا دفعة واحدة لم يكن لوثا، وهو الذي ذكر الرافعي أنه الأشهر، وفيه إشارة إلىٰ أنه قول الأكثر.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٢٥ ط. د. رفعت فوزي): «أو يوجد قتيل، فتأتي بينة متفرقة من المسلمين من نواح لم يجتمعوا، فيثبت كل واحد منهم علىٰ الانفراد علىٰ رجل أنه قتله، فتتواطأ شهادتهم، ولم يسمع بعضهم شهادة بعض، وإن لم يكونوا ممن يعدل في الشهادة».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤١١ ط. الداغستاني): «أو تأتي بينة متفرقة من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيها، يثبت كل واحد علىٰ الانفراد علىٰ رجل أنه قتله، فتتواطأ شهاداتهم، ولم يسمع بعضهم شهادة بعض، وإن لم يكونوا ممن يعدل، أو يشهد عدل أنه قتله؛ لأن كل سبب من هذا شهادتهم يغلب علىٰ عقل الحاكم أنه كما ادعىٰ وليه».

وهو الذي عزاه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤١١) وابن عبد البر

في التمهيد (١٥/ ١٥١ ط. بشار) للشافعي.

وهذه النص من الإمام صريح في اشتراط تفرقهم، وصححه الشيرازي في المهذب (٣/ ٤٩٢) فقال: «وإن شهد جماعة من النساء أو العبيد علىٰ رجل بالقتل نظرت، فإن جاءوا دفعة واحدة، وسمع بعضهم كلام البعض، لم يكن ذلك لوثا، لأنه يجوز أن يكونوا قد تواطئوا علىٰ الشهادة، وإن جاءوا متفرقين، واتفقت أقوالهم، ثبت اللوث، ويحلف الولي معهم».

واعتمده البغوي في شرح السنة (١٠/ ٢١٦) والتهذيب (٧/ ٢٢٥)، والقفال في الحلية (٨/ ٢٣٢)، وحكاه العمراني في البيان (١٣/ ٢٣٧) عن أكثر الأصحاب.

وذكر ابن الرفعة في المطلب (ص ٦٢٧ تحقيق عبد الهادي بن حسين الرشيدي) نص الشافعي الذي ذكرناه، ثم قال (ص ٦٣٣): «النص الذي ذكرناه في المختصر والأم صريح في اشتراط أمر ينتفي معه احتمال التواطؤ ممن لا تقبل شهادته، بأن يأتوا متفرقين من نواحي، ولا يسمع بعض شهادة بعض، وعليه جرىٰ البندنيجي والقاضي الحسين».

وقال الإسنوي في المهمات (٨/ ٢٦٩ تعقيبا علىٰ النووي في الروضة): «قد

أطلق التصحيح بأنه لوث، ولم يذكر ما ذكره الرافعي من كونه بحثا[1]، وأن الجمهور علىٰ خلافه، وهو عجيب، لاسيما وقد نقل ابن الرفعة في «المطلب» عن الشافعي أيضا أنه ليس بلوث، فتعين أن تكون الفتوىٰ عليه».

وقال الزركشي في الخادم (ص ٢٢٤ تحقيق منصور بن عبد الوهاب الشقحاء) بعد ذكر نص الشافعي: «وظهر بهذا أن ما وقع في الروضة والمنهاج من تصحيح اللوث خلاف مذهب الشافعي.

وقوله: إن الأقوىٰ لا يشترط تفرقهم ممنوع، بل الأقوىٰ ليحصل الظن المؤكد اشتراط تفرقهم»، واطال في مناقشة ما استدل به من قول ابن الصباغ وأبي حامد والبغوي في التهذيب.

وفي تحرير الفتاوىٰ (٣/ ١٥١): «وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه ظاهر نص «الأم» و«المختصر» حيث قال: «أو تأتي ببينة متفرقة من المسلمين من نواحي لم يجتمعوا».

قال: والمعروف عند الأصحاب الجري علىٰ اعتبار تفرقهم وهو المذهب،

---

(١) قال ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٤/ ١٥٢): «واعترض: بأن الرافعي قال: إنه الأقوىٰ، وأراد من جهة البحث لا النقل».

وقول الرافعي: إن مقابله أقوىٰ ممنوع، بل الأقوىٰ لتحصيل الظن المؤكد: اشتراط تفرقهم».

وفي عجالة المحتاج لابن الملقن (٤/ ١٥٩٩): «حكىٰ صاحب البيان فيه وجهين؛ فإن أكثر الأصحاب علىٰ اشتراط ذلك، وهو ظاهر في المذهب».

[٨٩] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٨٢ ط. الحداد): «ولو ظهر لوث فقال أحد بنيه: قتله فلان، وكذبه الآخر، بطل اللوث، وفي قول: لا، وقيل: لا يبطل بتكذيب فاسق».

تبع النووي في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٧٩) ولفظه: «ولو قال أحد الوارثين: قتل مُورِّثَنا فلان، وقد ظهر عليه اللوث، وقال الآخر: إنه لم يقتله، فهل يبطل تكذيبه اللوث؟ فيه قولان، أقواهما: نعم».

وأما في الشرح الكبير فلم يصرح بالترجيح، بل ذكر فيه (١١/ ٢١-٢٢) أن فيه قولان منصوصان في المختصر، أحدهما: لا يبطل، وأنه اختيار المزني، وصححه البغوي، والثاني: يبطل، وأنه اختيار العراقيين وغيرهم، ويفهم منه أنه قول الأكثرين.

وأما النووي في الروضة (١٠/ ١٤) فصرح بترجيح البطلان فقال: «فيه

قولان، أظهرهما: نعم، وسواء كان المكذب عدلا أو فاسقا».

○ قال أبو عبد الباري:

وما ضعفه النووي هنا بقوله (وفي قول: لوث) تبعا للرافعي في المحرر هو الذي نص عليه الشافعي في الأم، وقد رجح أحد القولين بجزمه في موضع آخر.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٣٢ ط. د. رفعت فوزي): «وإن ترك وارثين أو أكثر، فكان أحدهما صغيرا، أو غائبا، أو مغلوبا علىٰ عقله، أو حاضرا بالغا فلم يحلف، فأراد أحدهما اليمين لم يحبس علىٰ غائب ولا صغير، ولم يبطل حقه من ميراثه من ديته بامتناع غيره من اليمين، ولا إكذابه دعوىٰ أخيه، ولا صغره».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤١٥ط. الداغستاني): «فإن ترك ابنين كبيرا وصغيرا، أو غائبا وحاضرا، أو أكذب أخاه، وأراد الآخر اليمين، قيل له: لا تستوجب شيئا من الدية إلا بخمسين يمينا، فإن شئت فاحلف خمسين يمينا وخذ من الدية مورثك، وإن امتنعت فدع حتىٰ يحضر معك وارث تقبل يمينه، فتحلفان خمسين يمينا».

وهذا النص صريح في أن تكذيب الآخر لا يبطل حق من حلف خمسين يمينا، بل يستحق قسطه من الدية.

واختاره المزني ورجحه لما حكىٰ عن الشافعي القولين (٢/ ٤١٦ ط.

الداغستاني) فقال: «قياس قوله أن من يثبت السبب الذي به القسامة حلف، ولم يمنعه من ذلك إنكار الآخر؛ كما لو أقام أحدهما شاهدا لأبيهما بدين وأنكر الآخر ما ادعىٰ أخوه وأكذبه أن للمدعي مع الشاهد اليمين ويستحق، كذلك للمدعي مع السبب القسامة ويستحق، فالسبب والشاهد بمعنىٰ واحد في قوله؛ لأنه يوجب مع كل واحد اليمين والاستحقاق، إلا أن في الدم خمسين يمينا، وفي غيره يمين يمين».

وصححه البغوي في التهذيب (٧/ ٢٤٣) فقال: «وإذا قُتل رجلٌ، وهناك لوثٌ، وله ابنان، قال أحدهما: قتل أبانا فلانٌ، وعين رجلًا، وقال الآخر: لم يقتله فلانٌ، بل كان غائبا يوم قتله، أو قال: مات الأب حتف أنفه؛ سواء كان المكذب عدلًا أولم يكن - فهل يبطل اللوث في حق المدعي؟ - فيه قولان:

أحدهما: يبطل، فتسقط القسامة؛ لأن اللوث ما يغلب علىٰ القلب صدق المدعي، وإذا كذبه أخوه - لا يغلب علىٰ القلب صدقه.

والثاني: وهو الأصح، واختاره المزني-: لا يبطل؛ لأن اليمين مع السبب كاليمين مع الشاهد».

قال ابن الرفعة في المطلب (ص ٦٦٧ تحقيق عبد الهادي الرشيدي): «وهو

الذي يميل إلىٰ ترجيحه كلام العراقيين».

وقال الزركشي في الخادم (ص ٢٤٥ تحقيق منصور بن عبد الوهاب الشقحاء): «الراجح في المحرر والمنهاج الثاني، ونسبه في الشرح الصغير إلىٰ الأكثرين، لكن الشافعي نص في الأم علىٰ القولين، وقطع قبل ذلك بالأول منهما.

والأول منهما: أن لولي الدم المدعي الذي لم يبرئ أن يحلف خمسين يمينا، ويستحق علىٰ المدعىٰ عليهم نصف الدية، إن كان عمدا في ماله، وعلىٰ العاقلة إن كان خطأ.

وقطع به في مختصر المزني أيضا، واختاره المزني، وهذا يؤيد ترجيح البغوي فإن المزني قال: قد قطع بالقول الأول في الباب الذي قبله، وهذا مقيس علىٰ أصله، لأن الشريكين عنده في الدم يحلفان مع السبب، كالشريكين عنده في المال يحلفان مع الشاهد».

واختاره البلقيني في التدريب (٤/ ١٤٦) فقال: «ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه: قتله فلان، وكذبه الآخر، وقد ثبت اللوث بالشاهد الواحد بعد الدعوىٰ، والحال أن المدعي قتل شبه عمد أو خطأ، فلا يبطل هذا اللوث بتكذيب أحد

الولدين قطعا، بناء علىٰ أن شهادة العدل الواحد لوث».

وأما القول الثاني: فهو ما ذكره المزني في المختصر (٢/ ٤١٦ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ولو ادعىٰ أحد الابنين علىٰ رجل من أهل هذه المحلة أنه قتل أباه وحده، وقال الآخر -وهو عدل-: ما قتله؛ فإنه كان في الوقت الذي قتل فيه ببلد لا يمكن أن يصل إليه في ذلك الوقت، ففيها قولان:

أحدهما: أن للمدعي أن يقسم خمسين يمينا، ويستحق نصف الدية.

والثاني: أن ليس له أن يقسم علىٰ رجل يبرئه وارث».

والجواب من وجهين:

الأول: أن الشافعي أطلق الخلاف هنا، وجزم بالقول الثاني في موضعين، فدل ذلك علىٰ اختياره وترجيحه، ولا يمنع حكاية الخلاف والسكوت عن الترجيح في موضع، من ترجيحه في موضع آخر، وهو كثير في صنيع الشافعي.

الثاني: أن الثاني هو الموافق لأصوله كما قال المزني عقبه: «قياس قوله أن من يثبت السبب الذي به القسامة حلف، ولم يمنعه من ذلك إنكار الآخر؛ كما لو أقام أحدهما شاهدا لأبيهما بدين، وأنكر الآخر ما ادعىٰ أخوه وأكذبه، أن للمدعي مع الشاهد اليمين ويستحق، كذلك للمدعي مع السبب القسامة

ويستحق، فالسبب والشاهد بمعنىٰ واحد في قوله؛ لأنه يوجب مع كل واحد اليمين والاستحقاق، إلا أن في الدم خمسين يمينا، وفي غيره يمين يمين».

وأما ما في مختصر البويطي (ص ٨٩٢ ط. القره داغي): «وإن كان وليان فقال أحدهما: أقسم علىٰ العمد، وقال الآخر: أقسم علىٰ الخطأ، فلا قسامة، كما لو شهد شاهدان أنه قتل عمدا، وشهد شاهدان أنه قتل خطأ، لأن بعضهم يكذب بعضا».

فالجواب: أن هذه مسألة أخرىٰ، وقد ذكرها النووي بعد ذلك، وليس فيها إبطال أصل القسامة، وإنما العلة أن موجب العمد مخالف لموجب الخطأ، فلا قسامة حتىٰ يتبين المستحق من الدية المغلظة أو المخففة، ولا يصح الاعتبار في حق كل منهما بقوله، لأنه يؤدي إلىٰ أن تكون الدية الواحدة مغلظة ومخففة.

[٩٠] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٨٧ ط. الحداد): «ويشترط لموضحة: ضربه فأوضح عظم رأسه، وقيل: يكفي فأوضح رأسه».

تبع النووي في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٨٥-١٣٨٦) ولفظه: «ولو قال: «ضربه بالسيف فأوضح رأسه» فهل يثبت به الموضحة، أو يشترط التعرض لإيضاح العظم؟ فيه وجهان: الأقوىٰ الثاني».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ضعفه النووي بقوله (وقيل: يكفي فأوضح رأسه) تبعا للرافعي، هو المنصوص المعتمد للشافعي ﷺ.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٤٥ ط. د. رفعت فوزي): «ولو قالا: ضربه في رأسه، فرأينا دما سائلا، لم أجعله جارحا، إلا بأن يقولا: سال من ضربته، ثم لم أجعلها دامية حتىٰ يقولا: وأوضحها، وهذه هي نفسها، أو هي في موضع كذا وكذا، فإن برأ منها فأراد القصاص، لم أقضه إلا بأن يقولا: هي هذه بعينها، أو يصفاها طولها وعرضها، فإن قالا: أوضحه، ولا ندري كم طول الموضحة، لم أقضه منه، وإن قالا: أوضحه في رأسه، ولا نثبت أين موضع الموضحة لم أقضه؛ لأني لا أدري أين آخذ منه القصاص من رأسه، وجعلت عليه الدية؛ لأنهما قد ثبّتا علىٰ أنه أوضحه في رأسه».

وقد كرر الشافعي ذكر قول الشاهدين أنه أوضح رأسه، وأوجب الدية علىٰ ذلك إذا لم يعرفا موضعها لتعذر القصاص، وأما إذا عرفا مكانها فأوجب القصاص عليه إذا كان عمدا، ولم يكن فيه مانع.

وهذا هو الذي رجحه الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٥٤) فقال: «ولو قال:

ضربه بالسيف، فأوضح رأسه أو اتضح من ضربه أو بجراحته، تثبت الموضحة».

ثم قال الرافعي: «وحكىٰ الإمام وصاحب الكتاب؛ أنه يشترط التعرض لوضوح العظم، وإلا، فلفظ الامام الموضحة من الإيضاح، وليست مخصوصة بإيضاح العظم، وتنزيل لفظ الشاهد علىٰ الألقاب التي اصطلح عليها الفقهاء لا وجه له[(١)]»، وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ٣٣).

وهو قول الجمهور، ففي الخادم للزركشي (ص ٢٨٤ تحقيق منصور بن عبد الوهاب الشقحاء) أنه الصواب المنصوص للشافعي وأصحابه، وهو مقتضىٰ كلام الماوردي، والروياني، والمحاملي، وابن الصباغ، وسليم في المجرد، وغيرهم من العراقيين، وقضية ما في التهذيب، ومختصر الجويني، والخلاصة للغزالي، وغيرهم، ولهذا قال في المطلب: إن كلام الأصحاب دال عليه».

وذكر البلقيني في التدريب (٤/ ١٥٠) أنه الذي جرىٰ عليه الجمهور، قال:

---

(١) قال الجويني في نهاية المطلب (١٧/ ١٠١): «وتحقيق هذا يرجع إلىٰ أن الموضحة إن كانت تجري علىٰ لفظها في اللغة، فهي من الإيضاح، وليس فيها تعرض لإيضاح العظم، والمطلوب إثبات إيضاح العظم، وإن كانت تحمل علىٰ تعارف الفقهاء، فلا يمكن حمل لفظ الشاهد علىٰ ألقاب تواضع الفقهاء عليها، واللفظ متردد في نفسه».
وقال الغزالي في الوسيط (٦/ ٤٠٨): «ولو قال :أشهد أنه أوضح رأسه، لم يكف ما لم يصرح بالجراحة وإيضاح العظم».

«وقول الإمام: إن الإيضاح لفظ اصطلح الفقهاء عليه ممنوع، فهو لغوي مشهور، أناط به الشرع الأحكام، فهو كصرائح الطلاق يقضىٰ به مع الاحتمال». وانظر: تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ١٥٩).

وقد ذكر غير واحد من شراح المنهاج أنه المعتمد، وجعلوه من القيلات المعتمدة، وقد ذكرت جملة من تعقيبات شرح المنهاج في المسألة الثامنة من «التوضيحات المسددة لمسائل القيلات المعتمدة».





كتاب البغاة

[٩١] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٨٩ ط. الحداد) في تعريف البغاة: «هم مخالفو الإمام بخروج عليه، وترك الانقياد، أو منع حق توجه عليهم».

أطلق النووي هنا الإمام، وأفاد ذلك عدم اشتراط أن يكون عادلا، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٨٩) بقوله: «أهل البغي الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه، وترك الانقياد، والامتناع عن أداء الحق المتوجه عليهم».

وهو الذي ذكره العمراني وعزاه للقفال فقال في البيان (١٢/ ١٨): «قال القفال: وسواء كان الإمام عادلا أو جائرا، فإن الخارج عليه باغ، إذ الإمام لا ينعزل بالجور، وسواء كان الخارج عليه عادلا أو جائرا.. فإن خروجه علىٰ الإمام جور».

وأيده التاج السبكي في التوشيح (٣/ ٢٧٦) بوجوب طاعته في الشرع.

○ قال أبو عبد الباري:

نصوص الإمام الشافعي متطابقة علىٰ أن ذلك في الإمام العادل:

قال الشافعي في الأم (٥/ ٥١٧-٥١٨ ط. د. رفعت فوزي): «فالباغي يقاتل الإمام العادل في مثل هذا المعنىٰ في: أنه لا يعطي الإمام العادل حقا إذا وجب

عليه، ويمتنع من حكمه، ويزيد علىٰ مانع الصدقة أن يريد أن يحكم هو علىٰ الإمام العادل ويقاتله، فيحل قتاله بإرادته قتال الإمام».

وقال في الأم أيضا (٥/ ٥٢٤ ط. د. رفعت فوزي): «فإذا كانت لأهل البغي جماعة تكثر، ويمتنع مثلها بموضعها الذي هي به بعض الامتناع، حتىٰ يعرف أن مثلها لا ينال حتىٰ تكثر نكايته، واعتقدت، ونصبوا إماما، وأظهروا حكما، وامتنعوا من حكم الإمام العادل، فهذه الفئة الباغية التي تفارق حكم من ذكرنا قبلها، فينبغي إذا فعلوا هذا أن نسألهم ما نقموا، فإن ذكروا مظلمة بينة ردت، فإن لم يذكروها بينة قيل لهم: عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٣٣ ط. الداغستاني): «فالباغي: الذي يقاتل الإمام العادل في مثل معناهم، في أنه لا يعطي الإمام العادل حقا يجب عليه، ويمتنع من حكمه، ويزيد علىٰ مانع الصدقة أن يريد أن يحكم هو علىٰ الإمام العادل، قال: ولو أن نفرا يسيرا قليلي العدد يعرف أن مثلهم لا يمتنع إذا أريدوا، فأظهروا رأيهم، ونابذوا الإمام العادل».

وقال فيه أيضا (٢/ ٤٣٤): «وإذا كانت لأهل البغي جماعة تكثر، ويمتنع مثلها بموضعها الذي هي به بعض الامتناع، حتىٰ يعرف أن مثلها لا ينال حتىٰ

تكثر نكايته، واعتقدت ونصبت إماما، وأظهرت حكما، وامتنعت من حكم الإمام العادل، فهذه الفئة الباغية التي تفارق حكم من ذكرنا قبلها، فينبغي إذا فعلوا مثل هذا أن يسألوا ما نقموا، فإن ذكروا مظلمة بينة ردت، وإن لم يذكروها بينة قيل: عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل».

وفي مناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٤٤٧): «وفي كل هذا دلالة علىٰ أن الشافعي ﷺ كان يعتقد في علي ﷺ أنه كان محقا في قتاله من خرج عليه، وأن معاوية ومن قاتله لم يخرجوا بالبغي من الإيمان؛ لأن الله تعالىٰ سمىٰ الطائفتين جميعا: مؤمنين، والآية عامة. وجرىٰ علي، ﷺ، في قتالهم مجرىٰ قتال الإمام العادل من خرج من طاعته من المؤمنين».

وهكذا كلما ذكر صنفا من أصناف البغاة ذكر أنها الخارجة علىٰ الإمام العادل.

وهذا هو المعتمد، وبه قال الإمام في النهاية (١٧/ ١٢٦) والمتولي في التتمة (ص ٧٥٩ تحقيق عبد الرحيم مرداد الحارثي) والبغوي في التهذيب (٧/ ٢٦٣)، وعزاه التاج السبكي في التوشيح (٣/ ٢٧٦) للمحاملي في المقنع.

وبه قال الرافعي في الشرح الكبير، والنووي في الروضة.

قال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٦٩): «الباغي في اصطلاح الفقهاء: المخالف للإمام العادل، الخارج عن طاعته بالامتناع عن أداء ما وجب عليه أو غيره»، وتبعه في الروضة (١٠/ ٥٠).

وقال الزركشي في الخادم (ص ٣١٩ تحقيق منصور بن عبد الوهاب الشقحاء): «ما ذكره من تقييد المنع بالخروج علىٰ الإمام العادل هو الموجود في نص الشافعي في الأم والمختصر، وجرىٰ عليه الجمهور، وهو قضية كلام المحاملي، والفوراني في العمد، والمتولي، وأبي الفرج الزاز في تعليقه، وهو قضية كلام الماوردي أيضا فإنه قال: «وإذا قام الإمام بما يلزمه وجب علىٰ الرعايا إجابة طاعته، ونصرته ما لم يتغير حاله».

[٩٢] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٩٠ ط. الحداد): «ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات، وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا، وإلا فقطاع طريق».

تبع النووي في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٣٨٩) ولفظه بعد ذكر وصف الخوارج: «فإن أظهر قوم رأيهم، وكانوا في قبضة الإمام لا يقاتلون فلا يقاتلون، فإن قاتلوا فحكمهم حكم قطاع الطريق».

ومدار هذا علىٰ أن قطاع الطريق ليس لهم تأويل، وتأويل الخوارج لا عبرة به، فهم في هذا كقطاع الطريق وأهل الردة، بخلاف البغاة إذا كان لهم تأويل، فيختلف حالهم عن هذا إذا كانت لهم شوكة يمتنعون بها.

ففي الشرح الكبير (١١/ ٧٩) أن الخوارج علىٰ القول بعدم تكفيرهم، فيهم وجهان:

أحدهما: أن شبهتهم كتاويل البغاة، وحكمهم حكمهم.

وأصحهما: أنهم كأهل الردة؛ فلا نبالي بما يتمسكون به؛ لظهور فساده، وعلىٰ هذا، فلا تنفذ أحكامهم بخلاف أحكام البغاة».

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا الذي قالاه ورجحاه مخالف لظاهر نصوص الشافعي في الأم والمزني، ولم أر للشافعي نصا يفرق بين أهل الأهواء والشبهة في الأحكام إذا خرجوا علىٰ الإمام العادل، بل نص الشافعي - كما يأتي - علىٰ أنه لا يفرق بينهم في الأحكام، وساق الشافعي البغاة والخوارج الذين خرجوا علىٰ علي بن أبي طالب وقاتلهم مساقا واحدا، وفرق بين من خرج بتأويل، ومن لم يخرج بتأويل، وبين من له شوكة، ومن ليس له شوكة.

ذكر الشافعي في الأم (٥/ ٥٢٣) أن الخارجين علىٰ الإمام العادل ثلاث أصناف:

- الصنف الأول: قوم امتنعوا من غير تأويل، ولم ينصبوا لهم إماما، فهولاء تقام عليهم الحدود، وتؤخذ منهم الحقوق متىٰ قدر الإمام عليهم.

قال الشاقعي في الأم (٥/ ٥٢٣ ط. د. رفعت فوزي) بعد ذكر الخوارج في قصة عمر بن عبد العزيز: «وهكذا من بغىٰ من أهل الأهواء، ولا يفرق بينهم وبين غيرهم فيما يجب لهم وعليهم من أخذ الحق والحدود والأحكام، ولو أصابوا في هذه الحال حدا لله ﷻ، أو للناس دما أو غيره، ثم اعتقدوا ونصبوا إماما وامتنعوا، ثم سألوا أن يؤمنوا علىٰ أن يسقط عنهم ما أصابوا قبل أن يعتقدوا، أو شيء منه، لم يكن للإمام أن يسقط عنهم منه شيئا لله عز ذكره ولا للناس، وكان عليه أخذهم به، كما يكون عليه أخذ من أحدث حدا لله تبارك وتعالىٰ، أو للناس ثم هرب، ولم يتأول ويمتنع».

فنص الشافعي هنا علىٰ أنه لا يفرق بين الخوارج وغيرهم في هذا الحكم، وبوب عليه بقوله (باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغي).

وظاهر قوله «ولم يتأول ولم يمتنع» أن من امتنع وتأول لا يكون حكمه

كحكم غيرهم ممن لم تتوفر فيه هاتان الصفتان، وأن هذان وصفان مؤثران في كل من خرج علىٰ الإمام العادل من أهل الأهواء، وهو ما يأتي في الصنف الثالث.

وقال الشافعي في الأم (٥/ ٥٣٣ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا قتلت الجماعة الممتنعة من أهل القبلة غير المتأولة، أو أخذت المال فحكمهم حكم قطاع الطريق، وهذا مكتوب في كتاب قطع الطريق» ومثله في مختصر المزني (٢/ ٤٣٥).

الصنف الثاني: قوم ليست لهم شوكة، ولا لهم إمام نصبوه، فهؤلاء كالصنف الأول في الأحكام.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٥٢٤ ط. د. رفعت فوزي): «وهكذا لو خرج رجل أو رجلان، أو نفر يسير قليلو العدد، يعرف أن مثلهم لا يمتنع إذا أريد، فأظهروا رأيهم، ونابذوا إمامهم العادل، وقالوا: نمتنع من الحكم، فأصابوا دما وأموالا وحدودا في هذه الحال متأولين، ثم ظهر عليهم، أقيمت عليهم الحدود، وأخذت منهم الحقوق لله تعالىٰ وللناس في كل شيء، كما يؤخذ من غير المتأولين».

ومثله في مختصر المزني (٢/ ٤٣٣-٤٣٤ ط. الداغستاني).

وقال الشافعي في الأم (٥/ ٥٢٣-٥٢٤): «ولو أن قوما متأولين كثيرا كانوا أو قليلا اعتزلوا جماعة الناس، فكان عليهم وال لأهل العدل يجري حكمه، فقتلوه وغيره قبل أن ينصبوا إماما، ويعتقدوا ويظهروا حكما مخالفا لحكمه، كان عليهم في ذلك القصاص.

وهكذا كان شأن الذين اعتزلوا عليا عليه السلام ونقموا عليه الحكومة فقالوا: «لا نساكنك في بلد»، فاستعمل عليهم عاملا، فسمعوا له ما شاء الله ثم قتلوه، فأرسل إليهم «أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به»، قالوا: كلنا قاتله«، قال: «فاستسلموا نحكم عليكم»، قالوا: «لا»، فسار إليهم، فقاتلهم فأصاب أكثرهم.

قال: وكل ما أصابوه في هذه الحال من حد لله تبارك وتعالىٰ أو للناس أقيم عليهم متىٰ قدر عليهم، وليس عليهم في هذه الحال أن يبدءوا بقتال حتىٰ يمتنعوا من الحكم وينتصبوا».

فضرب الشافعي المثل بالخوارج الذين خرجوا علىٰ علي بن أبي طالب، وجعل مناط إقامة الحدود عليهم: أن لا يعتقدوا ولا ينصبوا لهم إماما قبل ارتكاب الحدود والحقوق.

وفي مختصر البويطي (ص ٩٦٤ ط. القره داغي) مثله في حق الواحد

والاثنين، وهو أنه يؤخذ منه ما ارتكب من حقوق الله والناس، ونصه: «ولو فعل ذلك رجل وحده اقتص منه في القولين جميعا»، وستأتي تتمة الكلام.

الصنف الثالث: قوم جمعوا بين الشوكة والتأويل، ونصبوا لأنفسهم إماما يصدرون من أمره، فهؤلاء هم البغاة، سواء كانوا علىٰ رأي الخوارج أم لا.

قال الشافعي في الأم أيضا (٥/ ٥٢٤ ط. د. رفعت فوزي): «فإذا كانت لأهل البغي جماعة تكثر، ويمتنع مثلها بموضعها الذي هي به بعض الامتناع، حتىٰ يعرف أن مثلها لا ينال حتىٰ تكثر نكايته، واعتقدت، ونصبوا إماما، وأظهروا حكما، وامتنعوا من حكم الإمام العادل، فهذه الفئة الباغية التي تفارق حكم من ذكرنا قبلها، فينبغي إذا فعلوا هذا أن نسألهم ما نقموا، فإن ذكروا مظلمة بينة ردت، فإن لم يذكروها بينة، قيل لهم: عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل، وأن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين الله علىٰ المشركين واحدة، وأن لا تمتنعوا من الحكم، فإن فعلوا قبل منهم، وإن امتنعوا قيل: إنا مؤذنوكم بحرب، فإن لم يجيبوا قوتلوا، ولا يقاتلون حتىٰ يدعوا ويناظروا إلا أن يمتنعوا من المناظرة فيقاتلوا.

قال: وإذا امتنعوا من الإجابة، وحكم عليهم بحكم فلم يسلموا، أو حلت عليهم صدقة فمنعوها، وحالوا دونها، وقالوا: لا نبدؤكم بقتال، قوتلوا حتىٰ يقروا

بالحكم، ويعودوا لما امتنعوا إن شاء الله تعالىٰ». ومثله في المزني (٢/ ٤٣٤).

وذكر الشافعي مرة قولين ولم يرجح، ففي مختصر البويطي (ص ٩٦٣، ٩٦٤ ط. القره داغي): «وإذا قوتل الخوارج لم تسب لهم ذرية، ولم يغنم لهم مال، ولم يتبع مدبر، ولم يذفف علىٰ جريح، ولم يقتل أسيرهم، لقول الله ﷻ: ﴿فَإِن فَآءَتْ﴾ [الحجرات: ٩] والفيئة عندنا: الترك، والحجة في ذلك فعل علي.

وإذا قتلوا منا، وأخذوا مالا، واستحلوا فرجا، حكم عليهم بحكم الإسلام، وما قتل منهم المسلمون لم يكن عليهم فيه شيء، فأما المال فيردوه.

وقد قيل: لا يقتص منهم في مال، ولا في دم، ولا غيره، إذا أخذوا علىٰ التأويل، وكان لهم جماعة يمتنعون بمثلها، ولو فعل ذلك رجل وحده اقتص منه في القولين جميعا».

ولم يرجح الشافعي هنا، ويستفاد مما سبق له من نصوص الأم أن الراجح عنده أن حكمهم حكم سائر البغاة وأهل الأهواء الخارجين علىٰ الإمام العادل.

ويدل علىٰ ذلك من قوله هنا؛ استدلاله بآية الحجرات في أهل البغي ﴿فَإِن فَآءَتْ﴾ [الحجرات: ٩] وقوله: «والفيئة عندنا: الترك».

وفي تحرير الفتاوىٰ (٣/ ١٦٤) عن البلقيني أنه لم يقل هذا إلا البغوي

والمتولي()، وهو طريق حكاه القاضي حسين، ومذهب الشافعي أن الخوارج إذا تأولوا، وقامت لهم شوكة، ونصوبوا إماما؛ أن لهم حكم البغاة، وجرىٰ عليه أبو حامد وأتباعه».

قلت: ولاشتراطهم في الإمام أن يكون عادلا لم يذكروا الحسين بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير من البغاة بل سموهم شهداء، ولا يكون الباغي شهيد بإجماع الفقهاء(١) لما علم من جور أئمة بني أمية في ذلك الزمان، ولما اشترط الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال ذكر كل من تكلم فيه بحق أو بباطل لم يذكر هؤلاء فيهم ولا زيد بن علي بن الحسين رحمه الله ورضي عنه.

وأصل ذلك اختلاف الأصحاب في الإمام يطرأ عليه الفسق هل ينعزل بفسقه؟ فيه وجهان، صحح العمراني في البيان (١٢/ ١٣) أنه ينعزل، والأكثرون علىٰ خلافه، ولفظه: «وإن فسق الإمام.. فهل ينخلع؟ فيه ثلاثة أوجه، حكاها الجويني:

أحدها: ينخلع بنفس الفسق، وهو الأصح، كما لو مات.

والثاني: لا ينخلع حتىٰ يحكم بخلعه، كما إذا فك عنه الحجر، ثم صار

---

(١) ذكره ابن الوزير في الروض الباسم (٢/ ٣٨١).

مبذرا.. فإنه لا يصير محجورا عليه إلا بالحكم.

والثالث: إن أمكن استتابته وتقويم أوده.. لم يخلع، وإن لم يمكن ذلك.. خلع».

[٩٣] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٩٣ ط. الحداد): «ولا بمن يرىٰ قتلهم مدبرين».

جزم النووي هنا تحريم الاستعانة علىٰ البغاة المسلمين بمن يرىٰ قتلهم مدبرين، وتابع الرافعي في المحرر (ص ١٣٩٤) ولفظه كالمنهاج: «ولا بمن يرىٰ قتلهم مدبرين».

وهذا المنع المطلق أخذه الرافعي والنووي مما جاء في مختصر المزني (٢/ ٤٣٨ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ولا يستعان عليهم بمن يرىٰ قتلهم مدبرين»[(١)].

---

(١) وأخص من هذا الاستعانة بالمشركين عليهم، فهذا منعه الشافعي، ففي الأم (٥/ ٥٢٧ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا علىٰ أهل البغي بأحد من المشركين ذمي ولا حربي، ولو كان حكم المسلمين الظاهر، ولا أجعل لمن خالف دين الله عز وجل الذريعة إلىٰ قتل أهل دين الله».

○ قال أبو عبد الباري:

أجاز الشافعي الاستعانة بمن يرىٰ قتلهم من المسلمين بشرطين:

الأول: أن يقدر علىٰ ضبطهم بقوته وكثرة من معه.

الثاني: ألا يوجد من يكفي غيرهم.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٥٢٧ ط. د. رفعت فوزي): «ولا أحب أن يقاتلهم أيضا بأحد يستحل قتلهم مدبرين، وجرحىٰ، وأسرىٰ من المسلمين، فيسلط عليهم من يعلم أنه يعمل فيهم بخلاف الحق، وهكذا من ولي شيئا ينبغي أن لا يولاه، وهو يعلم أنه يعمل بخلاف الحق فيه.

وفي مختصر البويطي (ص ٩٦٦ ط. القره داغي): «ولا يتسعان بالمشركين علىٰ قتال أهل البغي».

لكن قال الزركشي في الخادم (ص٣٦١-٣٦٢ تحقيق منصور الشحقاء):« ينبغي أن يستثنىٰ ما إذا دعت الضرورة، بأن خيف علىٰ أهل العدل الاصطلام ونحوه، ولهذا جاز رميهم بالمنجنيق والنار ونحوهما مما يعم إهلاكه للضرورة، وهذا مثله، ويشهد له قول صاحب التتمة: ((إن البغاة إذا كانوا في قوة، والإمام في ضعف، ولم يرغبوا في مهادنته، وقصدوا قتاله، فله أن يستعين عليهم بمن يقدر عليه من أهل الذمة والحرب، ومن يعاديهم، ومن يرىٰ قتلهم، لمكان الضرورة))، وقد سوىٰ الجرجاني في التحرير في استثناء الحاجة من الاستعانة عليهم بالكفار ، وبمن يرىٰ قتلهم مدبرين».

وذكر المحقق أن ذلك في التتمة (٢ ٨٤٨، ٨٤٩) والتحرير (٢/ ٢٨٧).

ولو كان المسلمون الذين يستحلون من أهل البغي ما وصفت، يُضبطون بقوة الإمام، وكثرة من معه، حتىٰ لا يتقدموا علىٰ خلافه وإن رأوه حقا، لم أر بأسا أن يستعان بهم علىٰ أهل البغي، علىٰ هذا المعنىٰ، إذا لم يوجد غيرهم يكفي كفايتهم، وكانوا أجزأ في قتالهم من غيرهم».

فنص الشافعي هنا علىٰ جواز الاستعانة بهم بدون كراهة بالشرطين المذكورين، فإذا توفر هذان الشرطان فلا كراهة في الاستعانة بمن يرىٰ قتلهم مدبرين، وإذا لم يتوفر ذلك فيكره الاستعانة بهم وهو ما يفيد قوله (ولا أحب)، وليس ذلك بمحرم خلافا لما في «المنهاج».

ويمكن التوفيق بين ما في «الأم» وما في المزني بأن المنع المطلق في المختصر محمول علىٰ ما جاء مفصلا في الأم، ففي نهاية المطلب للجويني (١٧/ ١٥٤) عن المختصر: «ثم قال: «لا ينبغي أن يستعين الإمام علىٰ أهل البغي بمن يرىٰ قتلهم مدبرين».

فقوله (لا ينبغي) موافق لقوله (ولا أحب) في المعنىٰ الذي يفيد الكراهة، والجواز بدون كراهة بالشرطين المذكورين زيادة ليست في المختصر.

وذكر الماوردي في الحاوي (١٣/ ١٢٩) أن الأصحاب اختلفوا علىٰ المنع في كلام الشافعي علىٰ وجهين، هما: المنع والتحريم، والندب والاستحباب.

والأول: هو الذي مشىٰ عليه الرافعي، وتبعه النووي.

والثاني: هو الأقرب لظاهر اللفظ «لا أحب» أو «لا ينبغي».

ثم ذكر الماوردي أنه إن دعت الضرورة لذلك جاز بثلاثة شروط، والثالث: أن يثق بما شرطه عليهم، أن لا يتبعوا مدبرا، ولا يجهزوا علىٰ جريح، فإن لم يثق بوفائهم لم يجز». ونحوه في المهذب للشيرازي (٣/ ٢٥٢) وغيره.

وقال النووي في الروضة (١٠/ ٦٠) بعد ذكر المنع: «إلا أن يحتاج إلىٰ الاستعانة بهم، فيجوز بشرطين:

أحدهما: أن تكون فيهم جرأة وحسن إقدام.

والثاني: أن يتمكن من منعهم لو ابتغوا أهل البغي بعد هزيمتهم.

ولا بد من اجتماع الشرطين لجواز الاستعانة، كذا حكاه ابن الصباغ والروياني وغيرهما عن اتفاق الأصحاب، ولفظ البغوي يقتضي جوازها بأحدهما»[(١)].

وبذلك قال السبكي في التوشيح (٣/ ٢٧٨) والبلقيني في التدريب

---

(١) قال البغوي في التهذيب (٧/ ٢٨٦): «لا يستعين بهم علىٰ قتالهم، إلا أن يكون للإمام قوة ونجدة، يعلم أنه يقدر علىٰ منعهم من أهل البغي، فإذا ولوا مدبرين، ولا يجد من يقوم مقامهم في القتال، حينئذ: يجوز أن يستعين بهم».

(٤/ ١٥٦، ١٥٧).

[٩٤] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٩٦ ط. الحداد): «قلت: ولو ادعىٰ دفع زكاة إلىٰ البغاة صدق بيمينه».

أطلق النووي تحليف من ادعىٰ دفع زكاته للبغاة، وهو من زياداته علىٰ المحرر.

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٨٤): «وإذا عاد البلد إلىٰ قبضة الإمام، فادعىٰ من كان عليه حق أن أهل البغي استوفوه، ولا علم للإمام بذلك، ولا قامت عليه بينة، فهل يصدق بيمينه؟ أما في الزكاة فنعم؛ لأن المسلم أمين في أمور الدين؛ ولأن الزكاة مال مواساة، واللائق به التساهل».

وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ٥٤) فقال: «إذا عاد البلد إلىٰ أهل العدل، فادعىٰ من عليه حق أن البغاة استوفوه، ولا يعلم الإمام ذلك ولا بينة، فإن كان زكاة، صدق بيمينه».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكراه من الإطلاق مخالف لنص الشافعي في تقيي التحليف فيما إذا كانت فيه ريبة، ففي الأم (٥/ ٥٢٩ ط. د. رفعت فوزي): «وإن أراد إمام أهل العدل

أخذ الصدقة منهم، وادعوا أن إمام أهل البغي أخذها منهم، فهم أمناء علىٰ صدقاتهم، وإن ارتاب بأحد منهم أحلفه، فإذا حلف لم تعد عليه الصدقة».

وظاهره عدم التحليف إذا لم تكن فيه ريبة خلافا لما ذكره الشيخان من التحليف مطلقا.

وهذا هو الذي عزاه ابن المنذر للشافعي، فقال في الإشراف (٣/ ٩٧): «وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان: يستحلفون إذا اتهموا».

وظاهر القول بالتحليف أن ذلك واجب، وهو الذي صححه في تصحيح التنبيه (٣/ ٤٤١ فقرة ١١٢٩ ط. د. محمد عقلة الإبراهيم) فقال: «وأن من ادعىٰ دفع الزكاة إلىٰ أهل البغي لزمه اليمين».

وفي بداية المحتاج لابن قاضي شهبة (٤/ ١٧٤) وصححه في «تصحيح التنبيه»، وهو ظاهر نص الإمام إن كانت فيه ريبة.

وصحح في الزكاة من الروضة الاستحباب، فقال في التنازع بين العامل ورب المال (٢/ ٢٠٦): «قلت: الأصح أن اليمين مستحبة، والله أعلم».

وقال في المالك يدعي هلاك الثمار المخروصة عليه أو بعضها، وأسند ذلك لسبب خفي (٢/ ٢٥٣): «وهل يمينه واجبة أم مستحبة؟ وجهان. أصحهما: مستحبة»، وفي (٢/ ٢٥٤): «فاليمين مستحبة لا واجبة علىٰ الأصح كما سبق»،

ونحوه في الروضة (٢/ ٣٤٠).

[٩٥] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٩٧ ط. الحداد): «أو جزية فلا علىٰ الصحيح، وكذا خراج الأرض في الأصح».

كذا قال في الجزية والخراج أنه لا يجزئ فيها دفعها للبغاة، وأن الخلاف في الجزية أضعف منه في الخراج.

وكذلك قال في الروضة (١٠/ ٥٤-٥٥): «وإن كان جزية، لم يصدق علىٰ الصحيح، وكذا إن كان خراجا علىٰ الأصح، لأنه أجرة، أو ثمن، بخلاف الزكاة، فإنها عبادة ومواساة، ومبناها علىٰ الرفق»، تبعا للرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٨٤)، وكذلك قال في الخراج في تصحيح التنبيه (٣/ ٤٤١ فقرة ١١٢٩ ط. د. محمد عقلة الإبراهيم).

وظاهر صنيع الرافعي والنووي أن الخلاف بين الأصحاب، ولهذا عبر النووي عن الجزية بالصحيح، والخراج بالأصح.

وهذه المسألة مما اضطرب فيها قول الشيخين كما سيأتي.

○ قال أبو عبد الباري:

وما ذكراه مخالف لنص الشافعي في الأم، ففيه أنه يصح أخذهم كالصدقات.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٥٢٩ ط. د. رفعت فوزي): وإن أراد إمام أهل العدل أخذ الصدقة منهم، وادعوا أن إمام أهل البغي أخذها منهم، فهم أمناء علىٰ صدقاتهم، وإن ارتاب بأحد منهم أحلفه، فإذا حلف لم تعد عليه الصدقة، وكذلك ما أخذوا من خراج الأرض، وجزية الرقاب، لم يعد علىٰ من أخذوه منه، لأنهم مسلمون، ظاهر حكمهم في الموضع الذي أخذوا ذلك فيه ما عليهم من خراج، وجزية رقبة، وحق لزم في مال أو غيره».

ويؤيده قبول أمان البغاة لأهل الحرب، ففي مختصر البويطي (ص ٩٦٧ ط. القره داغي): «ويجوز أمان أهل البغي لأهل الحرب، ولا يقاتلهم الإمام حتىٰ ينبذ إليهم».

فإذا كان أمانهم لهم جائزا، فما ترتب عليه من أخذ الجزية فهو جائز.

واضطرب فيها قول الشيخين كما تقجمت الإشارة إليه:

أما الرافعي: فقال في المحرر (ص ١٣٩١): «وما أقاموا من الحدود، وأخذوا من الزكاة والجزية والخراج واقعة مواقعها، وكذا يعتد بتفريقهم سهم المرتزقة علىٰ أجنادهم في أظهر الوجهين».

وقال في الشرح الكبير (١١/ ٨٣، ٨٤):« إذا أقام أهل البغي الحدود علىٰ

جناة البلد الذي استولوا عليه، وأخذوا الزكاة من أهله أو خراج أرضه أو الجزية من أهل الذمة فيه، اعتد بما فعلوه، وإذا عاد البلد إلىٰ أهل العدل، لم يطالبوا أهله بشيء من ذلك، وفي الجزية وجه رواه الفوراني وغيره: أنه لا يعتد بأخذها لهم؛ لأنها عوض السكنىٰ والأعواض بعيدة عن المسامحة، والظاهر الأول؛ واحتج له بأن عليا -كرم الله وجهه- قاتل أهل البصرة، ولم يتتبع بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق، وبأنهم فعلوا ذلك بناء علىٰ تأويل محتمل؛ فأشبه ما إذا قضىٰ القاضي بالاجتهاد، لا ينقضه قاض، آخر، وبأن في إعادة المطالبة إضرارا بأهل البلدة».

وأما النووي: فقال في المنهاج (٣/ ١٩١ ط. الحداد) فقال: «ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا، وفرقوا سهم المرتزقة علىٰ جندهم صح، وفي الأخير وجه».

وقال في الروضة (١٠/ ٥٤):«المسألة الثانية: إذا أقام البغاة الحدود علىٰ جناة البلد الذي استولوا عليه، وأخذوا الزكاة من أهله وخراج أرضه، وجزية الذميين فيه، اعتد بما فعلوه، وإذا عاد البلد إلىٰ أهل العدل، لم يطالبوا أهله بشيء من ذلك، وفي الجزية وجه شاذ لبعدها عن المسافة».

فإذا كان يصح ذلك منهم، ويعتد به، فلا معنىٰ لعدم القبول ممن يدعي ذلك، وغايته أن يحلف عند الريبة، وقد يطول زمان حكم البغاة لبعض الأقاليم، ويتعسر إقامة البينة علىٰ ذلك، ولو قلنا: إن ذلك أجرة، فقد استمتعوا بها تحت حكم البغاة، ولهذا سوىٰ بينها الشافعي في النص المتقدم عن الأم.

وعليه مشىٰ البلقيني في التدريب في الفقه (٤/ ١٢٨) فهو المعتمد.

[٩٦] وقال النووي في المنهاج (٣/ ١٩٧ ط. الحداد): «ويصدق في حدٍّ إلا أن يثبت ببينة، ولا أثر له في البدن».

ما ذكره النووي هنا من زياداته علىٰ المحرر، وقد نقله الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٨٤) عن أبي سعيد المتولي في التتمة، وتبعه النووي علىٰ ذلك في الروضة (١٠/ ٥٥) ولم يرجحا شيئا، ونصه في الروضة: «وإن كان حدًّا فقال المتولي: يصدق إن كان أثره باقيا علىٰ بدنه، وإلا فإن ثبت بالإقرار صدق؛ لأنه يقبل رجوعه، وإن ثبت بالبينة فلا».

○ قال أبو عبد الباري:

لم يفرق الشافعي بين ثبوت الحد بالبينة أو الإقرار في الأم والمزني والبويطي، بل أطلق عدم إقامة الحد عليه مرة أخرىٰ، وهو المعتمد الذي تقتضيه

نصوصه.

قال الشافعي في الأم (٥/٥٢٨-٥٢٩ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا ظهر أهل البغي علىٰ بلد من بلدان المسلمين، فأقام إمامهم علىٰ أحد حدا لله أو للناس، فأصاب في إقامته، أو أخذ صدقات المسلمين، فاستوفىٰ ما عليهم أو زاد مع أخذه ما عليهم ما ليس عليهم، ثم ظهر أهل العدل عليهم، لم يعودوا علىٰ من حده إمام أهل البغي بحد، ولا علىٰ من أخذوا صدقته بصدقة عامه ذلك، فإن كانت وجبت عليهم صدقة فأخذوا بعضها، استوفىٰ إمام أهل العدل ما بقي منها، وحسب لهم ما أخذ أهل البغي منها».

وفي مختصر المزني (٢/٤٣٨ ط.الداغستاني): «وإذا غلبوا علىٰ بلاد، فأخذوا صدقات أهلها، وأقاموا عليهم الحدود، لم تعد عليهم».

وفي مختصر البويطي (ص ٩٦٦ ط. القره داغي): «وإذا ظهر أهل البغي علىٰ أهل بلد، فأقاموا حدود الله، وأخذوا صدقاتهم، ثم ظهر عليهم المسلمون، فالحكم جائز، والصدقة قد جازت، وليس عليهم إخراجها ثانية».

وهذا هو المعتمد المنصوص عليه، فلا فرق بين حدٍّ ثبت بالبينة أو ثبت بالإقرار، ولا فرق أيضا بين ما إذا كان علىٰ البدن أثر أو لم يكن، وذلك لأن حكم البغاة علىٰ البلد قد يطول، فتزول الآثار، ويعسر علىٰ الناس إقامة البينة علىٰ

ذلك، ولا يشترط في كثير من الحدود بقاء الآثار طويلا كحد الشرب ونحوه.

قال الزركشي في الخادم (ص ٣٤٠ تحقيق منصور بن عبد الوهاب الشقحاء): «الذي حكاه الماوردي وغيره أن من ادعىٰ استيفاء الحد يقبل بلا يمين؛ لأنه مما يدرأ بالشبهات، وكلام ابن الرفعة في الكفاية يفهم أنه المذهب، وساق ما حكاه المتولي وجها». وهو كما قال في الكفاية (١٦/ ٢٨١).

وهذا هو الذي تدل عليه النصوص التي نقلناه عن الشيخين في المسألة التي قبل هذه.





كتاب الردة

[٩٧] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٠٤ ط. الحداد): «وبيعه وهبته وكتابته باطلة، وفي القديم موقوفة».

كذا قال النووي، وهو تبع الرافعي في المحرر فإنه صحح وقف ملكه أولا، فقال في المحرر (ص ١٤٠٣): «وهل يزول ملك المرتد عن أمواله؟ فيه ثلاثة أقوال، ثالثها وهو الأصح: أنا نتوقف، إن هلك علىٰ الردة بان زوال ملكه بالردة، وإن عاد إلىٰ الإسلام بان أنه لم يزل».

ثم قال في المحرر (ص ١٤٠٤): «وبيعه وهبته وكتابته علىٰ قول وقف العقود فعلىٰ الجديد هي باطل، وعلىٰ القديم موقوف».

○ قال أبو عبد الباري:

هذا الإطلاق في وقف تصرفه في ماله بعد الردة، وإبطال ما لا يحتمل الوقف كما قال الشيخان مخالف لنصوص الشافعي في الأم والمزني والبويطي، وهذه جملة من أقواله:

١. قال الشافعي في الأم (٤/ ٣١٥ ط. د. رفعت فوزي): «إذا ارتد الرجل عن

الإسلام، ثم رهن عبدا له، فمن أجاز بيع المرتد أجاز رهنه، ومن رد بيعه رد رهنه. قال الربيع: كان الشافعي يجيز رهن المرتد كما يُجوِّز بيعه».

٢. وقال الشافعي في الأم (٧/ ٤٠٦-٤٠٧ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فلم يوقف ماله، فما صنع فيه فهو جائز، كما يجوز له في ماله ما صنع قبل الردة، فإذا وقف فلا سبيل له علىٰ إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفا، فإن أعتق، أو كاتب، أو دبر، أو اشترىٰ، أو باع، فذلك كله موقوف، لا ينفذ منه شيء في حال ردته، فإن رجع إلىٰ الإسلام لزمه ذلك كله إلا البيع، فإذا فسخ بيعه فقد انفسخ، لأنه لم يكن محولا بينه وبين ماله في الحال الذي أحدث ذلك فيه حول الحجر، إنما كان موقوفا عنه ليقتل، فيعلم أن ملكه كان زائلا عنه بالردة، إن لم يتب حتىٰ يموت فيصير فيئا، أو يسلم فيكون علىٰ ما كان في ملكه أولا، فلما أسلم علمنا أن فعله فيما يملك».

٣. وقال الشافعي في الأم (٩/ ٣٥٩ ط. د. رفعت فوزي): «إذا ارتد الرجل عن الإسلام، فكاتب عبده قبل أن يقف الحاكم ماله، فكتابته جائزة، وكذلك كل ما صنع في ماله فأمره فيه جائز، كما كان قبل الردة، فإذا وقف

الحاكم ماله حتىٰ يموت، أو يقتل علىٰ الردة فيصير ماله يومئذ فيئا، أو يتوب فيكون علىٰ ملكه، لم تجز كتابته».

٤. وقال في مختصر المزني (٢/ ٧٦٠ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ولو كاتب المرتد عبده قبل أن يقف الحاكم ماله كان جائزا».

٥. وقال في مختصر البويطي (ص ١١٢٠ ط. القره داغي): «وإذا دبره ثم ارتد السيد، فإن رجع إلىٰ الإسلام فهو علىٰ تدبيره، وإن قتل أو مات فهو حرّ إن حمله الثلث وماله فيء، فإن رجع في التدبير قبل أن يوقف السلطان ماله فأخرجه من ملكه فذلك رجوع، وإن كان بعد إيقاف السلطان لم يجز».

٦. وقال في مختصر البويطي أيضا (ص ١١٢٩ ط. القره داغي): «وإذا ارتد الرجل عن الإسلام، ثم كاتب عبده قبل أن يرجع إلىٰ الإسلام، فكتابته جائزة، وكل ما صنع في ماله فأمره جائز فيه كما كان قبل الردة، وإذا أوقف الحاكم ماله فلا يجوز».

هذه النصوص متطابقة في أن جميع تصرفاته في ماله نافذة قبل حجره، وأن الحجر علىٰ المرتد لا يكون إلا بالقاضي والسلطان، وبعد حجره موقوفة، سواء ما كان منها بعوض ككتابة وبيع، أو بدون عوض كعتق وهبة وتدبير، لا فرق في ذلك، إلا ما ذكر في البيع من جواز الفسخ، ومن هذا يتبين أن ما نسبه

للجديد من البطلان غير صحيح، وأن أكثر أقواله في الجديد وقف تصرفات المرتد بالقاضي لا بالردة.

وهذا هو الذي رجحه النووي في الروضة (١٠/ ٧٩-٨٠) فقال: «وهل يصير بنفس الردة محجورا عليه، أم لا بد من ضرب القاضي؟ وجهان، ويقال قولان، أصحهما: الثاني، ومنهم من قطع به».

فإن قيل: للشافعي قول آخر بالوقف بالردة.

ففي مختصر البويطي (ص ٨٩٧، ٨٩٨ ط. القره داغي): «وإذا ارتد المرتد فكل ما عمل في ردته من بيع أو شراء أو هبة أو غير ذلك قبل أن يوقف السلطان ماله ويستتيبه فهو موقوف، فإن رجع إلىٰ الإسلام فهو جائز، وإن قتل علىٰ ردته لم يجز منه شيء.

وقد قيل: كل ما عمل به بعد إيقاف السلطان لم يجز ويفسخ، «والأول أحب إلي».

فذكر هنا قولين ورجح الوقف بالردة، بقوله «والأول أحب إلي».

فالجواب عنه من وجوه:

الأول: أن الشافعي اختار الوقف بالردة، وما في المنهاج من اختيار البطلان

ونسبته للجديد مخالف لذلك، كما أنه مخالف.

الثاني: أن قول الشافعي هنا «والأول أحب إلي» يمكن حمله علىٰ الاستحباب، جمعا بينه وبين نصوصه في الأم والمزني والبويطي التي اختار فيها الثاني، وهو أن وقف ماله يكون بالقاضي.

الثالث: أن أقواله في الأم والمزني والبويطي أكثر وأولىٰ من قوله هذا في البويطي، لأنها أكثر، توافق عليها الربيع والبويطي والمزني، فتكون أولىٰ من رواية واحدة.

❐ **والخلاصة**: أن ما في «المنهاج» من بطلان بيعه وهبته وعتقه، ونسبة الوقف للقديم لا يصح، بل المنصوص في «الأم» والمزني والبويطي -وكلها من الجديد- علىٰ أن ذلك موقوف بعد حجر القاضي عليه قولا واحدا، وقبل حجر القاضي كذلك كما في البويطي، ويمكن التوفيق بينه وبين ما في البويطي بحمل الأول علىٰ اللزوم، والثاني علىٰ الاستحباب، وإلا فالراجح نصوصه الكثيرة علىٰ نصوص البويطي الوحيد.





كتاب الزنا

[٩٨] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٠٦ ط. الحداد): «ولا بهيمة في الأظهر».

ما ذكره النووي هنا تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٤٠٧) في قوله: «وإتيان البهيمة فأصح القولين أن الواجب فيه التعزير دون الحد».

وقال في الروضة (١٠/ ٩٢): «إتيان البهيمة حرام، وفي واجبه أقوال، أظهرها: التعزير»، وهو تبع الرافعي في ذلك (١١/ ١٤٢) لكنه جعل في أصل وجوب الحد علىٰ قولين، ثم علىٰ القول بالحد جعل قولين: أحدهما: كالزنا في البكر والإحصان، والثاني: يقتل مطلقا، وهذا هو الصحيح في قولهم «أقوال»، لكن الشافعي رجع عن قول القتل مطلقا.

○ قال أبو عبد الباري:

هذاالترجيح ضعيف، لأنه نوع تأويل، والظاهر الصريح عن الشافعي أنه كالزنا في وجوب الحد، وهذه نصوصه:

قال الشافعي في الأم (٨/ ١٣٨ ط. د. رفعت فوزي): «والشهادة علىٰ اللواط وإتيان البهائم أربعة، لا يقبل فيها أقل منهم؛ لأن كلاً جماع».

ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣١٥) ثم قال: «هذا هو المذهب»، ثم أجاب علىٰ ما احتج به من خالف ذلك من أقوال الشافعي وسيأتي.

وفي مختصر المزني (٢/ ٦٧٩ ط. الداغستاني): «قال المزني: وقد قال في كتاب الحدود: «إن إتيان البهيمة كالزنا يحد فيه».

وقال بعده بسطور: «قال المزني: قد قطع في غير موضع بحدهم».

وفي مختصر البويطي (ص ١٠٠٤ ط. القره داغي): «ولا تجوز الشهادة في اللواط والبهائم أقل من أربع، ويحد في اللواط والبهائم كما يحد في المرأة، لأنه فرج بفرج».

وهذا نص صريح في وجوب الحد في اللواط والبهائم كما تجب في الزنا، وهو الذي أشار إليه المزني، وهو بمعنىٰ قوله «لأن كلاً جماع» في النقل المتقدم عن الأم، وليس للشافعي نص صريح يعارضه، وإنما فيه نص محتمل، وقد تنازع أصحابنا في دلالته، واضطربت أقوالهم فيه، ولم يذكروا نصه في البويطي، وهو قاطع لكل الاحتمالات التي يأتي ذكرها.

ولهذه النصوص قال الماوردي في الإقناع (ص ١٦٨): «واللواط وإتيان

البهائم زنا».

وقال في الأحكام السلطانية له (ص ٣٢٩): «واللواط وإتيان البهائم زنا يوجب جلد البكر، ورجم المحصن».

وقال القاضي أبو شجاع في مختصره (ص ٣٩): «وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا».

وفي التدريب للبلقيني (٤/ ١٦٧): «ويحد في البهيمة علىٰ المنصوص خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله».

ويؤيد ذلك أن الشافعي قرن بين اللواط وإتيان البهائم، وقد ذكر أن اللواط كالزنا في الحكم في مواضع من الأم.

وإذا علم أن المعتمد عن الشافعي في اللواط أنه كالزنا في الحد، وأنه رجع عن القول بالقتل مطلقا، ترجح أن إتيان البهيمة حكمها حكم الزنا، وأن النقل عن الشافعي في الاقتران بينهما يدل علىٰ أن مذهبه كذلك.

وعلىٰ هذا النسق جاءت أقوال الشافعي في التسوية بين اللواط، وإتيان المرأة، والبهيمة في الأحكام، كوجوب الغسل عند تغييب الحشفة في الفرج، وبطلان الصيام مع وجوب الكفارة.

قال الشافعي في الأم (٢/ ٨١ ط. د. رفعت فوزي): «وكذلك كل فرج أو دبر أو غيره، من امرأة، أو بهيمة، وجب عليه الغسل، إذا غيب الحشفة فيه، مع معصية الله تعالىٰ في إتيان ذلك من غير امرأته».

فجعل الشافعي حكم إتيان البهيمة والمرأة واحدا في وجوب الغسل إذا غابت الحشفة في الفرج.

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٢٥١ ط. د. رفعت فوزي): «ولو جامع صبية لم تبلغ، أو أتىٰ بهيمة فكفارة واحدة، ولو جامع بالغة كانت كفارة لا يزاد عليها علىٰ الرجل».

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٢٥٤ ط. د. رفعت فوزي): «وإن أتىٰ امرأته في دبرها فغيبه، أو بهيمة، أو تلوط، أفسد وكفر مع الإثم بالله في المحرم الذي أتىٰ مع إفساد الصوم».

فجعل حكم إتيان البهائم والنساء في رمضان واحدا في وجوب الكفارة وفساد الصوم.

والمقصود: أن الشافعي جعل اللواط وإتيان البهيمة كإتيان المرأة في الأحكام، ونص علىٰ ذلك في الزنا ووجوب الحد ونصاب شهادة الزنا، فهذا هو مذهبه كما قال البيهقي والماوردي وغيرهما كما تقدم.

اعتراض وجوابه

فإن قيل: اعتمد الشيخان علىٰ قول الشافعي في الأم (٨/ ١٢٦ ط. د. رفعت فوزي) في استفسار شهود الزنا: «ويكون فيما يسأل الإمام الشهود عليه: أزنىٰ بامرأة؟ لأنهم قد يعدون الزنا وقع علىٰ بهيمة، ولعلهم أن يعدوا الاستمناء زنا، فلا نحده أبدا حتىٰ يثبتوا الشهادة، ويبينوها له فيما يجب في مثله الزنا».

فقوله: «لأنهم قد يعدون الزنا وقع علىٰ بهيمة» يدل علىٰ أن إتيان البهيمة ليس كإتيان المرأة في حكم الزنا، وهو كما قال الروياني في بحر المذهب (١٣/ ٢٦): «وهذا نص علىٰ أن إتيان البهيمة ليس بزنا».

فالجواب: أن هذا محتمل، وليس بصريح، فلا يعارض بالصريح من قوله.

قال البيهقي في المعرفة (١٢/ ٣١٥): «قوله في مسألة الشهود «أزنىٰ بامرأة لأنهم قد يعدون الزنا وقوعا علىٰ بهيمة»، فيحتمل أنه إنما قاله للفرق بين حديهما، ففي الزنا لا يرجم ما لم يكن محصنا، وفي إتيان البهيمة يقتل بكل حال في أحد القولين علىٰ ظاهر الحديث».

وفي تحرير الفتاوىٰ (٣/ ١٩٠) عن البلقيني نحوه، وزاد عنه أن الشافعي نص عليه في الحدود، وكلامه في غيره محتمل».

وأما قول الروياني أنه نص في المسألة، فيرده أن الروياني نفسه جعله غير

صريح في ذلك، فقال في بحر المذهب (١٣/ ٢٦): «ربما تعد الشهود إتيان البهيمة زنا والقاضي لا يعده زنا، ولهذا يستفسرهم».

فعده الروياني مرة نصا علىٰ المسألة، ومرة محتملا، والثاني هو الصواب، وتبين بذلك أن مذهب الشافعي وجوب الحد في إتيان البهائم كالزنا، لأنه فرج بفرج، ولأنه جماع .

وقال الزركشي في الخادم (ص ٣٠٩-٣١٩ صالح بن عبد العزيز الخطيب): «هذا الترجيح تابع فيه البغوي، وقد اغتر به في المطلب فقال: إنه الصحيح عند عامة الأصحاب، وليس كذلك، فإن كثيرا من الأصحاب سكتوا عن الترجيح كالفوراني والقاضي الحسين، وقد نص الشافعي في كتاب الحدود علىٰ إيجاب الحد فيه كما حكاه المزني في كتاب الشهادات، فقال في كتاب الحدود (إن إتيان البهيمة كالزنا يحد فيه) يشير إلىٰ قوله (ولا يجوز علىٰ الزنا واللواط وإتيان البهائم إلا أربعة، يقولون: رأيناه يدخل ذلك منه في ذلك منها دخول المرود في المكحلة).

وأما القول بعدم الحدّ فلم ينص عليه صريحا، بل هو قضية نصه في الشهادات، وفي الطهارة حيث لم ينقض بمس فرج البهيمة، ولهذا قال

الماوردي: إنه مخرج، يعني أن إيجاب التعزيز مخرج من قوله في كتاب الشهادات، وممن اختار الحد الروياني في الكافي، فقال: «والصحيح أن إتيان البهائم زنا»، واختاره البيهقي».

وهو الذي يؤيده ظاهر الدليل أيضا، فيكون أولىٰ بقول الشافعي من غيره، ففي تحفة المحتاج للهيتمي (٩/ ١٠٦): «في حديث صحيح «من أتىٰ بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»[(١)] والجواب عنه مشكل، إذ لا يتأتىٰ إلا بالنسخ، وهو يحتاج لدليل آخر».

[٩٩] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٠٩ ط. الحداد): «ولا تُغرَّب المرأة وحدها في الأصح».

أفاد كلام النووي هنا أن الخلاف وجهان، أصحهما: المنع، وهو تبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٤٠٩) ولفظه: «وأصح الوجهين أن المرأة لا تُغرَّب وحدها».

وبمثل ذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ١٣٥-١٣٦) وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ٨٧) وجعلا الخلاف وجهين، أصحهما: لا تُغرَّبُ وحدها.

---

(١) رواه أبو داود (رقم ٤٤٦٤) من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعا. وصححه الألباني.

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكراه من منع تغريب المرأة وحدها مخالف لنصوص الشافعي في الأم وغيره، وقد جعله الشافعي سفرا واجبا لا يشترط فيه وجود المحرم كسائر الأسفار الواجبة إذا كان الطريق آمنا.

ذكر الشافعي في الأم (٣/ ٢٩٢ ط. د. رفعت فوزي) جواز سفر المرأة لأداء حج الفريضة بدون محرم، إذا كانت مع الرفقة امرأة ثقة، ثم قال: «فإن قال قائل: فهل من شيء بيّنته غير ما ذكرت؟ قيل: نعم. ما لا يخالفنا فيه أحد علمته من أن المرأة يلزمها الحق، وتثبت عليها الدعوىٰ ببلد لا قاضي به، فتجلب من ذلك البلد، ولعل الدعوىٰ تبطل عنها، أو تأتي بمخرج من حق لو ثبت عليها مسيرة أيام مع غير ذي محرم إذا كانت معها امرأة، وأن الله تعالىٰ قال في المعتدات: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، فقيل: يقام عليها الحد، فإذا كان هذا هكذا، فقد بين الله ﷻ أنه لم يمنعها الخروج من حق لزمها».

ووجهه: أن الحق إذا لزم المرأة لم يلزم المحرمُ في أداء ذلك الحق، والتغريب من هذا الباب، لأنه وجب عليها مع الحد، فيجوز ذلك كسائر الحقوق اللازمة، ولا يشترط المحرم في ذلك.

وذكر الشافعي في باب «الاعتراف بالزنا والنفي» من الأم مسألة التغريب

وناقش فيها القائلين بعدم النفي مناقشة طويلة مدارها علىٰ التفريق بين السفر اللازم وغيره، وهو الذي كرره مرتين أو أكثر في هذا الباب.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣٣٧-٣٣٩ ط. د. رفعت فوزي): فإن قال قائل: لا أنفي أحدا، فقيل لبعض من يقول قوله: ولم رددت النفي في الزنا، وهو ثابت عن النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، والناس عندنا إلىٰ اليوم؟.

قال: رددته؛ لأن رسول الله ﷺ قال: «لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم».

فقلت له: سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما لا يلزمها من الأسفار، وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل، وأمرت بالقرار في بيتها، وقيل لها: صلاتك في بيتك أفضل، لئلا تعرضي أن تفتتني، ولا يفتتن بك أحد، وليس هذا مما يلزمها بسبيل.

أرأيت لو قال قائل يستخف بخلاف السنة: لا أجلدها فتمجن، ما الحجة عليه إلا ترك الحجة بالكتاب والخبر، أو رأيت إذا اعتللت في النفي بأن النبي ﷺ: «نهىٰ أن تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم«ما هو من حد الزنا؟ قال: إنهما

يجتمعان في معنىٰ أن في النفي سفرا.

قلنا: وإذا اجتمع الحديثان من الصنفين المختلفين في معنىٰ من المعاني أزلت أحدهما بالآخر؟ قال: نعم، قلنا: إذا كان النفي من أثبت ما روي عن رسول الله ﷺ والأئمة بعده، والناس إلىٰ اليوم عندنا أن نقول كما قلت: لما اجتمعا في أن فيه سفرا، أبحنا للمرأة أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي رحم محرم، قال: لا، قلنا: فلم كان لك أن تزيل أحدهما بالآخر، ولا يكون ذلك لنا عليك؟...

وقلنا له: أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا علىٰ ثلاث ليال أو أكثر، فادعىٰ عليها مدع حقا، أو أصابت حدا؟.

قال: ترفع إلىٰ القاضي، قلنا: مع غير ذي محرم؟ قال: نعم، قلنا: فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم، قال : هذا يلزمها، قلنا: فهذا يلزمها برأيك، فأبحته لها، ومنعتها منه فيما سن فيه رسول الله ﷺ، وأخبر به عن الله جل وعلا فيها»[(١)].

وبهذا يتبين من مذهب الشافعي أمران:

أولهما: أن التغريب من حد الزنا اللازم، والنصوص الواردة فيه لم تفرق بين

---

(١) اختصرته ووضعت مواضع الحذف ثلاث نقاط هكذا ...

الرجل والمرأة، فيلزم التغريب في زنا البكر للنصوص الكثيرة.

ثانيهما: أن سفر المرأة اللازم لا يشترط فيه وجود محرم كسفر الحج، والهجرة، وإقامة الحد، وحضور الدعوىٰ، ونحوها إذا أمن الطريق، وكان معها رفقة آمنة من نسوة ثقات، أو امرأة ثقة.

وقال الزركشي في الخادم (ص ٢٨٣ تحقيق صالح بن عبد العزيز الخطيب) فقال: «ما صححه من المنع مخالف لنص الشافعي، فإنه نص في اختلاف الحديث علىٰ التغريب من غير محرم، لأن اعتبار المحرم إنما يكون في سفر لا يلزم، والتغريب لازم، قال: «ولا علم مخالفا في أنا لو كانت ببلد بعيد عن الحاكم فأحدثت حدا يلزمها حدٌّ جلبت إلىٰ الحاكم، فدل هذا علىٰ أنها إنما نهيت عن السفر فيما لا يلزمها»[(١)].

وفي النجم (٩/ ١٢٠): «والثاني: تغرب وحدها؛ لأنه سفر واجب فأشبه سفر الهجرة، كذا أطلق الخلاف جماعة، وخصه الإمام والغزالي بأمن الطريق، وإلا امتنع سفرها وحدها جزما».

وفي تحرير الفتاوىٰ (٣/ ١٩٥) عن البلقيني: «نص الشَّافعي في «الأم» في

---

(١) انظر: اختلاف الحديث (ص ١٠٦ تحقيق أحمد عبد العزيز)

باب حج المرأة والعبد صريح في الاكتفاء في الحج بالمرأة الواحدة، وصرح به الماوردي والنووي في «شرح المهذب»، قال: ونص في موضعين من «الأم» علىٰ تغريبها وحدها، وأن النهي عن سفرها وحدها إنما هو فيما لا يلزمها، قال: ولم أقف علىٰ نص للشافعي يخالفه».

وقال في التدريب (٤/ ١٦٨): «وتغرب المرأة وحدها علىٰ النص، وهو مقيد بما إذا كان الطريق آمنا، خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله».

وتلخص من ذلك أن مذهبه تغريب المرأة وحدها مع أمن الطريق، ولا يشترط وجود زوج أو محرم خلافا لما صححه النووي هنا في «المنهاج».

[١٠٠]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢١٢ ط. الحداد): «وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم».

ذكر النووي هنا أن المكاتب يحد عبيده علىٰ الأصح، فجعله الراجح من وجوه الأصحاب، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٤١٤) ولفظه: «والفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم علىٰ الأصح».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ١٦٥): «والأظهر: أنهم يقيمون الحد، ويقال: إنه منصوص عليه في القديم في حق الفاسق».

وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٠٤) فقال: «وللفاسق والمكاتب والكافر إقامته علىٰ رقيقهم علىٰ الأصح بناء علىٰ أن سبيله سبيل الإصلاح»[(١)].

○ قال أبو عبد الباري:

ما صححه الشيخان هنا من أن المكاتب يحد عبيده مخالف لنصوص الشافعي الصريحة في المنع.

قال الشافعي في الأم (٩/ ٤١٨ ط. د. رفعت فوزي): «وللمكاتب أن يؤدب عبده، وليس له أن يحده؛ لأن الحد لا يكون إلىٰ غير حر».

وفي مختصر المزني (٢/ ٧٦٣ ط. الداغستاني): «وللمكاتب أن يؤدب رقيقه، ولا يحدهم؛ لأن الحد لا يكون لغير حر».

وهذان النصان صريحان في أن المكاتب لا يحد عبيده لبقاء الرق فيه، وهو الذي رجحه الشيرازي في التنبيه (ص ٢٤٢) فقال: «وإن كان مكاتبًا، فقد قيل: يقيم، وقيل: لا يقيم، وهو الأصح».

وقال الإسنوي في المهمات (٨/ ٣٢٤ عن الرافعي): وما ذكره في المكاتب

---

(١) يستثنىٰ من ذلك إقامة الكافر الحد علىٰ عبيده ما إذا كان عبده مسلما، فلا يحده بحال، نقله النووي في الروضة (١٠/ ١٠٤) عن كتاب ابن كج أنه المذهب، وأقره عليه، ومشىٰ عليه البلقيني في التدريب (٤/ ١٧١).

مردود، فإنه مصادم لنص الشافعي في «الأم» ... فذكر نصه المتقدم، ثم قال: «هذا لفظه بحروفه ومن الأم نقلته، وهو ظاهر مقيس».

وقال الأذرعي في قوت المحتاج (٩/ ٧٠): «المذهب المنصوص في الأم والمختصر في كتاب «الكتابة«أن المكاتب يؤدب عبيده ولا يحدهم».

وقال الزركشي في الخادم (ص ٣٨١-٣٨٢ تحقيق صالح بن عبد العزيز الخطيب): «ما رجحه في المكاتب من الجواز ليس كذلك، فقد نص الشافعي فيه علىٰ المنع في المختصر في باب الكتابة...» ثم ذكر نصوص الشافعي المتقدمة ثم قال: «وعليه جرىٰ الأصحاب هناك منهم الماوردي في الحاوي، وابن الصباغ في الشامل، والمحاملي في المقنع، والدارمي في الاستذكار، والجويني في مختصره، وفروقه، والغزالي في الخلاصة، والروياني في الحلية، وهو الأصح في التنبيه، والشافي للجرجاني، وعليه جرىٰ الروياني في البحر، والبغوي في التهذيب، وغيرهم، وعللوا المنع بأن الحرية هي المعتبرة في عدة آلات الحدود، ولضعف ملكه، وبأنه ولاية وليس من أهلها».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ١٧١): «وليس للمكاتب أن يقيم الحد علىٰ عبده علىٰ النص في «الأم» خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله».

[١٠١]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢١٢ ط. الحداد): «ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين، وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار».

هكذا رجح النووي عدم التأخير مطلقا، وجعل القول بالتفصيل وجها ضعيفا، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٤١٦) ولفظه: «ولا يؤخر الرجم بالمرض، وفيما إذا ثبت بالإقرار وجه أنه يؤخر».

وكذلك الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ١٥٧)، وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ٩٩) فقال: «الصحيح الذي قطع به الجمهور؛ أن الرجم لا يؤخر للمرض، لأن نفسه مستوفاة، فلا فرق بينه وبين الصحيح، وقيل: إن ثبت بالإقرار أخر حتىٰ يبرأ، لأنه ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ذلك علىٰ قتله، ومثل هذا الخلاف يعود في أنه هل يرجم في شدة الحر والبرد؟».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ضعفاه من التفصيل هو منصوص الشافعي في الأم، وهو المعتمد.

قال الشافعي في الأم (٧/ ١٤٧ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا وجب عليه رجم ببينة أخذ في الحر والبرد، وأخذ وهو مريض، وإذا وجب عليه باعتراف لم يؤخذ مريضا، ولا في حر، ولا برد؛ لأنه متىٰ رجع قبل الرجم وبعده تركته».

وهذا النص صريح في التفصيل المذكور، وهو الذي ذكره الشيرازي في التنبيه (ص٢٤٣) فقال: «فإن وجب الرجم في الحر أو البرد أو المرض؛ فإن كان قد ثبت بالبينة رجم، وإن ثبت بالإقرار فالمنصوص: أنَّه يؤخر إلىٰ أن يبرأ ويعتدل الزمان».

وقال الروياني في بحر المذهب (١٣/ ٢١): «إن كان هناك مرض، أو كان الزمان غير معتدل، نظر، فإن كان الرجم ثبت بالبينة أقيم في الحال ولم يؤخر؛ لأن القصد قتله فلا يعتبر حال الزمان، وإن كان ثبت بالإقرار فالمنصوص أنه يؤخر إلي اعتدال الزمان والبرد؛ لأنه ربما يمسه حر الحجارة فيرجع، فيعين الزمان علىٰ قتله، ومن أصحابنا من قال: يقام عليه الحد؛ لأن القصد منه القتل، وقد وجب كما وجب بالبينة، وهذا اختيار أبي إسحاق».

وقال الأذرعي في قوت المحتاج (٩/ ٧٧): «هذا ليس بوجه مرجوح، بل هو منصوص في الأم، وجزم به الفوراني، وصححه القاضي حسين في كتاب اللعان، وصاحب التنبيه هنا، ونسبه الإمام هنا للأئمة، وإلىٰ النص في اللعان».

وقال الزر كشي في الخادم (ص ٣٦٢-٣٦٣ تحقيق صالح بن عبد العزيز الخطيب): «حكايته هذا وجها غريب، فإن الشافعي نص عليه في «الأم»».

ثم ذكر كلام الروياني المتقدم، ثم ذكر قريبا من كلام الأذرعي، ونقل عن ابن

الرفعة في المطلب العالي أنه ذكر فيها أربعة أوجه فقال: «أحدها: التعجيل، والثاني: التأخير، والثالث: إن ثبت بالبينة عجل وإلا فلا وهو المنصوص في الأم، والرابع: عكسه».

وعلىٰ هذا فالمعتمد التفصيل، لأنه يمكن الجمع بينهما بحمل العام علىٰ ما ثبت بالبينة وما يقوم مقامها كاللعان، وتقديم الخاص فيما ثبت بالإقرار، والتوفيق بين نصوص الإمام أولىٰ من شرح بعضها.

اعتراض وجواب

فإن قيل: جاء في مختصر المزني (٢/ ٤٥٣): «ولا يقام حد الجلد علىٰ الحبلىٰ، ولا علىٰ المريض الدنف، ولا في يومٍ حرُّه أو برده مفرطٌ، ولا في أسباب التلف، ويرجم المحصن في كل ذلك، إلا أن تكون امرأة حبلىٰ، فتترك حتىٰ تضع وتكفل ولدها».

فالجواب: أن هذا عام فيما ثبت بالإقرار وبالبينة، وما تقدم من النص علىٰ التفصيل خاص، والخاص مقدم علىٰ العام في موضعه.

ويجاب أيضا: بأن المزني اختصر كلام الشافعي اختصارا مخلا بتمام المعنىٰ، وهو يصنع ذلك في غير موضع كما تقدم في أول الكتاب عن البيهقي

والجويني وغيرهما، ونبهنا عليه مرارا في هذا الكتاب.

[١٠٢]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢١٣ ط. الحداد): «وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ضمان علىٰ النص، فيقتضي أن التأخير مستحب».

ما ذكره النووي من أن عدم الضمان يقتضي أن التأخير مستحب لا واجب، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٤١٦) ولفظه: «ولو جلد الإمام في المرض أو في الحر والبرد فهلك المجلود فلا ضمان علىٰ الأظهر، وبذلك يتبين أن التأخير مستحب».

○ قال أبو عبد الباري:

وهو مخالف لنص الإمام الشافعي واختيار النووي في الروضة.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢١٥ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا وقع علىٰ الرجل حد فضربه الإمام وهو مريض، أو في برد شديد، أو حر شديد، كرهت ذلك، وإن مات من ذلك الضرب فلا عقل، ولا قود، ولا كفارة».

وهذ النص موافق لما تقدم للإمام في القصاص فيما دون النفس؛ فإنه قال في الأم (٧/ ١٤٥ ط. د. رفعت فوزي): «إذا كان القود في بلاد باردة، وساعة باردة، أو بلاد حارة، وساعة حارة، فإن كان ما دون النفس أخر حتىٰ يذهب حد البرد،

وحد الحر، ويقتص منه في الحال التي ليست بحال تلف، ولا شديدة المباينة لما سواها من الأحوال، وكان حكم الحر والبرد حكم مرضه، يقتص منه في النفس، ولا يقتص منه فيما دونها، والمرأة والرجل في هذا سواء».

وقال فيه أيضا (٧/ ١٤٦-١٤٧ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كان الذي يجب عليه جراحا لا يأتي علىٰ النفس لم يؤخذ ذلك منه مريضا، ولا في حر شديد، وبرد شديد، وحبس حتىٰ تذهب تلك الحال، ثم يؤخذ منه».

وكذلك موافق لقوله في الختان في الأم (٧/ ٢١٨ ط. د. رفعت فوزي): «ولو كان رجل أغلف، أو امرأة لم تخفض، فأمر السلطان بهما فعذرا فماتا، لم يضمن السلطان؛ لأنه قد كان عليهما أن يفعلا، إلا أن يعذرهما في حر شديد، أو برد شديد، يكون الأغلب أنه لا يسلم من عذر في مثله فيضمن عاقلته ديتهما». ونحوه في مختصر المزني (٢/ ٤٨٠ ط. الداغستاني).

فمنع من الختان في الحر والبرد الشديدين، وجعل الضمان علىٰ عاقلة السلطان لأنه خطأ، لأنه لم يكن له أن يعفل ذلك في هذه الحالة.

ولا تلازم عند الإمام بين وجوب الضمان، ووجوب التأخير أو استحبابه، وبالوجوب جزم غير واحد من الأئمة، فقال الماوردي في الحاوي (١٣/ ٣٢٥): «ولا يقطع في حر شديد ولا برد شديد خوفا من تلفه فيه، كما لا يحد

الزاني في شدة حر ولا برد».

وقال الشيرازي في التنبيه (ص ٢٤٢): «ولا يحدّ في حرٍّ شديد ولا برد شديد». ونحوه في المهذب (٣/ ٣٤٣).

وهو اختيار النووي في الروضة (١٠/ ١٠٢) فقال: «قلت: المذهب وجوب التأخير مطلقا والله أعلم».

وفي الخادم للزركشي (ص ٣٧٠-٣٧١ تحقيق صالح بن عبد العزيز الخطيب): «وفي تعليق الشيخ أبي حامد عن أبي إسحاق: لا خلاف من أصحابنا أن الإمام ليس له أن يقيم الحدّ في شدة حر أو برد، وكان ذلك حذرا من أن يعين الزمان علىٰ قتله».

وفصل البلقيني فذهب إلىٰ أن التأخير مستحب، ولا يجب إذا كان الضرب لا يهلك غالبا، ووجوبه إذا كان يهلك غالبا، حكاه عنه العراقي في التحرير (٣/ ٢٠٢).





كتاب قطع السرقة

[١٠٣]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢١٨، ٢١٩ ط. الحداد): «ولا قطع في طنبور ونحوه، وقيل: إن بلغ مكسره نصابا قطع، قلت: الثاني أصح».

صحح النووي هنا التفصيل، وجعله الوجه الراجح، وضعَّف ما رجحه الرافعي في المحرر (ص ١٤٢١-١٤٢٢) في قوله: «ولا قطع في سرقة الطنبور وما في معناه، إن كان لا يبلغ بعد الكسر نصابا، وكذا إن كان يبلغه في أصح الوجهين» وجها ضعيفا.

وقال في الروضة (١٠/ ١١٦): «ولو سرق آلات الملاهي كالطنبور والمزمار، أو صنما، فإن كان لا يبلغ بعد الكسر والتغيير نصابا، فلا قطع، وإن بلغه، قطع علىٰ الأصح عند الأكثرين منهم العراقيون والروياني، لأنه سرق نصابا من حرز».

○ قال أبو عبد الباري:

الصحيح المعتمد قول الرافعي في المحرر من أنه لا قطع فيه مطلقا، لأنه الموافق لنص الشافعي إمام المذهب.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣٧٣ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يقطع في ثمن الطنبور، ولا المزمار».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٦٩ ط. الداغستاني): «ولا قطع في طنبور، ولا مزمار، ولا خمر، ولا خنزير».

وهذا النص هو المشهور عن الإمام، وهو الذي صححه الرافعي في المحرر، وقبله الإمام في نهاية المطلب (١٧/ ٢٨٩-٢٩٠) فقال في شرح نص المزني: «فأما آلات الملاهي، وهي التي يستحق كسرها، فالقول في أنها إلىٰ أي حد تنتهي في التكسير والترضيض مذكور في موضعه من الغصوب، والغرض الآن القول في السرقة، فإن كان مترضض ما أخذه لا يبلغ نصابا، فلا قطع بلا خلاف، وإن كان الرضاض الذي لا يجوز المزيد في ترضيضه بحيث يبلغ نصابا، فإذا أخرجه السارق من الحرز، ففي وجوب القطع وجهان: أصحهما: أنه لا يجب؛ لأن الحرز لا يتحقق في حق هذه الآلات، ويجوز الهجوم علىٰ الدور لأجلها».

وذكر الماوردي في الحاوي الكبير (١٣/ ٣٥١) أنه أيضا اختيار أبي علي بن أبي هريرة.

وقال الزركشي في الخادم (ص ٤٣١-٤٣٢ تحقيق صالح بن عبد العزيز

الخطيب): «قوله: (قلت: الثاني أصح) مخالف لنص الشافعي، ولقاعدة الباب، أما النص ففي الأم ومختصر المزني إطلاق أنه لاقطع في الطنبور والمزمار ولم يفصل، وإنما هذا التفصيل اختيار أبي حامد وأتباعه، نعم، كلام الروياني في الكافي يقتضي أنه منصوص وهو غريب، وممن جرىٰ علىٰ ظاهر النص صاحب التقريب، والإمام، وأبو الفرج الزاز، وقال: (إن مقابله ضعيف، ويؤيده ما ذهب إليه الأكثرون في البيع بإبطال بيع آلات الملاهي مطلقا)، وجرىٰ عليه النووي هناك في البيع، وجعل التفصيل وجها ضعيفا».

واعتمده البلقيني في التدريب (٤/ ١٨١) فقال: «ولا يقطع في طنبور ومزمار، وكذا كل ما سلط الشرع علىٰ كسره، فإن بلغ بكثيره نصابا فلا قطع علىٰ المنصوص، وصححه الأكثرون، خلافا لما صححه في «المنهاج» من القطع».

وحكىٰ الولي العراقي في التحرير (٣/ ٢٠٩) عن الروياني في الكافي أن ما رجحه النووي هو نص للشافعي وأنه قال: «إلا أن تبلغ قيمتها مخلعة ربع دينار»(١)، وعن البلقيني أنه قال: لم أقف علىٰ هذا النص الذي ذكره، ولا ذكره غيره».

---

(١) بحر المذهب (١٣/ ١٠٠).

وأغرب الدميري في النجم الوهاج (٩/ ١٥٥) فقال في وجوب القطع: «هو منصوص الأم وصححه الأكثرون، لا جرم قال المصنف: «قلت: الثاني أصح والله أعلم»؛ لأنه مال يقوم علىٰ متلفه فأشبه ما لو سرقه مفصلا».

وهو وهم منه، فالذي في الأم هو ما تقدم ذكره، واختاره من ذكرنا من الإمام والبلقيني وغيرهما.

ويؤيد عدم القطع أن ثمن الطنبور والمزمار حرام، وقاعدة الشافعي في القطع بالسرقة أن يكون المسروق مما يحل ثمنه.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٧٢١ ط. د. رفعت فوزي): «ومن سرق خمرا من كتابي وغيره، فلا غرم عليه ولا قطع، وكذلك إن سرق ميتة من مجوسي فلا قطع ولا غرم، لا يكون القطع والغرم إلا فيما يحل ثمنه».

وقال فيه أيضا (٧/ ٣٧٣ ط. د. رفعت فوزي): «فإن سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع؛ لأن هذا حرام الثمن».

[١٠٤] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٢٠ ط. الحداد): «والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر».

الذي رجحه النووي تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٤٢٣) ولفظه:

«والأصح أنه يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر إذا كان محرزا عنه».

وذكر الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ١٩١) أن الأصح القطع ما لم يكن محرزا، واحتج له بأمرين:

الأول: عموم نصوص السرقة من الآية والأخبار.

الثاني: ما جاء في مختصر المزني (٢/ ٤٦٩ ط. الداغستاني) عن الشافعي: «وقال في (كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي): إذا سرقت من مال زوجها الذي لم يأتمنها عليه، وفي حرز منها قطع».

ثم قال المزني: هذا عندي أقيس».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٧/ ٢١٠): «وهذا أصح قوليه».

وقال الرافعي: «وأيضا فالزوجية عقد تملك به المنفعة فلا يؤثر في إسقاط الحد، كالإجارة، ولا يسقط بها الحد عن الأجير، إذا سرق من المستأجر، وكذا بالعكس»، وحمل نص المنع علىٰ ما إذا لم يكن، المال محرزا عن السارق، وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٢٠).

○ قال أبو عبد الباري:

وفيما قالاه نظر، وفي صحة ذلك عن الشافعي وقفة، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الشافعي نص في غير موضع من كتبه علىٰ عدم القطع مطلقا للأثر والشبهة.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣٨٣ ط. د. رفعت فوزي): «أرىٰ – والله أعلم- علىٰ الاحتياط أن لا يقطع الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا، للأثر والشبهة فيه».

و في مختصر المزني (٢/ ٤٦٩ ط. الداغستاني): قال الشافعي: «لا قطع علىٰ من سرق من غير حرز ... ولا علىٰ زوج سرق من متاع امرأته، ولا علىٰ امرأة سرقت من متاع زوجها ... للأثر والشبهة، ولخلطة كل واحد منهما بصاحبه».

وفي مختصر المزني أيضا (٢/ ٥٠٨): «وقال في «كتاب السرقة»: إن سرق من امرأته لم يقطع».

وهذه النصوص صريحة في أنه لا يقطع أي من الزوجين سرق من الآخر، وأن سبب المنع للأثر والشبهة، وجميع الأمثلة التي ذكرها في هذا السياق تجري علىٰ هذا المنوال.

أما الأثر: فلما يأتي من أثر عمر في سرقة العبد من متاع سيده.

وأما الشبهة: فلما بينهما من الخلطة كما قال: «ولخلطة كل واحد منهما بصاحبه».

الوجه الثاني: أن النص المنقول عن كتاب «اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة» يشبه أن يكون المزني اختصره فوهم في اختصاره، وذلك أن الشافعي ذكر هذا القول عن صاحب له في الأم، وليس الأوزاعي صاحبه ولا أبو حنيفة، وإنما هو الإمام مالك رحمه الله[(١)].

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣٨٣ ط. د. رفعت فوزي): «وقد قال صاحبنا: إذا سرق الرجل من امرأته، أو المرأة من زوجها من البيت الذي هما فيه، لم يقطع واحد منهما، وإن سرق غلامه من امرأته، أو غلامها منه، وهو يخدمهما لم يقطع؛ لأن هذه خيانة، فإذا سرق من امرأته، أو هي منه من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا، أو سرق عبدها منه أو عبده منها، وليس بالذي يلي خدمتهما، قطع، أيَّ هؤلاء سرق».

---

(١) وهذا هو اصطلاح الشافعي وعرفه، فقد روى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (ص ١٥٥) عن أبيه عن الربيع قال: قال الشافعي: إذا قلت: قال بعض أصحابنا، فهو أهل المدينة، وإذا قلت: قال بعض الناس فهم أهل العراق».
وهذا هو قول مالك في الموطأ (٢/ ٨٣٦ ط. محمد فؤاد عبد الباقي) وذكره البيهقي في المعرفة (١٢/ ٤٣٢) وابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٥٥٩).

وهذا معنىٰ قول الرافعي «إذا كان محرزا عنه»، والصاحب المذكور هو الإمام مالك.

وهذا بين في أنه حكىٰ رأي غيره وحجته، ثم ذكر أن في الحجة احتمالا، ثم ختم بما يراه راجحا والله أعلم.

واحتج الشافعي علىٰ ذلك بالقياس علىٰ سرقة العبد من متاع سيده.

ذكر الشافعي في الأم (٧/ ٣٨٢-٣٨٣ ط. د. رفعت فوزي) أثر عمر المذكور في سرقة العبد من مال سيده، واختار أنه لا قطع عليه مطلقا ثم قال: «فبهذا كله نقول، والعبد إذا سرق من متاع سيده مما اؤتمن عليه، أو لم يؤتمن، أحق أن لا يقطع، من قبل أن ماله أخذ بعضه بعضا».

وذكر الشافعي مرة أخرىٰ في الأم (٨/ ٦٤٦ ط. د. رفعت فوزي) أن مسألة العبد والزوجين من باب واحد فقال: «بهذا نقول، لأن العبد ملك لسيده، أخذ من ملكه، فلا يقطع ملكه لما سرق من ملكه، كان معه في بيته يأمنه، أو كان خارجا، فكذلك لا يقطع من سرق من ملك امرأته بحال، بخلطة امرأته زوجها، وهذا معنىٰ قول عمر، لأنه لم يسأله: أتأمنونه أو لا تأمنونه».

قال الشافعي: وهذا مما خالفتم فيه عمر، لا مخالف له علمناه، فقلتم بقطع

العبد فيما سرق لامرأة سيده إن كان لا يكون معهم في منزل يأمنونه فيه».

وحكىٰ الشافعي هنا إجماع الصحابة بقوله (وهذا مما خالفتم فيه عمر لا مخالف له علمناه)، ولا يظن به مخالفته، وهذا في العبد يسرق من مال سيده.

وقد حكىٰ هذا الإجماع أيضا ابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٥٥٨) فقال بعد ذكر قول عمر (خادمكم سرق متاعكم)، وقول ابن مسعود: (مالُك سرق بعضه بعضا): «ولا أعلم لعمر وابن مسعود مخالفا من الصحابة، ولا من التابعين بعدهم إلىٰ ما ذكرنا من اتفاق العلماء أئمة الفتوىٰ بالأمصار علىٰ ذلك».

وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٢): «وفي قوله «المرأة راعية علىٰ بيت بعلها» دليل علىٰ سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها».

وقال الماوردي في الإقناع (ص ١٧٢): «ولا قطع علىٰ غاصب ... ولا علىٰ زوج سرق من مال زوجته، ولا علىٰ زوجة سرقت من مال زوجها».

وذكر الأذرعي في قوت المحتاج (٩/ ١٠٤، ١٠٥) أن الشيخ أبا محمد في مختصره، والغزالي في خلاصته، وصاحب المعتبر صححوا عدم القطع».

وعلىٰ هذا الترجيح اعتمد البلقيني في التدريب (٤/ ١٨٢) فقال: «ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر علىٰ المنصوص، خلافا لما في «المنهاج» تبعا للمحرر».

[١٠٥]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٢٢ ط. الحداد): «فإن خلت، فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه، فإن فقد شرط فلا».

تابع النووي هنا الرافعي في المحرر (ص ١٤٢٦) ولفظه: «و إن لم يكن فيها أحد، فالظاهر أنه إن كان الباب مغلقا فهي حرز بالنهار في وقت الأمن، وليست حرزا في وقت الخوف، ولا بالليالي».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ١٩٩)، وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٢٤) فقال: «إذا لم يكن فيها أحد، فالمذهب وبه قطع البغوي: أنه إن كان الباب مغلقا، فهو حزر بالنهار في وقت الأمن، وليس حرزا في وقت الخوف، ولا في الليل».

○ قال أبو عبد الباري:

ظاهر نصوص الشافعي ﷺ أن البيت إذا كان مغلقا فهو حرز مطلقا، سواء كان فيه حافظ أم لا، وسواء نهارا أو ليلا، وزمن أمن أو خوف، وهو المعتمد.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣٧٨ ط. د. رفعت فوزي): «والبيوت المغلقة حرز لما فيها، فإن سرق سارق من بيت مغلق، فتح الغلق، أو نقب البيت، أو قلع الباب، فأخرج المتاع من حرزه قطع، وإن كان البيت مفتوحا، فدخل فسرق منه

لم يقطع، فإن كان علىٰ الباب المفتوح حجرة مغلقة، أو دار مغلقة، فسرق منها قطع ... وكذلك بيوت السوق ما كانت مفتوحة، فدخلها داخل فسرق منها لم يقطع، وإن كان فيها صاحبها، وهذه خيانة؛ لأن ما في البيوت لا يحرزها قعود عندها».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٦٢ ط. الداغستاني): «والبيوت المغلقة حرز لما فيها، فإن سرق منها شيء، فأخرج بنقب أو فتح باب أو قلعه قطع، وإن كان البيت مفتوحا لم يقطع».

فهذه النصوص متفقة علىٰ أن الحكم عنده يدور علىٰ أن الدار حرز لما فيها إذا كانت مغلقة، وإن كانت مفتوحة فليست بحرز، ولم يفرق بين بيوت السوق وغيرها، ولا بين زمن الأمن والخوف، أو الليل والنهار، ولم يشترط وجود لحَّاظ فيها.

وهو ظاهر في أن وجود اللحَّاظ والقعود عليها لا يجعلها حرزا إذا كانت مفتوحة.

قال الروياني في البحر (١٣/ ٦٣): «البيوت في القرىٰ والبلاد؛ فإن كانت مغلقة فهي حرزٌ لما فيها، وإن كانت مفتوحة وليس فيها أحدٌ يراعيها فليست حرزا، لأن العامة تنسب فاعل ذلك إلىٰ التفريط والتغرير بما فيه، ولهذا يقولون: خرج ونسي باب الدار مفتوحا، ومتىٰ كان البيت مغلقا فسرق منه سارق شيئا

بفتح الغلق أو نقب البيت أو قلع الباب أو كسر القفل وإخراج المتاع من حرزه يقطع». ونحوه في الحاوي للماوردي (١٣/ ٢٩٠، ٣١١).

وقال الزركشي في الخادم (ص ٤٧٦ تحقيق صالح بن عبد العزيز الخطيب): «ما حكاه عن البغوي واقتصر عليه عجيب، فإن الشافعي نص في المختصر علىٰ هذه المسألة، وذكر أن المغلقة حرز من غير شرط»، ثم ذكر النص المتقدم ثم قال: «وجرىٰ عليه الشارحون، وهو الصواب، وإلا فمتىٰ اعتبرنا ما قاله البغوي لزم اختلاط السارق بالمنتهب، فالصواب القطع بأنها حرز مطلقا من تقييد بنهار ولا وقت أمن غير شرط».

قال البلقيني في التدريب (٤/ ١٨٥): «فإن خلت وهي مغلقة فهي حرز علىٰ المنصوص، ولا فرق في ذلك بين الليل والنهار، ولا بين الأمن والخوف، خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله».

وأما اشتراط اللحَّاظ فهو من قول الربيع من عنده، ففي الأم بعد كلام الشافعي السابق: قال الربيع: «إلا أن يكون بصره يحيط بها كلها، أو يكون يحرسها فأغفله فأخذ منها ما يسوىٰ ربع دينار قطع»[(١)].

---

(١) وقول الربيع صريح في أن السارق إذا استغفل الحارس قطع، وخالفه النووي فقال في المنهاج (٣/ ٢٢٣ ط. الحداد): «وكذا يقظان تغفله سارق في الأصح» أي ليست حرزا فلا قطع فيه.

فرجحه البغوي في التهذيب (٧/ ٣٦٧) وتابعه عليه الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ١٩٩) والنووي في الروضة (١٠/ ١٢٤).

وفي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ٢١٥) عن البلقيني أن هذا مما شذ به البغوي، فتابعه عليه الرافعي والنووي، قال: والذي نص عليه الشافعي ﷺ في «الأم» و«المختصر» وجرىٰ عليه شراح «المختصر»: أن المغلقة حرز وإن لم يكن صاحبها فيها، ولا فرق في ذلك بين الليل والنهار، ولا بين الأمن والخوف».

[١٠٦]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٢٢ط. الحداد): «ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها».

اشتراط النووي التفات القائد كل ساعة إلىٰ المقطورة، تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٤٢٧) ولفظه: «والإبل المقطرة ينبغي أن يلتفت القائد إليها كل ساعة، ويشترط أن ينتهي نظره إليها إذا التفت».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٢٠٣): «أما الإبل، فإن كانت مقطرة، وكان يسوقها سائق، فهي محفوظة به، إن كان ينتهي النظر إليها، وإن كان يقودها قائد، يشترط أن يلتفت إليها كل ساعة، وإلا فهو مضيع، ويشترط أن ينتهي نظره إليها إذا التفت، فإن كان لا يرىٰ البعض لحائل جبل أو بناء إذا كانت تسير في

العمران، فذلك البعض ليس بمحرز»، وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٢٨).

○ قال أبو عبد الباري:

ما اشترطاه من الالتفات كل ساعة ليس بشرط علىٰ ظاهر نص الشافعي.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣٧٨ ط. د. رفعت فوزي): «وأي إبل الرجل كانت تسير وهو يقودها، فقطر بعضها إلىٰ بعض، فسرق منها، أو مما عليها شيئا، قطع فيه».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٦٢ ط. الداغستاني): «وإذا كان يقود قطار إبل أو يسوقها، وقطر بعضها إلىٰ بعض، فسرق منها، أو مما عليها شيئا سارق قطع».

وهذا النص من الأم والمختصر ليس فيه اشترط الملاحظة والالتفات كل ساعة، ولا فيهما تحديد عدد معين في القطار.

أما الالتفات كل ساعة، فقد قال الزركشي في الخادم (ص ٤٨٩ تحقيق صالح بن عبد العزيز الخطيب): «وأما الشافعي وكثير من الأصحاب فلم يعتبروا الالتفات، وفي مختصر المزني: (فيقطر بعضها إلىٰ بعض فسرق منها أو مما عليها شيئا قطع)، ولم يتعرض الشافعي للالتفات كل ساعة، وهذا أمر يشق علىٰ القائد».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ١٨٥): «لم يتعرض الشافعي للالتفات كل ساعة، وهذا أمر يشق علىٰ القائد، ولو كان هذا معتبرا لذكره الشافعي، فما وقع

في «المنهاج» تبعا لأصله من اشتراط التفات القائد إليها كل ساعة غير معتمد».

وهو كما قال في ظاهر النص عن الإمام الشافعي رضي الله عنه.

وكذلك قال الشافعي في ضمان البهائم من غير تعيين عدد أو اشتراط الالتفات.

قال في مختصر المزني (٢/ ٤٩١ ط. الداغستاني): «وكذلك إذا كان سائقا أو قائدا، وكذلك الإبل المقطرة بالبعير الذي هو عليه؛ لأنه قائد لها».

[١٠٧] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٢٤ ط. الحداد) في سارق الكفن: «لا بمضيعة في الأصح».

رجح النووي هنا عدم القطع في سرقة الكفن من القبر إذا كان خارج العمران، وجعل الخلاف وجهين عن الأصحاب، وهو تابع الرافعي في المحرر (ص ١٤٢٨) في قوله: «وإن كان في بقعة ضائعة فأظهر الوجهين أنه لا يجب».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٢٠٥): «وبهذا الوجه، أجاب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وصاحب الكتاب، وعزاه الإمام إلىٰ جماهير الأصحاب»، وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٣٠).

○ قال أبو عبد الباري:

ظاهر نص الشافعي في الأم القطع مطلقا من غير تفصيل، وعلله بأن القبر

حرز للكفن، وهذا لا يختلف بين الصحراء وغيره.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣٨٠ ط. د. رفعت فوزي): «ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٦٤ ط. الداعساني): «ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله».

فلم يفرق بين كون القبر في العمران أو خارجا منها، وهو ظاهر، وحمل كلامه علىٰ ما في العمران أو طرف منها غير ظاهر، ولا مقتضي لذلك.

وهذا الإطلاق موافق لقاعدته فيما يكون حرزا، وذلك في قوله في الأم (٧/ ٣٧٧ ط. د. رفعت فوزي): «وأنظر إلىٰ المسروق، فإن كان في الموضع الذي سرق فيه في الموضع الذي تنسبه العامة إلىٰ أنه في مثل ذلك الموضع محرز، فأقطع فيه، وإن كانت العامة لا تنسبه إلىٰ أنه في مثل ذلك الموضع محرز، فلا يقطع فيه».

فبين هنا أن المرجع فيما يكون حرزا إلىٰ العرف، ثم لما ذكر سرقة الكفن من القبر أطلق ولم يفرق بين حالات القبر، وبين أنه حرز مثله.

واعتمده الشيرازي في التنبيه (ص ٢٤٥) فقال: «أو الكفن من القبر».

قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (١٧/ ٢٩٩): أطلق الشيخ هنا ذكر القبر، ولم

يفصل فيه بين أن يكون في مفازة، أو في مقابر المسلمين في الصحراء، أو في العمران، وهو متبع في الإطلاق للقاضي أبي الطيب والبندنيجي، وعليه جرىٰ ابن الصباغ أيضا.

وقضيته: أن القبر حرز علىٰ الإطلاق، كما حكىٰ ذلك وجها، ويعزىٰ إلىٰ اختيار الشيخ أبي حامد والقفال والقاضي الحسين وأبي الحسن العبادي؛ لأن النفوس تهاب الموتىٰ».

وتلخص من ذلك أنه يقطع مطلقا علىٰ ظاهر نص الشافعي، وبه قال من ذكرهم ابن الرفعة وغيرهم كالشاشي في الحلية (٨/ ٥٥).

واختاره البلقيني في التدريب (٤/ ١٨٦) فقال: «وكذا بمضيعة علىٰ النص خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله، قال الشافعي ﷺ: «ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله»، فلم يقيد الشافعي بأن يكون القبر في المقبرة المتصلة بالعمران».

وفي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ٢٢٠) عن البلقيني أنه قال: «هو الذي يعتمد في الفتوىٰ».

[١٠٨]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٢٨ ط. الحداد): «وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح».

ما رجحه النووي هنا تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٤٣٤) ولفظه: «تثبت السرقة بيمين المدعي المردودة علىٰ الأظهر».

وحكاه الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٢٢٧-٢٢٨) عن الغزالي في الوجيز (٢/ ١٧٥) والوسيط (٦/ ٤٨٠)، وإبراهيم المروزي في تعليقه، وحكىٰ عن الإمام في النهاية (١٧/ ٢٧٠) أنه نقله عن الأصحاب، وعلله بأن اليمين المردودة كالبينة، أو كإقرار المدعىٰ عليه، والقطع يثبت بالأمرين، فأشبه القصاص يثبت باليمين المردودة، وظاهر السياق اختياره لهذا القول، وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٤٣).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكراه مخالف لنصوص الشافعي في الأم والمزني، في أنه لا يثبت القطع باليمين والشاهد، ولا بامرأة ورجل، وإنما يثبت فقط بالإقرار أو بشهادة رجلين عدلين.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٣٨٧ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يقام علىٰ سارق ولا محارب حد إلا بواحد من وجهين: إما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما في مثله الحد، وإما باعتراف يثبت عليه حتىٰ يقام عليه الحد».

وقال بعده بقليل (٧/ ٣٨٨ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يجوز في الحدود شهادة النساء، ولا يقبل في السرقة ولا قطع الطريق أقل من شاهدين، ولا يقبل

فيه شاهد ويمين، وكذلك حتىٰ يبينوا الجارح، والقاتل، وآخذ المتاع بأعيانهم، فإن لم يوجد شاهدان، فجاء رب السرقة بشاهد حلف مع شاهده، وأخذ سرقته بعينها، أو قيمتها يوم سرقت إن فاتت؛ لأن هذا مال يستحقه، ولم يقطع السارق».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٦٦ ط. الداغستاني): قال الشافعي: «ولا يقام علىٰ سارق حد إلا بأن يثبت علىٰ إقراره حتىٰ يقام عليه الحد، أو بعدلين يقولان: إن هذا بعينه سرق متاعا لهذا من حرز يصفانه يسوىٰ ربع دينار، ويحضر المسروق منه يدعي شهادتهما».

وفي مختصر المزني أيضا (٢/ ٤٦٦ ط. الداغستاني): «ولو شهد رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين علىٰ سرقة، أوجبتُ الغرم في المال، ولم أوجبه في الحد».

وكل ذلك صريح في أنه لا يثبت القطع عند الشافعي باليمين المردودة، وإنما يستحق الغرم، أو عين ماله إن كان باقيا، خلافا لما في «المنهاج» وأصله.

وهذا القول هو الذي اختاره ابن الصباغ كما في الشرح الكبير للرافعي (١١/ ٢٢٧) والروضة للنووي (١٠/ ١٤٣).

وقال العمراني في البيان (١٣/ ٩٨): «وإن نكل عن اليمين.. ردت اليمين علىٰ المسروق منه، فإذا حلف.. ثبت الغرم له، ولا يثبت القطع؛ لأنه حق لله تعالىٰ، فلا يثبت بيمين المدعي».

وجزم به الرافعي في الدعاوي من الشرح الكبير (١٣/ ٢٠١): فقال: «ولو ادعىٰ سرقة مال سمعت دعواه للمال، وحلف المدعىٰ عليه، فإن نكل حلف المدعي واستحق المال، ولا يقطع المدعىٰ عليه؛ لأن حدود الله تعالىٰ لا تثبت باليمين المردودة». وتبعه النووي في الدعاوىٰ من الروضة (١٢/ ٣٨).

ومشىٰ عليه في الحاوي الصغير (ص ٥٩٢) فقال: «وتثبت بالمردودة، لا القطع».

وقال الأذرعي في قوت المحتاج (٩/ ١٥٥): «هذا هو المذهب، والصواب الذي أورده العراقيون، منهم: المحاملي والجرجاني والماوردي وابن الصباغ، وهو قضية كلام البغوي وغيره من المراوزة، صرح به البغوي في تعليقه، وظاهر نصوص الشافعي».

وقال الزركشي في الخادم (ص ٥٦٣ تحقيق صالح بن عبد العزيز الخطيب): «اضطرب ترجيح الرافعي والنووي فيه هنا، وفي الدعاوىٰ، والراجح عدم الثبوت، وبه قطع الجمهور، وبه أجاب العراقيون، منهم: الماوردي، والمحاملي في المقنع، وابن الصباغ، والجرجاني في الشافي، وهو قضية كلام البغوي وغيره من المراوزة، واختاره الشيخ العماد بن يونس، نقله عنه حفيده صاحب التعجيز في نهاية كتاب النفاسة، وهو ظاهر نص الشافعي في الأم ... ».

واعتمده البلقيني في التدريب (٤/ ١٨٩) فقال: «ولا يثبت قطع السرقة

باليمين المردودة علىٰ المنصوص خلافا لما في «المنهاج»تبعا لأصله».





باب قاطع الطريق

[١٠٩]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٣٤ ط. الحداد): «هو مسلم، مكلف، له شوكة».

اشترط النووي هنا في قاطع الطريق أن يكون مسلما، ويقتضي أن الذمي والمرتد لا يدخلان في حد قاطع الطريق المذكور، وهو تابع في ذلك الرافعي في المحرر (١٤٣٩) ولفظه: «يعتبر في قطاع الطريق الذين تشرع في حقهم العقوبات المذكورة من بعد الإسلام والتكليف: بالشوكة بأن يعتمدوا العدد والقوة».

وقد صرح الرافعي باشتراط الإسلام أيضا في الشرح الكبير (١١/ ٢٤٩) فقال: «لا بد مع ذلك من الإسلام، فالكفار ليس لهم حكم القطاع، وإن أخافوا السبيل، وتعرضوا للأنفس، والأموال».

وتبعه النووي أيضا في الروضة (١٠/ ١٥٤) فقال: «وأن يكونوا مسلمين مكلفين، فالكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا السبيل».

وحكىٰ ابن الرفعة في الكفاية (١٧/ ٣٨٠) أن الأصحاب صرحوا بعدم

قطعهما.

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا ضعيف مخالف لنصوص الإمام الشافعي في الأم والمزني والبويطي، فإنه ذكر وجوب ذلك في الذمي والمرتد، وكلاهما ليس مسلما، وهذه جملة منها:

قال الشافعي في الأم (٥/ ٤٤٩ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا أخذت الجزية من قوم، فقطع قوم منهم الطريق، أو قاتلوا رجلا مسلما فضربوه، أو ظلموا مسلما أو معاهدا، أو زنىٰ منهم زان، أو أظهر فسادا في مسلم أو معاهد، حُدَّ فيما فيه الحدُّ، وعوقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة، ولم يقتل إلا بأن يجب عليه القتل، ولم يكن هذا نقضا للعهد يحل دمه».

وقال في الأم أيضا (٥/ ٤٩٥ ط. د. رفعت فوزي): «ومن أصاب منهم مظلمة لأحد فيها حد مثل: قطع الطريق، والفرية، وغير ذلك أقيم عليه، وإن غش أحد منهم المسلمين بأن يكتب إلىٰ العدو لهم بعورة، أو يحدثهم شيئا أرادوه بهم، وما أشبه هذا، عوقب وحبس، ولم يكن هذا ولا قطع الطريق نقضا للعهد ما أدوا الجزية علىٰ أن يجري عليهم الحكم».

وقال في الأم أيضا (٧/ ١٤٦ ط. د. رفعت فوزي): «لا يصلب أحد أحدا إلا

قاطع الطريق الذي أخذ المال وقتل، فإنه يقتل ثم يصلب ثلاثا، ثم ينزل ويصلىٰ عليهم كلهم إلا المرتد، فإنه لا يصلىٰ علىٰ كافر».

وقال في المزني (٢/ ٤٨٥ ط. الداغستاني): «وما أصاب أهل الردة من المسلمين، في حال الردة وبعد إظهار التوبة في قتال وهم ممتنعون أو غير قتال، أو علىٰ نائرة أو غيرها فسواء، والحكم عليهم كالحكم علىٰ المسلمين، لا يختلف في القود والعقل وضمان ما يصيبون».

وقال في البويطي (ص ٨٣٠ ط. القره داغي): «ولو أن مسلما ارتد وحارب، وقتل المسلمين في محاربته، ثم ظفر به الإمام، فعليه الحكم في ذلك مثل ما كان في إسلامه، ولم تنقصه الردة والمحاربة شيئا من ذلك».

فبين في هذه النصوص أن الذمي والمرتد تقام عليهما الحدود سواء الزنا والسرقة وقطع الطريق وغيرها، كما تقام علىٰ المسلمين، ويعزر فيما ليس فيه حد، وهو المراد بالعقوبة، ويقتل فيما فيه القتل، ولا يكون ذلك كله نقضا للعهد، بل يبقىٰ ذميا.

وهذا هو المعروف عن الشافعي ﷺ تعالىٰ، وتتابع علىٰ نقله عنه العلماء.

قال ابن المنذر في الإشراف (٧/ ٢٤٦): «وقال الشافعي وأبو ثور: إذا قطع

أهل الذمة علىٰ المسلمين، حدوا حدود المسلمين، وبه قال أصحاب الرأي».

وقال أبو العباس بن القاص في كتاب السرقة (٢/ ٥٠٩): «وقال الشافعي والكوفي وأصحابه وأبو ثور: إذا قطع أهل الذمة علىٰ المسلمين حدوا حدود المسلمين».

وقد تعقب الشيخين علىٰ ذلك غيرُ واحد من أهل العلم، وبينوا مخالفتهم لنصوص الشافعي في ذلك.

قال الأذرعي في قوت المحتاج (٩/ ١٧٣): «اعلم أني لم أر في الكتب المشهورة بعد الكشف التام التنصيص علىٰ أن شرط قاطع الطريق الإسلام إلا في كلام الرافعي ومن أخذ منه».

وقد احتج الأذرعي في القوت (٩/ ١٩٠) بنصوصه في المرتد فقال: «وفي هذا إشارة ظاهرة إلىٰ أنه ليس من شرط قاطع الطريق الإسلام كما سبق بيانه».

وقال الزركشي في الخادم (ص ٩٨-٩٩ تحقيق شمشول الشمري): «اشتراط الإسلام يقتضي أن الذميين والمرتدين والمعاهدين لا يثبت لهم حكم قطاع الطرق، وليس كذلك، فقال الشافعي في سير الواقدي في آخر باب المرتد: «وإذا قطع أهل الذمة علىٰ المسلمين حدوا حدود المسلمين، وإذا قطع

المسلمون علىٰ أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا علىٰ المسلمين، إلا أني أتوقف في أن أقتلهم إن قتلوا، أو أضمنهم الدية»، هذا لفظه، ولا شيء أصرح بعد هذا.

وقال في الأم أيضا في جراح العمد: «ولا يصلب أحد أحدا إلا قاطع الطريق الذي أخذ المال وقتل؛ فإنه يقتل ثم يصلب ثلاثا، ثم ينزل ويصلىٰ عليهم كلهم إلا المرتد؛ فإنه لا يصلىٰ علىٰ الكافر».

وقال في المختصر في الجزية: «ويشترط عليهم أن من ذكر كتاب الله، أو محمدا رسول الله، أو زنا بمسلمة، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق».

قال ابن خيران في اللطيف: وهذا الذي ذكره الشافعي منه ما يجب إقامة الحد فيه مثل الزنا، وقطع الطريق، وما سوى ذلك فيه التعزير»، وجرى عليه الأصحاب على اختلاف طبقاتهم في باب الجزية».

ثم أطال في البحث رحمه الله.

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ١٩٣، ١٩٤): «ولا يشترط ... ولا إسلامه، خلافا لما ذكره الرافعي ومن تبعه، فالذمي اذا قطع الطريق يقام عليه مقتضاه، سواء انتقض عهده بذلك أم لم ينتقض».

وقال الولي العراقي في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٢٣٩): «ولا وجه لذلك في الذِّمِّيّ، فإن كان لانتقاض عهدهم بذلك، وأنا نقتلهم كالحربيين، فليس كذلك؛ لأن الصحيح: أن العهد لا ينتقض به إلَّا إذا شرط عليهم تركه، وشرط عليهم الانتقاض به لو فعلوه، وبتقدير الانتقاض فسيأتي أن من انتقض عهده بذلك أو غيره .. يقام عليه ما يقتضيه ذلك الشيء، ثم يفعل فيه بعد ذلك من القتل أو غيره ما ذكروه، وكذلك يجري حكم القطاع علىٰ المرتدين».

وقد حكاه أبو بكر الجصاص الحنفي في شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٣٣٢) عن الجماهير فقال: «لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن قطاع الطريق قد يكونون من أهل الإسلام، وأهل الذمة، وأن حكم الآية المذكورة في المحاربين جار عليهم، وهو قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا﴾ [المائدة: ٣٣] إلىٰ آخر القصة.

وقال بعض المتأخرين ممن لا يعتد بخلافهم: إن ذلك مخصوص في المرتدين».

وأما نسبة ابن الرفعة اشتراط الإسلام للأصحاب، فقد علق عليه الأذرعي والدميري.

قال الأذرعي في القوت (٩/ ١٧٥): «قوله: إن الأصحاب صرحوا بعدم قطعهما ... لم أر من صرح بذلك في الذمي إذا قلنا لا ينتقض عهده بقطع الطريق، وصار من أهل الحرب كما نص عليه ورجحه الشيخان، وابن الرفعة بنىٰ كلامه علىٰ الانتقاض، وأحسب مسنده في قوله : «المسلم» كلام الرافعي، وأفاد بأن المرتد كالمسلم في ذلك، ونصه في جراح العمد من «الأم» كالمصرح، أو مصرح بذلك».

وقال الدميري في النجم الوهاج (٩/ ٢٠٣): «وجرىٰ عليه في «الكفايه»، وأغرب فنقله عن الأصحاب، وهو لا يعرف لغير الرافعي، والصواب: أن حكمهم حكم المسلمين في ذلك، لالتزامهم الأحكام؛ فقد نص الشافعي عليه في «الأم» صريحا، وحكاه عنه ابن المنذر في «الإشراف»، فالصواب: التعبير بالتزام الأحكام ليخرج الحربي، وكذا المعاهد في الأصح، فإنهما لا يضمنان نفسا ولا مالا».

[١١٠]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٣٧ ط. الحداد): «ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر».

رجح النووي أن الحدود لا تسقط بالتوبة قبل القدرة علىٰ صاحبها إلا حد

الحرابة، ولم يفرق بين ما هو من حق بني آدم كالقذف، وما هو من حق الله تعالىٰ كالزنا والسرقة والشرب.

والنووي تابع الرافعي في المحرر (ص ١٤٤٤) في قوله: «وفي سقوط سائر الحدود بالتوبة قولان، رجح منهما المنع أيضا».

وبمثل ذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٢٥٩) وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٥٨) فقال بعد أن ذكر أن الخلاف قولان: «الأظهر: لا يسقط، صححه الإمام والبغوي وغيرهما، وهو منسوب إلىٰ الجديد لإطلاق آية الزنىٰ، وقياسا علىٰ الكفارة».

○ قال أبو عبد الباري:

للشافعي نصوص كثيرة في الأم والمزني والبويطي، منها ما حكىٰ الخلاف فيه ولم يرجح، ومنها ما صرح فيه باختيار سقوط الحدود بالتوبة، ولم أر له تصريحا بترجيح عدم السقوط إلا من تخريج الربيع ﷺ تعالىٰ، وهذه نصوصه التي وقفنا عليها:

قال الشافعي في الأم (٨/ ١٣٥-١٣٧ ط. د. رفعت فوزي): «الحد حدان، حد لله تبارك وتعالىٰ لما أراد من تنكيل من غشيه عنه، وما أراد من تطهيره به، أو

غير ذلك مما هو أعلم به، وليس للآدميين في هذا حق، وحدٌّ أوجبه الله ﷻ علىٰ من أتاه من الآدميين فذلك إليهم، ولهما في كتاب الله تبارك اسمه أصل.

فأما أصل حد الله تبارك وتعالىٰ في كتابه فقوله ﷻ: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [المائدة: ٣٣] إلىٰ قوله: ﴿رَّحِيمٌ﴾ فأخبر الله تبارك اسمه بما عليهم من الحد، إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم، ثم ذكر حد الزنا والسرقة ولم يذكره فيما استثنىٰ.

فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة، واحتمل أن يكون علىٰ كل حد لله ﷻ، فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه، كما احتمل حين قال النبي ﷺ في حد الزنا في ماعز: «ألا تركتموه» أن يكون كذلك عند أهل العلم، السارق إذا اعترف بالسرقة، والشارب إذا اعترف بالشرب ثم رجع عنه قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه.

ومن قال هكذا كان هذا في كل حد لله ﷻ فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه، سقط عنه حد الله تبارك وتعالىٰ في الدنيا، وأخذ بحقوق الآدميين.

واحتج بالمرتد يرتد عن الإسلام، ثم يرجع إلىٰ الإسلام فيسقط عنه القتل، فيبطل القطع عن السارق، ويلزمه المال، لأنه قد اعترف بشيئين: أحدهما لله ﷻ،

والآخر للآدميين، فأخذناه بما للآدميين، وأسقطنا عنه ما لله جل وعلا.

ومن ذهب إلىٰ أن الاستثناء في المحارب ليس إلا حيث هو، جعل الحد علىٰ من أتىٰ حد الله متىٰ قدر عليه وإن تقادم، فأما حدود الآدميين من القذف وغيره فتقام أبدا لا تسقط.

قال الربيع: قول الشافعي: الاستثناء في التوبة للمحارب وحده الذي أظن أنه يذهب إليه.

قال الربيع: والحجة عندي في أن الاستثناء لا يكون إلا في المحارب خاصة حديث ماعز حين أتىٰ النبي ﷺ، فأقر الزنا، فأمر النبي ﷺ برجمه، ولا نشك أن ماعزا لم يأت النبي ﷺ فيخبره إلا تائبا إلىٰ الله ﷻ قبل أن يأتيه، فلما أقام عليه الحد دل ذلك علىٰ أن الاستثناء في المحارب خاصة«[(١)].

والظاهر من هذا النص أن الشافعي حكىٰ قولين، ولم يصرح بالترجيح، وإن كان ظاهر الاحتجاج يقتضي ترجيح الاحتمال الثاني وهو السقوط بالتوبة.

وأما ترجيح الاحتمال الأول، وهو تخصيص السقوط بالحرابة فهو من تخريج للربيع واختياره، وأما روايته عن الشافعي فمشكوك فيه.

---

(١) وذكره البيهقي في المعرفة (١٢/ ٤٣٧) مختصرا دون قول الربيع وترجيحه.

وقال الشافعي في الأم (٨/ ٢٨٢ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا شهد الشهود علىٰ حد لله أو للناس، أو حد فيه شيء لله ﷻ وللناس، مثل الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وأثبتوا الشهادة علىٰ المشهود عليه أنها بعد بلوغه في حال يعقل فيها، أقيم عليه ذلك الحد، إلا أن يحدث بعده توبة، فيلزمه ما للناس، ويسقط عنه ما لله، قياسا علىٰ قول الله ﷻ في المحاربين ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ﴾ [المائدة: ٣٤] الآية، فما كان من حدّ لله تاب صاحبه من قبل أن يقدر عليه سقط عنه، والتوبة مما كان ذنبا بالكلام، مثل القذف وما أشبهه الكلام بالرجوع عن ذلك، والنزوع عنه، والتوبة مما كان ذنبا بالفعل مثل الزنا وما أشبهه، فيترك الفعل مدة يختبر فيها، حتىٰ يكون ذلك معروفا، وإنما يخرج من الشيء بترك الذي دخل به فيه.

قال الربيع: للشافعي فيها قول آخر: أنه يقام عليه الحد وإن تاب؛ لأن الذي جاء إلىٰ النبي ﷺ فأقر بالحد لم يأته - إن شاء الله - إلا تائبا، وقد أمر النبي ﷺ برجمه، وليس طرح الحدود التي لله ﷻ إلا في المحاربين خاصة».

فحكىٰ الربيع هنا قولا ثانيا عن الشافعي، وهو إقامة الحدود عليه مطلقا إلا ما يختص بالمحاربة، وظاهر كلام الشافعي اختياره للقول الأول بالسقوط،لأنه

الذي جزم به، ولم يذكر غيره.

وما حكاه الربيع هنا عن الشافعي فيشبه أن يكون قولا مخرجا من قبل الربيع، وكان يشك في روايته عن الشافعي كما تقدم، وما ذكره في الرجل الذي جاء إلىٰ النبي ﷺ معترفا بالحد، يشير به إلىٰ ما احتج به من قصة ماعز رضي الله عنه.

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٦٢ ط. الداغستاني): «ومن تاب منهم من قبل أن يقدر عليه .. سقط عنه الحد، ولا تسقط حقوق الآدميين، ويحتمل أن يسقط كل حق لله بالتوبة، وقال في كتاب الحدود: وبه أقول».

وفي مختصر البويطي (ص ١٠٠٢ ط. القره داغي): «وكل حد لله إذا لم يقم علىٰ من أتاه حتىٰ يتوب فقد سقط عنه الحد لقول الله تبارك وتعالىٰ: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ﴾.

وهذه النصوص ظاهرة علىٰ أن اختيار الشافعي هو التفريق بين النوعين من الحقوق، فتسقط حقوق الله بالتوبة قبل القدرة دون حقوق الآدميين، ولم يذكر فيها خلافا.

❐ والخلاصة: أن التعميم مخالف لنصوص الإمام الشافعي، وأن أكثر نصوصه صريحة علىٰ التفصيل بين حقوق الله تعالىٰ فتسقط بالتوبة قبل القدرة

كحد الزنا والسرقة والشرب ونحوها، دون حقوق الآدميين كحد القذف والقصاص ورد المال المسروق، وليس للشافعي نص صريح مخالف لذلك، وإنما المخالف قول من تخريج الربيع استنبطه مما ظنه مذهب الشافعي.

وعلىٰ هذا جرىٰ غير واحد من أئمة التحقيق وشراح المنهاج، وهذه نتف من أقوالهم:

قال الأذرعي في قوت المحتاج (٩/ ١٩٥): «ورجحه أكثر العراقيين، وقال البندنيجي: إنه المذهب، أنها تؤثر في إسقاطها كحد المحاربة، وقد قال الله تعالىٰ: ﴿فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٦] وقال تعالىٰ: ﴿فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩].

وفي الصحيح «التوبة تجب ما قبلها»، وفيه «أن رجلا قال لرسول الله ﷺ إني أصبت حدا فأقمه عليَّ، فقال ﷺ: ألست صليت معنا؟ قال: نعم، قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال: حدك»، وفي المسألة أحاديث كثيرة».

وقال الشافعي في الأم[(١)]: «ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر، وأن

---

(١) الأم (٧/ ٣٥٠ ط. د. رفعت فوزي).

يتقي الله ﷻ، ولا يعود لمعصية الله، فإن الله ﷻ يقبل التوبة عن عباده«، والمرجحون لهذا القول حملوا العمومات علىٰ حالة الإصرار».

وكذلك رجحه الدميري في النجم الوهاج (٩/ ٢١٣) وزاد: وروىٰ مسلم (رقم٢٧٠٣) عن أبىٰ هريره: أن النبىٰ ﷺ قال: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه».

وتقدم فىٰ أول الجنائز حديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

وفي المستدرك[(١)] عن ابن عمر أن النبيّ ﷺ قال: «اجتنبوا هذه القاذورات التىٰ نهىٰ الله عنها؛ فمن ألم بشئ منها فليستتر بستر الله وليتب إلىٰ الله؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد».

فلولا أنها تسقط الحد لكان فيه حث علىٰ كتمان الحق، وصحح هذا جماعة؛ منهم ابن خيران والحليمي والماوردي والمحاملي والروياني وصاحب (المهذب) والبندنيجي والعمراني؛ وهو المنصوص في (الأم) أيضا؛ ولأنه محض حق الله تعالىٰ فأشبه المحاربه»[(٢)].

---

(١) المستدرك للحاكم (رقم ٧٦١٥، ٨١٥٨).

(٢) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (٣/ ١٢٠-١٢٣) وشعب الإيمان للبيهقي (٩/ ٢٧٨ ط. الرشد).

وعلىٰ هذا الترجيح سار البلقيني في التدريب في الفقه (٤/ ١٩٦) فقال: «وتسقط سائر حدود الله تعالىٰ بالتوبة علىٰ المنصوص خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله ثم قال بعد ذكر نص الشافعي من الأم: «وقد جزم الشافعي بالسقوط لما ذكر الكلام علىٰ توبة قاطع الطريق، قال الشافعي ﷺ: «السارق مثله قياسا عليه، يسقط عنه القطع، ويوجد مغرم ما سرق، وإن فات ما سرق».

تنبيهات

الأول: قال ابن حزم في المحلىٰ (١٢/ ٢٢): قال قوم: إن الحدود كلها تسقط بالتوبة، وهذه رواية رواها أبو عبد الرحمن الأشعري عن الشافعي(١)، قالها بالعراق ورجع عنها بمصر».

ويرد ذلك ثبوت ذلك عن الشافعي في الأم برواية الربيع، ومختصري المزني والبويطي، وكلها من الجديد، فيدل - إن صح ما ذكره ابن حزم - علىٰ أن

---

(١) أبو عبد الرحمن الأشعري هذا هو: أحمد بن يحيىٰ بن عبد العزيز البغدادي، تفقه بالشافعي، وغلب عليه الجدل والمناظرة والكلام، كان من كبار أصحاب الشافعي، ثم صار من أصحاب ابن أبي دؤاد، واتبعه علىٰ رأيه في القول بخلق القرآن، وذهب إلىٰ الاعتزال، وكان ممن يمتحن به الناس، وقال بمنكرات من المسائل، وكان الشافعي منعه عن قراءة كتبه لأن كان ضعيف البصر سيئه. طبقات الشافعية الكبرىٰ للسبكي (٢/ ٦٥).

الشافعي لم يتغير قوله في العراق ومصر، وأن قوله فيهما سقوط الحدود بالتوبة.

وإن صح ما ذكره النووي والرافعي فيكون قولان في الجديد، وقد تقدم أن القول بعدم السقوط حكاه الشافعي احتمالا، ورجحه الربيع استنباطا وتخريجا.

الثاني: هذا الاختلاف في سقوط حقوق الله تعالىٰ بالتوبة محله ما قبل القدرة عليه، وقبل رفعها للإمام ونائبه، وأما بعد الرفع فلا تسقط اتفاقا، وهذه نتف من حكاية الإجماع علىٰ ذلك:

قال ابن تيمية في الفتاوىٰ (٢٨/ ٣٠٠): «اتفق العلماء فيما أعلم علىٰ أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلىٰ وليّ الأمر ثم تابوا بعد ذلك، لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا».

وقال ابن القيم في الإعلام (٣/ ١٠٥): «الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقًا».

وقال ابن المرتضىٰ في البحر الزخار (٦/ ١٥٨): «ولا يسقط -أي الحد- بالتوبة بعد الرفع إجماعا».

الثالث: وردت أحاديث تؤيد سقوط الحدود بالتوبة منها:

ما تقدم ذكره من رواية البخاري (رقم ٦٨٢٣) ومسلم (رقم ٢٧٦٤) من

طريق عمرو بن عاصم عن همام بن يحيىٰ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ﷺ قال: كنت عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه عليّ، ولم يسأله، قال: وحضرت الصلاة فصلىٰ مع النبي ﷺ، فلما قضىٰ النبي ﷺ قام إليه رجلُ فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه عليّ، قال: ولم يسأل عنه، قال: أليس قد صليت معنا قال: نعم قال: فإن الله ﷻ قد غفر لك ذنبك».

ورواه ابن حزم في المحلىٰ (١٢/ ١٦) عن المهلب بن أبي صفرة الأسدي التميمي ثنا عبد الله بن إبراهيم الأصيلي نا محمد بن أحمد الصواف نا أحمد بن هارون بن روح البرذنجي نا محمد بن عبد الملك الواسطي نا عمرو بن عاصم عن همام بن يحيىٰ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا أتىٰ النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ الحد، ثم أقيمت الصلاة، فصلىٰ مع النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ قد كفر عنك بصلاتك».

فدلت هذه الرواية علىٰ أن الحد الذي اعترف به الرجل كان حد الزنا.

قال الحافظ في فتح الباري (١٢/ ١٣٤، ١٣٥): يحتمل أن يكون الراوي عبر بالزنا من قوله «أصبت حدا» فرواه بالمعنىٰ الذي ظنه، والأصل ما في

الصحيح فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن عاصم بسنده المذكور، ويحتمل أن يختص ذلك بالمذكور لإخبار النبي ﷺ إن الله قد كفر عنه حده بصلاته، فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي فلا يستمر الحكم في غيره إلا في من علم أنه مثله في ذلك، وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبي ﷺ، وقد تمسك بظاهره صاحب الهدىٰ فقال: «للناس في حديث أبي أمامة يعني المذكور قبل ثلاث مسالك:

أحدها: أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه، والإصرار عليه من المقر به.

والثاني: أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة.

والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة.

قال: وهذا أصح المسالك، وقواه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملها، لأن حكمة الحدود الردع عن العود، وصنيعه ذلك دال علىٰ ارتداعه، فناسب رفع الحد عنه لذلك».

وروىٰ مسلم (رقم ٢٧٦٥) من حديث أبي أمامة قال: بينما رسول الله ﷺ في المسجد، ونحن قعود معه، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدا. فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله ﷺ. ثم أعاد فقال: يا رسول الله! إني

أصبت حدا. فأقمه علي. فسكت عنه. وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله ﷺ قال أبو أمامة: فاتبع الرجل رسول الله ﷺ حين انصرف. واتبعت رسول الله ﷺ أَنظُر ما يرد علىٰ الرجل، فلحق الرجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدا، فأقمه علي. قال أبو أمامة: فقال له رسول الله ﷺ «أرأيت حين خرجت من بيتك، أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ «قال: بلىٰ. يا رسول الله! قال «ثم شهدت الصلاة معنا؟ «فقال نعم. يا رسول الله! قال فقال له رسول الله ﷺ: «فإن الله قد غفر لك حدك – أو قال: ذنبك».

وروىٰ أبو داود (رقم ٤٣٧٩ واللفظ له) والترمذي (رقم ١٤٥٤) وأحمد (رقم ٢٧٢٤٠) من طريق إسرائيل، والنسائي في الكبرىٰ (رقم ٧٢٧٠) وابن الجارود في المنتقىٰ (رقم ٨٢٣) والبيهقي في الكبرىٰ (رقم ١٧٣٢٣) والصغير (رقم ٢٦٥٢) والخلافيات (رقم ٥٠٣٦) من طريق أسباط بن نصر كلاهما عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت علىٰ عهد النبي ﷺ تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجللها، فقضىٰ حاجته منها، فصاحت، وانطلق، فمر عليها رجل، فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به النبي ﷺ، فلما أمر به قام

صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله ﷺ، أنا صاحبها، فقال لها: «اذهبي، فقد غفر الله لك»، وقال للرجل قولا حسنا - قال أبو داود: يعني الرجل المأخوذ - فقالوا للرجل الذي وقع عليها: ارجمه، فقال: «لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم».

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه».

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٨): هذا حديث منكر جدا علىٰ نظافة إسناده».

وخرجه الألباني في الصحيحة (رقم ٩٠٠) فراجع تفصيل تخريجه هناك.

وقال: «وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في «الإعلام» فراجعه».

[١١١] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٣٩ ط. الحداد): «وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم علىٰ الزنا».

رجح النووي هنا أن حق الآدمي مقدم مطلقا، فالقطع قصاصا مقدم علىٰ الزنا مطلقا، والقتل قصاصا كذلك، وتابع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٤٤٦) في قوله: «وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم علىٰ حد الزنا والله أعلم».

وذكر هذا المعنىٰ في الشرح الكبير (١١/ ٢٦٩) وذكر أن الأصح عند الأئمة تقديم حق الآدميين، وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٦٥).

○ قال أبو عبد الباري:

هذا الإطلاق مخالف لنص الشافعي الذي فيه تقديم الجلد في الزنا علىٰ القتل والقطع قصاصا.

قال الشافعي في الأم (٧/ ١٤٤ ط. د. رفعت فوزي): «وإن اجتمعت علىٰ رجل حدود: حد بكر في الزنا، وحد في القذف، وحد في سرقة يقطع فيها، وقطع طريق يقطع فيه أو يقتل، وقتل رجل: بدئ بحق الآدميين مما ليس فيه قتل، ثم حق الله تبارك وتعالىٰ فيما لا نفس فيه، ثم كان القتل من ورائها، يحد أولا في القذف، ثم حبس، فإذا برئ حد في الزنا، ثم حبس حتىٰ يبرأ، ثم قطعت يده اليمنىٰ ورجله اليسرىٰ من خلاف، وكانت يده اليمنىٰ للسرقة وقطع الطريق معا، ورجله لقطع الطريق مع يده، ثم قتل قودا، أو بردة».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٧٢ ط. الداغستاني): «وإذا اجتمعت علىٰ رجل حدود وقذف .. بدئ بحد القذف ثمانين جلدة، ثم حبس، فإذا برأ حد في الزنا مائة جلدة، فإذا برأ قطعت يده اليمنىٰ ورجله اليسرىٰ من خلاف لقطع الطريق،

وكانت يده اليمنىٰ للسرقة وقطع الطريق معا، ورجله لقطع الطريق مع يده، ثم قتل قودا، وإن مات في الحد الأول سقطت عنه الحدود كلها، وفي ماله دية النفس».

وذكره الطحاوي في اختلاف الفقهاء (٣/ ٣٠٠) وابن القاص في أدب القاضي (٢/ ٤٨٧) والماوردي في الحاوي (١٣/ ٣٧٣) وابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ١٥٢).

وهذا النص صريح علىٰ تقديم الجلد في الزنا علىٰ القطع في السرقة، وقد قيّد الشافعي تقديم حق الآدميين، أو حق الله تعالىٰ فيما ليس فيه قتل نفس، فإذا كان في أحدهما قتل النفس دون الآخر، قدم الأخف منهما علىٰ الأثقل.

وقد نبه علىٰ ذلك غير واحد من الأئمة والشراح.

قال الماوردي في الحاوي (١٣/ ٣٧٣) بعد ذكر نص الشافعي: «إذا اجتمع علىٰ رجل حدود من جلد، وقطع، وقتل، بدئ بالجلد، ثم بالقطع، ثم بالقتل، ولا يسقط بالقتل ما عداه».

وقال الروياني في البحر (١٣/ ١١٦): «ذكر الشافعي ﷺ هنا حد القذف، وحد الزنا، والقطع في السرقة، والقطع في المحاربة، والقود في غير المحاربة، بدأ بحد القذف ثم بحد الزنا ثم تقطع اليد اليمنىٰ للسرقة والمحاربة جميعًا، ثم يقطع الرجل للمحاربة ثم بالقتل قودًا وأمر بالتربص بعد إقامة حد الله تعالىٰ حتىٰ يبرأ

جلده، ثم أمر بحد الزنا وقال: يترك حتىٰ يبرأ ثم والىٰ بين قطع اليمنىٰ ورجله اليسرىٰ لأنها حد واحد للمحاربة ولم ينتظر البرء من القطعين وأمر بقتله لأن انتظار البرء لئلا يتلف بالموالاة بين حدين مختلفين وهنا يريد قتله فما معنىٰ الانتظار».

وقال ابن النقيب في النكت السراج (٧/ ٣٥٧): «ظاهره يشمل صورا فيها الخلاف، وهي تقديم القتل قصاصا علىٰ حد الزنا جلدا أو رجما، وتقديم القطع قصاصا علىٰ الزنا جلدا أو رجما ... »إلىٰ أن قال: «والمشكل فيه شموله تصحيح تقديم قتل القصاص علىٰ حد الزنا، ولم أره الآن مصرحا به».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ١٩٨): «ومقتضىٰ نص «الأم» تقديم حدّ القذف علىٰ حدّ الشرب، وهو المعتمد خلافا لما صححوه، نظرا إلىٰ تقديم حد الآدمي لا إلىٰ الأخف، وأنه يقدم القطع قصاصا علىٰ حد الزنا، وأما القتل قصاصا فلا يقدم علىٰ حد الزنا الذي هو الجلد، بل يجلد، ثم يمهل، ثم يقتل قصاصا، نص عليه.

وإن كان حد الزنا الرجم ففي وجه يرجم بإذن الولي ليتأدىٰ به الحقان، والأصح أنه يسلم إلىٰ الولي ليقتله قصاصا، وما وقع في «المحرر» و«المنهاج» من إطلاق تقديم القتل قصاصا علىٰ الزنا متعقب بما ذكرناه».

وفي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ٢٥٠) عن البلقيني: «إذا كان حد الزنا يوجب الجلد .. قدم علىٰ القتل، نص عليه، ولا خلاف فيه».

تنبيه: في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٢٥٠): «إن كان حد الزنا رجما، فلا خلاف في تقديم القطع قصاصا عليه؛ فإدخاله في الخلاف غير مستقيم، وإن كان جلدا فهو محل الخلاف في صورة القطع، وليس محل خلاف في صورة الرجم».



كتاب الأشربة

[١١٢]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٤٥ ط. الحداد): قيل: والرأس».

جعل النووي هنا اتقاء الرأس وجها ضعيفا، وهو تابع الرافعي في المحرر (ص ١٤٥٠) ولفظه: «ويتقي المقاتل والوجه، وليس الرأس كالوجه في أظهر الوجهين».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٢٨٦): «وفي الرأس وجهان:

أحدهما: أنه يتقي أيضا، وبه قال أبو حنيفة، واختاره الماسرجسي، وابن الصباغ، والروياني؛ لأنه مقتل، ويخاف منه العمىٰ.

وأظهرهما: عند أكثرهم - وهو المذكور في الكتاب: المنع، لما روي عن أبي بكر ﷺ أنه قال للجلاد: «اضرب الرأس، فإن الشيطان فيه[(١)]، ويخالف الوجه فإنه مستور بالشعر، وغيره غالبا، فلا يخاف من ضربه ما يخاف من ضرب الوجه».

وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٧٢) فقال: «وهل يجتنب الرأس؟ وجهان،

---

(١) أثر أبي بكر الصديق: رواه ابن أبي شيبة (رقم ٢٩٠٣٣ ط. الحوت) وابن حزم في المحلىٰ (١٢/ ٢٤٧) من طريق وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي بكر به. والقاسم لم يدرك جده أبا بكر فهو منقطع.
والاستدلال بقصة عمر بن الخطاب مع صبيغ أولىٰ، وهي أصح.

أصحهما عند الجمهور: لا؛ لأنه مستور بالشعر بخلاف الوجه».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره الرافعي وتبعه عليه النووي يدل علىٰ أنهما لم يطلعا علىٰ نص للشافعي في المسألة، وقد نص الشافعي في البويطي علىٰ اتقاء الرأس، فيترجح بذلك اختيار ابن أبي هريرة ومن قال بقوله من الأصحاب، ويكون هو المعتمد للنص.

قال الشافعي في مختصر البويطي (ص ٩٧٢، ٩٧٣ ط. القره داغي): «ويضرب الرجال في الحدود قياما، والنساء قعودا، ويترك لهم أيديهم يتقون بها، لا يربطون ولا يمدون، ويعطىٰ كل عضو حقه ما خلا الوجه والرأس والمذاكير والبطن».

وهذا ما جزم به الشيرازي في جلد الزاني من التنبيه (٢٤٢) فقال: «ويتوقَّىٰ الوجه والرأس والفرج والخاصرة؛ وسائر المواضع المخوفة».

وقال الماوردي في الحاوي الكبير (١٣/ ٤٣٧، ٤٣٨): «يجب في جلد الحدود أن يفرق الضرب في جميع البدن؛ ليأخذ كل عضو حظه من الألم، ولا يجمعه في موضع واحد فيفضي إلىٰ تلفه إلا في موضعين عليه أن يتقي ضربهما:

أحدهما: المواضع القاتلة كالرأس، والخاصرة، والقواد، والنحر، والذكر،

والأنثيين.

والثاني: ما شانه الضرب وقبحه كالوجه لرواية أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا جلد أحدكم أخاه فليجتنب الوجه والفرج»، وقال علي بن أبي طالب ﷺ للجلاد: «اضرب وأوجع، واتق الرأس والفرج»[(١)]. وبنحوه قال الروياني في بحر المذهب (١٣/ ١٤٦).

وفي البيان للعمراني (١٢/ ٣٨٣) أنه اختيار الماسرجسي وابن الصباغ».

---

(١) أثر علي بن أبي طالب: رواه عبد الرزاق (رقم ١٣٥١٧) عن الثوري عن ابن أبي ليلىٰ الفقيه عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن خالد عن علي به.

ورواه وابن أبي شيبة (رقم ٢٨٦٧٥ ط. الحوت) عن حفص بن غياث، وأبو يوسف القاضي في الخراج (ص ١٧٧) كلاهما عن ابن أبي ليلىٰ عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي قال: أتي برجل سكران أو في حد، فقال:« اضرب، وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير« واللفظ لابن أبي شيبة.

وسنده ضعيف، فيه ابن أبي ليلىٰ الفقيه وهو ضعيف من قبل حفظه، وقد اضطرب في إسناده كما ترىٰ.

والمهاجر بن عميرة الذي في سند ابن أبي شيبة مجهول، وهو معروف بهذه الرواية، وبه ضعفه الألباني في الإرواء (رقم ٢٣٣١).

وفوق ذلك لم أر في شيء من الروايات ذكر الرأس، وقد احتج به أبو يوسف في الخراج (ص ١٧٧) علىٰ جواز ضرب الرأس.

وجاء مرفوعا من وجه ضعيف عند الطبراني في الكبير (رقم ٢١٣٠).

وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه (١٧/ ٢١٩): «صححه أبو الطيب في هذا الباب، وبه جزم الماوردي في باب صفة السوط، وكذا ابن الصباغ والروياني».

وقال الأذرعي في قوت المحتاج (٩/ ٢١٩): «جزم به الماوردي في باب صفة السوط، وابن الصباغ، وصاحب التنبيه والروياني والجرجاني في «الشافي» و«التحرير»، وهو الأصح، ولا يعلم للشافعي نص يعارضه».

قال: «وقال الروياني في التجربة: وغلط من قال بخلافه».

وقال الزركشي في الخادم (ص ١٨٩ حقيق شمشول الشمري): «ما ضعفه أولا هو المنصوص للشافعي، كما نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه فقال: سمعت الماسجرسي يقول: غلط بعض أصحابنا فقال: يضرب علىٰ الرأس، لأن المزني خص الوجه بالذكر، وهذا خطأ، لأن الوجه عبارة عما علا، وقد نص الشافعي في البويطي، في باب الإيلاء فقال: «ويعطىٰ كل عضو حقه ما خلا الوجه والرأس والمذاكير والبطن».

قال القاضي: وهذا أصح، وجزم به الماوردي في باب صفة السوط.... » نحو كلام الأذرعي.

وفي تحرير الفتاوىٰ عن البلقيني (٣/ ٢٥٤): «يقتضي أن استثناء الرأس وجه ضعيف، وعليه مشىٰ «الحاوي» فقال (ص ٥٩٦): «ويفرق علىٰ البدن، لا الوجه

والمقتل»، قال شيخنا الإمام البلقيني: وليس كذلك، بل هو نص الشَّافعي في «مختصر البويطي»، وقد نقله القاضي أَبو الطيب في «تعليقه»، وصححه، وقال: إذا اتقينا الفرج؛ لأنه مقْتل، فالرأس بذلك أولىٰ؛ لأنه موضع شريف، وفيه مقتل، ويخاف من ضربه نزف الماء في العين وزوال العقل، وحكاه أيضًا ابن الصباغ والروياني في «الكافي»، وقال: إن مقابله خطأ، وجزم به الخوارزمي في «الكافي»، قال شيخنا: ولا نص للشافعي يخالفه؛ فهو المعتمد».

وفي التدريب للبلقيني (٤/ ٢٠١، ٢٠٢): «ويفرقه علىٰ الأعضاء إلا المقاتل، والوجه والرأس علىٰ المنصوص في البويطي، ولا نص له يخالفه، فهو المعتمد خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله، من جعل استثناء الرأس وجها ضعيفا».

[١١٣]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٤٦ ط. الحداد) في التعزير بالحبس والضرب والصفع والتوبيخ: «ويجتهد الإمام في جنسه وقدره».

تابع الرافعي في هذا فإنه قال في المحرر (ص ١٤٥٢): «وجنسه من الحبس أو الضرب جلدا أو صفعا إلىٰ رأي الإمام».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٢٨٩): «وأما قدره، فيتعلق باجتهاده

أيضا إن خالف جنسه جنس الحد، كالحبس».

وبنحوه قال في الروضة (١٠/ ١٧٤): «فإن كان من غير جنس الحد، كالحبس، تعلق باجتهاد الإمام».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكراه من ترك اختيار قدر التعزير بالحبس للإمام مخالف لنص الشافعي في أنه لا يبلغ به السنة، فكان عليهما التقييد بذلك.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٩٩ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يبلغ بحبسه سنة، ولكن حبس يبتلىٰ به، وهو ضرب من التعزير».

وبهذا النص تعقب الإسنوي في أوهام الكفاية (٢٠/ ٥٧١ مطبوع مع الكفاية) علىٰ ابن الرفعة في دعواه أنه لم يقدر الحبس بمدة غير الزبيري، ثم قال: «وهي فائدة جليلة، وحكمها متجه منقاس، فإن الشارع جعل تغريب السنة واجبا في حد الزنىٰ، والحبس في معناه وأشد منه، فوجب أن يكون التعزير به ناقصا عنه علىٰ قياس سائر التعازير، وعذر المصنف وغيره من الأصحاب ممن ينشط فيطالع «الأم» في عدم وقوفهم علىٰ هذا النص، كونه مذكورا في غير مظنته».

وأورده أيضا في المهمات (٨/ ٣٦٢) وقال: «وهي مسألة مهمة جليلة،

وحكمها متجه مقاس، والعذر في عدم وقوف الأصحاب علىٰ هذا النص كونه مذكورا في غير مظنته، فلله الحمد علىٰ تيسير مثل هذه الأمور التي غفل عن مثلها فحول المتقدمين، وتسهيل الاطلاع عليها لتسليم الحاكم والمفتي بخلافها عن الخطأ.

وقد ذهل إمام الحرمين في كتابه المسمىٰ بـــ«الغياثي» عن نص إمام المذهب علىٰ المسألة، فنقل التقدير المذكور عن بعضهم ثم خطأه فيه فقال: «ولست أرىٰ للسلطان اتساع التعزير إلا في إطالة الحبس، وليس الحبس ثابتًا في حد حتىٰ يحط التعزير عنه»(١).

وقال الأذرعي في القوت (٩/ ٢٢٩): «مدة الحبس إذا رآه هل تقدر؟ قال الزبيري: نعم، بشهر للاستبراء والكشف، وستة أشهر للتأديب والتقويم، ولم

---

(١) ذكر ذلك الإمام في غياث الأمم في التياث اللمم (ص ٢٢٧ تحقيق عبد العظيم الديب) ونصه: «وقد منع بعض الفقهاء تبليغ مدة الحبس في التعزير سنة، نظرا إلىٰ مدة التغريب في حد الزنا، وهذا فاسد عندي، لما قدمت ذكره، وليس التغريب حدا كاملا فينقص عليه تعزير، وإنما هو جزء من حد فليتفطن لذلك الناظر».
وتعقبه الزركشي في الخادم (ص ٢١١ تحقيق شمشول الشمري) فقال: «ونص الشافعي في قتل المسلم الكافر أنه لا يبلغ به سنة يرد علىٰ الإمام، ويبعد تخصيصه بذلك دون غيره».

يقدرها غيره، والمنصوص المشهور: أنه لا يبلغ بحبسه سنة، اللهم إن تدعو إلىٰ إدامته مصلحة، فهذا موضع نظر، ويجعل ذلك كاستئناف حبسه ثانيا».

وفي الخادم للزركشي (ص ٢٠٩ تحقيق شمشول الشمري): «وقد سبق في باب حد الزنا أن الشافعي ذكر النفي، وكذا ذكره الأصحاب منهم الماوردي والروياني والشاشي وصاحب الذخائر، وقالوا: إن ظاهر المذهب أنه ينقص عن السنة قليلا لئلا يساوي تغريب الزاني، وقد نص عليه الشافعي في الأم أيضا».

وقال (ص ٢١١): «والثاني: وبه قال ابن سريج أنه يقدر بسنة ولا يزاد عليها، لئلا يزاد عن تغريب الحر في حد الزنا، وإن كان الحبس في قتل المسلم الكافر فقد نص الشافعي علىٰ أنه لا يبلغ به سنة».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٢٠٤): «الذي نص عليه الشافعي - وهو المشهور - أنه لا يبلغ بحبسه سنة».

وقال ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٤/ ٢٤٤): «ويشترط أن ينقص مدة الحبس عن سنة، نص عليه في «الأم«في (قتل المؤمن بالكافر)، فقال: «ولا يبلغ بحبسه سنة».

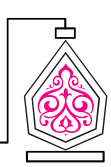
وقال السخاوي في الأجوبة المرضية (٢/ ٧٥٨): «أطلق الرافعي جعله لرأي الحاكم، فقال: إن جنس التعزير من الحبس أو الضرب جلدًا أو صفعا إلىٰ رأي

الإمام، ثم قال: وأما قدره، فيتعلق باجتهاده أيضًا إن خالف جنس الحد كالحبس. انتهىٰ.

وتابعه عليه في الروضة ومقتضاه: أنه يجوز زيادة في الحبس علىٰ السنة، لكن قد حكىٰ إمام الحرمين أن بعض الفقهاء منع تبليغ مدة الحبس سنة، نظرًا إلىٰ مدة التغريب في الزنا قال: وهذا عندي فاسد، وليس التغريب حدًا كاملًا وإنما هو جزء من حد وقال: ولست أرىٰ للسلطان اتساع التعزير إلا في إطاعة الحبس، قال: وليس الحد ثابتًا في حد حتىٰ يحط التعزير عنه وكل هذا منهم رحمهم الله مخالف للنص، فإن الشافعي رحمه الله قال في الأم: فإذا قتل المؤمن الكافر عزر، ولا يبلغ بتعزيزه في قتل ولا غيره حدا، ولا يبلغ بحبسه سنة، ولكن حبس يرتدع به، وهو ضرب من التعزير. انتهىٰ.

قال بعض شيوخنا: والظاهر أن الإمام والرافعي لم يقفا علىٰ هذا النص».



كتاب الصيال وضمان الولاة

[١١٤]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٥٢ ط. الحداد): «وكذا أربعون سوطا علىٰ المشهور».

ذكر النووي أن المشهور من قول الشافعي أنه لا شيء علىٰ الإمام أو الجلاد فيما إذا ضربه في الخمر أربعين سوطا، وهذا معنىٰ قول الرافعي في المحرر (ص ١٤٥٩): «أو ضرب أربعين جلدة فمات فلا ضمان»، وزاد النووي توضيحا كلمة «السوط».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٢٩٧): «ولو ضرب أربعين جلدة فمات، ففي وجوب الضمان قولان، ويقال: وجهان:

أحدهما: يجب؛ لأن التقويم بأربعين جلدة كان بالاجتهاد، ويدل عليه حديث علي - كرم الله وجهه - أنه شيء أحدثناه بعد رسول الله -ﷺ.

وأصحهما: أنه لا يجب، كما في سائر الحدود، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعت علىٰ أن الشارب مضروب أربعين جلدة، وعدلت ما كان بهذا القدر».

وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٧٨).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكر النووي هنا فيه نظر من وجهين:

الوجه الأول: أن تعبيره بـ(المشهور) ليس جيدا علىٰ فرض ثبوت النصين أو النصوص، لأن النص الآخر ثابت في الأم كما يأتي، فكان حقه أن يقول (علىٰ الأظهر) قاله الأذرعي في القوت (٩/ ٢٦٣).

الوجه الثاني: أن الشافعي نص في الأم (٧/ ٢١٤ ط. د. رفعت فوزي) علىٰ وجوب الضمان في الضرب بالسوط أربعين فقال: «فإن ضربه أربعين أو نحوها، أو ضربه أربعين أو أقل منها بسوط، أو ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير ذلك، فمات فديته علىٰ عاقلة الإمام، دون بيت المال».

فهذا النص ثابت عن الشافعي، وفي ثبوت النص الآخر نظر ومناقشة.

وفي بحر المذهب للروياني (١٣/ ١٣٢): «وقال القاضي أبو حامد: الشافعي ﷺ في جراح العمد في باب جناية السلطان: إذا ضربه بالسوط أربعين أو أقل فمات ضمن، وقال في «المختصر» و «الأم» مثل هذا، والقول الآخر لأصحابنا، لا عن الشافعي»، واعتمده الأذرعي في القوت (٩/ ٢٦٣).

وقال الزركشي في الخادم (ص ٢٣٩-٢٤٠ تحقيق شمشول الشمري): «حكاية الخلاف قولين، وترجيح عدم الضمان ممنوع، بل لم يثبت الشافعي في

المسألة قولين، بل الموجود في الأم الجزم بالضمان[١] فقال: «فإن ضربه أربعين أو أقل منها بسوط، أو أكثر من أربعين بالنعال، فمات فديته علىٰ عاقلة الإمام«واحتج بحديث علي الثابت في الصحيحين: «ما كنت لأقيم الحد علىٰ أحد فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات فديته، وكذا ورثتهم، فإن رسول الله ﷺ لم يسنه، ولهذا نقل الدارمي عن النص الضمان ...» وأطال الزركشي النفس فيه.

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٢٠٩): «فإن ضربه أربعين سوطا ضمن علىٰ النص خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله، أو أكثر فالأصح بمقتضىٰ النص إيجاب نصف الدية خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله».

وفي تحرير الفتاوىٰ عن البلقيني (٣/ ٢٧١) قال: «ولم أجد له نصا بعدم الضمان، وحكىٰ الماوردي عن الجمهور ما يقتضي التضمين». وانظره في الحاوي للماوردي (١٣/ ٤١٥).

اعتراض وجواب

فإن قيل: في مختصر المزني (٢/ ٤٧٧ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: وإذا

---

(١) في الأصل «بعدم الضمان» وأظن قوله «بعدم» من الأوهام كما يدل عليه كلامه والنص المنقول.

ضرب الإمام في الخمر، أو ما يسكر من الشراب بنعلين، أو طرف ثوب، أو رداء، أو ما أشبهه، ضربا يحيط العلم أنه لم يجاوز أربعين، فمات من ذلك، فالحق قتله، وإن ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير ذلك فمات، فديته علىٰ عاقلة الإمام».

فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: أنه ليس في نقل المزني ذكر السوط، وإنما نقله في الضرب بالنعال وطرف الثوب والرداء، والذي في «الأم» نص صريح في حكم السوط سواء كان أربعين أو أقل منها.

الوجه الثاني: أن في نقل المزني سقطا، بينه ابن المنذر في الإشراف فقال (٧/ ٣٣٨): «وقال الشافعي: «إن ضرب بنعلين، أو بطرف ثوب ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها، فمات، فالحق قتله، وإذا كان كذلك فلا عقل، ولا قود، ولا كفارة علىٰ الإمام، وإنه ضربه أربعين سوطا، أو أكثر من أربعين بالنعال، فمات: فديته علىٰ عاقلة الإمام دون بيت المال».

فسقط من رواية المزني قوله (وإنه ضربه أربعين سوطا) وهو الثابت في «الأم»، ومثل هذا الاختصار المخل يرد في نقل المزني كما تقدم أول الكتاب.

وعلىٰ هذا فالمتعمد المنصوص أن من ضرب بأربعين سوطا ضمن ما ترتب عليه من جناية.

[١١٥]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٥٢ ط. الحداد): «وله - أي الأب - ولسلطان قطعها بلا خطر، وفصد وحجامة».

ما ذكره النووي هنا من أن للسلطان قطع السلعة عن الصبي والمجنون إذا لم يكن في القطع خطر، تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٤٦٠) ولفظه: «ويجوز للولي والسلطان معا قطع سلعة لا خطر في قطعها، والفصد والحجامة».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٣٠١-٣٠٢): «وقطع السلعة، إذا لم يكن فيه خطر، فيجوز الإتيان به للولي الخاص والسلطان جميعا؛ لأنهما يليان ماله، ويصونانه عن أن يضيع، فصيانة بدنه وأبدان الحيوان في معرض العلل والتغاير بالمعالجة أولىٰ».

وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٨٠) فقال: «وأما ما لا خطر فيه ولا خوف غالبا، كالفصد والحجامة وقطع سلعة بلا خطر، فيجوز فعله للولي الخاص، وكذا للسلطان».

وقد تابعا الإمام الجويني في ذلك، والتعليل الذي ذكره الرافعي هو تعليل

الإمام في النهاية، وفسر قول الشافعي الآتي بما فيه مخاطرة في القطع والترك فقال في النهاية (١٧/ ٣٥٣): «فأما إذا كان قطع السلعة مخطرا، وكانت تبقيتها مخطرة أيضا، ومست الحاجة إلىٰ النظر في تغليب أحد الظنين، فهاهنا قال الشافعي: لا يقطع السلطان السلعة والأكلة».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره الإمام في توجيه كلام الشافعي لا يساعده عليه ظاهره، والأولىٰ إبقاؤه علىٰ إطلاقه كما حكاه الجويني في النهاية عن الأصحاب، ولهذا قال الأذرعي في القوت (٩/ ٢٦٥): «وأما في السلطان فهو شيء أبداه الإمام وتابعه عليه أتباعه».

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢١٧-٢١٨ ط. د. رفعت فوزي): فإذا كانت لرجل سلعة، فأمر السلطان بقطعها، أو أكلة فأمر السلطان بقطع عضوه الذي هي فيه، والذي هي به لا يعقل؛ إما صبي، وإما مغلوب علىٰ عقله، أو عاقل فأكرهه علىٰ ذلك فمات، فعلىٰ السلطان القود في المكره، إلا أن تشاء ورثته أن يأخذوا الدية، وقد قيل: عليه القود في الذي لا يعقل، وقيل: لا قود علىٰ السلطان في الذي لا يعقل، وعليه الدية في ماله».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٧٩، ٤٨٠ ط. الداغستاني): «وإذا كانت برجل سلعة، فأمر السلطان بقطعها، وآكلة، فأمر بقطع عضو منه فمات، فعلىٰ السلطان القود في المكره، وقد قيل: عليه القود في الذي لا يعقل، وقيل: لا قود عليه في الذي لا يعقل، وعليه الدية في ماله، وأما غير السلطان يفعل هذا فعليه القود».

هذا نص الشافعي بحروفه، وليس فيه تقييد ولا تفصيل بين الصور، بل هو منع مطلق، وجزم بأنه يضمن علىٰ كل حال، والضمان القود في قول، والدية في قول آخر، وليس في شيء من ذلك أنه لا شيء عليه، وهذا هو المعتمد خلافا للمنهاج.

وقد ذكر أبو الحسن الماوردي هذا النص عن الشافعي في الحاوي ثم شرحه (١٣/ ٤٢٩، ٤٣٠) فجعل من له ولاية بسلطنة علىٰ ضربين، فقال: «أحدهما: أن يكون قطعها أخوف من تركها، فالقود فيها علىٰ السلطان واجب؛ لأنها جناية منه.

والضرب الثاني: أن يكون تركها أخوف من قطعها، ففي وجوب القود عليه قولان:

أحدهما: لا قود عليه؛ لأنها من مصالحه، وعليه الدية؛ لأنها من خطئه.

والقول الثاني: عليه القود؛ لأنه عجل من تلفه ما كان مؤخرا، فهذا حكم السلطان إن لم يكن إماما كالأمير والقاضي.

وإن كان إماما فقد اختلف أصحابنا فيه علىٰ وجهين:

أحدهما: أنه في وجوب القود عليه كغيره، من أمير وقاض؛ لعموم ولاية جميعهم.

والوجه الثاني: وأشار إليه أبو إسحاق المروزي. أنه لا قود عليه بخلاف غيره لأمرين:

أحدهما: أنه من التهمة أبعد.

والثاني: أن ولايته أعم.

وإذا وجبت الدية، فإن قيل: باستحقاق القود عليه، كانت دية عمد تجب في ماله حالة، ولا تكون علىٰ عاقلته، ولا في بيت المال.

وإن قيل: إن القود لا يستحق، كان دية عمد شبه الخطأ؛ لأنه عامد في فعله مخطئ في قصده، وأين تكون الدية؟ علىٰ قولين:

أحدهما: علىٰ عاقلته، والثاني: في بيت المال». ونحوه في بحر المذهب (١٣/ ١٤٠).

وقال البغوي في التهذيب (٧/ ٤٢٧): «إن كان المقطوع منه صبيا أو مجنونا - فلا يجوز قطعه، خوفا من الهلاك، فإن قطع - نظر: إن قطعها غير الولي،

فمات- يجب القود، وإن قطعها وليه أو السلطان - تجب الدية مغلظة في ماله، وهل يجب القود؟ إن كان القاطع غير الأب والجد - فيه قولان:

أحدهما: يجب القود؛ لأنه قطع ما لم يكن له قطعه.

والثاني: لا يجب؛ لأنه قصد الإصلاح لا الإهلاك».

فأطلق البغوي وجوب الضمان علىٰ السلطان ولم يفصل ولم يستثن، وحصر الخلاف علىٰ القود والدية.

وقال الأذرعي في القوت (٩/ ٢٦٥): «الذي رأيته في كتب المذهب منعه من قطع السلعة من غير تفصيل».

وكذلك قال الزركشي في الخادم (ص ٢٥٢-٢٥٣ تحقيق شمشول الشمري): «وما ذكر من جوازه للسلطان هو شيء أبداه الإمام، والمنقول في كتب الأصحاب إطلاق منعه من قطع السلعة من غير تفصيل، وقد قال الإمام بعد ما صرح بالجواز في هذه الحالة: «وقد نقل الأصحاب مطلقا أن السلطان لا يقطع السلعة، ولم يريدوا هذه الصورة، لأنها من المعالجات»، فحمل كلامهم علىٰ غير هذه الصورة، وهو ممنوع».

[١١٦]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٥٥ ط. الحداد): «ولو بالت أو راثت بطرق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان».

جزم المصنف هنا عدم الضمان تبعا للرافعي في المحرر (ص ١٤٦٥) ولفظه: «وإذا بالت أو راثت في الطريق فزلق به مارٌّ وتلف نفس أو مال فلا ضمان».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٣٣١) فقال: «وإذا راثت الدابة أو بالت في سيرها في الطريق، فزلق به إنسان، وتلف نفس أو مال، أو فسد شيء من رشاش الوحل بممشاها وقت الوحل والأنداء، أو بما يثور من الغبار، وقد يضر ذلك بثياب البزازين، وبالفواكه، فلا ضمان؛ لأن الطريق لا تخلو عن ذلك والمنع من الطروق مما لا سبيل إليه».

وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ١٩٨) فقال: «وإذا راثت الدابة، أو بالت في سيرها في الطريق، فزلق به إنسان، وتلفت نفس أو مال، أو فسد شيء من رشاش الوحل بممشاها وقت الوحول والأنداء، أو مما يثور من الغبار، وقد يضر ذلك بثياب البزازين والفواكه، فلا ضمان في كل ذلك؛ لأن الطريق لا يخلو عنه، والمنع من الطرق لا سبيل إليه».

○ قال أبو عبد الباري:

اختلف قول الشيخين في هذه المسألة، وما تقدم عنهما هو احتمال للإمام في النهاية، وذلك أنه قال في الديات من النهاية (١٦/ ٥٧٠): «ومما تشتد الحاجة إليه، ويظهر فيه إسقاط الضمان، ولا يخلو عن خلاف في إيجابه هو إتلاف البهائم.

والوجه عندنا أن نقول: البهائم الطارقة إذا كانت تبول وتروث، ثم فرض تزلق بعض المارة بأبوالها وأرواثها، فلا ضمان علىٰ أصحاب الدواب؛ فإن هذا مما لا يمكن التصون منه، وفي إثبات الضمان فيه - منع من المرور والطروق، فإن كان يتجه نفي الضمان في اشتداد الحاجة، فهذا أولىٰ الصور، وقد ذكر الأصحاب فيها وجوب الضمان علىٰ من يستاق البهائم، والذي ذكرته مأخوذ من كلام الأئمة عند اعتبارهم الضرورة الخاصة، والحاجة البينة في إسقاط الضمان، وإذا كانوا يسقطون الضمان في المرازيب لحاجات الأملاك؛ فلأن يسقطوا الضمان في هذه الحالة أولىٰ».

فبين هنا أن الأصحاب قالوا بالضمان، وأن القول بعدم الضمان رأي للإمام بناه علىٰ الضرورة الخاصة، ثم لما تكلم عن جناية البهائم في النهاية جزم بذلك

فقال (١٧/ ٣٧٨): إذا وقفت الدابة، فبالت وراثت، فالبول منها والروث لا يتعلق بهما ضمان في الممر، وهذا لا سبيل إلىٰ دفعه، فأما إذا اتفق مزيد انتشار بسبب وقوف الدابة، فقد قال الأصحاب: إن كان الطريق ضيقا، فوقف الدابة عدوان، وما يترتب عليه يقتضي الضمان، وإن كان الطريق واسعة، فوقف الدابة معتاد، ووقوفها كمشيها.

وهذا عندنا يلتفت علىٰ مسألة في باب الاصطدام، وهي إذا اصطدم الماشي بالواقف، فهل ينسب إلىٰ الواقف عدوان؟ فيه كلام، وما ذكرناه منزل عليه».

وتبعه الغزالي فقال في الوسيط (٦/ ٥٣٧): «أما الضرر الذي ينشأ من رشاش الوحل وانتشار الغبار إلىٰ الفواكه فلا ضمان، إذ هو ضرورة الطرق، ولا يمكن المنع منه».

وعلق علىٰ ذلك ابن الرفعة في الكفاية (١٦/ ٣٦) فقال: «وحكم بول الدابة في يده إذا تلف به إنسان، أو تزلق به شخص فهلك، حكم تلفه بيدها.

ولو لم تكن في يده لم يضمن ذلك، صرح به الماوردي وغيره، وحكىٰ الإمام ذلك في باب وضع الحجر في حال طروقها عن الأصحاب، وأبدىٰ عدم الضمان احتمالاً لنفسه، ووجهه: بأن هذا لا يمكن التصون منه؛ فلو ثبت الضمان لمنع من المرور والطروق».

○ قال أبو عبد الباري:

المشهور عن الإمام الشافعي وجوب الضمان، وقد تتابع الأئمة علىٰ نقله عن الشافعي، ومنهم من عزاه للأم ولم أقف عليه، ولفظه فيما ذكره الزركشي في الخادم (ص ٣٢٣ تحقيق شمشول الشمري): «وعليه نص الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه في «الأم» أيضا كما حكاه المحاملي في المجموع حيث قال: وقال في الأم: «إذا بالت دابة في الطريق فزلق به إنسان كانت الدية علىٰ عاقلته أيضا، سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا؛ لأن يده عليها، فهو كما لو بال في المكان».

ويشهد لذلك ما في مختصري المزني والبويطي.

ففي مختصر المزني (٢/ ٤٠٢ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ولو وضع حجرا في أرض لا يملكها، وآخر حديدة، فتعقل رجل بالحجر فوقع علىٰ الحديدة، فمات فعلىٰ واضع الحجر دية؛ لأنه كالدافع».

وفي مختصر المزني (٢/ ٤٩٢ ط. الداغستاني): «ولو أوقفها في موضع ليس له أن يقفها فيه ضمن، ولو أوقفها في ملكه لم يضمن».

وظاهر هذا أن التسبب في مثل هذا يوجب الضمان، وعلىٰ هذا بنىٰ الماوردي ومن تبعه وجوب الضمان في مسألة بول الدابة وروثها في الطريق فيزلق به إنسان فيعطب.

وفي مختصر البويطي (ص ٩٦٩ ط. القره داغي): «وإن كانت دابة تتبع رجلا، وليس بقائد لها، أو كانت بين يديه وهي تنساق بإذعاره أو برجزه فأصابت شيئا فهو ضامن».

وهذا يدل بعمومه علىٰ وجوب الضمان مطلقا، أي سواء أصابته مباشرة أو تسببا، وقد نص قبل ذلك بسطور علىٰ المباشرة فقال (ص ٩٦٩ ط. القره داغي): «ويضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب».

فبين بالنصين وجوب الضمان إذا كان مع الدابة مباشرة أو تسببا، وإنما يسقط الضمان إذا لم يكن معها أحد، وهو معنىٰ الحديث: «العجماء جبار» كما قال في مختصر البويطي (ص ٩٦٩ ط. القره داغي): «ومعنىٰ حديث «العجماء جبار «هي كل بهيمة أفسدت شيئا أو أتلفته وليس معها سائق ولا قائد ولا راكب إلا في موضع واحد خصه رسول الله ﷺ إذ قال: «ما أفسدت المواشي بالليل فذلك ضامن علىٰ أهلها»، وما عدا هذا الموضع فهو جبار، إلا أن يكون معها سائق جنحت به الدابة أو غلبته فهو ضامن».

وجزم به الرافعي والنووي في باب محرمات الإحرام.

قال الرافعي في الشرح الكبير (٣/ ٥٠٠) وجوب الضمان فقال: «... وكذا

لو بالت في الطريق فزلق به صيد، وهلك كما لو زلق به آدمي، أو بهيمة».

وتبعه النووي في الروضة هنا (٣/ ١٥٠) فقال: «لو حصل التلف بسبب في يده، بأن كان راكب دابة، فتلف صيد بعضها، أو رفسها، أو بالت في الطرق، فزلق به صيد فهلك، لزمه الضمان».

وكذلك في شرح المهذب فقال (٧/ ٢٩٨): «لو حصل تلف الصيد بسبب شئ في يد المحرم بأن كان راكب دابة، أو سائقها، أو قائدها، فتلف صيد بعضِّها، أو رفسها، أو بالت في الطريق فزلق به صيد فهلك به ضمنه، لأنها منسوبة إليه، فضمن ما أتلفته أو تلف بسببها كما لو أتلفت آدميا ومالا».

وذكر الأذرعي في قوت المحتاج (٩/ ٢٨٣، ٢٨٤) أن الجمهور جزموا بالتضمين منهم الفوراني في كتابيه، والبغوي في «التهذيب» (٧/ ٢٠٥) و«التعليق»، والشيخ أبو حامد وأتباعه، والجرجاني في «الشافي» و«التحرير»، وابن الصباغ، والشاشي في «الحلية» (٧/ ٦٤٢)، وصاحب «المعتمد»، والمتولي في «الديات»[(١)] ... ثم ذكر قول ابن الرفعة ثم قال: وتبعه الغزالي

(١) زاد الزركشي في الخادم (ص ٣٢٤ تحقيق شمشول الشمري) البندنيجي، والماوردي وصاحب المهذب، والبيان، ومن المراوزة: القفال في شرح التلخيص، والشيخ أبو الفرج الزاز».

وغيره هنا علىٰ عدم الضمان، وجرىٰ عليه الشيخان، (وما جزما به هنا تبعا للإمام لا ينكر اتجاهه، ولكن المذهب: نقل)[١]، وما بنىٰ عليه الإمام كلامه وجه ضعيف لبعض المراوزة، وبه أجاب إبراهيم المروزي هنا فقال: إذا بالت الدابة التي ركبها في وقت سيرها فزلقت رجل إنسان لا يضمن، وإن أوقفها فبالت إن كان الطريق ضيقا يضمن، وإن كان واسعا لم يضمن لعدم التعدي.

وفي «تعليق البغوي» هنا ذكر الفرق بين الطريق الضيق والواسع، ثم قال: وذكر العراقيون من أصحابنا أنه يضمن بكل حال، وهو أحسن، لأن الارتفاق بالطريق إنما يباح بشرط السلامة».

وفي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ٢٧٩) عن البلقيني أنه صرح بإيجاب الضمان أيضا الماوردي (١٢/ ٣٧٢)[٢] والبندنيجي والشيخ في «المهذب» (٣/ ٢٠٧) وابن الصباغ والقفال في «شرح التلخيص«وأبو الفرج الزاز»، وأن ابن القاص والشيخ أبا حامد، نقلاه عن النص، ثم قال: فظهر أن المسألة مذكورة في كتب الطريقين علىٰ خلاف ما جزم به المصنف وأصله، ولم يستحضر المنقول

---

(١) في المطبوع من القوت هنا خلط لا يتضح المراد منه، والتصحيح من بداية المحتاج لابن قاضي شهبة (٤/ ٢٦٠).

(٢) وتبعه الروياني في البحر (١٢/ ٣٤١).

في المسألة حين كتابة هذا الموضع».

وقال الدميري في النجم الوهاج (٩/ ٢٧٦): «والصواب: تضمين المالك بذلك؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كالجناح والروشن، وقد حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب، وبه جزم الماوردي والروياني وابن الصباغ والبندنيجي».

وقال ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٤/ ٢٦٠): «والمذهب المنصوص: الضمان؛ لأن الارتفاق مشروط بسلامة العاقبة».

وقال الهيتمي في تحفة المحتاج (٩/ ٢٠٥): «والمنقول عن نص الأم والأصحاب ما جريا عليه في غير هذا الباب، وجزم به في المجموع من الضمان حيث لم يتعمد المار المشي عليه؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة».

وفي مغني المحتاج للخطيب الشربيني (٥/ ٥٤٣): «ما جزم به من عدم الضمان كذا هو في الشرح والروضة هنا، وخالفاه في كتاب الحج فجزما فيه بالضمان ونص عليه في الأم؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كإخراج الجناح والروشن إلىٰ الطريق.

وهذا ما عليه الأصحاب، والأول احتمال للإمام فإنه نقل في باب وضع

الحجر أن من كان مع دابة ضمن ما تتلفه ببولها في الطريق لأنه سبب من جهته، ثم أبدىٰ احتمالا لنفسه بعدم الضمان، ثم إنه جرىٰ علىٰ احتماله هنا وجزم به فتبعه الغزالي والرافعي وغيرهما.

قال الأذرعي: وما جزم به هنا تبعا للإمام لا ينكر اتجاهه، ولكن المذهب نقل.

ومن هنا قال البلقيني: عدم الضمان فيما تلف بركض معتاد بحث للإمام بناه علىٰ احتماله المذكور والذي يقتضيه قياس المذهب الضمان، وإطلاق نصوص الشافعي والأصحاب قاضية به».

وأغرب الرملي في نهاية المحتاج (٨/ ٤١) فقال: «هو المعتمد، وإن زعم كثير أن نص «الأم» والأصحاب الضمان، وقد مرَّ أنه لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون».

قلت: هذا عجيب، وكأنه لم يمعن النظر في وجوه الاعتراض الثلاثة، وهي:

أولا: اختلاف قولهما.

ثانيا: مخالفة قولهما لنص الإمام الشافعي.

ثالثا: مخالفة قولهما لما عليه الأكثرون الموافق لما تقدم.

وهب أنه لا يعترض عليهما -علىٰ ضعفه- بمخالفة الأكثرين، فما بال قولهما اختلف؟ وما ذا عن نصّ الشافعي الذي أشار إليه، هل قولهما في المذهب مقدم علىٰ قول الشافعي إمام المذهب؟.





كتاب السير

[١١٧]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٦٧ ط. الحداد): «ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع، وإرسال الماء عليهم، ورميهم بنار ومنجنيق، وتبييتهم في غفلة».

تابع النووي الرافعي في المحرر (ص ١٤٧٩) في قوله: «ويجوز محاصرة الكفار في البلاد والقلاع، وإضرام النار عليهم، وإرسال الماء، ورميهم بالمنجنيق، وتبييتهم وهم غارون».

وذكر الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٣٩٤، ٣٩٦) مثل ذلك، وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ٢٤٥).

○ قال أبو عبد الباري:

ظاهر إطلاق الشيخين هنا يعمُّ الأشخاص والأماكن، وليس كذلك، بل يستثنىٰ من ذلك أمران:

الأمر الأول: من لم تبلغه الدعوة، فلا يجوز قتالهم قبل التبليغ.

قال الشافعي في الأم (٢/ ٥٨٦ ط. د. رفعت فوزي): «وأما من لم تبلغه الدعوة فلا أغير عليه حتىٰ أدعوه، ولا أغنم من ماله شيئا حتىٰ أدعوه فيمتنع فيحل

دمه وماله».

وقال الشافعي في الأم (٥/ ٥٨١ ط. د. رفعت فوزي): «فأما من لم تبلغه دعوة المسلمين، فلا يجوز أن يقاتلوا حتىٰ يدعوا إلىٰ الإيمان، إن كانوا من غير أهل الكتاب، أو إلىٰ الإيمان أو إعطاء الجزية إن كانوا من أهل الكتاب، ولا أعلم أحدا لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدونا الذين يقاتلونا أمة من المشركين، فلعل أولئك أن لا تكون الدعوة بلغتهم، وذلك مثل أن يكون خلف الروم، أو الترك، أو الخزر، أمة لا نعرفهم، فإن قتل أحد من المسلمين أحدا من المشركين لم تبلغه الدعوة وداه، إن كان نصرانيا أو يهوديا، دية نصراني أو يهودي، وإن كان وثنيا أو مجوسيا دية المجوسي».

وفي مختصر المزني (٢/ ٥٠٩ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ولا أعلم أحدا من المشركين لم تبلغه الدعوة اليوم، إلا أن يكون خلف الذين يقاتلوننا أمة من المشركين خلف الخزر والترك لم تبلغهم الدعوة، فلا يقاتلون حتىٰ يدعوا إلىٰ الإيمان، فإن قتل منهم أحد قبل ذلك فعلىٰ من قتله الدية».

فدل ذلك علىٰ استثناء من لم تبلغه الدعوة، ويختص ما ذكره النووي بمن بلغته الدعوة، وهذا يرجع لتبييتهم وهم غافلون.

وقد نقل ابن المنذر في الإشراف (٢/ ٨٣١) عن الشافعي أن من قتل من لم تبلغه الدعوة ضمن ديته، وأخذ به بعض أصحابنا منهم الشيرازي في المهذب

(٣/ ٢٠٢) وعلله بقوله: «لأنه محقون الدم مع كونه من أهل القتال فكان مضمونـًا بالقتل كالذمي».

وكذلك قال البغوي في شرح السنة (١١/ ٨) ولفظه: «فأما من لم تبلغه الدعوة من الكفار فما بعدت داره، ونأىٰ محله، فإنه لا يقاتل حتىٰ يدعىٰ إلىٰ الإسلام، فإن قتل منهم واحد قبل الدعوة فتجب فيه الكفارة والدية».

قال الدميري في النجم (٩/ ٣٢٥): «ويستثنىٰ من إطلاق المصنف: من لم تبلغه الدعوة من الكفار؛ فإنه لا يجوز قتالهم حتىٰ يدعوا إلىٰ الإسلام؛ لقوله تعالىٰ {ومَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا}، كذا نص عليه الشافعي والأصحاب».

الأمر الثاني: مكة المكرمة، فلا يقام فيها حرب عامة بالنار والماء والمنجنيق.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٧١٢-٧١٣ ط. د. رفعت فوزي): «ولو أن قوما من أهل دار الحرب لجئوا إلىٰ الحرم، فكانوا ممتنعين لجئوا فيه، أخذوا كما يؤخذون في غير الحرم، فنحكم فيهم من القتل وغيره كما نحكم فيمن كان في غير الحرم.

فإن قال قائل: وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم، وقد قال رسول الله ﷺ

في مكة: «هي حرام بحرمة الله، لم تحلل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي إلا ساعة من نهار» وهي ساعتها هذه محرمة؟.

قيل: إنما معنىٰ ذلك - والله أعلم - أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتىٰ تكون كغيرها.

فإن قال: ما دل علىٰ ما وصفت؟.

قيل: أمر النبي ﷺ عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب وابن حسان بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة [إن][(١)] قدر عليه.

وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة، فدل علىٰ أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه، وأنها إنما تمنع أن ينصب عليها الحرب كما ينصب علىٰ غيرها».

وقد اعتمده القفال في شرح التلخيص فقال: «لا يجوز القتال بمكة، حتىٰ لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها»، ذكره النووي في شرح المهذب (٧/ ٤٧٤) ثم غلطه فقال: «وهذا الذي قاله القفال غلط نبهت عليه لئلا يغتر به».

فإن قيل: فقد ثبت عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ في اليوم

---

(١) كلمة (إن) زيادة من طبعة دار الفكر ليتم المعنىٰ.

الذي بعد يوم فتح مكة يقول: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ﷺ فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب» رواه البخاري ومسلم.

وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بمعناه في تحريم القتال بمكة، وأنها لم يحل القتال بها إلا ساعة للنبي ﷺ.

فالجواب: أن معناها: تحريم نصب القتال عليهم، وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره، إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحصن كفار في بلد آخر، فإنه يجوز قتالهم علىٰ كل وجه، وبكل شيء، وقد نص الشافعي رضي الله عنه علىٰ هذا التأويل في آخر كتابه المعروف بسير الواقدي من كتب الأم» ونحوه في شرح مسلم (٩/ ١٢٥) وتهذيب الأسماء واللغات له (٣/ ٨٤).

قلت: قول النووي (إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك) ليس في نص الشافعي وإنما هو تأويل من النووي لحمل كلام الشافعي علىٰ هذه الحالة كما بينه، وظاهر نص الشافعي المنع من نصب الحرب عليها مطلقا.

قال الأذرعي في القوت (٩/ ٣٤٢): «وهو غير ظاهر فيما ذكره المصنف من التأويل، بل هو مصرح بأنه لا ينصب عليها القتال العام كما ينصب علىٰ غيرها».

قلت: وعلىٰ تأويل النووي في شرح المهذب فكان ينبغي استثناء مكة من إطلاق نصب الحرب عليها، وبيان اختلاف حالها عن غيرها من البلاد.

وأعتمده البلقيني في التدريب (٤/ ٢١٧) فقال: «ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع، وإرسال الماء عليهم، ورميهم بنار، ومنجنيق إلا في مكة المشرفة، فإنه لو تحصن بها أو بموضع من حرمها طائفة من الكفار الحربيين لم يجز قتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك. ولا نصب الحرب عليها كغيرها. نص علىٰ هذا الأخير الشافعي رضي الله عنه».

وقال الولي العراقي في التحرير (٣/ ٣٠٠): «محله: في غير مكة، فلو تحصن بها أو بموضع من حرمها طائفة من الحربيين لم يجز قتالهم بما يعم، كما نص عليه في «الأم» في سير الواقدي».

وقال الهيتمي في تحفة المحتاج (٩/ ٢٤١): «لو تحصن حربيون بمحل من حرم مكة لم يجز حصارهم ولا قتالهم بما يعم تعظيما للحرم، وظاهر أن محله حيث لم يضطر لذلك» ونحوه في المغني للخطيب (٦/ ٣٠، ٣١) والنهاية للرملي

(٨/ ٦٤).

[١١٨]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٧٠ ط. الحداد): «ويشارك متحيز إلىٰ فئة قريبة في الأصح».

ما ذكره النووي هنا من مشاركة المحتيز إلىٰ الفئة القريبة في الغنيمة تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٤٨١) ولفظه: «والمتحيز إلىٰ الفئة القريبة يشارك فيها علىٰ الأشبه».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٤٠٤): «هل يشارك المتحيز إلىٰ الفئة القريبة الغانمين في المغنوم بعد ما ولىٰ؟ ذكر صاحب الكتاب فيه وجهين:

أشبههما: الاستحقاق؛ لأنه لا يفوت نصرته، والاستنجاد به، فهو كالسرية يشارك جند الإمام فيما يغنمون إذا كانت بالقرب منهم».

وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ٢٤٨) وعبر عنه بالأصح.

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره من مشاركة المتحيز للفئة القريبة دون البعيدة مخالف لظاهر نصّ الشافعي رضي الله عنه.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٣٩٤ ط. د. رفعت): «فإن قالوا: ولينا متحرفين

لقتال، أو متحيزين إلىٰ فئة، كانت لهم سهمانهم فيما غنم قبل يولون، ولو غنموا بعد التولية شيئا ثم عادوا لم يكن لهم سهمانهم فيما غنم بعدُ، لأنهم لم يكونوا مقاتلين ولا ردءًا»[(١)].

ودلالة هذا النص على عدم مشاركتهم من وجهين:

أولهما: أنه لم يفرق بين التحيز لفئة قريبة أو بعيدة، بل كلامه يشمل الأمرين.

ثانيهما: أن قوله «ثم عادوا» ظاهر في دخول القريبة، لأن العود يقتضي أن يكون التحيز إلىٰ فئة قريبة.

وتأوله الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٤٠٤) بالبعيد فقال: «والمتحيز إلىٰ الفئة البعيدة لا يشارك الغانمين في الغنيمة، إن فارق قبل الاغتنام وإن غنم شيء دون شيء -لم يبطل حقه مما غنم قبل مفارقته، ولا شيء فيما غنم بعدها، هكذا نُقل عن نص الشافعي رضي الله عنه».

وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ٢٤٨): «المتحيز إلىٰ فئة بعيدة لا يشارك الجيش فيما يغنمونه بعد مفارقته، ولا يبطل حقه مما غنموه قبل مفارقته، هكذا

---

(١) وهو هكذا في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٣٠٤) للولي العراقي، وفي طبعة دار الفكر للأم (٤/ ١٧٩) سقط يتضح من المقارنة.

نص عليه».

قال البلقيني في التدريب (٤/ ٢١٩): «المتحيز إلىٰ الفئة البعيدة لا يشارك الغانمين فيما يغنمونه بعد المفارقة، ولا المتحيز إلىٰ الفئة القريبة علىٰ النص، خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله».

ونقل العراقي في التحرير (٣/ ٣٠٤) عن البلقيني أنه قال: «وظاهر النص أنه في المتحيز إلىٰ فئة قريبة؛ لقوله: (ثم عادوا) وإذا حمل علىٰ الأعم .. حصل لنا العمل بظاهر النص، ونقل في "الروضة» وأصلها النص في المتحيز إلىٰ البعيدة، وليس كما ذكراه».

[١١٩]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٧١ط. الحداد): «أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره».

ما ذكره النووي هنا تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٤٨٦) في قوله: «... وإلا إذا غنمناها وخفنا أن يستردوها ويعظم الأمر».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٤٢٣): «وإذا خفنا أنهم يأخذون الخيول ويقاتلون عليها، ويشتد الأمر، يجوز إتلافها»، وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ٢٥٨).

○ قال أبو عبد الباري:

ما جزم به النووي تبعا للرافعي مخالف لنصوص الشافعي في الأم وغيره، والتي فيها المنع مطلقا.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٥٩٥-٥٩٦ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا حاصرنا المشركين فظفرنا لهم بخيل أحرزناها أو لم نحرزها، أو نبا بنا عنهم، فرجعت علينا، واستلحمنا وهي في أيدينا، أو خفنا الدرك وهي في أيدينا، ولا حاجة لنا بركوبها، إنما نريد غنيمتها، أو بنا حاجة إلىٰ ركوبها، أو كانت معها ماشية ما كانت، أو نحل أو ذو روح من أموالهم، مما يحل للمسلمين اتخاذه لمأكلة، فلا يجوز عقر شيء منه،ا ولا قتله بشيء من الوجوه، إلا أن نذبحه كما قال أبو بكر: «لا تعقروا شاة، ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه»[(١)].

فإن قال قائل: فقد قال أبو بكر«ولا تقطعوا شجرا مثمرا» فقطعته.

---

(١) رواه مالك في الموطأ (رقم ١٦٢٧ رواية يحيىٰ)، وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٣٣١٢١ ط. الحوت) عن محمد بن فضي كلاهما عن يحيىٰ بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر به. وهو معضل.
ورواه البيهقي في سننة (رقم ١٨١٢٥) من طريق ابن المبارك عن يونس الأيلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر به.
وهو منقطع بين ابن المسيب وأبي بكر الصديق.

قيل: فإنا قطعناه بالسنة، واتباع ما جاء عن رسول الله ﷺ، وكان أولىٰ بي وبالمسلمين، ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة، ولا مثله من أصحاب رسول الله ﷺ فيما حفظت، فلو لم يكن فيه إلا اتباع أبي بكر كانت في اتباعه حجة، مع أن السنة تدل علىٰ مثل ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم.

فإن قال قائل: ما السنة؟.

قلنا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولىٰ بني عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله ﷻ عن قتله»، قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها».

وقد نهىٰ رسول الله ﷺ عن المصبورة، ووجدت الله ﷻ أباح قتل ذوات الأرواح من المأكول بواحد من معنيين:

أحدهما: أن تذكىٰ فتؤكل إذا قدر عليها.

والآخر: أن تذكىٰ بالرمي إذا لم يقدر عليها.

ولم أجده أباح قتلها لغير منفعة، وقتلها لغير هذا الوجه عندي محظور.

فإن قال قائل: ففي ذلك نكايتهم وتوهين وغيظ.

قلنا: قد يغاظون بما يحل فنفعله، وبما لا يحل فنتركه.

فإن قال: ومثل ما يغاظون به فنتركه؟.

قلنا: قتل نسائهم وأولادهم، فهم لو أدركونا وهم في أيدينا لم نقتلهم، وكذلك لو كان إلىٰ جنبنا رهبان يغيظهم قتلهم لم نقتلهم».

وفي الأم أيضا (٥/ ٦٣٣-٦٣٤ ط. د. رفعت فوزي): «قلت للشافعي ﷺ: أفرأيت ما ظفر المسلمون به من ذوات الأرواح من أموال المشركين من الخيل والنحل وغيرها من الماشية، فقدروا علىٰ إتلافه قبل أن يغنموه، أو غنموه فأدركهم العدو فخافوا أن يستنقذوه منهم، ويقووا به علىٰ المسلمين، أيجوز لهم إتلافه بذبح، أو عقر، أو تحريق، أو تغريق، في شيء من الأحوال؟.

قال الشافعي ﷺ: لا يحل عندي أن يقصد قصده بشيء يتلفه، إذا كان لا راكب عليه.

فقلت للشافعي: ولم قلت، وإنما هو مال من أموالهم، لا يقصد قصده بالتلف؟

قال الشافعي ﷺ: لفراقه ما سواه من المال، لأنه ذو روح يألم بالعذاب، ولا ذنب له، وليس كما لا روح له يألم بالعذاب من أموالهم، وقد نهي عن ذوات

الأرواح أن يقتل ما قدر عليه منها إلا بأوحىٰ القتل لتؤكل[(١)]، وما امتنع بما نيل من السلاح لتؤكل، وما كان منها عدوا وضارا للضرورة.

قلت للشافعي: اذكر ما وصفت.

فقال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولىٰ عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله ﷻ عن قتلها».

قال الشافعي ﷺ: فلما كان قتل ذوات الأرواح من البهائم محظورا إلا بما وصفت، كان عقر الخيل والدواب التي لا ركبان عليها من المشركين داخلا في معنىٰ الحظر، خارجا من معنىٰ المباح، فلم يجز عندي أن تعقر ذوات الأرواح إلا علىٰ معنىٰ ما وصفت».

وقال أيضا في الأم (٥/ ٧٠٦ ط. د. رفعت فوزي) «ولا بأس بقطع الشجر المثمر وغير المثمر، وتخريب العامر وتحريقه من بلاد العدو، وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مال وطعام لا روح فيه، لأن رسول الله ﷺ حرق نخل بني النضير وأهل خيبر وأهل الطائف وقطع، فأنزل الله ﷻ في بني النضير

---

(١) في طبعة دار الفكر «إلا بالذبح لتؤكل» وهو أوضح معنىٰ.

﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا﴾ [الحشر: ٥] الآية.

فأما ما له روح فإنه يألم مما أصابه، فقتله محرم إلا بأن يذبح فيؤكل، ولا يحل قتله لمغايظة العدو، لأن رسول الله ﷺ قال: «من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عنها»، قيل: وما حقها يا رسول الله؟ قال: «يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به»، ولا يحرق نحلا ولا يغرق، لأنه له روح«، ومثله في الأم (٨/ ٦٣١-٦٣٣ ط. د. رفعت فوزي).

وفي مختصر المزني (٢/ ٥٠٥ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ولو أدركونا وفي أيدينا خيلهم وماشيتهم .. لم يحل قتل شيء منها ولا عقره، إلا أن يذبح لمأكله، ولو جاز ذلك لغيظهم بقتلهم طلبنا غيظهم بقتل أطفالهم، ولكن لو قاتلونا علىٰ خيلهم فوجدنا السبيل إلىٰ قتلهم بأن نعقر بهم فعلنا؛ لأنها تحتهم أداة لقتلنا، وقد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد، فاكتسعت به فرسه، فسقط عنها، فجلس علىٰ صدره ليذبحه، فرآه ابن شعوب فرجع إليه فقتله، واستنقذ أبا سفيان من تحته».

وفي مختصر البويطي (ص ٩٥٢ ط. القره داغي): «ولا تغرق النحل ولا تحرق، لأنها ذات أرواح، ولا تعرقب بهيمة مأكولة اللحم وغير مأكولة، لأن ذلك تعذيب، ولكن تذبح».

وفي مختصر البويطي (ص ١٠٧٣، ١٠٧٤): «قال مالك: لا بأس بعقر الدواب في أرض العدو إذا كثرت عليهم.

وقال الشافعي: لا يعرقب بهيمة، لأن النبي ﷺ قال: «من قتل عصفورا بغير حق سأله الله أي حوسب به، ونهي رسول الله ﷺ أن تصبر البهائم، وقال أبو بكر: لا تعقر شاة أو بعير إلا لمأكلة».

وهذه النصوص صريحة في المنع من إتلاف الحيوان وإن خفنا رجوعه إليهم، وعلم من ذلك أن الذي رجحه في «المنهاج» مخالف لنصوص الإمام الشافعي الكثيرة.

وهذا هو الذي عزاه ابن المنذر في الإشراف (٤/ ٣٠) للشافعي.

وهو الذي مشىٰ عليه الماوردي في الحاوي (١٤/ ١٩٠) فإنه نقل قول الشافعي ثم قال: «وهذا صحيح إذا غنمنا خيلهم ومواشيهم ثم أدركونا ولم نقدر علىٰ دفعهم عنها جاز تركها عليهم، ولم يجز قتلها وعقرها طلبا لغيظهم، أو قصدا لإضعافهم». وتابعه الروياني في البحر (١٣/ ٢٤٩).

وقال أبو إسحاق الشيرازي في «التنبيه» (ص ٢٣٤): «ولا يجوز قتل البهائم إلا إذا قاتلوا عليها».

وكذلك الجويني في نهاية المطلب (١٧/ ٤٦٣) فقال: «وإن أدركونا، وفي

أيدينا نساؤهم وصبيانهم، وعلمنا أنهم يستردونها، فلا يجوز لنا أن نقتلهم لنغيظهم، وفي مثل هذا المقام، تحرق الأموال، ويقطع النخيل، ولا نبالي.

ثم قال الأئمة: كما لا يحل لنا قتل النساء والولدان إذا أدركونا، فكذلك لا يحل لنا قتل البهائم رعاية لحرمة الروح بخلاف الأموال والأشجار المثمرة وغير المثمرة، ويجوز عقر الفرس تحت الكافر؛ فإنه قد لا نتوصل إلىٰ الكافر إلا بذلك، والفرس أداته وآلته، والأخبار في عقر الأفراس تحت الأبطال مشهورة».

وقال ابن الرفعة في الكفاية (١٦/ ٤٥٤): «ولا فرق في ذلك بين ألا يقع في أيدينا، أو يقع ويخشىٰ أن ينزع، أو تعذر سوقها ونقلها إلىٰ دار الإسلام، كما ذكره أبو الطيب وغيره، وهذا بخلاف ما ليس بحيوان؛ فإنا إذا تعذر علينا حمله أو خشينا أخذه أتلفناه».

ونبه علىٰ ذلك غير واحد من شراح المنهاج، وذكروا أن ما قرره النووي هنا مخالف لنصوص الإمام الشافعي.

قال الأذرعي في قوت المحتاج (٩/ ٣٥٥): «اعلم أن الشافعي لم يستثن هذه الصورة، بل كلامه مصرح بأنه لا يجوز إتلافها إلا في الحالة السابقة، وللأكل فقط...»، ثم ذكر نص الشافعي ونقل عن الدارمي من الشافعية أنه قال: وإذا أدركونا وفي أيدينا خيولهم ومواشيهم لم يحل قتلها إلا لمأكله».

ثم قال الأذرعي: وهذه طريقة العراقيين من أصحابنا، وهي ظاهر نص «المختصر» أو نصه».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٢٢٠): وأما الذي غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره، فإنا نذبحه للأكل، إن كان مأكولا، وإن لم يكن مأكولا لم نذبحه.

وإن كان مأكولا ولم نتمكن من ذبحه لم نتلفه بغير الذبح، ولو خفنا رجوعه إليهم وضرره.

هذا مذهب الشافعي الذي ذكره في كتبه، وجرىٰ عليه أصحابه، وما وقع في «المنهاج» تبعا لأصله مما يخالف ذلك ليس بمعتمد».

[١٢٠] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٧٢ ط. الحداد): «ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين، ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل، ومنٍّ، وفداء بأسرىٰ، أو مال، واسترقاق».

ما ذكره النووي هنا تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٤٨٣) ولفظه: «والرجال الكاملون يتخير الإمام فيهم بين القتل والمنّ بتخلية سبيلهم، والفداء بالرجال والمال أو الاسترقاق، يختار منها ما فيه حظ المسلمين بالاجتهاد».

وظاهر هذه العبارة يحتمل أن اختيار الأحظ واجب علىٰ الإمام، وقد صرح

بذلك الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٤٨٠) فقال: «ولا يجوز للحاكم أن يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والاسترقاق والسبي والمن والفداء».

وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ٢٥١) فقال: «وليس هذا التخيير للتشهي، بل يلزم الإمام أن يجتهد ويفعل من هذه الأمور الأربعة ما هو الحظ للمسلمين».

وانتصر له التاج السبكي في ترشيح التوشيح (ص ٥٨٩).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره الشيخان هنا من الوجوب مخالف لظاهر عبارة الشافعي التي تفيد الاستحباب.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٦١٦ ط. د. رفعت فوزي): «وقد وصفنا أن للإمام في الأسارىٰ الخيار في غير هذا الكتاب، وأحب أن يكون علىٰ النظر للإسلام وأهله، فيقتل إن كان ذلك أوهن للعدو، وأطفأ للحرب، ويدع إن كان ذلك أشد لنشر الحرب، وأطلب للعدو علىٰ نحو ما أشار أنس علىٰ عمر».

فقوله (وأحب) يدل علىٰ الاستحباب، ولهذا قال البلقيني في التدريب (٤/ ٢٢٠): «ويفعل الأحظ للمسلمين استحبابا من قتلٍ، ومنٍّ، وفداءٍ بأسرىٰ مسلمين، أو مال، واسترقاق، فإن خفي الأحظ اختار ما شاء تفريعا علىٰ النص أن فعل الأحظ مستحب كما تقدم».

وقال: كيف يلزم هذا وأبو عزة إنما نزله النبي ﷺ لبناته، وأخذ عليه عهدًا ألَّا

يعود لقتاله، وليس للمسلمين في ذلك حظ» كما في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٣٠٨).

وقصة أبي عزة الجمحي، ذكرها الشافعي في الأم (٥/ ٥٧٥-٥٧٦ ط. د. رفعت فوزي) فقال: «وكان من الممنون عليهم بلا فدية أبو عزة الجمحي، تركه رسول الله ﷺ لبناته، وأخذ عليه عهدا أن لا يقاتله، فأخفره وقاتله يوم أحد، فدعا رسول الله ﷺ أن لا يفلت، فما أسر من المشركين رجلا غيره، فقال: يا محمد امنن علي، ودعني لبناتي، وأعطيك عهدا أن لا أعود لقتالك، فقال النبي ﷺ: «لا تمسح علىٰ عارضيك بمكة تقول: قد خدعت محمدا مرتين، فأمر به فضربت عنقه»[(١)].

[١٢١]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٧٤ ط. الحداد): «لا عتيق مسلم، وزوجته علىٰ المذهب».

رجح النووي هنا تبعا للمحرر التفريق بين زوجة المسلم الحربية، وزوجة الحربي إذا أسلم دونها فوقعتا في الأسر، فمنع استرقاق الأولىٰ دون الثانية كما في قوله: «لا زوجته علىٰ المذهب».

---

(١) ضعيف: رواه البيهقي في الكبرىٰ (رقم ١٨٠٢٩) والمعرفة (رقم ١٨٠٨٣) من طريق محمد بن عمر الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب به. والواقدي متروك الحديث، وبه أعله الألباني في الإرواء (رقم ١٢١٥).

قال الرافعي في المحرر (ص ١٤٨٤): «والأظهر أنه لا يجوز استرقاق معتق المسلم، ولا زوجته الحربية».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكراه هنا من منع استرقاق زوجة المسلم الحربية إذا وقعت في الأسر مخالف لنصّ الشافعي في هذه المسألة.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٦٨٣ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يجوز أن يكون مال المسلم مغنوما بحال، فأما ولده الكبار وزوجته فحكمهم حكم أنفسهم، يجري عليهم ما يجري علىٰ أهل الحرب من القتل، والسباء، وإن سبيت امرأته حاملا منه، لم يكن إلىٰ إرقاق ذي بطنها سبيل، من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه، ولا يجري السباء علىٰ مسلم».

وقال الشافعي في الأم (٩/ ٢٧٤ ط. د. رفعت فوزي) فيمن خرج مستأمنا ثم أسلم في دار الإسلام فظهر المسلمون علىٰ ماله وأولاده وزوجاته: «وكل بالغ من ولده وزوجته يسبىٰ، لأن حكمهم حكم أنفسهم ، لا حكمه».

فهذان النصان للشافعي صريحان في المسألة، وما ذكروه من خلافه فهو مخرج من منع استرقاق معتقه، والصواب تقرير النصين في موضعهما.

قال الرافعي في الشرح الكبير (١١/ ٤١٣-٤١٤): «هل يعصم إسلام الكافر قبل الأسر زوجته عن الاسترقاق؟.

فيه وجهان، ويقال: قولان: منصوص، ومخرج ... «إلىٰ أن قال: والظاهر ما نص عليه في الصورتين، وإن قدر الخلاف، هكذا قاله الجمهور»، وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ٢٥٣).

وهو قول البغوي في التهذيب (٥/ ١٥٢) ولفظه: «ولو تزوج المسلم حربية، أو حربي أسلم، وله زوجة كافرة-: هل تُسبىٰ زوجته؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تسبىٰ؛ كما لا يسبي عتيقه.

والثاني - وهو الأصح، والمنصوص عليه-: تسبىٰ وينفسخ النكاح؛ لأن النكاح يبطل بأسباب لا يبطل بها الولاء».

وقال العمراني في البيان (١٢/ ١٦٨): «وإن تزوج المسلم حربية، أو تزوج الحربي حربية فأسلم، فالمنصوص: أنه يجوز سبيها واسترقاقها؛ لأنه لما جاز أن يطرأ علىٰ هذا النكاح الفسخ بالعيوب جاز أن يكون هذا السبي والاسترقاق سببًا لفسخه».

وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه (١٦/ ٤٠٨): «لا يمنع إسلامه استرقاق

زوجته علىٰ المنصوص في«سير» الواقدي والأوزاعي كما قاله البندنيجي، وهو الذي صححه القاضي أبو الطيب، وجزم به الماوردي».

وقال الأذرعي في القوت (٩/ ٣٦٢): «أما الزوجة الحربية فإنه تبع في الترجيح فيها «المحرر»، ويقتضي كلام «الشرحين» و«الروضة» أن الصحيح جواز استرقاقها كزوجة من أسلم قبل الظفر به كما سبق، وهو قضية كلام «النهاية» وغيره».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٢٢٢): «والمذهب المعتمد أنه لا فرق بين زوجة من أسلم قبل الأسر، ومن كان مسلما وله زوجة حربية وقعت في الأسر، في أن كلا منهما لا يعصم إسلامه زوجته من الحكم برقها بمجرد السبي، خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله».

وقال ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٤/ ٢٨٤): «وقال الزركشي: إنه الصواب، وقد نقله في «البحر» و«البيان» عن النص، وجزم به جمهور العراقيين، منهم الجرجاني».

وقال الهيتمي في تحفة المحتاج (٩/ ٢٥١): «والمعتمد فيها الجواز، كزوجة حربي أسلم».

ومما تقدم يتبين أن المعتمد المنصوص للشافعي هو جواز استرقاق زوجة المسلم الحربية إذا وقعت في السر، ولا يمنع كون زوجها مسلما من استرقاقها علىٰ المنصوص.

وأما القول الثاني الذي رجحه في المحرر وتبعه في المنهاج، فهو مخرج من منع استرقاق مُعتَق المسلم، ولهذا ذكر غير واحد الفرق بين الولاء والنكاح(١).

[١٢٢]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٨٢ ط. الحداد): «ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب ، وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشرط».

ما ذكره النووي هنا من عدم دخول ما مع الكافر من الأهل والمال في الأمان المطلق تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٤٩٤-١٤٩٥) ولفظه: «ولا يتعدىٰ

---

(١) عدم استرقاق معتق المسلم: قال الشافعي في الأم (٩/ ٣٥٦ ط. د. رفعت فوزي):« ولو كان العبد كافرا فيعتق بكتابة المسلم، ثم سباه المسلمون لم يكن رقيقا؛ لأن له أمانا من مسلم بعتقه إياه، ولو كان أعتقه كافر بكتابة، أو غير كتابة، فسباه المسلمون، كان رقيقا».

وفي مختصر المزني (٢/ ٧٥٨ ط. الداغستاني): «قال: ولو كان السيد مسلما، فالكتابة ثابتة، فإن سبي لم يكن رقيقا؛ لأن له أمانا من مسلم بعتقه إياه».

فخرَّج بعض الأصحاب من هذا عدم استرقاق زوجة المسلم الحربية إذا وقعت في الأسر، والمنصوص كما تقدم جواز استرقاقها، والتفريق بين الولاء والنكاح، وهو المذهب.

الأمان إلىٰ ما خلفه الكافر في دار الحرب من الأهل والمال، وما معه منها إن وقع التعرض له يتبع الشرط، وإلا فوجهان: رُجِّح منهما منع التعدي».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي هنا تبعا للرافعي في المحرر ضعيف مخالف لنصوص الإمام الشافعي، وما صححه الرافعي والنووي في الروضة.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٦٨٣ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا قدم الحربي دار الإسلام بأمان فمات، فالأمان لنفسه وماله، ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء، وعلىٰ الحاكم أن يرده إلىٰ ورثته حيث كانوا»[(١)].

وقال الشافعي في الأم (٥/ ٤٩٢ ط. د. رفعت فوزي): «وإن عقد لهم الأمان علىٰ دمائهم، لم يؤخذ من أموالهم شيء إن دخلوا بأموال، إلا بشرط علىٰ أموالهم، أو طيب أنفسهم».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٢٤ ط. القره داغي): «ومن أعطي أمانًا علىٰ نفسه، فهو آمن علىٰ نفسه وماله».

وهذه النصوص صريحة في أن الأمان يشمل ماله كنفسه، فهو المعتمد.

---

(١) وذكره البيهقي في تفسير الشافعي (٣/ ١٣٧٧).

وقال الشافعي في الأم (٥/ ٦٠١-٦٠٢ و ٧١٠-٧١١ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا دخل الذمي أو المسلم دار الحرب مستأمنا، فخرج بمال من مالهم يشتري لهم شيئا، فأما مع المسلم فلا نعرض له، ويرد إلىٰ أهله من أهل الحرب، لأن أقل ما فيه أن يكون خروج المسلم به أمانا للكافر فيه.

وأما مع الذمي: قال الربيع: ففيها قولان:

أحدهما: أنا نغنمه، لأنه لا تكون كينونته معه أمانا له منا، لأنه إنما روي: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعىٰ بذمتهم أدناهم»، فلا يكون ما مع الذمي من أموالهم أمانا لأموالهم، وإن ظن الحربي الذي بعث بماله معه أن ذلك أمان له، كما لو دخل حربي بتجارة إلينا بلا أمان منا، كان لنا أن نسبيه ونأخذ ماله، ولا يكون ظنه بأنه إذا دخل تاجرا أن ذلك أمان له ولماله بالذي يزيل عنه حكما.

والقول الثاني: أنا لا نغنم ما مع الذمي من مال الحربي، لأنه لما كان علينا أن لا نعرض للذمي في ماله، كان ما معه من مال غيره له أمان مثل ماله، كما لو أن حربيا دخل إلينا بأمان، وكان معه مال لنفسه، ومال لغيره من أهل الحرب، لم نعرض له في ماله لما تقدم له من الأمان، ولا في المال الذي معه لغيره، فهكذا لما كان للذمي أمان متقدم لم يتعرض له في ماله، ولا في المال الذي معه لغيره

مثل هذا سواء، والله نسأله التوفيق برحمته، وكان آخر القولين أشبه إن شاء الله تعالىٰ».

هكذا ذكره الربيع، فحكىٰ في المسألة قولين، وقد نوزع في ذلك، ووهَّمه بعض أئمة أصحابنا، وقالوا ليس في المسألة عن الشافعي قولان، وإنما هو قول واحد، هو الثاني[(١)].

وقد جزم الرافعي والنووي بما في النص خلافا لما في «المنهاج» و«المحرر».

قال الرافعي في فتح العزيز (١١/ ٤٧٥): «إذا دخل الكافر دار الإسلام بعقد أمان أو ذمة، كان ما معه من المال والأولاد في أمان، فإن شرط الأمان في المال والولد، فهو زيادة تأكيد».

وتبعه النووي فقال في الروضة (١٠/ ٢٨٩): «المسألة التاسعة: إذا دخل

---

(١) قال العمراني في البيان (١٢/ ٣٣١): حكىٰ الربيع فيه قولين:
أحدهما: يكون الأمان لذلك المال، كما لو كان دفعه إلىٰ مسلم.
والثاني: لا يكون له أمان؛ لأن أمان الذمي لا يصح.
قال أصحابنا: هذا القول من كيس الربيع، بل يجب رده إلىٰ الحربي قولا واحدا؛ لأن الذمي وإن لم يصح أمانه إلا أن الحربي قد اعتقد صحة الأمان لماله، فوجب رده إليه، كما لو دخل الحربي بأمان صبي».

كافر دار الإسلام بأمان أو ذمة، كان ما معه من المال والأولاد في أمان، فإن شرط الأمان في المال والأهل، فهو تأكيد».

وهذا هو الصحيح الموافق لنص الشافعي، وهو الذي رجحه الإسنوي في المهمات (٨/ ٤٣٠) فقال: «الراجح الدخول مطلقًا، فقد جزم به الرافعي في أثناء الباب قبيل قوله: الثانية: المستأمن فقال: «إذا دخل الكافر دار الإسلام بعقد أمان أو ذمة كان ما معه من المال والأولاد في أمان، فإن شرط الأمان في المال والولد فهو زيادة تأكيد. هذا لفظه.

وذكر أيضًا مثله في آخر كتاب الجزية فقال في الكلام علىٰ الذمي إذا انتقض عهده: «وهل يبطل أمان النساء والصبيان ببطلان أمانهم؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم كما كانوا تبعا في ثبوت الأمان[1]. انتهىٰ.

وقد أطلق النووي تصحيح الموضع الأول في أصل «الروضة» ذاهلًا عن ما ذكره الرافعي بعد ذلك ووافقه عليه، فوقع في صريح التناقض، وعبر في «الشرح الصغير» و«المحرر» بقوله: فيه وجهان، رجح منهما منع الدخول ولا تصريح فيه

---

(١) قال في الروضة (١٠/ ٣٣١): «وهل يبطل أمان النساء والصبيان تبعا كما يثبت تبعا؟ وجهان: أصحهما: لا، إذا لم توجد منهم خيانة ناقضة، فعلىٰ هذا لا يجوز سبيهم، ويجوز تقريرهم في دارنا».

أيضًا، لكن صرح في «المنهاج» بتصحيحه».

وقال الأذرعي في القوت (٩/ ٤٠٧) بعد مناقشة وذكر بعض نصوص الشافعي: «وبالجملة فكون أمان الحربي أمانا لماله الذي هو معه هو المذهب، فظاهر نصوصه في «سير الواقدي» وغيرها من «الأم» في مواضع، وعليه جرىٰ العراقيون».

وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب (٣/ ٣٣٠): «فصل: إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان في تجارة أو رسالة ثبت له الأمان في نفسه وماله، ويكون حكمه في ضمان النفس والمال وما يجب عليه من الضمان والحدود حكم المهادن، لأنه مثله في الأمان، فكان مثله فيما ذكرناه».

وقال القفال الشاشي في الحلية (٧/ ٧٢٤): «فإن دخل حربي إلىٰ دار الإسلام بأمان في تجارة، أو رسالة، ثبت الأمان له في نفسه وماله».

وقال العمراني في البيان (١٢/ ٣٢٨): «إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان، فإن الأمان ينعقد له ولماله وأولاده الصغار؛ لأن الأمان يقتضي الكف عن ذلك، فإن عقد الأمان لنفسه وماله وأولاده الصغار.. كان ذلك تأكيدا».

وبناء علىٰ ما تقدم فالصحيح المنصوص دخول ما معه من المال والأهل في الأمان المطلق، وإن ذكر فتأكيد وليس ذلك شرطا في الأمان والله أعلم.

[١٢٣]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٨٥ ط. الحداد): «وهو أجرة مثل، وقيل: قيمتها».

ما ذكره النووي من وجوب أجرة المثل تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٤٩٩) ولفظه: «وإن وجدنا الجارية مسلمة، فالظاهر وجوب البدل».

وقال قبل ذلك: «وبدلها أجرة المثل إن جعلنا الجعل مضمونا ضمان العقد، وقيمتها إن جعلناه مضمونا ضمان اليد، وفيه قولان كما في الصداق».

وقد قال في الصداق (ص ١٠٠٥): «وإذا أصدقها عينا، فتلك العين في يد الزوج مضمونة ضمان العقد أو ضمان اليد؟ فيه قولان: أصحهما الأول أي ضمان العقد، فيجب أجرة المثل».

○ قال أبو عبد الباري:

ما جعله النووي هنا وجها ضعيفا بقوله (وقيل: قيمتها)، هو المنصوص في الأم، فهو المعتمد.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٧٠١ ط. د. رفعت فوزي): «وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها فلا سبيل إليها، ويعطىٰ قيمتها، وإن ماتت عوض منها بالقيمة، ولا يبين في الموت كما يبين إذا أسلمت».

وبهذا اللفظ ذكره ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٢٧٥) والإسنوي في المهمات (٨/ ٤٣٣) والولي العراقي في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٣٣٣).

وهذا النص صريح في أن البدل الواجب إنما هو القيمة، وليس أجرة المثل كما جزم به النووي، وقد اختصره المزني اختصارا مخلا (٢/ ٥٠٧ ط. الداغستاني) فقال: «فإن كانت أسلمت قبل الظفر أو ماتت عوض، ولا يبين ذلك في الموت كما يبين إذا أسلمت».

فترك في اختصاره ذكر القيمة، وهو ثابت في الأم كما تقدم.

وقد جزم بالقيمة البغوي في التهذيب (٧/ ٤٨١) فقال: «فإن وجدها، وقد أسلمت نظر: إن أسلمت قبل الظفر لاتسلم إليه؛ لأن إسلامها يمنع استرقاقها، ويعطي قيمتها من بيت المال؛ لأن النبي ﷺ «صالح أهل مكة علىٰ أن يرد إليهم من جاءه منهم؛ فمنعه الله من رد النساء، وأمر برد مهورهن».

وقال الجويني في نهاية المطلب (١٧/ ٤٨٣): «ومما يتصل بتقاسيم المسألة أنا إذا وجدناها، ولكنها كانت مسلمة، فالذي ذهب إليه المحققون أنا نغرم قيمتها للدال، سواء أسلمت قبل الظفر أو بعده».

وقال الدميري في النجم الوهاج (٩/ ٣٨٠): «والموجود لعامة الأصحاب: وجوب القيمة لا جرم، جزم به صاحب «الحاوي الصغير»، وصححه في «التنجيز»، ونقله في «المهمات» عن النص، فهو المفتىٰ به، عكس ما في «المنهاج».

واعتمده جملة من شراح المنهاج كالهيتمي في التحفة (٩/ ٢٧٤) والرملي

في النهاية (٨/ ٨٤) والخطيب في المغني (٦/ ٥٨) والقليوبي في حاشيته (٤/ ٢٢٨).

[١٢٤]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٨٩ ط. الحداد): «فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته، أو كثيرا كيوم ويوم، فالأصح تلفيق الإفاقة، فإن بلغت سنة وجبت».

صحح النووي هنا أن الجنون المتقطع إذا كان كثيرا كأن يكون الجنون يوما والإفاقة يوما مثلا فتجب الجزية بالتلفيق، فإن بلغت مدة الإفاقة سنة وجبت وإلا فلا.

وهو تبع الرافعي في المحرر (ص ١٥٠٤) ولفظه: «وإن كان يجنّ ويفيق، فإن كان زمان جنونه يسيرا كالساعة في الشهر أخذت منه الجزية، وإن كثر كالتقطع يوما ويوما، فالأصح أن أيام الإفاقة تلتقط، فإذا تمت سنة أخذت الجزية».

وكذلك قال النووي في الروضة (١٠/ ٣٠٠): «وإن كثر بأن يقطع يوما ويوما، أو يومين، فأوجه:

أصحها: تلفق أيام الإفاقة، فإذا تمت سنة، أخذت الجزية».

وهو تابع البغوي في التهذيب (٧/ ٥٠٢) كعادته: «ومنهم من قال-: وهو الأصح، وبه قال أبو حنيفة-: تلفق أيام الإفاقة، فإذا بلغت سنة-: تؤخذ الجزية».

وذكر الجويني في النهاية (١٨/ ٢٨) أن الأصحاب اضطربوا في جزية من جنونه متقطع، ثم ذكر عدة وجوه منها ما رجحه الشيخان.

○ قال أبو عبد الباري:

هذا التفصيل بين الكثير والقليل مخالف لنصّ الشافعي، والذي نصّ عليه الشافعي في الأم عدم التفريق بين القليل والكثير ما لم يكن الجنون مطبقا.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٤١٣ ط. د. رفعت فوزي): «فأما من غلب علىٰ عقله أياما ثم أفاق، أو جن ثم أفاق، فتؤخذ منه الجزية؛ لأنه يجري عليه القلم في حال إفاقته، وليس يخلو بعض الناس من العلة يغرب بها عقله ثم يفيق، فإذا أخذت من صحيح ثم غلب علىٰ عقله، حسب له من يوم غلب علىٰ عقله، فإن أفاق لم ترفع عنه الجزية، وإن لم يفق رفعت عنه من يوم غلب علىٰ عقله».

وظاهر هذا النصّ وجوب الجزية إذا أفاق في السنة، ولم يفرق بين القليل والكثير.

وقال الشافعي في الأم (٥/ ٤٨٧ ط. د. رفعت فوزي): «فإن جن، فكان يجن ويفيق، لم ترفع الجزية، لأن هذا ممن تجري عليه الأحكام في حال إفاقته،

وكذلك إن مرض فذهب عقله أياما ثم عاد، إنما ترفع الجزية إذا ذهب عقله فلم يعد».

فقوله «إنما ترفع الجزية إذا ذهب عقله فلم يعُد» صريح في أن الجنون المتقطع لا يرفع الجزية عند الشافعي رحمه الله.

وهذا هو الذي حكاه ابن المنذر في الإشراف (٤/ ٤٤) عن الشافعي فقال: «واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان الشافعي يقول: «من غلب علىٰ عقله أياما، ثم أفاق، أو جن، فأفاق تؤخذ منه الجزية لأنه يجري عليه القلم في حال أفاقته».

وفي المعرفة للبيهقي (١٣/ ٣٧٩) عن الشافعي: «وكذلك لا جزية علىٰ مغلوب علىٰ عقله، من قبل أنه لا دين له يمسك به، وترك له الإسلام».

وفي مختصر المزني (٢/ ٥٢٨): «ولا مجنون حتىٰ يفيق»، وليس فيه أكثر من هذا، فكان اختصارا مخلا بالمعنىٰ.

وقد أقر أن هذا هو المنصوص الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه (ص ٢٣٨)، وابن الرفعة في الكفاية (١٧/ ٤٥) ثم قال: «وهذه طريقة الشيخ أبي حامد كما نقلها العمراني في «زوائده» عنه».

وذكر الأذرعي في القوت (٩/ ٤٣٧) أن وجوب الجزية ما لم يكن جنونه مطبقا هو المنصوص.

وعلىٰ نصّ الشافعي مشىٰ البلقيني في التدريب (٤/ ٢٣٩) فقال: «ولا جزية علىٰ من فيه رق، وصبي، ومجنون، فإن انقطع جنونه وجبت من غير تلفيق علىٰ النص».

[١٢٥]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٨٩ ط. الحداد): «ولو بلغ ابن ذمي، ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه، وإن بذلها عقد له، وقيل: عليه كجزية أبيه».

ما ذكره النووي هنا تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٠٤) ولفظه: «وإذا بلغ ولد الذمي ولم يختر بذل الجزية أبلغ بمأمنه، وإن اختاره فيحتاج إلىٰ استئناف عقد أو يكتفي بعقد أبيه؟ فيه وجهان، أظهرهما الأول».

وقال النووي في الروضة (١٠/ ٣٠٠): «وإذا بلغ ولد ذمي، فهو في أمان فلا يغتال، بل يقال له: لا نقرك في دار الإسلام إلا بجزية، فإن لم يبذل الجزية، ألحقناه بمأمنه، وإن اختار بذلها، فهل يحتاج إلىٰ استئناف عقد، أم يكفي عقد أبيه؟ وجهان، أصحهما عند العراقيين وغيرهم: الأول».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي هنا تبعا للرافعي من لزوم عقد جديد لمن بلغ من أولاد أهل الذمة مخالف لظاهر نصوص الإمام الشافعي:

قال الشافعي في الأم (٥/ ٤٧٤ ط. د. رفعت فوزي): «وعلىٰ أن من أنبت الشعر تحت ثيابه، أو احتلم، أو استكمل خمس عشرة سنة قبل ذلك، فهذه الشروط لازمة له إن رضيها، فإن لم يرضها فلا عقد له».

وقال الشافعي في الأم أيضا (٥/ ٤١٥ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا صالح القوم من أهل الذمة علىٰ الجزية، ثم بلغ منهم مولود قبل حولهم بيوم أو أقل أو أكثر، فرضي بالصلح سئل: فإن طابت نفسه بالأداء بحول قومه أخذت منه، وإن لم تطب نفسه فحوله حول نفسه؛ لأنه إنما وجب عليه الجزية بالبلوغ والرضا، ويأخذ منه الإمام من حين رضي علىٰ حول أصحابه، وفضل إن كان عليه من سنة قبلها، لئلا تختلف أحوالهم، كأنه بلغ قبل الحول بشهر، فصالحه علىٰ دينار كل حول، فيأخذ منه إذا حال حول أصحابه نصف سدس دينار، وفي حول مستقبل معهم دينارا، فإذا أخره أخذ منه في حول أصحابه دينار ونصف سدس دينار».

وفي مختصر البويطي (ص ٨٢٦ ط. القره داغي): «وإذا صالح الإمام أهل قرية علىٰ جزية وفيهم من لم يبلغ، فإذا بلغ فإن رضي بما فعلوا فذلك له، وإن لم يرض فذلك له، وبلغه الإمام أدنىٰ مأمنه وحاربه».

فهذه النصوص تدل علىٰ أن ولد الذمي إذا بلغ يكتفي بعقد أبيه في الذمة، فلا

يحتاج إلىٰ استئناف عقد جديد، إلا إذا لم يرض.

وعلىٰ هذا المعني تجري عبارات المزني في مختصره.

ففي مختصر المزني (٢/ ٥٢٨ ط. الداغستاني): « ولا تؤخذ من امرأة، ولا مجنون حتىٰ يفيق، ولا مملوك حتىٰ يعتق، ولا صبي حتىٰ ينبت الشعر تحت ثيابه، أو يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة سنة، فتلزمه الجزية كأصحابه».

وفيه أيضا بعد بسطور: « ومن بلغ وأمه نصرانية وأبوه مجوسي، أو أمه مجوسية وأبوه نصراني .. فجزيته جزية أبيه؛ لأن الأب هو الذي عليه الجزية، لست أنظر إلىٰ غير ذلك ».

وهذا هو الذي عزاه غير واحد من الأئمة لظاهر مذهب الشافعي.

قال الماوردي في الحاوي (١٤/ ٣٠٩): «والظاهر من مذهب الشافعي أنهم يلتزمون جزية آبائهم من غير استئناف عقد معهم، لأنهم خلف لسلفهم»، وتبعه الروياني في بحر المذهب (١٣/ ٣٥٧) وفيهما نسبة ما رجحه الشيخان لأبي حامد الإسفرائيني.

وقال الجويني في النهاية (١٨/ ٢٦): «فإذا بلغ الطفل، فقد ذكر العراقيون وصاحب التقريب في حق ولده إذا بلغ وجهين .... والوجه الثاني: أنا نكتفي

بعقد أبيه، وإذا بلغ استمر عليه حكم العقد غير أنه لم يكن مقامه معه مقابلا بغرم، والآن بعد ما استقل تجري عليه الذمة، من غير احتياج إلىٰ عقد، وظاهر النص يدل علىٰ هذا».

وقال الشاشي في الحلية (٧/ ٧٠٤): «وإن بلغ صبي استؤنف له عقد الذمة في أحد الوجهين، وعلىٰ الوجه الآخر: وهو ظاهر كلام الشافعي ﷺ أنه يلزمه جزية أبيه».

وفي النجم (٩/ ٣٩٦): «وادعي الإمام: أنه ظاهر النص، وقال في (الحاوي): إنه ظاهر مذهب الشافعي، وصححه القاضي حسين، ولأن أحدا من الأئمة لم يستأنف العقد للأولاد عند بلوغهم»[(١)].

وتبعه ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٤/ ٣٠٢).

[١٢٦]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٩٢ ط.الحداد): «فإن دفن نبش وأخرج».

أطلق النووي وجوب النبش هنا مطلقا، أي سواء تقطع أم لا، وتابع في ذلك

---

(١) وخالفهم الشيرازي فجعل الأول ظاهر نص الشافعي فقال في التنبيه (ص ٢٣٧): ومن بلغ من أولادهم استؤنف له عقد الذمة علىٰ ظاهر النص، وقيل: يؤخذ منه جزية أبيه».

الرافعي في المحرر (ص ١٥٠٧) ولفظه: «وإن دفن نبش قبره وأخرج».

وهو قول الإمام في نهاية المطلب (١٨/ ٦٤) ونصه: «ولو دفنه أهله علىٰ اختفاء في الحرم، فكما شعرنا به ننقله، وإن تفتت، جمعناه ونقينا الحرم منه».

وتبعه الغزالي في الوسيط (٧/ ٦٨) فقال: «ولو دفن نبش قبره، وأخرج عظامه، تطهيرا للحرم»، فتبعهما الرافعي في «المحرر» ثم النووي في «المنهاج».

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا الإطلاق مخالف لنص الشافعي ﷺ، فإنه قيَّد ذلك بما إذا لم يتقطع، وبه قال الجمهور والرافعي في الشرح الكبير والنووي في الروضة.

قال الشافعي في الأم (٤/ ١٨٨): «ولو دفن بها نبش ما لم يتقطع».

وهو قول الشيرازي في المهذب (٣/ ٣٢٠) ولفظه: «وإن تقطع ترك، لأن النبي ﷺ لم يأمر بنقل من مات فيه منهم ودفن قبل الفتح».

ونحوه في التهذيب للبغوي (٧/ ٥١٢) والبيان للعمراني (١٢/ ٢٩٥) والمحاملي في اللباب (ص ٣٧٦) والتدريب للبلقيني (٤/ ٢٤٠) والنجم الوهاج (٩/ ٤٠٢) وتحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ٣٤٢).

وقال النووي في الروضة (١٠/ ٣٠٩): «فإن دفن نبش وأخرج، فإن تقطع

ترك، وفي «البحر» وجه أنه تجمع عظامه إن أمكن وتخرج، وبهذا قطع الإمام، وبالأول قال الجمهور».

وهكذا قال في شرح مسلم (١١/ ٩٤) ولفظه: «فإن دخله في خفية، وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم يتغير، هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء»، وهو الذي عزاه ابن المنذر في الأوسط (٦/ ١٨) للشافعي.

[١٢٧]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٩٥ ط. الحداد): «ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا».

ظاهر عبارة النووي أنه لا حصر لعدد الضيفان، وتابع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٥١٢) ولفظه: «ويتعرض الإمام عند اشتراط الضيافة لعدد الضيفان، الفرسان منهم والرجالة».

وقد صرح بذلك في الروضة (١٠/ ٣١٤) فقال: «إن تساووا في الجزية تساووا في الضيافة، وإن تفاوتوا فاوت بينهم، فيجعل علىٰ الغني ضيافة عشرين مثلا، وعلىٰ المتوسط عشرة، والفقير إن قلنا باشتراطها عليه خمسة، وفي وجه يسوي بينهم في الضيافة، وإن تفاوتوا في الجزية، ولو شرط عدد الضيفان علىٰ جميعهم، وقال: تضيفون في كل سنة ألف مسلم، قال الروياني: يكفي ذلك، ثم

هم يوزعونها أو يتحمل بعضهم عن بعض».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره من عدم تحديد عدد الضيفان، وأن التقدير متروك للإمام مخالف لنصّ الشافعي في الأم، فإنه ذكر أن الغني يشارط عليه ضيافة ثلاثة إلىٰ ستة، والمتوسط إلىٰ ثلاثة، لا يزاد عليهم.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٤٧٥ ط. د. رفعت فوزي): «وعلىٰ الوسط أن ينزل كل من مر به رجلين وثلاثة، لا يزيد عليهم، ويصنع لهم ما وصفت، وعلىٰ الموسع أن ينزل كل من مر به ما بين ثلاثة إلىٰ ستة، لا يزيدون علىٰ ذلك ... ولا ضيافة علىٰ أحد أكثر مما وصفت».

وهذا النص صريح في أن عدد الضيفان لا يزيد علىٰ ثلاثة في حق المتوسط، وستة في حق الغني، وهو الصواب، وبه قال الأذرعي في القوت (٩/ ٢٦٢، ٢٦٣) والبلقيني في التدريب (٤/ ٢٤٢) وغيرهما.

وعلىٰ هذا النص يحمل ما جاء عن الشافعي مطلقا من غير تحديد لأكثر عدد الضيفان، ومن ذلك:

ففي مختصر البويطي (ص ٨٢٥ ط. القره داغي): «وإذا صالح علىٰ أكثر من

دينار وضيافة وغير ذلك فهو علىٰ ما صولحوا عليه، وفعل عمر عندنا علىٰ الصلح».

فأطلق هنا ولم يحدد عدد الضيفان في حق الموسر والمتوسط، وهو محمول علىٰ النص الصريح المتقدم.

وفي مختصر المزني (٢/ ٥٢٧ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: وإن صولحوا علىٰ ضيافة وصفت ثلاثا، وقال: «يضيف الموسر كذا، والوسط كذا».

فهذا النص في الأم (٥/ ٦٩٥ ط. د. رفعت فوزي) بعد النص المتقدم، وهو مختصر وبسطه في الموضع الأول، فجاء المزني علىٰ عادته، فنقل هذا الموضع المختصر، وترك الموضع الأول الصريح، وقد عدّ البيهقي مثل هذا الصنيع من أغلاط المزني علىٰ الشافعي كما تقدم أول الكتاب.

[١٢٨]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٢٩٨ ط. الحداد): «ولا يقرون علىٰ كنيسة كانت فيه في الأصح».

رجح النووي هنا عدم إقرار أهل الذمة علىٰ كنائسهم إذا فتحت البلاد عنوة، وكانت الكنائس قائمة قبل فتحها، وجعل ذلك الأصح من أقوال الأصحاب.

وهو تابع الرافعي في المحرر (ص ١٥١٦) ولفظه: «وأما التي فتحت عنوة،

فإن لم يكن فيها كنيسة لم يكن لهم بناؤها، وإن كانت، فالأصح: أنه لا يجوز تقريرهم عليها».

وقال في الروضة (١٠/ ٣٢٣): «وهل يجوز تقريرهم علىٰ الكنيسة القائمة؟ وجهان: أصحهما: لا، وبه قطع جماعة».

وهذا الذي قالاه هو اختيار الإمام في النهاية (١٨/ ٤٩-٥٠).

○ قال أبو عبد الباري:

ما صححه النووي تبعا للرافعي من منع إقرارهم علىٰ كنائسهم مخالف لنصّ الشافعي، فإنه أجاز ذلك.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٤٩٤ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كانوا بمصر للمسلمين لهم فيه كنيسة، أو بناء طائل كبناء المسلمين، لم يكن للإمام هدمها، ولا هدم بنائهم، وترك كلا علىٰ ما وجده عليه، ومنع من إحداث الكنيسة، ... ولا يجوز للإمام أن يصالح أحدا من أهل الذمة علىٰ أن ينزله من بلاد المسلمين منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا، إنما يصالحهم علىٰ ذلك في بلادهم التي وجدوا فيها، ففتحها عنوة أو صلحا، فأما بلاد لم تكن لهم فلا يجوز هذا له فيها». وبلفظه نقله ابن المنذر في الأوسط (١١/ ١٩) عن الشافعي.

وفي مختصر المزني (٢/ ٥٢٩ ط. الداغستاني): «وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة، أو بناء طائل لبناء المسلمين، لم يكن للمسلمين هدم ذلك، وترك علىٰ ما وجد، ومنعوا إحداث مثله.

وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة، وشرط هذا علىٰ أهل الذمة».

فجزم الشافعي هنا إقرارهم علىٰ ما كان لهم من الكنائس في بلادهم سواء فتحت عنوة أو صلحا.

وذكر الولي العراقي في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٣٥٤) عن الروياني في «الكافي» أنه قال: «وإن فتحها المسلمون عنوة، يجوز للإمام إقرار الكفار فيها باستطابة أنفس الغانمين، وإقرارهم علىٰ مالهم من البيع والكنائس من غير أن يحدثوا غيرها، كما فعل عمر ﷺ في أرض العراق، وغلط من قال بخلافه».

وقال الماوردي في الحاوي (١٤/ ٣٢١، ٣٢٢): «وأما القسم الثاني: وهو ما فتحه المسلمون عنوة من بلاد الشرك، فلا يجوز أن يصالحوا علىٰ استئناف بيع وكنائس فيها، فأما ما تقدم من بيعهم وكنائسهم، فما كان منها خرابا عند فتحها لم يجز أن يعمروه، لدروسها قبل الفتح، فصارت كالموات.

فأما العامر من البيع والكنائس عند فتحها، ففي جواز إقرارها عليهم إذا

صولحوا وجهان:

أحدهما: يجوز إقرارها عليهم لخروجها عن أملاكهم المغنومة، وهو الصحيح ولذلك أقرت البيع والكنائس في بلاد العنوة».

وتبعه الروياني في بحر المذهب (١٣/ ٣٧٢).

وفي فتاوىٰ التقي السبكي (٢/ ٤١١): «قال الرافعي ﷺ: وهل يجوز تقريرهم علىٰ الكنيسة القائمة؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز، لأن المصلحة قد تقتضي ذلك، وليس فيه إحداث ما لم يكن.

قلت: قال الشيخ أبو حامد: إن هذا هو الأصح، ووافقه صاحباه سليم والبندنيجي».

واختاره البلقيني في التدريب (٤/ ٢٤٣) فقال: «وما فتح عنوة لا يحدثونها فيها، ويقرون علىٰ كنيسة كانت فيه علىٰ المنصوص».





كتاب الصيد والذبائح

[١٢٩]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣١٥ ط. الحداد): «فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حلّ الجميع، وقيل: يحرم العضو».

ما ذكره النووي هنا تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٣٣) ولفظه: «وإن مات من تلك الجراحة ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن، وكذا العضو المبان في أصح الوجهين».

○ قال أبو عبد الباري:

ما جعله النووي تبعا للرافعي وجها ضعيفا بقوله «وقيل: يحرم العضو»، هو المعتمد الموافق لنص الشافعي ﷺ.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٦١٨ ط. د. رفعت فوزي): «ولا تعدو الضربة أو الرمية أن تكون ذكاة، والذكاة لا تكون علىٰ بعض البدن دون بعض، أو لا تكون ذكاة فلا يؤكل منه شيء، ولكنه لو أبان منه عضوا ثم أدرك ذكاته فذكاه لم يأكل العضو الذي أبان؛ لأن الضربة الأولىٰ صارت غير ذكاة، وكانت الذكاة في الذبح، ولا يقع إلا علىٰ البدن وما ثبت فيه منه ولم يزايله، وما زايله كان بمنزلة الميتة، ألا

ترىٰ أنه لو ضرب منه عضوا، ثم أدرك ذكاته فتركها لم يأكل منه شيئا؟ لأن الذكاة قد أمكنته، فصارت الضربة الأولىٰ غير الذكاة».

فبين الشافعي أن الضربة نوعان:

الأولىٰ: ضربة تقع موقع الذكاة، وهي الضربة المذففة، فيحل الصيد بها، لأن الذكاة لا تكون لبعض البدن دون بعض.

الثانية: ألا تقع موقع الذكاة فلا يحل بها الصيد أو بعضه، ولا يحل إلا بالذبح، وما أبين منه حيا فلا يحل أكله.

ثم صرح بأن العضو المبان لا تؤثر فيه الذكاة، وإنما تؤثر علىٰ البدن، وقد رجحه النووي في الروضة والمجموع خلافا للمنهاج.

قال النووي في الروضة (٣/ ٢٤٢): «ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن، ولم يتمكن من ذبحه، حل باقي البدن، ولم يحل العضو علىٰ الأصح لأنه أبين من حي، فهو كمن قطع ألية شاة ثم ذبحها، لا تحل الألية قطعا».

وقال في المجموع (٩/ ١١٧): «ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن ولم يتمكن من ذبحه حل باقي البدن وفي العضو وجهان، أصحهما: يحرم لأنه أبين من حي فهو كمن قطع ألية شاة ثم ذبحها فإنه لا تحل الألية».

وقوله هنا «وجهان» متعقب بما ذكرنا من النص عن الشافعي.

ولهذا جُعِل قوله (وقيل: يحرم العضو) من القيلات المعتمدة، وبما ذكرنا ونحوه تعقبه كثير من شراح المنهاج، وقد ذكرت شيئا من ذلك في «التوضيحات المسددة لمسائل القيلات المعتمدة».

[١٣٠] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣١٨ ط. الحداد): «... أو جرحه نصل وأثَّر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما حرم».

ذكر النووي هنا أن الصيد إذا جرحه النّصل وأثَّر فيه عرض النصل لم يحل أكله ما لم يذبح، وهو تبع في هذا الرافعي في المحرر (ص ١٥٣٦) ولفظه: «وكذا إذا مات بسهم أو بندقة، أو أثر فيه عرض السهم في مروره، وجرحه طرف من النصل فمات منهما».

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ١٧) وتبعه النووي في الروضة (٣/ ٢٤٤) وشرح المهذب (٩/ ١١٢)، وهذا مبني علىٰ اجتماع الحاظر والمبيح فيغلب الحاظر.

○ قال أبو عبد الباري:

الذي نص عليه الشافعي أن السهم إذا كان محددا، والغالب فيه أن يقتل بحده

وقد أصابه، أو كان في معنىٰ المحدد فيحل أكله، وإن أثر فيه عرض السهم.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٦١٠ ط. د. رفعت فوزي): «ولو حدد المعراض حتىٰ يمور موران السلاح، فلا بأس بأكله».

وقال فيه أيضا (٣/ ٦١٢ ط. د. رفعت فوزي): «ولو رمىٰ بعصا أو عود كان موقوذا، ولو خسق كل واحد منهما، فإن كان الخاسق منهما محددا يمور مور السلاح بعجلة السلاح أكل، وإن كان لا يمور إلا مستكرها نظرت، فإن كان العود أو العصا خفيفين كخفة السهم أكلت، لأنهما إذا خفا قتلا بالمور وإن أبطيا، وإن كانا أثقل من ذلك بشيء متباين لم يؤكل، من قبل أن الأغلب علىٰ أن القتل بالثقل فيكون موقوذا».

وقال في البويطي (ص ٩٢٨ ط. القره داغي): «وما خسق المعراض أو السهم أو الرمح الذي لا حديد فيه فقتل فكل».

وظاهر هذه النصوص جواز أكله إن كان محددا، أو في معنىٰ المحدد، وأن الضابط كونه جرحه وانهر به الدم، وإلا لم يجز لأنه من جنس الموقوذة، وبهذا أخذ البلقيني في التدريب وتصحيح المنهاج.

قال البلقيني في التدريب (٤/ ٢٥٨): «وإن جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم، فلا يحرم علىٰ المعتمد؛ لأنه إذا جرحه النّصل ثم مرَّ السَّهم وأثَّر فيه

عرضه، كان ذلك من ضرورة الرَّمي، فأشبه ما لو خرقه بالنَّصل، ونفذ السَّهم من ذلك الخرق، فإن مثل هذا لا يؤثر قطعًا».

وفي تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٣٨٥) عن البلقيني في تصحيح أنه قال: «وما ذكره الرافعي والنووي لم أقف عليه في كلام غيرهما، ونص «الأم» يقتضي خلافه».

وأما تخريج المسألة علىٰ اجتماع الحاظر والمبيح هنا فليس كذلك، لأن عرض السهم إذا خسق وأنهر الدم فهو مبيح وليس بحاظر، فلم يجتمعا، بل إن حصل الغرض وهو الجرح والخسق المهريق للدم جاز.

وهذا هو الموافق لحديث عدي بن حاتم في البخاري (رقم ٥٤٧٧) ومسلم (رقم ١٩٢٩) قال: «قلت: يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب المعلمة قال: كل ما أمسكن عليك. قلت: وإن قتلن، قال: وإن قتلن. قلت: وإنا نرمي بالمعراض، قال: كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل».

[١٣١] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٢٠ ط. الحداد): «ولو تحاملت الجارحة علىٰ صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر».

رجح النووي هنا حلَّ الصيد إذا قتلته الجوارح المعلمة بثقلها، وتابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٣٩) ولفظه: «وأنه إذا تحامل علىٰ الصيد وقتله

بضغطته يحل الصيد».

وقال الأذرعي وفي قوت المحتاج (١٠/ ٥٣): «وصحح الحل المحاملي في «المقنع»، وبه أجاب البندنيجي، ورجحه الإمام ووالده، والغزالي في «الخلاصة»، والروياني والموفق بن طاهر، وسكت الجمهور عن الترجيح، وادعىٰ في «شرح المهذب» أنه الأصح عند الأصحاب».

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحه النووي هنا تبعا لهؤلاء الأئمة مخالف لما اختاره الشافعي في البويطي، وقد حكىٰ القولين في الأم من غير ترجيح.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٦١٧ ط. د. رفعت فوزي): «وما نالته الكلاب والصقور والجوارح كلها فقتلته ولم تدمه، احتمل معنيين:

أحدهما: أن لا يؤكل حتىٰ يخرق شيئا، لأن الجرح ما خرق، وقد قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿ٱلْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤]».

والمعنىٰ الثاني: أن فعلها كله ذكاة، فبأي فعلها قتلت حل، وقد يكون هذا جائزا، فيكون فعلها غير فعل السلاح، لأن فعل السلاح فعل الآدمي، وأدنىٰ ذكاة الآدمي ما خرق حتىٰ يدمي، وفعلها عمد القتل، لا علىٰ أن في القتل فعلين: أحدهما ذكاة، والآخر غير ذكاة، وقد تسمىٰ جوارح لأنها تجرح، فيكون اسما

لازما، وأكل ما أمسكن مطلقا، فيكون ما أمسكن حلالا بالإطلاق، ويكون الجرح إن جرحها هو اسم موضوع عليها، لا أنها إن لم تجرح لم يؤكل ما قتلت».

وقد حكىٰ المزني في مختصره (٢/ ٥٤٨، ٥٤٩ ط. الداغستاني) القولين، ثم قال: «الأول: أولاهما به، قياسا علىٰ رامي الصيد أو ضاربه، أنه لا يؤكل إلا أن يجرحه».

وهذا الذي اختاره المزني هو الصواب، وقد جزم به الشافعي في البويطي.

قال في مختصر البويطي(ص ٩٢٨ ط. القره داغي): «وما قتلت الكلاب والفهود والبزاة والصقور إذا كانت كلها معلمة فلا بأس بأكله، وإن لم تدرك ذكاته، وكذلك كلب الحرث إذا كان معلما، إذا نيبت أو جرحت، فأما إذا صدمت فمات فلا تأكله».

قال الأذرعي في قوت المحتاج (١٠/ ٥٣): «وهذا القول اختاره ابن أبي عصرون في «مرشده» و«التنبيه».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٢٦٠): «فإن تحاملت عليه من غير جرح فقتلته بثقلها، لم يحل علىٰ المنصوص في البويطي المجزوم به، خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله».

وقال الدميري في النجم الوهاج (٩/ ٤٨٢): «وادعىٰ المزني أن هذا أولىٰ القولين، وصححه صاحب «المرشد»، وبه جزم في «البويطي»، والقولان في «الأم» من غير ترجيح».





كتاب الأضحية

[١٣٢]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٣٠ ط. الحداد): «قلت: ارتفاع الشمس فضيلة، والشرط طلوعها، ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين».

ما ذكره النووي من أن ارتفاع الشمس ليس شرطا، هو مما خالف فيه الرافعي في المحرر كما هو ظاهر، وهكذا قال في المجموع (٨/ ٣٨٧، ٣٨٩) والروضة (٣/ ١٩٩).

وما قاله مبني علىٰ قوله في المنهاج بأن الصلاة في أوقات النهي مكروه كراهة تنزيه كما تقدم في أول كتاب الصلاة، المسألة (رقم ٥) وذكرنا هناك اضطراب النووي في ذلك، وأن الصواب التحريم بنص الشافعي في الرسالة.

○ قال أبو عبد الباري:

وما ذكره مخالف لظاهر نصوص الشافعي في اشتراط ذلك.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٥٧٧ ط. د. رفعت فوزي): «ووقت الضحايا انصراف الإمام من الصلاة، فإذا أبطأ الإمام أو كان الأضحىٰ ببلد لا إمام به، فقدر ما تحل الصلاة، ثم يقضي صلاته ركعتين، وليس علىٰ الإمام إن أبطأ بالصلاة عن وقتها، لأن الوقت إنما هو وقت رسول الله ﷺ، لا ما أحدث بعده».

فبين هنا أن قدر الركعتين محسوب مما بعد زوال النهي عن الصلاة، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح.

وقال في الأم أيضا (٣/ ٥٨١ ط. د. رفعت فوزي): «وقت الأضحىٰ قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة، وذلك إذا برزت الشمس فيصلي ركعتين، ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضىٰ من النهار قدر هذا الوقت حل الأضحىٰ، وليس الوقت في عمل الرجال الذين يتولون الصلاة، فيقدمونها قبل وقتها، أو يؤخرونها بعد وقتها».

وقال في الأم (٢/ ٤٩٠ ط. د. رفعت فوزي): «يغدو إلىٰ الأضحىٰ قدر ما يوافي المصلىٰ حين تبرز الشمس، وهذا أعجل ما يقدر عليه».

وهذا صريح في اشتراط ارتفاع الشمس حتىٰ تحل الصلاة ويزول النهي، ثم مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين.

وفي مختصر المزني (٢/ ٥٥٦ ط. الداغستاني): «ولا وقت للذبح يوم الأضحىٰ إلا في قدر صلاة النبي ﷺ، وذلك حين حلت الصلاة، وقدر خطبتين خفيفتين، فإذا كان هذا القدر فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان».

ومراده بوقت حلّ صلاة العيد ما تقدم ونصه (١/ ١٧٦ ط. الداغستاني): «وأحب أن يكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة، وذلك حين تبرز فيه الشمس، ويؤخر الخروج في الفطر عن ذلك قليلا».

قال الماوردي في الحاوي (١٥/ ٨٥): «اختلف الفقهاء في أول وقت الأضحية علىٰ أربعة مذاهب:

أحدها: وهو مذهب الشافعي إن أول وقتها في الأمصار والقرىٰ للحاضر والمسافر واحد، وهو معتبر بوقت الصلاة لا بفعلها، فإذا طلعت الشمس وارتفعت حتىٰ خرجت عن كراهة التنفل بالصلاة ومضىٰ بعد ذلك قدر ركعتين وخطبتين دخل وقت النحر، وجاز ذبح الأضحية فيه سواء صلىٰ الإمام في المصر، أو لم يصل» وتبعه الروياني في البحر (٤/ ١٨٢).

وهو الذي قال به الفوراني، وأبو الطيب الطبري، والماوردي، والبندنيجي، والإمام، والقاضي حسين، وحكاه الروياني في البحر عن الشافعي في المبسوط كما قال ابن الرفعة في الكفاية (٨/ ٦٣).

وقال الأذرعي في القوت (١٠/ ٩٨): «وممن نص علىٰ اعتبار ارتفاع الشمس المحاملي في المقنع، وهو ما نقله الغزالي عن العراقيين، وعليه جرىٰ الروياني في الحلية، ومما نلقناه يظهر أن الجمهور علىٰ اعتبار ارتفاع الشمس وخروج وقت الكراهة كما صرحوا به».

وقال ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٤/ ٣٥٢): «قال الأَذْرَعي ومن تبعه: والصواب من حيث النقل: ما في «المحرر»، فإن الجمهور عليه، وحكاه في «البحر» عن نص الشافعي في «المبسوط»، وهو الراجح من حيث الدليل كما

قرره في «المطلب».

اعتراض وجوابه

فإن قيل: قال الشافعي في الأم (٢/ ٤٩٠ ط. د. رفعت فوزي): «وإن غدا الإمام حين يصلي الصبح، وصلىٰ بعد طلوع الشمس لم يُعِد، ولو صلىٰ قبل الطلوع أعاد، لأنه صلىٰ قبل وقت العيد».

فالجواب من وجهين:

الأول: أن هذا النص محمول علىٰ النصوص الأخرىٰ الكثيرة التي دلت علىٰ لزوم ارتفاع الشمس وزال وقت النهي.

الثاني: أن التحريم لا يستلزم البطلان، فلو قلنا: بصحة الصلاة في وقت النهي مع التحريم جاز، وأن الصحة مع التحريم لا تستلزم أن خلافه من باب الاستحباب.

[١٣٣] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٣١ ط. الحداد): «وإطعام الأغنياء لا تمليكهم».

ذكر النووي هنا المنع من تمليك الأغنياء لحم الأضحية، وتابع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٥٥١) ولفظه: «يجوز الأكل من أضحية التطوع، وإطعام الأغنياء منها، ولا يجوز تمليكهم».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ١٠٥): «ولا يجوز تمليك الأغنياء

للبيع، ويجوز تمليك الفقراء للبيع» وتبعه في الروضة (٣/ ٢٢٢).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي هنا من تحريم تمليك الأغنياء لحم أضحية مخالف لظاهر نص الشافعي المفيد للجواز.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٥٦٧ ط. د. رفعت فوزي): «وكل ما كان أصله تطوعا مثل الضحايا والهدايا تطوعا أكل منه، وأطعم، وأهدىٰ، وادخر، وتصدق، وأحب إليّ أن لا يأكل ولا يحبس إلا ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث».

وفي مختصر المزني (٢/ ٣٩٧ ط. الداغستاني): «وما كان منها تطوعا أكل منها؛ لقول الله جل وعز: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ﴾ [الحج: ٣٦]، وأكل رسول الله ﷺ من لحم هديه وأطعم، وكان هديه تطوعا».

وفي مختصر البويطي (ص ٩٢٤ ط. القره داغي): «وأحب إليّ أن يبقي ثلثا، ويتصدق بثلث، ويهدي ثلثا».

قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٤/ ٢٢٠): «وهذا مما أبداه شيخه من عنده، وفيه نظر، وما أطلقه غيره من جواز الإهداء إلىٰ الأغنياء ظاهره الهدية المفيدة للملك، الممكنة من تصرفات المالكين، لا الإطعام علىٰ وجه الضيافة، فإنه لا يسمىٰ هدية، وقد فصل الشافعي فيما نقلناه آنفًا من كلامه الإطعام من

الهدية، والهدية قربة، وهي بتأديه مقصود قربة الضحية أولىٰ من الأكل وأجدر، إلا أنا لم نجد في شيء من نصوص الكتاب والسنة للفظ الهدية ذكرًا».

و في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٤١٤) عن شيخه البلقيني أنه قال: «إنما ذكره الإمام من تفقهه، وظاهر نصوص الشافعي والأصحاب وعمل الناس في الأعصار والأمصار علىٰ خلافه»[(١)].

وقد سبقه لذلك الأذرعي في القوت (١٠/ ١٠٧) فقال: «وأحسب أصل هذا قول الإمام ... ثم ذكره، ثم قال: «وتبعه الغزالي والرافعي».

وأما منازعة الدميري في النجم (٩/ ٥١٧) والهيتمي في الفتاوىٰ الكبرىٰ (٤/ ٢٥٣) بأن الهدية هنا محمولة علىٰ الإباحة، وأنها ليست هدية التمليك في حق الأغنياء، فمردود من وجوه:

الأول: أن ذلك خلاف ظاهر اللفظ، ولا يصار إليه إلا لدليل، ولا دليل هنا إلا ما قاله الجويني تفقها من عنده.

---

(١) يشير البلقيني إلىٰ قول الجويني في النهاية (١٨/ ٢٠٠): «لو وهب من غني شيئا من الضحية هبة تمليك حتىٰ يتصرف فيه المتهب بالبيع وما يراه الملاك، فالذي يظهر لنا أن ذلك ممتنع، فإن الهبة ليست صدقة، والضحية ينبغي أن تكون مرددة بين التطعم والإطعام، وبين الصدقة، فكأن الأغنياء ضيفان الله علىٰ لحوم الضحايا، وللفقراء حظ من الصدقة علىٰ وجه، والضيف لا يوهب، ولكن يطعم».

الثاني: أن الفقراء يملكون بالإعطاء، وهو واحد، وإنما هذا اختلاف تسمية، وإلا فالحقيقة في الإعطاء والقبض واحدة.

الثالث: أن تبدل اليد كتبدل العين، فإذا قبضها المتملك تبدل حكمها كما في حديث بريرة، وقوله ﷺ: «هو عليها صدقة، ولنا منها هدية» رواه الشيخان.

وقد استدل الشافعي بهذا الحديث علىٰ هذا المعنىٰ في «الأم» (٩/ ٣٤٦ ط. د. رفعت فوزي).

[١٣٤]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٣٣ط. الحداد): «ولا تضحية عن الغير بغير إذنه».

ما ذكره النووي هنا من منع التضحية عن الغير بغير إذنه، تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٥٣) ولفظه: «ولا تجوز التضحية عن الغير بغير إذنه».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٧٩): «لو ضحىٰ عن الغير بغير إذنه، لم يقع عنه. قاله في «التهذيب»، وتبعه النووي في الروضة (٣/ ٢٠١).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره الشيخان هنا مخالف لظاهر نصوص الشافعي، فقد صحح التضحية عن الغير بدون إذنه، ولم يأت عنه شيء يخالف ذلك نعلمه.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٦٢٢ ط. د. رفعت فوزي): «وإن ضحىٰ بها عن

أحد فقال: تقبل من فلان، فلا بأس، هذا دعاء له، لا يكره في حال».

وقال في مختصر البويطي (ص ٩٢٢ ط. القره داغي): «ومن ذبح عن رجل، أو امرأة، أو صبي مطيق للذبح وإن لم يبلغ أجزأه».

أطلق الشافعي هنا الذبح عن الرجل والمرأة، ولم يشترط أن يكون ذلك بإذنه، وهو أعمّ من الذبح عن أهله، ويؤيده ذكر الصبي لأن إذنه غير معتبر.

وفي مختصر المزني (٢/ ٥٥٩): «ولو أن مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه، ضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا، وأجزأ عن كل منهما أضحيته وهديه» وهو في الأم (٣/ ٥٨٧، ٥٨٨ ط. د. رفعت فوزي).

وهذا النص ظاهر في أن كلا منهما ذبح بغير إذن صاحبه، فأجزأت عنه بالشرط المذكور، وهذا قريب من الآتي بعده أي في المنذورة المعينة.

قال الماوردي في الحاوي (٢/ ٥٥٩): «ومقدمة هذه المسألة أن يذبح رجل أضحية غيره بغير أمره فمذهب الشافعي أن ذبحها يجزئ عن قربة صاحبها يسلك بها بعده مسلك الضحايا، ويكون الذابح ضامنا لنقصان ذبحها».

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٥٨٧ ط. د. رفعت فوزي): «فإذا أوجب الرجل ضحية أو هديا، فذبحا عنه في وقتهما بغير إذنه، فأدركهما قبل أن يستهلك لحمها، أجزأتا معا عنه، لأنهما ذكاتان ومذبوحتان في وقت».

وهذا النص صريح في المنذورة المعينة، وقد صحح الشافعي هذه التضحية

عن الغير بغير إذنه، بشرط أن يدرك من لحمها شيئا قبل أن يستهلك.

قال النووي في الروضة (٣/ ٢٠١): «إذا ضحىٰ عن غيره بلا إذن، فإن كانت الشاة معينة بالنذر، وقعت عن المضحي، وإلا فلا، كذا قاله صاحب «العدة» وغيره، وأطلق الشيخ إبرهيم المروزي: أنها تقع عن المضحي».

❐ ويتلخص من مجموع النصوص المذكورة عن الشافعي أنه أجاز التضحية عن الغير بدون إذنه مطلقا كما في نص البويطي، وذكر جوازها في المنذورة المعينة كما في نص الأم والمزني، وهما موافقان للنص المطلق، ولم يأت نص - علمناه - عن الشافعي في المنع من ذلك، فالمعتمد جواز التضحية عن الغير بدون إذنه.

ويؤيد ذلك أن قياس قول الشافعي في الحج عن الغير بدون إذنه يقتضي ذلك، وتعليله بأن الفرق بين الحج وغيره من الصوم والصلاة بأن في الحج نفقة من المال، وليس ذلك في صوم ولا صلاة[1] دليل علىٰ صحة التضحية عن الغير، لأن فيها التصدق بالمال عنه.

---

(١) اختلاف الحديث (ص ٢١٥ تحقيق محمد أحمد عبد العزيز) والأم (٥/ ٢٥٨ ط. د. رفعت فوزي).

وروىٰ البخاري (رقم ٢٩٤، ٥٥٥٩) ومسلم (رقم ١١٩/ ١٢١١) عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ ضحىٰ رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر»، وبوب عليه البخاري بقوله«باب من ذبح ضحية غيره».

واحتج به أبو الحسن العبادي من أئمة الشافعية علىٰ جواز التضحية عن الغير مطلقا كما ذكر الإسنوي في المهمات (٦/ ٣٧٣، ٣٧٤)[(١)].

وروىٰ البخاري (رقم ١٧٠٩) من حديث عائشة ﵂ قالت: فدخل علينا يوم

---

(١) قال الرافعي في الشرح الكبير (٧/ ١٣٠): «وقد رأيت أبا الحسن العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير، وروىٰ فيه حديث»، وتبعه النووي في الروضة (٦/ ٢٠٢) ولم يذكر هذا الحديث كما قال الإسنوي: «ولم يبين الرافعي ولا النووي الحديث الذي رواه العبادي»، ثم ذكر الحديث السابق.

وذكره النووي في المجموع (٨/ ٤٠٦) فقال: «واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان (يضحي بكبشين عن النبي ﷺ وبكبشين عن نفسه وقال أن رسول الله ﷺ أمرني أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي قال البيهقي إن ثبت هذا كان فيه دلالة علىٰ صحة التضحية عن الميت »، وتبعه الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٣ ط. قرطبة).

قلت: وفي الباب حديث آخر عن أبي رافع: أن النبي ﷺ ضحىٰ بكبش عنه، وبكبش عن أمته« . أخرجه البزار وغيره».

وضعف الشافعي حديث أبي رافع، ففي مختصر المزني (٢/ ٥٥٨ ط. الداغستاني):« وقد روي عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت أنه ضحىٰ بكبشين، فقال في أحدهما بعد ذكر الله:« اللهم عن محمد وآل محمد«، وفي الآخر:« اللهم عن محمد وأمة محمد».

النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه».

وبوب عليه البخاري بقوله «ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن».

وقال الماوردي في الحاوي (١٥/ ١٢٥): «يختار للإمام أن يضحي لكافة المسلمين وعنهم من بيت مالهم بدنة يذبحها في المصلىٰ بعد فراغه من صلاته لقول الله تعالىٰ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، وأقل ما ينحره شاة، لأن رسول الله ﷺ نحر بعد صلاته شاة عن أمته، ويتولىٰ نحرها بنفسه اقتداء برسول الله ﷺ والأئمة الراشدين، ويخلي بين الناس وبينها».

فهذه صور يؤيد بعضها بعضا، ولا نعلم معارضا لها من قول الشافعي ونصه، فهو المعتمد.

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٢٦٧) بجوازها في أربع صور:

الأولىٰ: الولي إذا ضحىٰ من ماله عن الذي تحت حجره من الأطفال والسفهاء، والمجانين.

الثانية: الأضحية الواقعة من واحد في البيت، تحصل بها سنة الكتابة لأهل البيت.

الثالثة: الإمام يضحي عن المسلمين من بيت مالهم.

الرابعة: إذا كانت الشاة معينة بالنذر فذبحها أجنبي في وقت التضحية.

وتبعه الولي العراقي في تحرير الفتاوىٰ (٣/ ٤١٦).





كتاب الأطعمة

[١٣٥]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٤٣ ط. الحداد): «وإذا ظهر تغير لحم جلالة حرم أكله، وقيل: يكره، قلت: الأصح يكره والله أعلم».

خالف النووي هنا الرافعي، وصحح أن لحم الجلالة إذا تغير بالنجاسة التي أكلته مكروه، وليس بمحرم، وكذلك قال في الروضة (٣/ ٢٧٨) ولفظه: «يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه علىٰ الأصح الذي ذكره أكثرهم، منهم العراقيون، والروياني وغيرهم».

وقال في شرح المهذب (٩/ ٢٨): «وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين، وصححه الروياني وغيره من المعتمدين أنه كراهة تنزيه، قال الرافعي: صححه الأكثرون».

○ قال أبو عبد الباري:

هذا الذي رجحه النووي وقطع به أكثرهم كما قال، مخالف لظاهر نصّ الشافعي.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٦٢٩ ط. د. رفعت فوزي): «والجلالة منهي عن لحومها حتىٰ تعلف علفا غيره، ما تصير به إلىٰ أن يوجد عرقها وجررها منقلبا عما كانت تكون عليه، فيعلم أن اغتذاءها قد انقلب، فانقلب عرقها وجررها

فتؤكل إذا كانت هكذا، ولا نجد شيئا نستطيع أن نجده فيها كلها أبين من هذا، وقد جاء في بعض الآثار: أن البعير يعلف أربعين ليلة، والشاة عددا أقل من هذا، والدجاجة سبعا، وكلهم فيما نرىٰ إنما أراد المعنىٰ الذي وصفت، من تغيرها من الطباع المكروهة، إلىٰ الطباع غير المكروهة، التي هي في فطرة الدواب».

وهو اختيار البغوي في التهذيب (٨/ ٦٦)، والإمام في نهاية المطلب (١٨/ ٢١٤) وقال: « وإن ظهرت الرائحة الكريهة علىٰ اللحم، فالمذهب تحريم اللحم، وفيه آثار تدل علىٰ التحريم»، والقفال الشاشي كما في البيان للعمراني (٤/ ٥٠٨) والشيخ أبو محمد الجويني في الجمع والفرق (٣/ ٥٧٧ مسألة ٧٣٧).

وهو اختيار الرافعي، ففي المحرر (ص ١٥٦٢) فقال: «والجلالة التي تأكل العذرة إذا ظهر النّتن والتّغيُّر في لحمها، فأحد الوجهين أنه يكره أكل لحمها، وأظهرهما أنه يحرم».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٢٧٣): «والجلالة التي تأكل العذرة، إذا ظهر النتن والتغير في لحمها، وكذلك في عرقها، أو أوجد ريح النجاسة، فيحرم أكلها علىٰ ظاهر النص، خلافا لما صححه في «المنهاج» من الكراهة».

وفي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ٤٣١) عن البلقيني: «قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: إن المصحح في «المحرر» وهو ظاهر نصّ «الأم» حيث

قال: والجلالة منهي عن لحومها، قال شيخنا: وهو ظاهر النهي الذي جاءت به الأخبار».

وإذا ورد النهي في النص النبوي، ونص الشافعي فالأصل حمله علىٰ التحريم كما هو قول الشافعي في الرسالة (ص ٣٠٧ وما بعدها) في باب (النهي عن معنىٰ دل عليه معنىٰ في حديث غيره)، وقد أفاض في بيان ذلك، فلا يصار إلىٰ غير المعنىٰ الأصلي في النهي إلا بدليل يصرفه عن ذلك، ولا دليل نعلمه.

[١٣٦]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٤٤ ط. الحداد): «وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه».

ذكر النووي هنا أن علة كراهة كسب الحجام هي مخالطة النجاسة، وهو تابع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٥٦٣) ولفظه: «وما اكتسب بمخامرة نجاسة ككسب الحجّام والكنّاس مكروه، وينبغي أن لا يأكل منه، ويطعم رقيقه وناضحه».

وعزاه الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ١٥٥، ١٥٦) للجمهور.

وتبعه النووي في الروضة (٣/ ٢٨٠)فقال: «وهذا الذي أطلقه جمهور الأصحاب»، ثم قاس من قال ذلك كل ما فيه مخالطة النجاسة من المكاسب كالجزار والكنس ونحوهما.

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره من التعليل بمخالطة النجاسة مخالف لنصّ الشافعي في التعليل، ثم ما ينبني عليه.

قال في مختصر المزني (٢/ ٥٦٧ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ولا بأس بكسب الحجام، فإن قيل: فما معنىٰ نهي النبي ﷺ السائل عن كسبه، وإرخاصه في أن يطعمه رقيقه وناضحه؟.

قيل: لا معنىٰ له إلا واحد، وهو أن من المكاسب دنيّـًا وحسنًا، فكان كسب الحجام دنيّـًا، فأحبّ له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه، فلما راده فيه أمره أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه، تنزيها له، لا تحريما عليه، وقد حجم أبو طيبة رسول الله ﷺ، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، ولو كان حراما لم يعطه رسول الله ﷺ؛ لأنه لا يعطي إلا ما يحل إعطاؤه ولآخذه ملكه، وقد روي أن رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه، فسأله عن معاشه، فذكر غلة حجام أو حجامين، فقال: إن كسبكم لوسخ، أو قال: لدنس،

أو: لرديء، أو كلمة تشبهها»[(١)].

وظاهر هذا التعليل أن الكراهة لأجل دناءة الكسب، فيقاس عليه ما كان من هذا القبيل مثل قيِّم الحمام والحلاق ونحوهما، وقد صرح القفال الشاشي بذلك في الحلية (٣/ ٤١٨) فقال: «واختلف أصحابنا في علة كراهة كسب الحجام.

فقيل: لأجل مباشرة النجاسة، فعلىٰ هذا يكره كسب الكناس والزبال، والقصاب، واختلف قول هذا القائل في الفصاد علىٰ وجهين:

أحدهما: أنه من جملتهم.

والثاني: هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره، لاقترانه بعلم الطب فأما الختان فمكروه كالحجام.

والوجه الثاني: أن كراهة التكسب بالحجامة لدنائتها، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، فعلىٰ هذا يكره كسب الدبّاغ والحلّاق، والقيّم».

وقال العمراني في البيان (٤/ ٥٢١): «والثاني: أن كراهة الحجامة لدناءتها، وهو ظاهر مذهب الشافعي».

وقال ابن الرفعة في الكفاية (٨/ ٢٨١): « ومنهم من قال: لدناءة الحجام عند

---

(١) هذا النص أيضا في اختلاف الحديث (ص ٢٠٦-٢٠٧ تحقيق محمد أحمد عبد العزيز) ومعرفة السنن والآثار (١٤/ ١١٥) ومناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٣٢٦).

الناس، قاله الماوردي، وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي؛ لأنه جعل من المكاسب دنيـًا وحسنـًا، ولم يورد في «المذهب» و«التهذيب» سواه».

وكذا قال البلقيني كما في تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ٤٣٣) أنه المذهب المعتمد المنصوص في «الأم» و«المختصر» وقال به جمع من الطريقين: أن النظر إلىٰ دناءة الحرفة».

وقال الجويني في نهاية المطلب (١٨/ ٢١٧): «لو لم يكن فيه إلا مجانبة المروءة، لكان في هذا مقنع في تثبيت الكراهية، وما ذكرناه لا يختص بكسب الحجام، بل تعاطي القاذورات، ومخالفة المروءات كلها بهذه المثابة».

وكذلك قال القاضي أبو الطيب الطبري في تعليقته (ص ٢٤٦، ٢٤٧ تحقيق أحمد الغامدي).

ومما تقدم تعلم أن قول الرافعي في فتح العزيز (١٢/ ١٥٦): «وهو الذي أطلقه عامة الأصحاب» ليس كما قال، لما تقدم عن جملة من الكبار في اختيارهم أن مذهب الشافعي هو التعليل بدناءة الحرفة والكسب.

فائدة: في تفضيل المكاسب بعضها علىٰ بعض

قال الماوردي في الحاوي (١٥/ ١٥٣): «اختلف الناس في أطيبها، فقال

قوم: الزراعات، وهو عندي أشبه؛ لأن الإنسان فيها متوكل علىٰ الله، في عطائه، مستسلم لقضائه.

وقال آخرون: التجارة أطيبها، وهو أشبه بمذهب الشافعي؛ لتصريح الله تعالىٰ بإحلاله في كتابه، بقوله: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، واقتداء بالصحابة ﷺ في اكتسابهم بها.

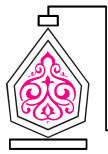
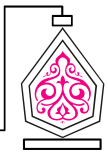
وقال آخرون: الصناعة: لاكتساب الإنسان فيها بكد يديه».

واحتج النووي في شرح المهذب (٩/ ٥٩) والروضة (٣/ ٢٨١) علىٰ ترجيح الزراعة موافقة للماوردي بما رواه البخاري عن المقدام بن معدي كرب ﷺ عن النبي ﷺ قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود ﷺ كان يأكل من عمل يده».

قال: «فالصواب ما نص عليه رسول الله ﷺ وهو عمل اليد فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب وأفضلها لأنه عمل يده ولأن فيه توكلا».

وفي الروضة: «فهذا صريح في ترجيح الزراعة، والصنعة، لكونهما من عمل يده، لكن الزراعة أفضلهما؛ لعموم النفع بها للآدمي وغيره، وعموم الحاجة إليها».



كتاب المسابقة والمناضلة

[١٣٧]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٥٢ ط. الحداد): «وإن تسابق ثلاثة فصاعدا، وشرط للثاني مثل الأول فسد».

هكذا قال النووي بفساد المساواة بين الأول والثاني، وتابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٧٢) ولفظه: «وإذا تسابق ثلاثة فصاعدا، فلا يجوز أن يشترط للثاني مثل ما شُرِط للأول، ويجوز أن يشترط له دون ما شُرِط للأول في أصح الوجهين».

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحه الشيخان هنا في المنهاج والمحرر مخالف لنصوص الشافعي واختيارهما في الشرح الكبير والروضة.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٥٥٥ ط. د. رفعت فوزي): «والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من مال متطوعا به، وذلك مثل أن يسبق بين الخيل من غاية إلىٰ غاية، فيجعل للسابق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع والذي يليه بقدر ما أرىٰ، فما جعل لهم كان لهم، وعلىٰ ما جعل لهم، وكان مأجورا عليه إن نوىٰ فيه، وحلالا لمن أخذه، وهذا وجه ليست فيه علة».

وفي مختصر المزني (٢/ ٥٧٣ ط. الداغستاني): «والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك أن يسبق بين الخيل إلىٰ غاية، فيجعل للسابق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة».

وهذان النصان في الأم والمختصر صريحان في جواز الاشتراط للثاني والثالث مثل الأول، وهو الذي اختاره الرافعي في الشرح الكبير، وتبعه النووي في الروضة.

قال في الروضة (١٠/ ٣٥٣): «إذا تسابق أكثر من ثلاثة حتىٰ لو كانوا عشرة، وشرط لكل واحدة سوىٰ الفسكل[1] مثل المشروط لمن قبله، جاز علىٰ الأصح، والأحب أن يكون المشروط لكل واحد دون المشروط لمن قبل».

وهو قول الرفعي في الشرح الكبير (١٣/ ١٨٠).

وهذا هو المعتمد الذي نص عليه الشافعي، وما جزم به في المنهاج وجه ضعيف لا يعول عليه.

---

(١) الفسكل: بكسر الفاء والكاف وإسكان السين المهملة بينهما وهو الأخير كما في الروضة (١٠/ ٣٥٣).

[١٣٨]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٥٤ ط. الحداد): «والأظهر: اشتراط بيان البادئ بالرمي».

تبع النووي هنا الرافعي في المحرر في فساد العقد ما لم يبينا البادئ منهما، ولفظه في المحرر (ص ١٥٧٥): «والأقوىٰ من القولين أنه يشترط بيان من يبدأ بالرمي، فإن تركاه لم يصح العقد».

وبهذا قال الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٢٠٤، ٢٠٥): «إن ذكرا في العقد من يبدأ بالرمي، اتبع الشرط، وإن أطلقا، فقولان: أظهرهما: فساد العقد».

وتبعه النووي في الروضة (١٠/ ٣٧٠).

وسبقهما إلىٰ ذلك الماوردي في الحاوي (١٥/ ٢٠٩) بعد ذكر نص المزني فقال: «وإن أغفل في العقد اشتراط البادئ بالرمي، ففي العقد قولان:

أحدهما: وهو اختيار الشافعي في هذا الموضع أن العقد باطل، لأن للبداية تأثيرا في قوة النفس، وكثرة الإصابة، فصارت مقصودة، فبطل العقد بإغفالها».

○ قال أبو عبد الباري:

الذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي صحة العقد إذا لم يبينا البادئ منهما، وأنه يقرع بينهما.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٥٥٩ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يجوز في القياس

(إلا) أن يتشارطا أيهما يبدأ، فإن لم يفعلا اقترعا، والقياس أن لا يرميا إلا عن شرط»[(١)].

وقوله هنا «فإن لم يفعلا اقترعا» ليس في المزني، وهو صريح في أن ترك الاشتراط لا يفسد العقد، وإنما ذلك من باب الندب لا الوجوب.

وفي مختصرالبويطي (ص ١١٠٨ط. القره داغي): «وإن استبقا في السهام علىٰ المبادرة الرمي خمسة خمسة، أقرع بينهما في الرمي أيهما أولا».

وظاهره قبول القرعة فيمن يبدأ منهما، وهو محمول علىٰ ما إذا أغفلا عن بيانه، وإلا فيبدأ الذي اتفقا عليه في الشرط، وبه قال أبو الطيب الطبري في تعليقته (ص ٣٢٥ تحقيق أحمد الغامدي).

وبما في الأم من الزيادة تعقب البلقيني المنهاج كما في تحرير العراقي (٣/ ٤٦١): «هذا موضع انفرد الرافعي بترجيحه، وهو مخالف لصريح نص «الأم» في أنه إذا لم يبيناه يصح العقد ويقرع، وعبارته: «ولا يجوز في القياس إلا أن يتشارطا أيّهما يبدأ، فإن لم يفعلا .. اقترعا»، وهذا هو المعتمد، وعليه جرىٰ

---

(١) كلمة الاستثناء (إلا) سقطت من نسخة د. رفعت فوزي، ومن نسخة دار الفكر، وهي في تحرير الفتاوي للولي العراقي (٣/ ٤٦١) وبها يستقيم المعنىٰ، ويؤيد صحة الزيادة موافقتها لما نقله المزني في المختصر كما يأتي قريبا.

القاضي أبو الطيب».

وقول البلقيني بتفرد الرافعي بترجيحه، يرده ما تقدم عن الماوردي في الحاوي.

وأما قوله في مختصر المزني (٢/ ٥٧٥): «قال الشافعي: ولا يجوز في القياس عندي إلا أن يتشارطا».

فالجواب عنه أن المزني اختصره اختصار مخلا بالمعنىٰ، يتبين من نص الأم، وقد تقدم في أول الكتاب عن البيهقي والجويني أن هذا مما أُخذ علىٰ المزني.

[١٣٩] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٥٥ ط. الحداد): «وإذا نضل حزب قسم المال بحسب الإصابة، وقيل: بالسوية».

ما رجحه النووي من اعتبار حصص الإصابة، تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٧٦) ولفظه: «وإن نضل أحد الحزبين، فيقسم المال بينهم بالسوية، أو بحسب إصابتهم؟ فيه وجهان، أشبههما الثاني».

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحه هنا مخالف لظواهر نصوص الشافعي التي مقتضاها أن القسمة بالسوية، لاجرم صححه الرافعي في الشرح الكبير، وتبعه النووي في الروضة، وهي من مسائل القيلات المعتمدة، وقد أوضحناها في «المسألة الحادية عشرة»،

من «التوضحيات المسددة».

وهذه خلاصة ما ذكرنا هناك:

قال الشافعي في الأم (٥/ ٥٧٠ ط. د. رفعت فوزي): «والسبق علىٰ من بذله دون حزبه، إلا أن يدخل حزبه أنفسهم معه في ضمان السبق، أو يأمروه أن يسبق عنهم، فيلزم كل واحد منهم حصته علىٰ قدر عدد الرجال، لا علىٰ قدر جودة الرمي».

هذا في السبق، فلا يفرق بين أفراد الحزب بجودة رميهم، وإنما يكون ضمان السبق علىٰ الرؤوس، والغُنم بالغرم، فكذلك يكون اقتسام ما وجدوه علىٰ الرؤوس.

ومنها: التسوية في استحقاق الشفعة بين الشركاء، ففي الأم (٥/ ٦ط. د. رفعت فوزي): «وإذا كانت الدار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر سدسها، وللآخر ثلثها، وباع صاحب الثلث، فأراد شركاؤه الأخذ بالشفعة، ففيها قولان:

أحدهما: أن صاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم، وصاحب السدس يأخذ سهما، علىٰ قدر ملكهم من الدار، ومن قال هذا القول: ذهب إلىٰ أنه إنما يجعل الشفعة بالملك، فإذا كان أحدهما أكثر ملكا من صاحبه، أعطي بقدر كثرة ملكه،

ولهذا وجه.

والقول الثاني: أنهما في الشفعة سواء، وبهذا القول أقول، ألا ترىٰ أن الرجل يملك شفعة من الدار فيباع نصفها، أو ما خلا حقه منها، فيريد الأخذ بالشفعة بقدر ملكه، فلا يكون ذلك له، ويقال له: خذ الكل، أو دع، فلما كان حكم قليل المال في الشفعة حكم كثيره، كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء؛ لأن اسم الملك يقع علىٰ كل واحد».

فحكىٰ قولين، واختار القول بالسوية وإن تفاوتت حصصهم، لأنهم سواء في أصل الاستحقاق، وقياس ذلك أن يكونوا في قسمة السبق سواء، لا يؤثر تفاوت إصاباتهم.

ومنها: التسوية في استحقاق الغنيمة: ففي الأم (٣/ ٢٢١ ط. د. رفعت فوزي): «وسن رسول الله ﷺ أن أربعة أخماسه لمن أوجف علىٰ الغنيمة، للفارس من ذلك ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، فلم نعلم رسول الله ﷺ فضل الفارس ذا الغناء العظيم علىٰ الفارس الذي ليس مثله، ولم نعلم المسلمين إلا سووا بين الفارسين؛ حتىٰ قالوا: لو كان فارس أعظم الناس غناء، وآخر جبان، سووا بينهما، وكذلك قالوا في الرجالة».

فإذا كان الجيش سواء، من كان ذا نكاية في الحرب، ومن كان دون ذلك، يستوي الفرسان فيما بينهم، والرجالة فيما بينهم، فقياس ذلك أن يستوي أفراد

الحزب الناضل في القسمة.

وبهذا قال الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٢٠٧) والنووي في الروضة (١٠/ ٣٧٣)، وتعقبهما به الإسنوي في المهمات (٩/ ١٠٠) وابن النقيب في النكت السراج (٨/ ١٢٨) والأذرعي في القوت (١٠/ ٢٣٣) وتراجع نصوصهم في «التوضيحات المسددة».

[١٤٠]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٥٥ ط. الحداد): «ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له، وإلا فلا يحسب عليه».

ذكر النووي هنا أن الرامي يحسب له إذا أصاب موضع الغرض بعد إزالته بريح، وإلا فلا، وهو تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٧٧) ولفظه: «ولو نقلت الريح الغرض من موضعه إلىٰ موضع آخر، فأصاب السهم موضعه، حسب له، وإلا فلا».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٢٢٢): «ولو هبت ريح، ونقلت الغرض إلىٰ موضع آخر، فأصاب السهم الموضع المنتقل عنه، حسب له، إن كان الشرط الإصابة».

وتبعه النووي فقال في الروضة (١٠/ ٣٨٦): «ولو هبت ريح نقلت الغرض إلىٰ موضع آخر، فأصاب السهم الموضع المنتقل عنه، حسب له، إن كان الشرط

الإصابة علىٰ الصحيح».

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا الذي ذكراه مخالف لنص الإمام الشافعي في أنه لا يحتسب له.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٥٦٢ ط. د. رفعت فوزي): «ولو رمىٰ والشن منصوب، فطرحت الريح الشن، أو أزاله إنسان قبل يقع سهمه، كان له أن يعود فيرمي بذلك السهم، لأن الرمية زالت».

وهذا النص صريح في أنه لا يحسب له هذا السهم من غير تفصيل، أي سواء أصاب موضع الغرض أم لا، والعلة زوال الرمية عن موضعها.

وقد نقل العمراني في البيان (٧/ ٤٦٠) عن ابن الصباغ أن ابن القاص قال: إن المسألة علىٰ ظاهرها.

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٢٨٤): «ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه، لا يحسب له علىٰ النص».

وفي تحرير الولي العراقي (٣/ ٤٦٤) عن البلقيني أنه قال: «هذا نص صاحب المذهب، فليعتمد عليه».

وأما حمل نص الإمام علىٰ أن أراد بالخسق فخلاف ظاهره فلا يصار إليه إلا

إذا كان هنا نص آخر للإمام يقتضي ذلك ، ولم أعلم من ذكره.

وهذا موافق لما ذكره الشافعي كقاعدة في هذا الباب، وهو أنه إذا أثر في السهم عارض رد السهم إليه، وذكر من أمثلتها فقال في الأم (٢/ ٥٥٩-٥٦٠ ط. د. رفعت فوزي) ومختصر المزني (٢/ ٥٧٦ ط. الداغستاني): «وإذا عرق أحدهما فخرج السهم من يده فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود فيرمي به من قبل العارض فيه، وكذلك لو زهق من قبل العارض فيه أعاده فرمىٰ به، وكذلك لو انقطع وتره فلم يبلغ أو انكسر قوسه فلم يبلغ كان له أن يعيده، وكذلك لو أرسله فعرض دونه دابة أو إنسان فأصابهما، كان له أن يعيده في هذه الحالات كلها، وكذلك لو اضطربت به يداه، أو عرض له في يديه ما لا يمضي معه السهم، كان له أن يعود، فأما إن جاز وأخطأ القصد، فرمىٰ فأصاب الناس، أو أجاز من ورائهم فهذا سوء رمي منه، ليس بعارض غلب عليه، وليس له أن يعيده».

فذكر مسائل هي: إذا عرض له عرق يديه، أو انقطع وتر القول، أو عرضت له دابة أو إنسان، ونحو ذلك كان له أن يعيد الرمي للعارض، وما أخطأ بدون عارض لم يكن له أن يعيد.





كتاب الأيمان

[١٤١]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٦٣ ط. الحداد): «وإن أذن في أحدهما، فالأصح اعتبار الحلف».

ما صححه النووي من أن العبرة في الإذن بالحلف دون الإذن بالحنث، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٨٦) ولفظه: «وإن كان أحدهما بإذنه دون الآخر، فأصح الوجهين: أن الاعتبار بالحلف».

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا الذي قاله النووي هنا مخالف لنص المختصر، وما صححه الرافعي في الشرح الكبير، والنووي في الروضة من أن العبرة بالحنث لا بالحلف، ولهذا قال بعض أهل العلم: بأن ما في المحرر والمنهاج سبق قلم من الحنث إلىٰ الحلف، وقيل: هي من متابعات المحرر لتهذيب البغوي، لأنه الذي صحح ذلك[(١)].

قال المزني في مختصره (٢/ ٦٠٤ ط. الداغستاني): «وليس له أن يصوم إلا

---

(١) قال البغوي في التهذيب (٨/ ١١٣):« وإن كان أحدهما بإذنه دون الآخر، ففيه وجهان: أصحهما: الاعتبار باليمين، فإن كان اليمين بإذنه، والحنث بغير إذنه- له أن يصوم بغير إذنه، وإن كان اليمين بغير إذنه- فلا يصوم إلا بإذن».

بإذن مولاه، إلا أن يكون ما لزمه بإذنه».

وظاهره إناطة الاستقلال بالصوم بالحنث، لأنه الذي يلزم منه وجوب التكفير.

وهو الذي عزاه الرافعي للأكثرين، وصححه في الشرح الكبير (٩/ ٣٢١) فقال: «وأصحهما عند الأكثرين، وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يستقل بالصوم؛ لأن لزوم الكفارة لا يلازم اليمين، بل اليمين مانعة من الحنث، فالإذن فيها لا يكون إذنا في التكفير».

وتبعه النووي في الروضة (٨/ ٣٠٠) فقال: «وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه، لم يستقل بالصوم علىٰ الأصح، وفي عكسه يستقل علىٰ المذهب».

وعليه مشىٰ الشيرازي في التنبيه (ص ١٩٩) فقال: «وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز وهو الأصح».

وكذلك القزويني في الحاوي الصغير (ص ٦٤٨) فقال: «وللسيد منعه إن امتنع خدمته، أو حنث لا بإذنه».

وهو اختيار الماوردي في الحاوي في قوله (١٥/ ٣٣٨): «والحال الثالثة: أن يحلف بغير إذنه، ويحنث بإذنه، فللعبد أن يصوم بغير إذنه، لأن وجوب الصيام بإذنه».

ورجحه الجويني في نهاية المطلب (١٨/ ٣٢٨) فقال: «ولو كانت اليمين

بإذن السيد، والحنث بغير إذنه، فالذي ذهب إليه المحققون أن للسيد أن يمنعه من الصوم إذا حنث، والسبب فيه أنه إذا حلف بإذن مولاه علىٰ الامتناع من دخول الدار، ودخل الدار من غير إذن، فالذي جاء به مبالغة في مخالفة المولىٰ، فإنه أذن له في أن يمتنع عن الدخول».

وصححه البلقيني في التدريب (٤/ ٢٩٣) فقال: «فإن كان قد أذن في الحلف فقط وحنث بغير إذنه لم يستقل بالصوم علىٰ الأصح، بل لا بد من إذن السيد في ذلك، وفي عكسه وهو الحنث بالإذن يستقل بالصوم علىٰ المذهب».

وقال كمال الدين أبو العباس النشائي في نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه (ص ١٠١): «وهو الأصح، صرح الرافعي بعزوه للأكثرين، وصححه في «الكفاية»، ووجهه واضح، والذي في «المحرر»سبق قلم، ولو عبر بغير الأصح لظُن اختياره، ويوضح ما أوضحته اتفاق المصححين فيما إذا حلف بغير الإذن وحنث بالإذن علىٰ الجواز، وإنما بالغت فيه؛ لأنه قد اغتُرَّ به». ونقله الولي العراقي في التحرير (٣/ ٤٨٠) ولم يتعقبه.

وقال الأذرعي في القوت (١٠/ ٣٠٤): «قيل: ولعل ما في المختصرين - يعني المحرر والمنهاج - سبق قلم من الحنث إلىٰ الحلف، وعندي أنه من متابعات المحرر للتهذيب.

[١٤٢]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٦٥ ط. الحداد): «ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث».

ما ذكره النووي هنا من بقاء أساس الحيطان تبع فيه المحرر (ص ١٥٨٩) ولفظه: «وإذا انهدمت الدار فدخلها، نظر: إن بقي أساس الحيطان حنث«، وتبع صاحب المحرر فيه البغوي في التهذيب(١).

وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٣٤٨)، وتبعه النووي في الروضة (١١/ ٨٤) فقال: «ولو قال: لا أدخل هذه الدار فانهدمت، نظر إن بقيت أصول الحيطان والرسوم، حنث، وإن صارت فضاء، فدخلها، لم يحنث علىٰ المذهب، وبه قطع الأكثرون».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره الشيخان تبعا للبغوي مخالف لنص الشافعي المفيد بأنه لا يحنث بمجرد بقاء أساس الحيطان.

قال الشافعي في الأم (٨/ ١٦٦ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا حلف الرجل أن

---

(١) قال البغوي في التهذيب (٨/ ١١٩): «ولو حلف ألا يدخل هذه الدار، فانهدمت، إن كانت الأسس باقية، فدخلها حنث».

لا يدخل هذه الدار فانهدمت حتىٰ صارت طريقا، ثم دخلها لم يحنث، لأنها ليست بدار».

وفي مختصر المزني (٢/٦٠٦ ط. الداغستاني): «ولو حلف لا يدخلها، فانهدمت حتىٰ صارت طريقا لم يحنث؛ لأنها ليست بدار».

وظاهر ما ذكره أن الدار المنهدمة أو التي هدمت إذا صارت طريقا أو خربة لا يحنث بدخولها، ولا يخفىٰ أن الدار المنهدمة تكون طريقا مع بقاء أساس الحيطان، وحتىٰ مع بقاء بعض مبانيها، وكذلك الخربة ما لم يكن للحالف نية يستدل بها علىٰ شيء آخر نواه.

والنظر بعد ذلك في معنىٰ الدار الخربة، والأقرب ما ذكره الماوردي في الحاوي الكبير من أن العبرة بإمكان السكن وعدمه، فتكون الدار ثلاثة أقسام، يحنث في بعضها دون بعض، وهي كما في الحاوي (١٥/ ٣٥٧): «أحدها: أن لا يمنع من سكنىٰ شيء منها، فيحنث بدخوله من المستهدم والعامر.

والقسم الثاني: أن يمنع بالهدم من سكنىٰ الباقي، وسكنىٰ المستهدم، فلا يحنث بدخول ما بقي، ولا بدخول ما انهدم.

والقسم الثالث: أن يمنع الهدم من سكنىٰ ما استهدم، ولا يمنع من سكنىٰ ما

بقي علىٰ عمارته، ولم يستهدم فلا يحنث بدخول المستهدم منها، ويحنث بدخول الباقي».

واختاره البلقيني في التدريب (٤/ ٢٩٥) وقال: «إنه الأرجح كما في تحرير الولي العراقي (٣/ ٤٨٥).

وقال الجويني في النهاية (١٨/ ٣٥٢) : «فالذي يجب اعتماده في ذلك أن البقعة التي دخلها إن كان يقال فيها إنها دارٌ خربة، فيحنث الحالف، وإن قيل: كانت داراً، فلا حنث، وإن قيل هذه رسوم دار فلان، فلا حنث، فالمتبع في النفي والإثبات هذا».

واستظهره الدميري في النجم (١٠/ ٤٥) وقال: «وذكر مثله الغزالي في «البسيط»، والجاجرمي والفوراني والماوردي.

والحاصل: أن الحكم يدار مع اسم الدار وعدمه، وهو ظاهر نص «الأم» و «المختصر» ، وأطبق عليه الأصحاب، وكأن الرافعي والمصنف لم يمعنا النظر في المسألة».

وفي تحفة المحتاج (١٠/ ٢٨): «وفي مسودة شرح المهذب عن الأصحاب: أنها متىٰ صارت ساحة فلا حنث، بخلاف ما إذا بقي منها ما تسمىٰ معه دارا،

وكالساحة ما إذا صارت تسمىٰ طريقا، وإن بقي بعض حيطانها كما دل عليه نص «الأم» واعتمده البلقيني وغيره» ونحوه في المغني (٦/ ١٩٩).

[١٤٣]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٦٧ ط. الحداد): «أو لا يدخل بيتا، حنث بكل بيت من طين، أو حجر، أو آجُرٍّ، أو خشب، أو خيمة».

جزم النووي هنا الحنث مطلقا أي سواء كانت له نية ببعض ما ذكره أم لا، أو كانت فيه قرينة تدل علىٰ نيته ببعض ما ذكره أم لا، وتابع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٥٩١) ولفظه: «ولو قال: لا أدخل بيتا، يحنث بدخول أي بيت كان، من طين أو آجرّ أو حجر أو خشب أو خيمة».

○ قال أبو عبد الباري:

الذي نص عليه الشافعي أن نية الحالف معتبرة، وأن وجود قرينة يستدل بها علىٰ مراده معتبرة أيضا.

قال الشافعي في الأم (٨/ ١٦٥-١٦٦ ط. د. رفعت فوزي): «وإن حلف الرجل أن لا يسكن بيتا وهو من أهل البادية، أو أهل القرية، ولا نية له، فأي بيتٍ - شعر، أو أدم، أو خيمة، أو ما وقع عليه اسم بيت، أو حجارة، أو مدر- سكن حنث».

وفي مختصر المزني (٢/ ٦٠٦ ط. الداغستاني): «ولو حلف لا يسكن بيتا، وهو بدوي أو قروي، ولا نية له، فأي بيت من أدم أو شعر أو خيمة أو بيت حجارة أو مدر أو ما وقع عليه اسم بيت سكنه حنث».

فقوله هنا «ولا نيَّة له» يدل علىٰ اعتبار نية الحالف، فلو كان مراده بعض ما ذكر لم يحنث بغيره.

وقال الشافعي في الأم (٨/ ١٦٥ ط. د. رفعت فوزي): «نقول فيمن حلف أن لا يسكن بيتا ولا نية له، وهو من أهل الحضارة، فسكن بيتا من بيوت الشعر، فإنه إن كان ليمينه معنىٰ يستدل عليه بالأمر الذي له حلف، مثل أن يكون سمع بقوم انهدم عليهم بيت فعمهم ترابه، فلا شيء عليه في سكناه في بيت شعر، وإن لم يكن له نية حين حلف، وإن كان إنما وجه يمينه أنه قيل له: إن الشمس محتجبة، وإن السكنىٰ في السطوح، والخروج من البيوت مصحة ويسرة، فحلف أن لا يسكن بيتا، فإنا نراه حانثا إن سكن بيت شعر».

وهذه النصوص صريحة في أن الحنث المطلق إنما هو فيما إذا لم يكن للحالف نية، أو قرينة تخصص لفظه المطلق والله أعلم.

وهذا هو الذي رجحه الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٢٨٤) فقال: «إذا حلف، لا يدخل ولا يسكن بيتا، قاسم البيت يقع علىٰ المبنىٰ من الطين، والآجر،

والمدر، والحجر، وعلىٰ المتخذ من الخشب، والشعر، والصوف، والجلد، وأنواع الخيام، فينظر، إن نوىٰ نوعا منها، حملت اليمين عليه، وإن أطلق، حنث بأي بيت كان».

وتبعه النووي في الروضة (١١/ ٣٠) فقال: «حلف لا يدخل أو لا يسكن بيتا، فاسم البيت يقع علىٰ المبني من طين أو آجر ومدر وحجر، وعلىٰ المتخذ من خشب وصوف ووبر وشعر وجلد وأنواع الخيام، فإن نوىٰ نوعا منها، حمل عليه، وإن أطلق، حمل علىٰ أي بيت كان منها».

وقد أطال البحث في هذه المسألة الجويني في النهاية (١٨/ ٣٤٠-٣٤٣) وخلاصته اعتبار النية إذا كانت له نية وقصد، وأما إذا أطلق القروي ففيه مسلكان:

أحدهما: أن يقال: لا يطلق اللفظ إلا عن قصد، ولعله ذَهل عنه بعد ما صدر منه، والقصد اللائق به الكلامُ علىٰ المتعالَم المتعارف في المكان الذي هو ساكنه، فعلىٰ هذا يحمل علىٰ بيوت المدر.

والمسلك الثاني: أن يقال: إذا قال: لم يكن قصدٌ، فقد قصد إلىٰ اللفظ، ولم يُنزله علىٰ شيء فأُخذ باللفظ، ونحن إنما نُزيل وضعَ اللفظ بالقصد، فإذا لم يوجد منه قصد إلىٰ ما يزيل اللفظ، واللفظ صريح، كان مؤاخذًا باللفظ، وكأنه

حلف علىٰ معنىٰ اللفظ».

[١٤٤]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٦٧ ط. الحداد): «قلت: ولو حلف لا يسلم عليه، فسلم علىٰ قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث، وإن أطلق حنث في الأظهر والله أعلم».

قول النووي «وإن أطلق حنث في الأظهر» قريب من قول الرافعي في المحرر (ص ١٥٩٩): «ولو حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه حنث».

وهو موافق لاختيار البغوي في التهذيب (٨/ ١٤١) والماوردي في الحاوي (١٥/ ٤٤٥) والشيخ أبي حامد كما في المهمات للإسنوي (٩/ ١٥٢).

○ قال أبو عبد الباري:

وما ذكروه مخالف لمنصوص الشافعي في الأم ومختصر المزني.

قال الشافعي في الأم (٨/ ١٨١ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا حلف أن لا يكلم فلانا، فسلم علىٰ قوم وهو فيهم لم يحنث، إلا بأن ينويه فيمن سلم عليهم».

وفي مختصر المزني (٢/ ٦١٥): «ولو حلف لا يكلم رجلا، فسلم علىٰ قوم والمحلوف عليه فيهم، لم يحنث إلا أن ينويه».

وفي هذين النصين مسألتان:

الأولىٰ: أن الاستثناء المقصود هو النية، ولا يشترط التلفظ بذلك كما هو ظاهر نص الشافعي، وجزم به الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٣٤٤).

وقال الشيرازي في المهذب (٣/ ١١٠): «وإن استثناه بقلبه لم يحنث، لأن اللفظ وإن كان عامًا إلا أنه يحتمل التخصيص، فجاز تخصيصه بالنية».

الثانية: عدم الحنث عند الإطلاق.

اعتراض وجوابه

فإن قيل: جاء في الأم (٨/ ١٨١ ط. د. رفعت فوزي): «قال الربيع: وله قول آخر -فيما أعلم-: أنه يحنث إلا أن يعزله بقلبه في أن لا يسلم عليه خاصة».

والقول الثاني الذي حكاه الربيع عن الشافعي هو الذي رجحه النووي.

فالجواب من وجوه:

الأول: أن الشافعي لم يرجح هنا شيئا صريحا، وتقديمه لعدم الحنث قرينة في أنه يختار القول الأول.

الثاني: أن الشافعي رجح القول الأول في مواضع أخرىٰ، فيقدم ما جزم به في غير موضع علىٰ ما ذكره الربيع من قوله الثاني.

الثالث: أن الربيع شك في رواية هذا القول بقوله «فيما أعلم» لأمرين:

أولهما: أن ذلك ليس من عادة الربيع، فقد روىٰ عنه بهذه العبارة ونحوها كقوله (وله قول آخر) وقوله (وللشافعي قول آخر) وقوله (وفيه قول آخر) وقوله (وفيها قول آخر) في أكثر من تسعين موضعا من الأم، ليس في شيء منها «فيما أعلم» إلا في موضعين، أحدهما هذا، والموضع الثاني في الأم (٥/ ٢٣٣ ط. د. رفعت فوزي): باب عطية الرجل في الحرب والبحر».

ثانيهما: أن هذه الصيغة «فيما أعلم» صيغة شك في الرواية عند أهل العلم بالرواية[١]، وما لم يشك فيه في موضع مقدم علىٰ ما شك فيه في هذا الموضع.

---

(١) وللفائدة فهذه أمثلة ونُقول تبين أن هذه الصيغة تفيد الشك في الرواية:

المثال الأول: روىٰ مسلم حديثًا في صحيحه (رقم ١٨٩/ ٢٥٢٠) من رواية سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال:قال رسول الله ﷺ «قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع، موالي. ليس لهم مولىٰ دون الله ورسوله».

ثم رواه من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم أيضًا، قال مسلم: «مثلُه، غير أن في الحديث قال سعد في بعض هذا: فيما أعلم».

وقد رواه أبو عوانة في صحيحه (رقم ١١٠٠٢) من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج قال شعبة: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة به.

ثم قال أبو عوانة: رواه معاذ بن معاذ عن شعبة بلا شك، غير أنه قال: قال سعد في بعض هذا فيما أعلم».

قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٧/ ٥٥٩) في قول سعد هذا: «كأنه شكك فيها، أو خالفه غيره فيها، فأخبر بما علمه».

فجعل قوله «فيما أعلم» مترددا بين الشك، والإشارة إلىٰ المخالف، وأنه إنما روىٰ ما علم، لكن لما لم يقل مثلها في بقية الروايات دل علىٰ أن لهذا المقال معنىٰ وتأثيرا.

المثال الثاني: روىٰ أبو داود (رقم ٤٢٩١) من طريق شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة - فيما أعلم - عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة علىٰ رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».

قال في مرقاة المفاتيح (١/ ٣٤٠): قوله: «فيما أعلم»، هذا لفظ المصنف، يعني: شك بعض الناس أن أبا هريرة روىٰ هذا الحديث عن رسول الله ﷺ أم لا؟».

المثال الثالث: روىٰ أحمد (رقم ١١٣٤٩، ١١٤٢٠) من طريق سليمان اليشكري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال في الوهم يتوخىٰ قال له رجل عن النبي ﷺ قال: فيما أعلم».

قال الساعاتي في الفتح الرباني (١/ ١٦٨):« فقوله:«فيما أعلم» مشعر بأنه يشك في السماع هل سمعه من النبي ﷺ بنفسه أو بلغه بواسطة غيره، ولولا ذلك لقال سمعته».

المثال الرابع: روىٰ أحمد (رقم ٨٣٢٤) عن موسىٰ بن داود عن عبد الرحمن بن ثابت عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ - فيما أعلم شك موسىٰ - قال:« ذراري المسلمين في الجنة، يكفلهم إبراهيم».

المثال الخامس: روىٰ أحمد (رقم ١٩٠٦١) عن موسىٰ بن داود عن علي بن عابس عن أبي فزارة عن عبد الرحمن بن أبي ليلىٰ عن أبيه فيما أعلم-شك موسىٰ- « أن النبي ﷺ اعتكف في قبة من خوص».

المثال السادس: روىٰ أحمد (رقم ١٠١١٩) عن يحيىٰ القطان عن سفيان الثوري عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ - فيما أعلم شك يحيىٰ - قال:

[١٤٥]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٧١ ط. الحداد): «وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت عينه ظاهرة».

ما ذكره النووي هنا من اشتراط ظهور العين، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٩٥) ولفظه: «وإن جعله في عصيدة فأكلها حنث إن كانت عينه ظاهرة فيها، وإن صار مستهلكا لم يحنث».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٣٠٢): «وإن جعله في عصيدة أو سويق، فعن نص الشافعي ﵁: أنه يحنث، وعنه فيما إذا حلف لا يأكل خلا؛ فأكل السكباج أنه لا يحنث.

«دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار في المساكين، ودينار في رقبة، ودينار في أهلك، أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه علىٰ أهلك».

فنص أحمد بن حنبل في هذه الأمثلة علىٰ أن موسىٰ بن داود شك فقال: فيما أعلم«، ودل ذلك علىٰ أن هذه الصيغة للشك في الرواية.

المثال السابع: روىٰ الفراء في معاني القرآن (٣/ ١٢٩) عن الفضيل بن عياض عن منصور عن المنهال بن عمرو رفعه إلىٰ عبد الله فيما أعلم - شك الفراء - قال{ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ} [الواقعة ٧٥] قال: بمحكم القرآن، وكان ينزل علىٰ النبي صلىٰ الله عليه نجوما».

فهذه الأمثلة وأمثالها تدل علىٰ أن النص المروي بهذه الصيغة غير محقق الثبوت، بل دخل في روايته الشك.

فقال عامة الأصحاب: ليس ذلك باختلاف قول، ولكن إن كان السمن ظاهرا في العصيدة والسويق يرىٰ جرمه، فيحنث إذا أكله، وهذه الحالة هي التي أرادها بنصه في السمن، وكذا الحكم في الخل، إذا كان ظاهرا بلونه وطعمه؛ بأن أكل المرقة وهي حامضة.

وإن كان السمن مستهلكا في العصيدة، فأكله لم يحنث، وكذا الخل إذا كان مستهلكا، وهذه الحالة هي التي أرادها بنصه في الخل«، وتبعه النووي في الروضة (١١/ ٤٣، ٤٤).

وما ذكر من النص علىٰ السّمن في العصيدة والسويق لم يذكره غيره، وهو قول الإمام في النهاية (١٨/ ٣٩٧ وما بعدها) وعزاه الماوردي في الحاوي (١٥/ ٤١٩) للشافعي وجمهور أصحابه.

○ قال أبو عبد الباري:

الصواب المعتمد الحنث في السمن مطلقا، لأنه لا يؤكل إلا بغيره، وهو المنصوص للشافعي:

قال الشافعي في الأم (٨/ ١٨٠-١٨١ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا حلف أن لا يأكل سمنا، فأكل السمن بالخبز، أو بالعصيدة، أو بالسويق حنث؛ لأن السمن

هكذا لا يؤكل، إنما يؤكل بغيره، ولا يكون مأكولا إلا بغيره، إلا أن يكون جامدا، فيقدر علىٰ أن يأكله جامدا منفردا».

وفي مختصر المزني (٢/ ٦١٤ ط. الداغستاني): «ولو حلف لا يأكل سمنا، فأكله بالخبز أو بالعصيدة أو بالسويق حنث؛ لأن السمن لا يكون مأكولا إلا بغيره، إلا أن يكون جامدا فيقدر علىٰ أن يأكله جامدا منفردا».

فأطلق الشافعي الحنث، وعلله بأن السمن يؤكل بغيره ما لم يكن جامدا، فدل علىٰ أن اشتراط ظهور عينه مخالف لنص الشافعي.

وهكذا أطلقه العمراني في البيان (١١/ ٥٤٠) فقال: «وإن حلف لا يأكل سمنا، نظرت في السمن، فإن كان جامدا، فأكله منفردا حنث؛ لأنه أكل المحلوف عليه، وإن أكله بالخبز، أو السويق، أو العصيدة حنث».

والظاهر أن اشتراط ظهور عينه قول مُخرَّج من قول الشافعي في الخل، وهو قوله في الأم (٧/ ٨٤) فيمن قال: «لا آكل خلا، فأكل مرقا فيه خل فلا حنث عليه، لأن الخل مستهلك فيه».

ففرق بين المستهلك في غيره، وبين ما لم يستهلك في غيره، وهو ما يبقي منه شيء، فيكون الاشتراط مخرجا من مسألة الخل، وقد تقدم عن الرافعي ما يدل

علىٰ ذلك، وتبعه النووي عليه، وقد ذكر الأذرعي في القوت هنا (١٠/ ٣٤٣) نص الشافعي في الخل وبحثها هناك.

وقال العمراني في البيان (١٠/ ٥٤٠): «وإن أكل عصيدة متخذة بسمن، فقال الشافعي: حنث وقال: إذا حلف: لا يأكل خلا، فأكل سكباجا بخل لم يحنث.

قال أصحابنا: ليست علىٰ قولين، وإنما أراد بالخل إذا لم يكن ظاهرا، وأراد بالسمن إذا كان ظاهرا».

فهذا هو التخريج باختصار مفيد بقلم العمراني ﷺ تعالىٰ، والصواب تقرير النصين، والتفريق بين السمن والخل، فيكون حكم الشافعي في السمن مخالفا لحكمه في الخلّ.

فإن قيل: فهل من فرق بينهما في الاستهلاك؟.

أجيب: بأن التفريق بينهما في ذلك ممكن، وذلك أن السمن لا يستهلك في غيره كما يستهلك الخل في غيره، وإنما يلتزق بالشيء حتىٰ إذا وضع في الماء الحار أمكن استخلاصه من السويق، لأنه يعصد فوقه فيجمع بخلاف الخل، كما

ذكر فقهاء المالكية في تفريق ابن القاسم بينهما في الاستهلاك[١]، وقد ذكر النووي في المجموع (١/ ٦٨) في تعارض المنصوص والمخرج أن الأصل تقرير النصين، وأنه قلّ أن يتعذر الفرق بينهما.

[١٤٦]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٧١ ط. الحداد): «لا قثاء وخيار».

ما ذكره النووي هنا من أن القثاء لا يدخل في الفاكهة من زياداته علىٰ المحرر.

○ قال أبو عبد الباري:

ما رجحه النووي هنا مخالف لنص الشافعي في الأم، فإنه ذكر في (باب وقت بيع الفاكهة) أنه من الفاكهة.

قال الشافعي في الأم (٤/ ١٣٦ ط. د. رفعت فوزي): «بلغني أن التين في بعض البلدان ينبت منه الشيء اليوم، ثم يقيم الأيام، ثم ينبت منه الشيء بعد، حتىٰ يكون ذلك مرارا، والقثاء والخربز حتىٰ يبلغ بعضه، وفي موضعه من شجر القثاء والخربز ما لم يخرج فيه شيء، فكان الشجر يتفرق مع ما يخرج فيه، ولم يبع ما لم يخرج فيه، وإن كان لا يعرف لم يجز بيعه، لاختلاط المبيع منه بغير

---

(١) انظر: الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٤٠٨) والتاج والإكليل (٤/ ٤٥٤) وجواهر الدرر (٣/ ٤٦٧).

المبيع، فيصير المبيع غير معلوم، فيأخذ مشتريه كله، أو ما حمل مما لم يشتر، فإن بيع وهو هكذا، فالبيع مفسوخ».

فجعل الخزبر -البطيخ- والقثاء واحدا في الوصف والحكم، فيلزم أن يكونا من الفاكهة كما هو عنوان تبويب الشافعي.

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٨٨-٨٩ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يؤخذ في شيء من الثفاء ولا الأسبيوش؛ لأن الأكثر من هذا أنه ينبت للدواء، ولا مما في معناه من حبوب الأدوية، ولا من حبوب البقل؛ لأنها كالفاكهة، وكذلك القثاء، والبطيخ وحبه لا زكاة فيه؛ لأنه كالفاكهة».

ونحوه في الأم (٣/ ٩٠ ط. د. رفعت فوزي) ومختصر المزني (١/ ٢٦٥) وزاد: « لا أعلمه يؤكل إلا دواء أو تفكها».

فجعل القثاء هنا والبطيخ سواء، وقال: لأنهما كالفاكهة، فيلزم استواؤهما في الحكم، ولا نعلم للشافعي نصا يخالف هذا ويذكر فيه أنهما ليسا من الفاكهة أو أحدهما.

وقد سوىٰ الشافعي أيضا بين القثاء والخيار والخزبر والأترج في الحكم كما في الأم (٤/ ٤٥ ط. د. رفعت فوزي) فالحكم استواؤها في هذا الباب أيضا.

وأما تفريق النووي بين الخيار والقثاء وبين البطيخ بقوله في الروضة (١١/ ٤٣): «ويحنث بالبطيخ علىٰ الأصح، وبه قال ابن سريج، لأن له نضجا

وإدراكا»، فمردود بأن لهما نضوجا أيضا كالبطيخ.

وقد نقل النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٨٠) عن الجوهري أنه قال: «القثاء: الخيار والواحدة قثاءة» ولم ينكره فكان ذلك منه موافقة.

قال الشافعي في الأم (٤/ ١٠٠ ط. د. رفعت فوزي): «وأما القثاء فيؤكل صغارا طيبا، فبدو صلاحه أن يتناهىٰ عظمه، أو عظم بعضه».

وقال الشافعي في الأم (٤/ ٢٦٦ ط. د. رفعت فوزي): «فأما البطيخ فليس في طعمه ألوان، ويقول: عظام أو صغار، ويقول في القثاء هكذا، فيقول: قثاء طوال، وقثاء مدحرجا، وخيارا يصفه بالعظم والصغر والوزن».

وقال الشافعي في الأم (٨/ ٦٠٥-٦٠٦ ط. د. رفعت فوزي): «لا يحل بيع القثاء ولا الخربز، وإن ظهر وعظم حتىٰ يرىٰ فيه النضج».

فسوىٰ الشّافعي بين البطيخ والخيار والثقاء في هذه الأوصاف، فتبين أن حكمهما والبطيخ واحد، والله أعلم.

وفي تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ٤٩٥):قول «المنهاج»: «لا قثاء وخيار» مخالف لمقتضىٰ نص «الأم» في (باب وقت بيع الفاكهة) فإنه ذكر فيه القثاء والخربز، وهو البطيخ، وقد صحح النووي: أن البطيخ من الفاكهة، فكذلك

القثاء، وفي معناه الخيار».

[١٤٧]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٧٢ ط. الحداد): «حلف لا يأكل هذه التمرة، فاختلطت بتمر، فأكله إلا تمرة، لم يحنث».

ما ذكره النووي هنا من الإطلاق تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٩٧) ولفظه: «إذا حلف لا يأكل هذه التمرة، فوقعت في صبرة ثمر، فأكل الجميع حنث، وإن بقيت واحدة لم يحنث».

وهكذا قال في الشرح الكبير (١٢/ ٢٩٢) وتبعه النووي في الروضة (١١/ ٣٦).

○ قال أبو عبد الباري:

وما ذكراه هنا من الإطلاق مخالف لنص الشافعي في «الأم» و«المختصر» من تقييد ذلك بما إذا لم يستيقن أن تلك التمرة فيما أكل.

قال الشافعي في الأم (٨/ ١٨١ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا حلف أن لا يأكل هذه التمرة، فوقعت في التمر، فأكل التمر كله حنث؛ لأنه قد أكلها، وإن بقي من التمر كله واحدة، أو هلكت من التمر كله واحدة لم يحنث، إلا أن يكون يستيقن أنها فيما أكل، وهذا في الحكم، والورع أن لا يأكل منه شيئا إلا حنَّث نفسه إن

أكله».

وفي مختصر المزني (٢/ ٦١٤ ط. الداغستاني): «وإذا حلف لا يأكل هذه التمرة، فوقعت في تمر فإن أكله إلا تمرة أو هلكت منه تمرة لم يحنث حتىٰ يستيقن أنه أكلها، والورع أن يحنث نفسه».

وفي هذين النصين أنه يحنث إذا استيقن أن تلك التمرة فيما أكل خلافا لإطلاق النووي تبعا للرافعي في نفي الحنث، والعبرة هنا في اليقين ولو لم يأكل أكثرها، فإنه قد يستيقن أن تلك التمرة فيما أكل لوجود علامة عليها، أو أن الباقي لا يمكن أن يكون تلك التمرة.

ولهذا قال الجويني في النهاية (١٨/ ٣٤٨): «نقول في مسألة الخلط: المتبع اليقين، وكل ما عداه غلط غير معتد به».

وكذلك صنع الماوردي في الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٠-٤٢١) وجعل الأحوال ثلاثة:

أولها: أن يستيقن أن تلك التمرة فيما أكل فيحنث.

ثانيها: أن يستيقن عكسها فلا يحنث.

ثالثها: أن يشك فلا يحنث، لأن الحنث لا يقع بالشك.

فتبين بذلك أن العبرة باليقين، وأن إطلاق النووي يلزم تقييده بما تقدم.

وهكذا قال المحاملي في اللباب (ص ٤٠٤) والشيرازي في التنبيه (ص ١٩٨) واختاره ابن النقيب في عمدة السالك (ص ٢٤٣) وزكريا الأنصاري في أسنىٰ المطالب (٤/ ٢٥٤) وبه قيده جملة من الشراح كالهيتمي (١٠/ ٤٤) والرملي (٨/ ٢٠٣).

ومما يؤيد ذلك ما في آخر الباب من المنهاج (٣/ ٣٧٩ ط. الحداد) فيمن حلف لا يأكل طعاما، أو من طعام اشتراه زيد، فاختلط بغيره أنه لا يحنث «حتىٰ يتيقن أكله من ماله»، فبنىٰ هنا الحكم علىٰ اليقين وهو الصواب الموافق لظاهر نص الشافعي.

[١٤٨] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٧٣ ط. الحداد): «وإن مات، أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث».

جزم النووي هنا لزوم الحنث إذا تمكن من فعله بعد دخول الوقت المحلوف فيه، وتابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٥٩٧، ١٥٩٨) ولفظه: «وإن مات أو تلف الطعام بعد مجيء الغد، فإن كان بعد التمكن من الأكل حنث».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٣٣٢) بعد ذكر الخلاف: «لكنّ الأظهر - وإن ثبت الخلاف -: أنه يحنث»، وتبعه النووي في الروضة (١١/ ٦٨).

وما رجحاه هنا تبعا فيه البغوي في التهذيب، فإنه قال فيه (٨/ ١٣٦): «ولو مات وتلف الطعام أو بعضه بعد مجيء الغد، نظر: إن كان بعد التمكن من الأكل حنث، وإن كان قبله، فعلىٰ قولي المكره».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكروه من الحنث مخالف لظاهر نصوص الشافعي في الأم والبويطي.

قال الشافعي في الأم (٨/ ١٧٥ ط. د. رفعت فوزي): «لو حلف ليعطينه حقه غدا، فمات من الغد بعلمه أو بغير علمه، لم يحنث».

وقال الشافعي في الأم (٨/ ١٧٥-١٧٦ ط. د. رفعت فوزي): «إن حلف ليقضينه ليلة يهل الهلال، فخرجت الليلة التي يهل فيها الهلال حنث، كما يحنث لو حلف ليقضينه حقه يوم الاثنين، فغابت الشمس يوم الاثنين حنث».

و في مختصر البويطي (ص ٩١٦ ط. القره داغي): «وإن حلف رجل ليذبحن هذا الطير، أو ليضربن هذا العبد، أو ليبتاعن بهذا الدينار طعاما، ثم تلف الدينار، ومات الطير، وأبق العبد، فإن كان وقَّت في ذلك وقتا، فتلف ذلك قبل مضي الوقت فلا شيء عليه».

وهذه النصوص صريحة في أن الحنث إنما يجب بمضي الوقت الذي هو ظرف للحلف، فهذا هو المعتمد الصحيح عن الإمام رحمه الله.

وفي تحرير الولي العراقي (٣/ ٤٩٧) عن البلقيني أنه قال في تصحيح المنهاج: «استقر الجواب عندنا أنه لا يحنث مع بقاء وقت يمكن فيه البر لو بقي الطعام، واستدل لذلك بقول الشافعي ﷺ في «الأم»: «لو حلف ليعطينه حقه غدًا، فمات من الغد بعلمه أو بغير علمه .. لم يحنث»، قال: ولم يفرق بين أن يتمكن الحالف من إعطائه في الغد وبين ألّا يتمكن، وأشار إلىٰ ذلك بقوله: (بعلمه أو بغير علمه).

وفي التدريب للبلقيني (٤/ ٣٠١): «وإن مات أو تلف الطعام في غد بعد غلته من أكله لا يحنث علىٰ النص، مع بقاء الوقت الذي يمكن فيه البر لو بقي الطعام. قال: وهو المذهب المعتمد».

وإنما علق الشافعي الحنث علىٰ الإمكان فيما إذا لم يوقت الحالف، ففي مختصر البويطي (ص ٩١٦، ٩١٧ ط. القره داغي): «وإن كان لم يوقت فأمكنه أن يفعل فلم يفعل حتىٰ تلف ذلك الشيء فهو حانث، وإن كان لم يفرط حتىٰ تلف ذلك الشيء فلا شيء عليه».

وقال فيه أيضا (ص ٩١٨ ط. القره داغي): «وإن حلف أن يقضي فلانا هذا الشيء بعينه، فغلب علىٰ ذلك الشيء قبل وقت أجله، فلا حنث عليه، وإن كان لم يوقت وأمكنه أن يقضيه فلم يقضه فهو حانث».

فهذا كله فيما إذا لم يوقت الحلف، وتمكن من الفعل، وأما من وقت كما هي

مسألة الباب، فإنما يحنث إذا مضىٰ الوقت الذي وقّت فيه حلفه، وأما مع بقاء الوقت فلا حنث عليه بالتلف أو الموت.

[١٤٩]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٧٨ ط. الحداد): «أو لا ينكح، حنث بعقد وكيله له، لا بقبوله لغيره».

جزم النووي هنا عدم الحنث في قبول وكيله له، تبعا للرافعي في المحرر (ص ١٦٠٤) ولفظه: «ولو حلف لا ينكح، فقبل له النكاح وكيله حنث، ولو قبل هو لغيره لم يحنث».

وقد جزم بذلك الرافعي أيضا في الشرح الكبير (٧/ ٥٦٩).

وحكىٰ الرافعي (١٢/ ٣٠٨) والنووي في الروضة (١١/ ٤٧-٤٨) عن المتولي وجهين فقال: «ولو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة، فهل يحنث؟ وجهان حكاهما المتولي:

أحدهما: لا، كالبيع، وبه قطع الصيدلاني، والغزالي.

والثاني: نعم، لأن الوكيل هنا سفير محض، ولهذا يجب تسمية الموكل، وبه قطع البغوي»[(١)].

(١) التهذيب (٨/ ١٤٢).

○ قال أبو عبد الباري:

ظاهر نص الشافعي عدم الحنث، وهو قول أكثر الأصحاب.

قال الشافعي في الأم (٨/ ١٧٦-١٧٧ ط. د. رفعت فوزي): «إذا حلف ألا يشتري عبدا، فأمر غيره فاشترىٰ له عبدا لم يحنث، إلا أن يكون نوىٰ أن لا يشتريه، ولا يشترىٰ له؛ لأنه لم يكن ولي عقدة شرائه، والذي ولي عقدة شرائه غيره، وعليه العهدة، ألا ترىٰ أن الذي ولي عقد شرائه لو زاد في ثمنه علىٰ ما يباع به مثله ما لا يتغابن الناس فيه، أو برئ من عيب لزمه البيع، وكان للآمر لا يأخذ بشراء غيره غير شرائه.

قال الشافعي ﷺ: وإذا حلف الرجل أن لا يطلق امرأته، فجعل أمرها بيدها، فطلقت نفسها لم يحنث، إلا أن يكون جعل إليها طلاقها، وكذلك لو جعل أمرها إلىٰ غيرها فطلقها.

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا حلف ليضربن عبده، فأمر غيره فضربه لم يبر إلا أن يكون نوىٰ ليضربن بأمره، وهكذا لو حلف أن لا يضربه، فأمر غيره فضربه لم يحنث، إلا أن يكون نوىٰ أن لا يأمر غيره بضربه».

وفي مختصر المزني (٢/ ٦٠٩ ط. الداغستاني): «ولو حلف لا يشتري، فأمر غيره فاشترىٰ، أو لا يطلق، فجعل طلاقها إليها فطلقت، أو لا يضرب عبده، فأمر

غيره فضربه .. أنه لا يحنث، إلا أن يكون نوىٰ ذلك».

وظاهر ذلك أن من أمر غيره بفعل ما حلف علىٰ أن لا يفعله لم يحنث، لأنه حلف علىٰ فعل نفسه، لا علىٰ فعل غيره، ولم يثبت عنه ما يبنىٰ عليه ما استثناه المصنف.

وأما الأصحاب: فقد جزم به الماوردي في الحاوي (١٥/ ٣٧٨) وقال: «الصحيح أن جميعها سواء في أنه لا يحنث الآمر بها والموكل فيها إذا كان العرف بمباشرته لها جاريا، لأن الأيمان تحمل علىٰ حقائق الأسماء والأفعال، ما لم ينقلها عرف الحقيقة في هذه الأفعال بمباشرتها، والعرف مقترن بها، فلم يجز أن يعدل في الأمر بها عن الحقيقة والعرف إلىٰ مجاز تجرد عن العرف فعلىٰ هذا لو حلف علىٰ امرأته أنه لا يطلقها، فرد إليها الطلاق، فطلقت نفسها لم يحنث، لأنه لا يكون مطلقا، وإنما يكون مخيرا في الطلاق، ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلتها طلقت وحنث، لأنه مطلق لها علىٰ صفة وقعت منها فلذلك افترقا».

وكذلك الإمام الجويني (١٨/ ٣٧٤) وحكىٰ عن الأصحاب أنهم قطعوا هذا في الطرق، فقال: «ولو قال: لا أتزوج، فانتصب وكيلا، وقبل نكاح امرأة لموكله، لم يحنث، وليس ما جاء به تزوجا منه، وإنما هو سفارة، والنكاح مضاف إلىٰ

الموكل، وسر الفصل أنه عقد اليمين علىٰ التزوج المطلق، ولا يصح من الوكيل بالتزوج مطلق لفظ التزوج حتىٰ يضيفه، وما لا يستقل إلا مضافا لا يندرج تحت المطلق الذي لم يضف.

والغرض من هذا يبين بصورتين، فإذا قال زيد: لا أتزوج، وقال عمرو: لا أتزوج، ثم وكل زيد عمرا حتىٰ يقبل له نكاح امرأة، فلا يحنث الموكل، ولا الوكيل، أما الموكل؛ فلأنه، لم يتعاط التزوج، بل تزوج الوكيل له، وأما الوكيل لم يتزوج مطلقا، فلم يحنث واحد منهما، وقد قطع الأصحاب بهذا في الطرق».

ووكذلك القفال في الحلية (٧/ ٢٩٣-٢٩٤) فقال: «وإن حلف: لا يتزوج، أو لا يطلق، فأمر غيره فطلق عنه، أو تزوج له لم يحنث».

وكذلك العمراني في البيان (١٠/ ٥٦١-٥٦٢) فقال: «وإن حلف: لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا يضرب عبده، أو لا يتزوج، أو لا يطلق، فأمر غيره، فباع عنه، أو اشترىٰ، أو ضرب العبد، أو نكح له، أو طلق.. لم يحنث.

وحكىٰ الربيع عن الشافعي قولا آخر: إذا كان الحالف سلطانا لا يتولىٰ البيع ولا الشراء ولا الضرب بنفسه، فأمر غيره، ففعل عنه ذلك حنث، وإن أمر غيره فنكح له، أو طلق عنه لم يحنث؛ لأن العادة أنه لا يتولىٰ البيع ولا الشراء ولا

الضرب بنفسه، وإنما يتولاه غيره عنه، وجرت العادة في النكاح والطلاق أنه يتولاه بنفسه، فانعقدت يمينه علىٰ ذلك»[(١)].

والمشهور: هو الأول؛ لأن اليمين تحمل علىٰ الحقيقة دون المجاز؛ ولهذا: لو حلف: لا أقعد في ضوء السراج، فقعد في ضوء الشمس لم يحنث».

وكذلك الشيرازي في التنبيه (ص ١٩٧، ١٩٨) فقال: «وإن حلف لا يتزوج

---

(١) نص رواية الربيع في الأم (٨/ ١٧٧ ط. د. رفعت فوزي): «قال الربيع: للشافعي رضي الله عنه في مثل هذا قول في موضع آخر: فإذا حلف ليضربن عبده، فإن كان ممن يلي الأشياء بيده فلا يبر حتىٰ يضربه بيده، فإن كان مثل الوالي، أو ممن لا يلي الأشياء بيده، فالأغلب أنه إنما يأمر؛ فإذا أمر فضرب فقد برّ».

وعلق عليه الجويني في النهاية (١٨/ ٣٧٤) فقال:« ولو قال: «لا أضرب فلانا»، وكان ممّن يتعاطىٰ مثلُه الضربَ، فأمر غيره حتىٰ ضرب لم يحنث، وإن كان محتشما لا يتعاطىٰ الضرب بنفسه، فأمر غيره حتىٰ ضرب، فالنصّ وما إليه مصير الأصحاب أنه لا يحنث، إذا كان اللفظ مطلقًا، وقال الربيع: إذا حصل الضرب بأمر من لا يتعاطىٰ الضربَ، كان ذلك بمثابة صدور الضرب منه.

وهذا وإن ألحق بالمذهب بعيدٌ، لا تعويل عليه، ثم إنما يجري في الفعل الذي وصفناه وأمثاله، فأما العقود، فيتعاطاها العظماء والأماثل».

وقال القفال الشاشي في الحلية (٧/ ٢٩٤): «فإن حلف: لا بعت أولا ضربت، فأمر غيره حتىٰ باع، أو ضرب، وكان ممن لا يتولىٰ الضرب، كالسلطان فالمنصوص: أنه لا يحنث.

وقال الربيع: فيه قول آخر أنه يحنث، والأول أصح».

أو لا يطلق فوكل فيه غيره حتىٰ فعله لم يحنث»[(١)].

وفي تحرير العراقي (٣/ ٥٠٥) عن البلقيني: «ولم أر أحدًا اعتمد مقابله إلا البغوي».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٣٠٥): «وإن حلف أن لا ينكح فلا يحنث بعقد وكيله له علىٰ مقتضىٰ النص، وقال به أكثر الأصحاب، وهو المعتمد في الفتوىٰ، خلافا لما في «المنهاج» تبعا لأصله، وكذا لا يحنث بقبوله هو لغيره».



(١) وقال في المهذب (٣/ ١١٢): «وإن حلف لا يتزوج أولا يطلق، فأمر غيره حتىٰ تزوج له، أو طلق عنه لم يحنث، لأنه حلف علىٰ فعله نفسه ولم يفعل».



كتاب النذر

[١٥٠]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٨١ ط. الحداد): «هو ضربان: نذر لجاج كإن كلمته فلله علي عتق أو صوم، وفيه كفارة يمين، وفي قول: ما التزم، وفي قول أيهما شاء، قلت: الثالث أظهر، ورجحه العراقيون والله أعلم».

رجح النووي القول الثالث هنا، وهو أنه مخير بينهما، وأما الرافعي فرجح في المحرر (ص ١٦٠٨) الأول فقال: «وأصحها: أن عليه كفارة اليمين».

وقال في الشرح الكبير (١٢/ ٢٤٩): «الأصح علىٰ ما ذكر صاحب «التهذيب» وإبراهيم المروزي والموفق بن طاهر وغيرهم».

وأما النووي فرجح في الروضة (٣/ ٢٩٥) ما رجحه في «المنهاج» فقال: «قلت: الأظهر: التخيير بين الجميع والله أعلم».

ورجحه أيضا الشيرازي في التنبيه (ص ٨٥) فقال: «ومن نذر شيئًا علىٰ وجه اللجاج؛ بأن قال: «إن كلمت فلانًا فعليّ كذا» فهو بالخيار عند وجود الشرط بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين».

وقال أبو الطيب الطبري في تعليقته (ص ٧٣٧ تحقيق أحمد الغامدي) إنه المذهب.

وقال الرافعي في فتح العزيز (١٢/ ٢٤٩): «والأقوال معزية إلىٰ نصوص الشافعي ﷺ في مواضع وصور مختلفة، ويقال: إن قول التخيير مخرج غير منصوص».

○ قال أبو عبد الباري:

المعتمد المنصوص هو القول الأول، وهو وجوب كفارة اليمين في نذر اللجاج، وذلك أن الشافعي فرق بين نذر اللجاج، ونذر التبرر، فجعل نذر اللجاج مثل اليمين، وقال: إنه في معنىٰ الأيمان لا النذور، وأوجب فيه كفارة يمين فقط، وأما في نذر التبرر فأوجب ما التزمه الناذر، وهذا كله في غير العتق والطلاق، فيستوي فيهما نذر اللجاج والتبرر، لتعلق حق الآدميين بهما.

قال الشافعي في الأم (٦/ ٦٧١ ط. د. رفعت فوزي): «والفرق بين العتق والطلاق ما وصفت، أن العتق والطلاق حقان لآدميين بأعيانهما، يقعان بإيقاع صاحبهما، ويلزمان تبررا أو غير تبرر، وما سوىٰ هذا إنما يلزم بالتبرر».

فعلم من ذلك أن الواجب في نذر اللجاج كفارة يمين فقط، وقد تضافرت نصوصه في الأم والمزني والبويطي علىٰ ذلك، وهذه جملة منها:

قال الشافعي في الأم (٣/ ٦٥٥ ط. د. رفعت فوزي): «نقول فيمن قال: «عليَّ نذر إن كلمت فلانا، أو علي نذر أن أكلم فلانا، يريد هجرته، أن عليه كفارة يمين».

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٦٥٩ ط. د. رفعت فوزي): «إذا قال: إن لم أقضك

حقك فعليَّ المشي إلىٰ بيت الله، فهذا من معاني الأيمان، لا معاني النذور».

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٦٥٦-٦٥٩ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا حلف الرجل في كل شيء سوىٰ العتق والطلاق من قوله: مالي هذا في سبيل الله، أو داري هذه في سبيل الله، أو غير ذلك مما يملك صدقة، أو في سبيل الله، إذا كان علىٰ معاني الأيمان، فالذي يذهب إليه عطاء: أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين.

ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوىٰ عتق أو طلاق.

وهو مذهب عائشة رضي الله عنها، والقياس، ومذهب عدة من أصحاب النبي ﷺ والله أعلم.

وقال غيره: يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال: ويحبس قدر ما يقوته، فإذا أيسر تصدق بالذي حبس.

وذهب غيره: إلىٰ أنه يتصدق بثلث ماله.

وذهب غيره: إلىٰ أنه يتصدق بزكاة ماله، قال: وسواء قال: صدقة، أو قال: في سبيل الله، إذا كانت علىٰ معاني الأيمان».

وقال الشافعي في الأم أيضا (٣/ ٥٦٨ ط. د. رفعت فوزي): «ومن حلف بصدقة ماله فحنث، فإن كان أراد يمينا فكفارة يمين، وإن أراد بذلك تبررا، مثل أن يقول: لله علي أن أتصدق بمالي كله، تصدق به كله، لأن رسول الله ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه».

وقال الشافعي في الأم أيضا (٦/ ٦٧١ ط. د. رفعت فوزي) فيمن قال لزوجته: «علي كفارة يمين إن قربتك» أو قال لها: «مالي في سبيل الله تعالىٰ، أو علي مشي إلىٰ بيت الله، أو علي صوم كذا، أو نحر كذا من الإبل إن قربتك، فهو مول، لأن هذا إما لزمه، وإما لزمته به كفارة يمين».

وقال في مختصر المزني (٢/ ١٧٤، ١٧٥): «ولو قال: إن قربتك فلله علي أن أعتق فلانا عن ظهاري، وهو متظاهر لم يكن موليا، وليس عليه أن يعتق فلانا عن ظهاره، وعليه فيه كفارة يمين».

وقال في مختصر المزني أيضا (٢/ ٦١٧، ٦١٨): «قال: ومن حنث في المشي إلىٰ بيت الله، ففيه قولان: أحدهما وهو قول عطاء: كفارة يمين، ومذهبه أن أعمال البر لا تكون إلا ما فرض الله أو تبررا يراد به الله، قال الشافعي: والتبرر أن يقول: لله علي إن شفاني أن أحج له نذرا، فأما إن لم أقضك حقك فعلي المشي إلىٰ بيت الله، فهذا من معاني الأيمان، لا معاني النذور».

قال المزني: «قد قطع بأنه قول عدد من أصحاب النبي ﷺ والقياس، وقد قال في غير هذا الموضع: لو قال: لله علي نذر حج إن شاء فلان، فشاء لم يكن عليه نذر، إنما النذر ما أريد به الله ﷻ، ليس علىٰ معاني الغلق، والشائي غير الناذر».

وقال في مختصر البويطي (ص ٩١٢ ط. القره داغي): «وإن قال: «مالي في سبيل الله، أو في المساكين، أو في رتاج الكعبة، أو هدي، أو قال ذلك في شيء من ماله بعينه، فإن كان أراد به الشكر والتقرب إلىٰ الله ﷻ فإن كان أوجبه فعليه إخراجه، وإن استشار أمر بالثلث مثل أبي لبابة، وإن كان عقد ذلك علىٰ موضع اليمين لم يكن عليه إلا الكفارة، وقد روي الكفارة في الصدقة عن عائشة زوج النبي ﷺ وعن عطاء والحسن».

وقال في مختصر البويطي أيضا (ص ٩١٣ ط. القره داغي): «ومن قال: عليه المشي إلىٰ بيت الله، أو إلىٰ الصفا، أو إلىٰ المروة، أو إلىٰ الحرم، فإن كان أراد الشكر والتقرب إلىٰ الله ﷻ فعليه أن يمشي، فإن عجز ركب وأهدىٰ، فإن كان إنما عقد ذلك في يمين فليس عليه إلا كفارة يمين، وقد رويت الكفارة عن عطاء والحسن».

هذه نصوص الشافعي، وهو الصحيح المعتمد عن الإمام الشافعي، وحكىٰ الأذرعي في القوت (١٠/ ٤٤٨) عن القاضي حسين أنه المذهب.

وعزاه البلقيني إلىٰ الإمام والفوراني والخوارزمي كما في تحرير العراقي (٣/ ٥١٤).

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٣٠٨): «هو الذي أفتىٰ به الشافعي،

والصحابة قبله والتابعون، ورجحه جمع كثير من أصحابه، فهو المعتمد في الفتوىٰ».

وأما القول الذي رجحه النووي وجعله الأظهر فليس بمنصوص للشافعي، وإنما هو قول مخرج، كما تقدم عن الرافعي.

وقال البلقيني كما في تحرير الفتاوىٰ للولي العراقي (٣/ ٥١٤): «ولم أجد القول الثالث - وهو التخيير - في منصوصاته، وقد يستشعر من بعض كلامه».

[١٥١] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٨٢ ط. الحداد): «ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه، لكن إن خالف لزمه كفارة يمين علىٰ المرجح».

هكذا قال النووي هنا، وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٦٠٩-١٦١٠) ولفظه: «وكذلك نذر فعل المباح أو تركه لا يوجب الوفاء، ولكنه يمين علىٰ ما رجح من المذهب».

وقد تابعا كالعادة[١] البغوي في التهذيب فإنه قال فيه (٨/ ١٥٢): «الإتيان بالمباحات، أو الإعراض عنها لا يلزم بالنذر، مثل: إن نذر أن يأكل أو يشرب، أو لا يأكل ولا يشرب- فلا يلزم بالنذر؛ لما روي عن ابن عباس قال: «بينما النبي

(١) قاله الأذرعي في القوت (١٠/ ٤٦٣).

ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي ﷺ: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه»[(١)] غير أنه يمين علىٰ ظاهر المذهب، فإذا نذر ألا يفعل ففعل، أو نذر أو يفعل، فلم يفعل - تلزمه كفارة اليمين».

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا كله مخالف لنصوص الشافعي، فالصحيح المعتمد عنه أنه لا شيء عليه، وليس له حكم كفارة اليمين.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٦٦٢-٦٦٣ ط. د. رفعت فوزي): «ولو أن رجلا قال: إن شفىٰ الله فلانا فلله علي أن أمشي، لم يكن عليه مشي حتىٰ يكون نوىٰ مشيا يكون مثله برا، فإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه، لأنه ليس في المشي إلىٰ غير مواضع البِرِّ بِرٌّ.

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو نذر فقال: علي المشي إلىٰ إفريقية، أو العراق، أو غيرهما من البلدان، لم يكن عليه شيء، لأنه ليس لله طاعة في المشي إلىٰ شيء من البلدان، وإنما يكون المشي إلىٰ المواضع التي يرتجىٰ فيها البر».

وفي مختصر المزني (٢/ ٦١٩): «ولو قال: علي أن أمشي لم يكن عليه مشي

---

(١) رواه البخاري (رقم ٦٧٠٤).

حتىٰ يكون نوىٰ، فإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه؛ لأنه ليس في المشي إلىٰ غير مواضع التبرر بر».

وهذه النصوص صريحة في أنه لا كفارة في نذر المباح، وهو الذي رجحه الرافعي في الشرح الكبير، والنووي في الروضة والمجموع.

قال الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٣٦٣): «القسم الثالث: المباحات التي لم يرد فيها استحباب وترغيب، كالأكل والنوم والقيام والقعود، فلو نذر فعلها أو تركها، لم ينعقد نذره، روي عن ابن عباس ﵄ قال: «بينما رسول الله ﷺ يخطب، إذا برجل قائم في الشمس، فسأل عنه، فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم، ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ: «مروه، فليتكلم، وليستظل وليقعد، وليتم صومه».

ثم حكىٰ وجوب كفارة اليمين عند المخالفة عن القاضي حسين من الشافعية.

وتبعه النووي في الروضة (٣/ ٣٠٣) فقال: «وأما المباح فالذي لم يرد فيه ترغيب، كالأكل، والنوم، والقيام، والقعود، فلو نذر فعلها أو تركها، لم ينعقد نذره».

وقال في المجموع (٨/ ٤٥٨): «إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور».

وذكر في الروضة (٣/ ٣٠٣) والمجموع (٨/ ٤٥٥) أنه مثل نذر المعاصي

والفروض[(١)].

فتبين مما سبق أنه لا كفارة في نذر المباح علىٰ المعتمد المنصوص، وهو اختيار الرافعي في الشرح والنووي في الروضة والمجموع.

[١٥٢]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٣٨٤ ط. الحداد): «فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما، ويقضي أثانينهما، وفي قول: لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر، قلت: ذا القول أظهر، والله أعلم».

رجح النووي هنا عدم وجوب قضاء يوم النذر إذا وافق صوم كفارة وجبت

---

(١) والذي قرره في المنهاج والروضة أنه لا كفارة في نذر المعصية والفرض.

قال في المنهاج (٣/ ٣٨١ ط. الحداد):« ولا يصح نذر معصية، ولا واجب».

وقال في الروضة (٣/ ٣٠٠):« الركن الثالث: المنذور. الملتزم بالنذر: معصية، أو طاعة، أو مباح، فالمعصية: كنذر شرب الخمر، أو الزنا، أو القتل، أو الصلاة في حال الحدث، أو الصوم في حال الحيض، أو القراءة حال الجنابة، أو نذر ذبح نفسه أو ولده، فلا ينعقد نذره، فإن لم يفعل المعصية المنذورة، فقد أحسن، ولا كفارة عليه علىٰ المذهب، وبه قطع جمهور الأصحاب».

خلاصته: أنه لا نذر في معصية، ولا كفارة فيه علىٰ المذهب، وقطع به الجمهور.

وأما نذر الفرض: فقال في الروضة (٣/ ٣٠٠-٣٠١):« وكذ لو نذر أن لا يشرب الخمر، ولا يزني، وسواء علق ذلك بحصول نعمة، أو التزمه ابتداء، وإذا خالف ما ذكره ففي لزوم الكفارة ما سبق في قسم المعصية، وادعىٰ صاحب «التهذيب« أن الظاهر هنا وجوبها».

عليه قبل النذر.

وقد جعل النووي الخلاف هنا قولين، ورجح في الروضة أنه وجهان، فقال (٣/ ٣١٧): «وإن لزمت الكفارة قبله، فوجهان. وقيل: قولان» وكذلك فعل في شرح المهذب (٨/ ٤٨٣) وجزم أن المنصوص في رواية الربيع الوجوب.

وممن جعل الخلاف وجهين الماوردي في الحاوي (١٥/ ٤٩٩) والغزالي في الوسيط (٧/ ٢٧١) والبغوي في التهذيب (٨/ ١٥٩-١٦٠) والشيرازي في المهذب (١/ ٤٤٦).

○ قال أبو عبد الباري:

الصواب المنصوص عليه في الأم والمختصر وجوب القضاء في هذه الصورة.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٦٦٧ ط. د. رفعت فوزي): «ولو كانت المسألة بحالها[1] وقدم فلان يوم الاثنين، وقد وجب عليه صوم شهرين متتابعين، صامهما، وقضىٰ كل اثنين منهما، ولا يشبه هذا شهر رمضان، لأن هذا شيء أدخله علىٰ نفسه بعدما أوجب عليه صوم يوم الاثنين، وصوم رمضان شيء أوجبه الله، لا شيء أدخله علىٰ نفسه».

---

(١) أي لو نذر صوم يوم قدوم فلان.

وفي مختصر المزني (٢/ ٦٢٢ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين صامهما، وقضىٰ كل اثنين فيهما، ولا يشبه شهر رمضان؛ لأن هذا شيء أدخله علىٰ نفسه بعدما وجب عليه صوم الاثنين، وشهر رمضان أوجبه الله عليه لا بشيء أدخله علىٰ نفسه».

وهذا هو المنصوص الصريح كما ترىٰ، وهو الذي رجحه البغوي في التهذيب (٨/ ١٦٠) والشيرازي في المهذب (١/ ٤٤٦) والرافعي في المحرر كما هنا.

ولوضوح النص عن الإمام قال الإسنوي في المهمات (٩/ ١٩٤): «الصواب أنه يجب، فإن الربيع قد نقله عن نص الشافعي، كذا نقله العمراني في البيان، والنووي في شرح المهذب».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٣١٠): «وإذا لزمه صوم شهرين متتابعين لكفارة، وسبقت الكفارة النذر فإنه يجب قضاء الأثانين الواقعة في شهري صوم الكفارة علىٰ المنصوص».

وفي تحرير الولي العراقي (٣/ ٥٢١) عن البلقيني أنه الأظهر المعتمد في المذهب».

وقال الأذرعي في القوت (١٠/ ٤٧٤): «الأظهر الوجوب، لأن الوقت غير

متعين لصوم الكفارة، ولو صام في الشهرين أثانينهما عن نذره لوقعت عنه، فإذا تركه قضىٰ بخلاف أثانين رمضان، وقد قال البندنيجي: بأن ذلك الوجه أو القول سهو لأن المذهب القضاء، وكذا في المهذب أنه المذهب، وممن صححه من المراوزة الشيخ أبو محمد في «مختصره» و«فروعه»، والغزالي في «خلاصته»، وغيرهما.

قال العمراني: إنه المنصوص في رواية الربيع، وبالجملة فالجمهور من الفريقين علىٰ ترجيحه، وهو ظاهر نص المختصر».





كتاب القضاء

[١٥٣]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤١٠ ط. الحداد): «وأنه يكفي: هو عدل، وقيل: يزيد: عليّ ولي».

تابع النووي هنا الرافعي في المحرر (ص ١٦٥١، ١٦٥٢) ولفظه: «وأنه - أي الأظهر - يكفي أن يقول: «إنه عدل»، والزيادة عليه بقوله «عليّ» و«لي» تأكيد».

وكذلك قال في الشرح الكبير (١٢/ ٥٠٦) ولفظه بعد ذكر الخلاف وأن نص الأم والمختصر علىٰ الاشتراط: «وقال آخرون، منهم الإصطخري وأبو علي الطبري: يكفي أن يقول: هو عدل والزيادة عليه تأكيد، وهذا أقوىٰ وأصح؛ علىٰ ما ذكره صاحب «التهذيب» وغيره»، وتبعه النووي في الروضة (١١/ ١٧٣).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ضعفه النووي بقوله «وقيل: يزيد: عليّ ولي» هو منصوص الشافعي في الأم والمختصر، فهو المعتمد خلافا للشيخين.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٥٠٩ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقفه المعدل عليه فيقول: عدل عليّ ولي».

وفي مختصر المزني (٢/ ٦٣٢): «ولا يقبل التعديل إلا بأن يقول: عدل علي ولي».

وذلك صريح في الاشتراط، وبه قال غير واحد، وهو قول أكثر الأصحاب.

قال الشاشي في الحلية (٨/ ١٣٠): «وقال أكثر أصحابنا: بظاهره».

وقال العمراني في البيان (١١/ ٥٣): «وقال أكثر أصحابنا: إن قوله: «علي ولي» شرط في التعديل».

وفي تحرير الولي العراقي (٣/ ٥٩٧) عن ابن الصباغ في «الشامل»: قال أكثر أصحابنا بظاهر لفظه».

ووجه اشتراطه: أن الشخص قد يكون عدلا جائز الشهادة تارة، ومردود الشهادة تارة أخرىٰ، فيقر بأنه عدل في الشهادة له، والشهادة عليه، وهذا يجري علىٰ قول الشافعي في الرسالة (ص ٣٩١): «العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمور ... قال: .. إذا شهد في موضع يجر به إلىٰ نفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر، أو يدفع بها عن نفسه غرما، أو إلىٰ ولده أو والده، أو يدفع بها عنهما، ومواضع الظنن سواها».

اعتراض وجوابه

فإن قيل: روي عن نصه في حرملة أنه يكفي: «هو عدل».

فالجواب من وجهين:

الأول: أن لفظ الرواية مختلف فيه، وبيانه:

قال الروياني في البحر (١١/ ١٨٤): «وقد قال في «حرملة»: إذا قال: هو عدل مرضي«كفي في التعديل».

وقال أبو الطيب الطبري في تعليقته (ص ٩٦٢ تحقيق أحمد الغامدي): «اختلف أصحابنا في لفظ التعديل، فقال أبو سعيد الاصطخري: يكفي أن يقول: هو عدل، وليس من شرطه أن يقول: عليّ ولي، نص علىٰ ذلك في حرملة، وهو قول أبي علي الطبري".

وقال أبو سعد الهروي (ت ٥١٨هـ) في الإشراف في غوامض الحكومات (ص ٧٠٦ تحقيق تحقيق أحمد بن صالح الصواب الرفاعي): «وكيفية لفظه ما نص عليه في كتاب حرملة أن يقول: «هو جائز الشهادة»، أو يقول: هو عدل مرضي، وهذا هو الأصح، ونقل المزني أن يقول: هو عدل عليّ ولي».

وذكرابن الرفعة في الكفاية (١٨/ ٢١٤) ذلك عن أبي الطيب الطبري وأبي سعد الهروي.

فهذه ثلاث صيغ حكيت بها رواية حرملة، وهي مختلفة الدلالة، وهذا يدل علىٰ أنها لم تحفظ كما ينبغي، فلا تعارض بالنصوص الصحيحة الصريحة عن الإمام.

ولهذا قال الأذرعي في القوت (١١/ ٢٧٨): «والنقل عن نصه في حرملة مختلف، فحكىٰ عنه في «الإشراف» أن يقول: «هو جائز الشهادة»، وحكىٰ في موضع ما سبق عن «البحر» وصححه، وما رجحه الرافعي والمصنف من الاكتفاء بقوله: هو عدل» تبعا للقفال والقاضي الحسين وصاحب «الإفصاح» وغيرهم ظاهر من حيث المعنىٰ، لكن قضية كلام الجمهور الوقوف مع نص «الأم» و«المختصر» كما بينته في «الغنية»، وصرح بنقله عن الأكثرين جماعة خلافا لأبي علي الطبري والاصطخري، وقال الدارمي: ولا يقبل التعديل حتىٰ يقول المعدل: عدل عليّ ولي، أو: عدل رضي، أو مرضي»، فلم يجعل نص «حرملة» مخالفا لنص «الأم»، بل اكتفىٰ بكل من اللفظين».

الثاني: أن ما في الأم والمختصر مقدم علىٰ ما في حرملة عند الاختلاف، كما تقدم في أول الكتاب عن الخطابي في معالم السنن (١/ ٤) وابن الصلاح في آداب المفتي والمستفتي (ص ١٢٦، ١٢٧) والنووي في المجموع (١/ ٦٨).

فتبين بهذا أن رواية المزني، أو الربيع المرادي مقدمة علىٰ رواية حرملة، فكيف إذا اجتمعا علىٰ خلافه، وكيف وقد اختلف في لفظها اختلافا بينا كما تقدم، لا جرم كانت رواية الربيع والمزني هي المعتمدة في هذه المسألة.





باب القسمة

[١٥٤] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٢٦ ط. الحداد): «ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فيه، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة».

فصل النووي فيما إذا استحق بعض المقسوم، وكان المستحق جزء مشاعا، فأبطل القسمة في الجزء المشاع، وصححها في الباقي بناء علىٰ اختياره السابق في صحة تفريق الصفقة وثبوت الخيار.

والنووي تابع الرافعي في المحرر (ص ١٦٧٣) ولفظه: «ولو استحق بعض ما قسم شائعا بطلت القسمة في المستحق، وفي الباقي الخلاف في تفريق الصفقة».

وقد ذكرها الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٥٥٢)، وتبعه في الروضة (١١/ ٢١٠) والتاج السبكي في الأشباه والنظائر (١/ ٣١٦).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره هنا من التفصيل مخالف لظاهر نص الأم والمختصر، ففيهما بطلان القسمة مطلقا من غير تفصيل، وعليه جرىٰ الأكثرون، وعد الإسنوي وغيره

التفصيل غلطا من الرافعي، توهمه من كلام الإمام الجويني والغزالي.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٥٢٩ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا قسمت الدار بين نفر، فاستحق بعضُها، أو لحق الميت دين فبيع بعضها، انتقض القسم».

وفي مختصر المزني (٢/ ٦٣٥ ط. الداغستاني): «وإذا استحق بعض المقسوم، أو لحق الميت دين فبيع بعضها، انتقض القسم».

وهذان النصان صريحان في بطلان القسمة مطلقا، وحملهما علىٰ المستحق فقط مبني علىٰ تصحيح الشيخين تفريق الصفقة، وقد ذكرنا في المسألة (رقم ٣٨) أول كتاب البيع أن الشافعي رجع عن القول بتصحيحها في بعضها، وأن آخر قوليه كما ذكر الربيع بطلان تفريق الصفقة.

وقد ناقش ذلك الإسنوي في المهمات (٩/ ٣١٠-٣١٢) ونذكر كلامه علىٰ طوله لنفاسته: «قوله: ولو جرت قسمة ثم استحق من المقسوم جزء شائع كالثلث بطلت القسمة في المستحق، وفي الباقي طريقان.

قال أبو علي بن أبي هريرة: إنه علىٰ الخلاف في تفريق الصفقة، وهذا ما أورده في «الكتاب» وبه أخذ أكثرهم.

وقال أبو إسحاق: تبطل القسمة قولاً واحداً، وبه أجاب الروياني في

«الحلية»؛ لأن المقصود من القسمة وهو التمييز لم يحصل. انتهىٰ.

ذكر نحوه في «الشرح الصغير» أيضـًا وفيه أمران:

أحدهما: أن النووي في «الروضة» لما اختصر هذا الكلام لم يذكر في الطريق الأول أنه علىٰ الخلاف في تفريق الصفقة، بل عبر بقوله: وفي الباقي طريقان، أصحهما قولان:

أحدهما: تبطل به.

والثاني: تصح ويثبت الخيار، وبهذا الطريق قال الأكثرون.

وقال أبو إسحاق: تبطل فيه قولاً واحداً.

هذا لفظه من غير زيادة عليه، فلزم منه عدم معرفة الصحيح في المسألة.

الأمر الثاني: أن ما نقله هاهنا عن الأكثرين من تخريجه علىٰ تفريق الصفقة حتىٰ يكون الأصح فيه الصحة عجيب جدًا وغلط فاحش، فقد أمعنت النظر في كلام الأصحاب فوجدتهم علىٰ ثلاثة أقسام:

قسم لم يصرح بالمسألة بالكلية، وهم جماعة منهم ابن سراقة في «التلقين» والفوراني في «العمد» و«الإبانة».

وقسم ذكرها ولم يصرح فيها بتصحيح، منهم القاضي أبو الطيب[(١)]، والدارمي في «الاستذكار» والشيخ في «المهذب» وابن الصباغ في «الشامل» والبغوي في «التهذيب» والشاشي في «الحلية» وشريح الروياني في كتابه المسمىٰ «بالروضة» وصاحب «البيان» وصاحب «الذخائر» والعراقي شارح «المهذب» وغيرهم[(٢)].

وقسم ذهبوا إلىٰ البطلان وهم الأكثرون، منهم الشيخ أبو حامد في «التعليق» وأبو علي البندنيجي في تعليقته المعروفة المسماة «بالجامع» وعبر فيها: بالمذهب، وسليم الرازي، وعبّر في «المجرد»: بالصحيح، والمحاملي، وعبّر في «المقنع»: بالأصح، والماوردي في «الحاوي» وعبّر: بالجمهور، والشيخ أبو إسحاق في «التنبيه» وأبو نصر البندنيجي في كتابه «المعتمد» جازماً به، وقال الخوارزمي في «الكافي» والروياني في «البحر»: إنه الأصح، وجزم به في «الحلية»[(٣)].

---

(١) وفي قوت المحتاج للأذرعي (١١/ ٤٦٢) أن القاضي أبا الطيب جزم بالبطلان، والصواب ما ذكره الإسنوي، فإنه ذكر في تعليقته (ص ١٠٢٢-١٠٢٣ تحقيق أحمد الغامدي) الخلاف من غير ترجيح.

(٢) التهذيب للبغوي (٨/ ٢١٥)، والحلية للشاشي (٨/ ١٧٨).

(٣) اللباب (١/ ٤٠٨)، وبحر المذهب للروياني (١٤/ ٤٤) الحاوي للماوردي (١٦/ ٢٦١).

وقال أبو عبد الله الحسين الطبري في «العدة»: إنه الصحيح، وقال ابن عصرون في «الانتصار»: إنه الأصح، وجزم به في «المرشد» وفي كتابه المسمىٰ «بالتنبيه»، وذكر نحو ذلك جماعة أيضًا، منهم القاضي الحسين في «تعليقه» وأبو منصور التميمي في كتابه المسمىٰ «بالمسافر» فإنهم جزموا ببطلان القسمة بخروج شيء مستحق، ولم يفصلوا بين المعين والشائع، فهذه كتب الأصحاب شاهدة علىٰ بطلان ما وقع في الرافعي هنا وتابعه عليه في «الروضة».

والسبب في وقوع الرافعي في ما وقع فيه أن الإمام قال[1]: ذكر العراقيون في ذلك قولين، وخرجوهما علىٰ تفريق الصفقة.

هذه عبارته من غير زيادة عليها، وهي عبارة توهم الواقف عليها أن العراقيين اقتصروا علىٰ هذه الطريقة، وكأنه أراد أنه وقع ذكرها في كتبهم، وإلا فنقول: العراقيون كتبهم -كما قدمته لك قاطبة- تغلط ما نسب إليهم، ثم إن الغزالي تابع

وفي قوت المحتاج للأذرعي (١١/ ٤٦٢) عن الفارقي: أنه الصحيح، وأن إبراهيم المروزي في تعليقه جزم به، وكذلك ابن أبي عصرون في مرشده وتنبيهه.
وقال ابن المنذر في الإقناع (٢/ ٦٩٩): «وإذا قسم القوم الشيء، ثم استحق بعض ما قسم انتقض القسم، واقتسموا ما لم يستحق من ذي قبل».

(١) نهاية المطلب (١٨/ ٥٦٠-٥٦١).

إمامه علىٰ عادته، فشرحه الرافعي مغترًا به، وبإيهام كلام الإمام، ولم يمعن النظر في المسألة فوقع فيما وقع، ومما يدل علىٰ عدم إمعانه أنه اقتصر من النقول التي نقلها عن أعلام المذهب في كتبهم المبسوطة والمتوسطة والمختصرة علىٰ نقل ذلك عن «حلية الروياني» خاصة.

والحاصل: أنه هاهنا لم ينظر غير «النهاية» و«الوجيز» و«الحلية»، وقد أوضحت لك بطلان مستنده، وهو كلام الإمام الموهم.

ولا شك أن المصنف قد لا يبسط في بعض الأوقات، فيقلد فيقع في الغلط بسبب ذلك، فأحمد الله تعالىٰ علىٰ التوفيق إلىٰ الصواب.

واعتمد ما ذكرته، فقد راجعت في هذه المسألة من المصنفات ما لعله لم يسمع به الرافعي فضلاً عن وقوفه عليه، وقد ذكرت لك عبارات أكثرها.

نعم صحح الجرجاني في «الشافي» و«التحرير» طريقة ابن أبي هريرة، وهي التخريج علىٰ تفريق الصفقة كما وقع في الرافعي، ورأيت مثل ذلك في «تتمة التتمة»، ولا أعلم أحدًا غير هذين إلا كلام الغزالي ومن تبعه لأجل الوهم أو الإيهام الواقع في كلام الإمام».

وقال الأذرعي في قوت المحتاج (١١/ ٤٦٣): «وأحسب الرافعي اعتبر نسبة الإمام والغزالي الطريقة الأولىٰ إلىٰ العراقيين مقتصرين عليها، فنسبها إلىٰ

الأكثرين».

وفي تحرير الولي العراقي (٣/ ٦٤٢) أن الشيخ أبا حامد نقل الطريق الأول عن عامة الأصحاب، والماوردي (١٦/ ٢٦١) عن جمهورهم البطلان مطلقاً».





كتاب الشهادات

[١٥٥]وقال النووي في منهاج الطالبين (٣/ ٤٢٩ ط. الحداد): «وشرط العدالة اجتناب الكبائر، والإصرار علىٰ صغيرة».

ظاهر تعبير النووي في «الإصرار علىٰ صغيرة» أن ذلك مسقط للعدالة مطلقا، أي سواء كان ذلك هو الغالب عليه أم لا، وأنه لو أصر علىٰ نوع من الصغائر دون نوع ردت شهادته، وهو أحد الوجهين في المذهب.

وهو تابع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٦٧٦) ولفظه: «ويعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر، وعن الإصرار علىٰ الصغائر».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٣/ ٩): «وأما الصغائر، فقليلا ما يسلم الإنسان منها حتىٰ اشتهر في الخبر «ما منا إلا من عصىٰ أو هم بمعصية إلا يحيىٰ بن زكريا صلوات الله عليهما» [(١)] فلا يشترط تجنبها بالكلية، لكن الشرط ألا

---

(١) رواه أحمد (رقم ٢٢٩٤، ٢٦٥٤، ٢٦٨٩، ٢٧٣٦، ٢٩٤٣) وأبو يعلىٰ (رقم ٢٥٤٤) وغيرهما من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به. وعلي بن زيد ضعيف.

يصر عليها، فإن أصر كان الإصرار كارتكاب الكبيرة»[(١)] وتبعه النووي في الروضة (١١/ ٢٢٥).

○ قال أبو عبد الباري:

المنصوص المعتمد هو الاعتبار بالغالب من الطاعة والمعصية، وبه قال جمهور الأصحاب.

قال الشافعي في الأم (٨/ ١٢٩-١٣٠ ط. د. رفعت فوزي): «وليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة، حتىٰ لا يخلطهما بشيء من معصية، ولا ترك مروءة، ولا يمحض المعصية ويترك المروءة حتىٰ لا يخلطه بشيء من الطاعة والمروءة.

---

(١) ثم تكلم الرافعي عن مفهوم الإصرار علىٰ الصغائر فقال: «وأما الإصرار السالب للعدالة أهو المداومة علىٰ نوع من الصغائر أم الإكثار منها، سواء كانت من نوع واحد، أو من أنواع مختلفة؟ منهم من يُفهم كلامُه الأول، ومنهم من يُفهم كلامُه الثاني، ويوافقه قول الجمهور، من تغلب طاعته معاصيه كان عدلا، ومن تغلب معاصيه طاعته كان مردود الشهادة، ولفظ الشافعي ﷺ في «المختصر» قريب منه، وإذا قلنا به، لم تضر المداومة علىٰ نوع واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات، وعلىٰ الاحتمال الأول يضر».
ولم يصرح بالراجح عنده إلا ما يفيده كلامه الذي قبله، وأفاد أن ظاهر النص البناء علىٰ الغالب من الطاعة والمعصية.

فإذا كان الأغلب علىٰ الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة رددت شهادته».

وفي مختصر المزني (٢/ ٦٧١ ط. الداغستاني): «قال الشافعي: ليس من الناس أحد - إلا أن يكون قليلا - يمحض الطاعة والمروة حتىٰ لا يخلطهما بمعصية، ولا يمحض المعصية وترك المروة حتىٰ لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروة، فإذا كان الأغلب علىٰ الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروة قبلت شهادته، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروة ردت شهادته».

وهذا النص مخالف لما رجحه النووي في المنهاج تبعا للرافعي في المحرر، فإن مقتضاه أنه يضر وإن لم تغلب عليه المعصية.

ولهذا قال الأذرعي في قوت المحتاج (١١/ ٤٩٢): «وهو قضية إطلاق المنهاج، والمذهب وقول الجمهور وما تضمنته النصوص أن من كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة قبلت شهادته، ومن كان الأغلب عليه المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته».

وقال قبل ذلك (١١/ ٤٩٠): «ظاهر كلام المصنف أن الإصرار علىٰ صغيرة مبطل للعدالة مطلقا، وهو وجه ظاهر المذهب علىٰ خلافه».

وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر (٢/ ٣٧٥): «المعتمد وفاقا لكثيرين من المتأخرين كالأذرعي والبلقيني والزركشي وابن العماد وغيرهم أنه لا تضر المداومة علىٰ نوع من الصغائر ولا علىٰ أنواع، سواء كان مقيما علىٰ الصغيرة أو الصغائر، أو مكثرا من فعل ذلك، حيث غلب الطاعات المعاصي وإلا ضر».

[١٥٦] وقال النووي في منهاج الطالبين (٣/ ٤٣٣ ط. الحداد) فيما ترد به الشهادة من خوارم العدالة: «أو يعرض بامرأة معينة».

إطلاق النووي هنا يقتضي أن التشبيب بزوجته وجاريته كذلك، وقد صرح برد شهادته بهما إذا ذكر ما كان حقه الإخفاء من أجل سقوط المروءة، فقال في الروضة (١١/ ٢٢٩): «فإن شبب بجاريته أو زوجته، فوجهان، أحدهما: يجوز ولا ترد شهادته، وهذا القائل يقول: إذا لم تكن المرأة معينة، لا ترد شهادته لاحتمال أنه يريد من تحل له، والصحيح أن ترد شهادته إذا ذكر جاريته أو زوجته بما حقه الإخفاء، لسقوط مروءته».

وكلام النووي في المنهاج والروضة يقتضي عدم الفرق بين الإكثار من التشبيب وغيره فيما إذا شبب بامرأة معينة، بل ترد شهادته بذلك مطلقا.

وهو تابع الرافعي في المحرر (ص ١٦٧٨) في قوله: «لو كان الشاعر يهجو، أو يفحش، أو يشبب بامرأة معينة، فترد شهادته».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٣/ ١٧): «فإن كانت التي شبب بها جاريته، أو زوجته، فمن الأصحاب من قال بأنه يجوز، ولا ترد شهادته، وهذا القائل يقول: لو لم تكن المرأة معينة لا ترد شهادته لجواز أن يريد من تحل له، ومنهم من قال: ترد شهادته إذا كان يذكر جاريته أو زوجته بما حقه الإخفاء؛ لأنه ساقط المروءة، وهذا هو الحق».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره الشيخان هنا مبني علىٰ نص مختصر المزني (٢/ ٦٧٥ ط. الداغستاني): «ولا يشبب بامرأة بعينها، ولا يبتهرها بما يشينها فجائز الشهادة، وإن كان علىٰ خلاف ذلك لم تجز شهادته».

فظاهر إطلاقه أن التشبيب بامرأة معينة يقتضي رد الشهادة، لكن اختصار المزني مخل بالمعنىٰ، ولهذا لزم حمله علىٰ المفصل في الأم كما صنع الجمهور، قاله الأذرعي في قوت المحتاج (١١/ ٥٤٥ ط. العلمية).

قال الشافعي في الأم (٧/ ٥١٤ ط. د. رفعت فوزي): «ومن شبب بامرأة بعينها ليست ممن يحل له وطؤها حين شبب، فأكثر فيها وشهرها، وشهر مثلها

بما يشبب - وإن لم يكن زنىٰ - ردت شهادته، ومن شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته، لأنه يمكن أن يشبب بامرأته وجاريته».

ونص الشافعي يبين أنه لا ترد شهادة من شبب بامرأة في ثلاث حالات:

الأولىٰ: أن يشبب بمن يحل له وطؤها أي زوجته وجاريته، فلا ترد شهادته بذلك، ولم يفرق بين ذكر ما حقه الإخفاء وغيره، وهذا مخالف لما قاله النووي في المنهاج والروضة.

الثانية: أن يشبب بامرأة لم يسمهما، فلا ترد شهادته، لأنه قد يريد بذلك زوجته أو جاريته، ولا ترد شهادته بالتشبيب بهما كما تقدم في الحالة الأولىٰ.

وهذا يخالف ما ذكره النووي في الروضة من تضعيف التعليل باحتمال إرادة زوجته وجارتيه التي يحل له وطؤها.

الثالثة: أن يشبب بغيرهما مع التسمية لكنه لم يكثر من ذلك، فإن الشافعي اشترط الإكثار والتشهير فقال: «فأكثر فيها وشهرها»، وهو ظاهر في أنه إذا لم يكثر لم ترد شهادته بذلك.

وهذا هو الذي عزاه البيهقي في الكبرىٰ (١٠/ ٤١١) للشافعي فقال: «باب: الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها

قال الشافعي رحمه الله: « ردت شهادته ».

فاختصره المزني اختصارا مخلا بالمعنىٰ، فأوهم اختصاره ما قاله من تمسك بظاهره.

قلت: وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلها في الإصرار علىٰ الصغائر، فقد تقدم أن الشافعي اشترط المداومة عليها، ومقتضىٰ كلامه هنا أن التشبيب من الصغائر.

[١٥٧]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٣٥ ط. الحداد): «ولو شهدا لاثنين بوصية، فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة، قبلت الشهادتان في الأصح».

رجح النووي هنا قبول شهادة أصحاب الوصايا بعضهم لبعض، تبعا للرافعي في المحرر (ص ١٦٨١) ولفظه: «ولو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة، فيشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية من تلك التركة، فالأصح قبول الشهادتين».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٣/ ٢٥): «والصحيح قبول الشهادتين؛ لأن كل بينة منفصلة عن الأخرىٰ، ولا يجر شاهد بشهادته نفعا إلىٰ نفسه ولا يدفع بها ضررا؛ ولذلك نقول: رفقاء القافلة يجوز أن يشهد بعضهم لبعض في قطع الطريق». وتبعه النووي في الروضة (١١/ ٢٣٦).

فعللا القبول بأمرين:

الأول: انفصال كل شهادة عن الأخرىٰ.

الثاني: القياس علىٰ شهادة الرفقة بعضهم لبعض في قطع الطريق.

والرافعي هنا تبع في ذلك الإمام في النهاية (١٩/ ٨٧) فإنه قال بعد حكاية قول صاحب التقريب: «وعندي أن ما ذكره مشكل، والقياس القطع بقبول الشهادة، ومن أحكم الأصول، لم يخف عليه درك ما ذكرناه، ولم أر ما حكاه صاحب التقريب في شيء من الكتب».

وتبعه الغزالي في الوسيط (٧/ ٣٥٤) فقال: «قال صاحب التقريب لا تقبل للتهمة، وهذا فاسد، لأن كل شهادة منفصلة عن الأخرىٰ، ليس فيها جر، وقد قطع الأصحاب بأن رفقاء القافلة إذا شهد بعضهم لبعض في قطع الطريق قبل، إذا لم يتعرض في شهادته لنصيب نفسه».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكروه هنا من قبول الشهادتين مخالف لظاهر قول الشافعي.

قال الشافعي في الأم (٨/ ٢٨٤ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض لم يجز؛ لأنهم شركاء في الوصية، الثلث بينهم».

وهذا هو المعروف عن الشافعي، حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف (٤/ ٢٩٨) والأوسط (٧/ ٣٣٤ ط. الفلاح)، وصاحب التقريب والعبادي وأبو

سعد الهروي والقاضي شرح الروياني كما في قوت المحتاج للأذرعي (١١/ ٥٧٦).

ومع ثبوت النص في الأم، وحكاية هؤلاء الأئمة، فلا معنىٰ لنفي الغزالي له كما حكاه الأذرعي عنه.

ولهذا النص رجح صاحب التقريب عدم القبول لتهمة المواطأة.

وأما قول الإمام: «ولم أر ما حكاه صاحب التقريب في شيء من الكتب» فإنما خفي عليه موضعه، وقد ذكرنا أنه في اختلاف العراقيين من الأم، والإشراف لابن المنذر، فهو ثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله.

وأما القياس: فيقابله قياس آخر ذكره صاحب التقريب كما في نهاية المطلب: «قال صاحب التقريب: كذلك لو كان لرجل ديون علىٰ طائفة من الغرماء، ولقوم عليهم ديون أيضا، فتناوبوا في الشهادة علىٰ الصورة التي ذكرناها، فالشهادة مردودة».

وأما قول بعضهم: إن العدالة تمنع المواطأة» فمردود، وذلك أن العدالة لا تمنع رد الشهادة كما إذا شهد لنفسه أو أصله أو فرعه، أو شهد علىٰ عدوه ونحو ذلك، فكذلك هنا.

[١٥٨]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٣٨ ط. الحداد): «وقدرها الأكثرون بسنة».

اختار النووي هنا أن مدة اختبار التائب من المعاصي الفعلية سنة، وعزاه للأكثرين، أي أكثر الذين قالوا بتحديد مدة الاختبار، وتابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٦٨٥) في قوله: «وقدر الأكثرون تلك المدة بسنة».

وتابعا البغوي في التهذيب (٨/ ٢٧٨) فإنه قال: «ولا بد من مضي مدة عليه في حسن الحال؛ حتىٰ تقبل شهادته، وتعود ولايته وقدر أصحابنا تلك المدة بسنة؛ حتىٰ تمر عليه الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأحوال والطباع؛ كما يضرب للعنين أجل سنة. وقد علق الشرع أحكاما بالسنة من الزكاة، والجزية، والعقل»[(١)].

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا الذي اختاره النووي تبعا للرافعي مخالف لظاهر نص الشافعي، وظاهر مذهبه أنه لا تقدير في ذلك.

---

(١) لكن نقل الأذرعي في القوت (١١/ ٦٤١) عن تعليق البغوي أنه قال في توبة القاذف: «وقد قيل: سنة، وقيل: ستة أشهر، وقيل: شهران، وقيل: شهر واحد، إلا أن الصحيح أنه لا تقدير له، لكن إذا استفاض فيما بين الناس توبته، وغلب علىٰ قلب القاضي».

قال الشافعي في الأم (٧/ ٥١٧ ط. د. رفعت فوزي): «ومن كانت حاله عند القذف بشهادة، أو غير شهادة حال من لا تجوز شهادته بأنه غير عدل حُدَّ أو لم يُحد فسواء، ولا تقبل شهادته حتىٰ تحدث له حال يصير بها عدلا».

وقال الشافعي في الأم (٨/ ١١٠ ط. د. رفعت فوزي): «فأما من أتىٰ محرما حد فيه، فلا تقبل شهادته إلا بمدة أشهر يختبر فيها بالانتقال من الحال السيئة إلىٰ الحال الحسنة، والعفاف عن الذنب الذي أتىٰ، وأما من قذف محصنة علىٰ موضع الشتم وغيره من غير مواضع الشهادات، فلا تقبل شهادته حتىٰ يختبر هذه المدة في الانتقال إلىٰ أحسن الحال، والكف عن القذف».

وقال الشافعي في الأم (٨/ ٢٨٢ ط. د. رفعت فوزي): «والتوبة مما كان ذنبا بالفعل، مثل الزنا وما أشبهه، فبترك الفعل مدة يختبر فيها حتىٰ يكون ذلك معروفا، وإنما يخرج من الشيء بترك الذي دخل به فيه».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٤/ ٢٦٨): «واختلفوا فيمن شهد بزور، ثم تاب وأناب، وظهرت توبته فعلىٰ مذهب الشافعي، والكوفي يجب قبول شهادته إذا أتت علىٰ ذلك مدة تظهر في مثلها توبته، وبه قال أبو ثور».

وظاهر هذه النصوص عن الإمام الشافعي عدم تقدير مدة للاختبار، وظاهر القرآن يشهد لقول الشافعي، وهو اختيار القاضي الحسين كما في قوت الأذرعي (١١/ ٦٤٠) والإمام الجويني (١٨/ ٦٠٤-٦٠٥) وعزاه للمحققين، والغزالي

في الوسيط (٧/ ٣٦٢).

واختاره ابن عبد السلام في قواعده (٢/ ٤٠) ولخص كلامهم فقال: «وقد اختلف في مقدار هذه المدة، فقدرها بعضهم بستة أشهر، وذلك تحكم، والمختار أن ذلك يختلف باختلاف ما ظهر من التائبين من التلهف، والتأسف، والتندم، والإقبال علىٰ الطاعات، وحفظ المروآت، والتباعد عن المعاصي والمخالفات، ويدل علىٰ ذلك قوله تعالىٰ في القذفة ﴿وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ۝٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ﴾ [النور: ٤-٥] فشرط في قبول الشهادة بعد التوبة الإصلاح».

والعبادي كما في الشرح الكبير (١٣/ ٤٠) والأذرعي في القوت (١١/ ٦٤٠) والبلقيني في التدريب (٤/ ١٩٦).

[١٥٩] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٥٠ ط. الحداد): «ويكفي شهادة اثنين علىٰ الشاهدين، وفي قول: يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان».

رجح النووي هنا أن شهادة رجلين علىٰ شهادة أكثر من شخص جائزة، وجعله أرجح القولين، وضعَّف القول الثاني، وهو أنه لا يكفي، بل لابد من رجلين لكل منهما، وتابع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٦٩٩) ولفظه: «وإن شهد اثنان علىٰ شهادة الأصلين معا، فيه قولان، أرجحهما الجواز».

وقال النووي في الروضة (١١/ ٢٩٣): «ولو شهد فرعان علىٰ شهادة الأصلين معا، ففي قبوله قولان، أظهرهما: الجواز، وهو الذي رجحه العراقيون، والإمام، والغزالي، والروياني، وصاحب العدة، وخالفهم البغوي، والسرخسي». وهو تابع الرافعي في الشرح الكبير (١٣/ ١١٨).

وقال الإسنوي في المهمات (٩/ ٣٧٤): «صححه الرافعي في «الشرح الصغير»: وعبر بالأصح».

○ قال أبو عبد الباري:

الذي اختاره الشافعي وصححه هو القول بعدم الجواز كما في الأم والبويطي، وحكىٰ مرة في الأم قولين، وحجة كل منهما، ولم يرجح، وهو الذي ذكره المزني في المختصر.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٥٧٠-٥٧١ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا شهد رجلان علىٰ شهادة رجلين، فقد رأيت كثيرا من الحكام والمفتين يجيزه، فمن أجازه فينبغي أن يكون من حجته أن يقول: ليسا بشاهدين علىٰ شهادة أنفسهما، وإنما يشهدان علىٰ شهادة رجلين، فهما رجلان، كل واحد منهما علىٰ رجل ورجل، وأدل من هذا علىٰ أمر كأنه يشبه أن يجوز أن يقول رجل، ألا ترىٰ أنهما لو شهدا علىٰ شهادة رجلين: أن هذا المملوك لهذا الرجل بعينه، وشهدا علىٰ شهادة رجلين آخرين: أن هذا المملوك بعينه لآخر غيره، لم يكونا شاهدي زور،

وإنما أدَّيا قول غيرهما، ولو كانا شاهدين علىٰ الأصل كانا شاهدي زور».

ثم قال في القول الثاني : «وقد سمعت من يقول: لا أقبل علىٰ رجل إلا شهادة رجلين، وعلىٰ آخر شهادة آخرين غيرهما، ومن قال هذا: انبغىٰ أن يكون من حجته أن يقول: أنا أقيمهما مقام الشاهد نفسه، فلم يكن لهما أكثر من حكمه، فهو لو شهد مرتين علىٰ شيء واحد لم يكن إلا مرة، فكذلك إذا شهدا هما علىٰ الآخر لم يكن إلا مرة، فلا تجوز شهادتهما، وينبغي أن يقول من قال هذا: أنهما إنما كانا غير مجروحين في شهادتهما علىٰ أربعة، وإن لم يكونا مجروحين علىٰ أربعة مختلفين، لأنهما لم يشهدا علىٰ العيان، وهما لا يقومان إلا مقام من شهدا علىٰ شهادته، فلا يجوز أن يقوم اثنان إلا مقام واحد، إذ لم يجز أن يجوز علىٰ الواحد إلا اثنان».

وقال في مختصر البويطي (ص ٩٩٢ ط. القره داغي): «ولا تجوز الشهادة علىٰ الشهادة إلا رجلين علىٰ كل رجل، ورجلين علىٰ كل امرأة، وقد قيل: يجوز شهادة رجلين علىٰ شهادة عدة».

فذكر في هذين النصين قولين من غير تصريح بالراجح.

وفي مختصر المزني (٢/ ٦٧٧-٦٧٨ ط. الداغستاني): «قال: ولو شهد رجلان علىٰ شهادة رجلين، فقد رأيت كثيرا من الحكام والمفتين يجيزه».

قال المزني: وخرجه علىٰ قولين، وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز

شهادتهما إلا علىٰ واحد ممن شهدا عليه، وآمره بطلب شاهدين علىٰ الشاهد الآخر.

قال المزني: ومن قطع بشيء كان أولىٰ به من حكايته له».

وما ذكره المزني عن الشافعي في ترجيح المنع هو كما قال.

فقد قال الشافعي في الأم (٨/ ٢٨٠ ط. د. رفعت فوزي): «وإذا شهد شاهدان علىٰ شهادة شاهدين، لم أقبل علىٰ كل شاهد إلا شهادة شاهدين معا.

قال الربيع: من قِبَل أن الشاهدين لو شهدا علىٰ شهادة شاهد لم يحكم بها الحاكم إلا بشهادة شاهد آخر، فلما شهدا علىٰ شهادة الشاهد الآخر كانا إنما جرا إلىٰ أنفسهما إجازة شهادتهما الأولىٰ التي أبطلها الحاكم، فلم نجزه إلا بشهادة شاهدين علىٰ كل شاهد».

وقال في مختصر البويطي (ص ٩٨٠ ط. القره داغي): «وكان يقول: لا تجوز شهادة شاهدين إلا علىٰ شهادة رجل، وآخرين غيرهما علىٰ شهادة آخر، وكذلك المرأة لا يجوز إلا شهادة رجلين علىٰ كل امرأة، ولا يعدل النساء ولا يجرحن، ولا يشهد علىٰ شهادتهن إلا الرجل، وقد قيل: تجوز شهادة رجلين علىٰ شهادة مائة».

وهذا المنصوص في الأم والبويطي الذي رجح المزني أنه مذهب الشافعي هو الأصح في «تعليقة» القاضي حسين، و«تهذيب» البغوي(٨/ ٢٩٤) وقال: إنه

الجديد، ومقابله القديم[١]، و«تعليق» البغوي وقال: إنه ظاهر المذهب، و«الكافي»، و«مختصر» الجويني، و«خلاصة» الغزالي[٢]، و«المعتبر» و«أمالي» السرخسي، ذكره ابن الرفعة في المطلب (ص ٣٥٨ تحقيق إسماعيل بن صالح المفضلي الزهراني) والأذرعي في القوت (١١/ ٧٧٦).



(١) وإليه أشار الرافعي بقوله في فتح العزيز (١٣/ ١١٨):« وربما سموه الجديد، ومقابله القديم».

(٢) قال الغزالي في الخلاصة (ص ٦٩٣-٦٩٤ تحقيق أمجد رشيد): «ولا يثبت شهادة أصل واحد إلا بشاهدين، فإن شهد شاهدان علىٰ شهادة شاهدين ، كل واحد منهما علىٰ شهادتهما جميعا، فأصح القولين: أنه لا يكتفىٰ بهما، حتىٰ يشهد شاهدان علىٰ كل واحد، لأن من ثبت شطر البينة بشهادته، لم يجز قبول في الشطر الثاني".



كتاب الدعوى والبينات

[١٦٠]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٦٢ ط. الحداد): «وإن أقرّ لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه، ويوقف الأمر حتىٰ يقدم الغائب، فإن كان للمدعي بينة قضىٰ بها، وهو قضاء علىٰ غائب فيحلف معه، وقيل: علىٰ حاضر».

صحح النووي هنا انصراف الخصومة عمن أقرّ ما في يده من العين لغائب، وأنه إن كانت للمدعي بينة قضىٰ بها الحاكم، وهو حكم علىٰ الغائب فيحتاج إلىٰ اليمين معه(١)، وأن القول بأنه حكم علىٰ حاضر وجه ضعيف.

وما ذكره النووي هنا تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٧١٧) ولفظه: «وإن أضافه إلىٰ غائب فأظهر الوجهين: انصراف الخصومة عنه ...، وإن كانت له بينة فيقضي له، وهو قضاء علىٰ الغائب حتىٰ يحتاج إلىٰ اليمين، أو علىٰ الحاضر؟ فيه وجهان: أصحهما الأول».

---

(١) قال الجويني في النهاية (١٩/ ١٢٧): «ذكر العراقيون في ذلك وجهين:

أحدهما: أن ذلك قضاء علىٰ الغائب.

والثاني: أنه قضاء علىٰ الحاضر، وفائدة قولنا أنه قضاء علىٰ الغائب أن القضاء لا يتم بالبيّنة، حتىٰ يحلف مُقيمُ البينة، علىٰ ما ذكرنا تفصيلَ ذلك في القضاء علىٰ الغائب».

وقال في الروضة (١٢/ ٢٤): «فإذا أضاف المدعي إلىٰ غائب، ففي انصراف الخصومة عنه أوجه، أصحها وبه قال الأكثرون: ينصرف».

وقال فيه أيضا (١٢/ ٢٥) في ترجيح كونه قضاء علىٰ الغائب إنه: «أقوىٰ وأليق بالوجه المفرع عليه، واختاره الإمام والغزالي».

وهو أيضا اختيار المزني، فإنه لما ذكر نص الشافعي الآتي علق عليه بقوله: «قال المزني: قد قطع بالقضاء علىٰ غائب، وهو أولىٰ بقوله»، وهو يفيد بظاهره أن هذا النص الذي ذكره هنا يدل علىٰ أنه قضاء علىٰ حاضر، وأن قول الشافعي في القضاء علىٰ الغائب أولىٰ بهذه الصورة.

○ قال أبو عبد الباري:

ظاهر نصوص الشافعي في الأم والمزني والبويطي أنها لا تنصرف عنه، بل يؤمر بالدفاع عنه، ثم يحكم القاضي بالبينة، وأنه قضاء علىٰ حاضر.

قال الشافعي في الأم (٧/ ٥٦٦-٥٦٧ ط. د. رفعت فوزي): «وإن كان فلان غائبا كتب إقراره له، وقيل لهذا المدعي: أقم البينة علىٰ دعواك، وللذي هو في يديه ادفع عنه، فإن أقام المدعي البينة عليه قضي له به علىٰ الذي هو في يديه، وكتب في القضاء: إني إنما قبلت بينة فلان المدعي بعد إقرار فلان الذي هو في

يديه بأن هذه الدار لفلان، ولم يكن فلان المقر له، ولا وكيل له حاضرا، فقالت البينة: لفلان المدعي هذه الدار، علىٰ ما حكيت في كتابي، ويحكي شهادة الشهود، وقضيت له بها علىٰ فلان الذي هي في يديه، وجعلت فلانا المقر له بها علىٰ حجته يستأنفها».

فقوله هنا «وقيل لهذا المدعي: أقم البينة علىٰ دعواك، وللذي هو في يديه ادفع عنه» ظاهر الدلالة علىٰ أن الخصومة لا تنصرف عنه، بل يؤمر بالدفع عمن أقرّ له بالعين، وبهذا يكون قضاء علىٰ حاضر.

وفي مختصر البويطي (ص ٩٧٥): «وإن قال الذي هو في يديه: هو عندي وديعة أو رهن ولست أملكه، وسمىٰ صاحبه أو لم يسم فسواء، فإن أقام شاهدين علىٰ ما ادعىٰ لم يحلف المدعي».

وهذا صريح في أنه المدعي لا يحلف مطلقا مع البينة المعتبرة، سواء سمىٰ المالك أو لم يسم، ولم يفرق مع قيام البينة بين حضور المالك وغيابه، وهو ظاهر نص الأم والمزني.

وفي مختصر المزني (٢/ ٦٩١ ط. الداغستاني): «ولو ادعىٰ دارا في يدي رجل، فقال: ليست بملك لي، وهي لفلان ...، فإن كان حاضرا صيرتها له،

وجعلته خصما عن نفسه، وإن كان غائبا كتب إقراره، وقيل للمدعي: أقم البينة، فإن أقامها قضي له بها علىٰ الذي هي في يديه، ويجعل في القضية أن المقر له بها علىٰ حجته».

وقال الروياني في البحر (١٤/ ٤٢٤): «وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه قضاء علىٰ صاحب اليد الحاضر، دون الغائب، وهو الظاهر من كلام الشافعي، لأنه قال: قضىٰ له علىٰ الذي هي في يديه، وإنما كان قضاء علىٰ الحاضر، لأن الدعوىٰ توجهت إليه، فتوجه القضاء عليه».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٤٠٠): «والمذهب المعتمد أنه قضاء علىٰ حاضر».

وفي تحرير العراقي (٣/ ٧٣٨) عن البلقيني إنه الموافق لظاهر نص «الأم» و«المختصر» ولكثير من الأصحاب في الطريقين، ولمقتضىٰ الدليل».

وقال الدميري في النجم (١٠/ ٤١٠): «والثاني- وهو ظاهر نص المختصر، وبه قال أبو حنيفة -: لا ينصرف؛ لأن المال في يده، والظاهر: أنه له، فلا يمكن منصرف الخصومة عنه بالإضافة إلىٰ غائب قد يرجع وقد لا يرجع».

وفي بداية المحتاج (٤/ ٥٣٠): «(وقيل: علىٰ حاضر) فلا يحلف معها؛ لأن

الدعوىٰ توجهت إليه فيوجه القضاء عليه، وهذا ما نقلاه عن ترجيح العراقيين والروياني، وهو المنصوص في «الأم» و«المختصر» كما قاله في «البحر»، قال: ولا معنىٰ للوجهين مع النص».

[١٦١]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٦٦ ط. الحداد): «فلو أقام المدعىٰ عليه بعدها بينة أو إبراء لم تُسمع».

هذا في اليمين المردودة، فإذا نكل المدعىٰ عليه من اليمين، فردت اليمين علىٰ المدعي، فحلف علىٰ دعواه، ثم جاء المدعىٰ عليه ببينة لم تسمع علىٰ ما في «المنهاج»، لأن اليمين كإقرار المدعىٰ عليه علىٰ الأظهر، وتبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٧٢٣) ولفظه: «لو أقام المدعىٰ عليه بينة علىٰ الأداء والإبراء بعد ما حلف المدعي لم تسمع بينته».

وقال الرافعي في الشرح الكبير (١٣/ ٢١١): «الحالة الأولىٰ: أن يحلف فيستحق المدعىٰ، ويمينه بعد نكول المدعىٰ عليه بمنزلة بينة يقيمها، أو بمنزلة إقرار المدعىٰ عليه؟ فيه قولان:

أحدهما: أنها كالبينة؛ لأن الحجة اليمين، واليمين وجدت منه.

وأصحهما: وهو المنصوص في «المختصر» ثم باب النكول: أنها بمثابة

إقرار المدعىٰ عليه؛ لأنه بنكوله توصل إلىٰ الحق؛ فأشبه إقراره».

وتبعه في الروضة (١٢/ ٤٥) فقال: «المدعي إذا ردت اليمين عليه قد يحلف، وقد يمتنع، فإن حلف استحق المدعىٰ، وهل يمينه بعد نكول المدعىٰ عليه كالبينة، أم كإقرار المدعىٰ عليه؟ فيه قولان، أظهرهما الثاني، ويتفرع عليهما مسائل كثيرة مذكورة في مواضعها. ومنها أن المدعىٰ عليه لو أقام بينة بالأداء أو الإبراء بعد ما حلف المدعي، فإن قلنا: يمينه كالبينة، سمعت بينة المدعىٰ عليه، وإن قلنا: كالإقرار، فلا، لكونه مكذبا للبينة بالإقرار».

○ قال أبو عبد الباري:

الذي نص عليه الشافعي في الأم سماعها، وقبولها إن استوفت شروط البينة.

قال الشافعي في الأم (٤/ ٥٣٣ ط. د. رفعت فوزي) في الاختلاف بين الغاصب والمغصوب منه في القيمة إذا تلفت العين المغصوبة: «قلنا لرب الثوب: ادع في قيمته ما شئت، فإذا فعل، قلنا للغاصب: قد ادعىٰ ما تسمع، فإن عرفته فأده إليه بلا يمين، وإن لم تعرفه فأقرَّ بما شئت نحلفك عليه وتدفعه إليه.

فإن قال: لا أحلف، قلنا: فرُدَّ اليمين عليه، فيحلف عليك، ويستحق ما ادعىٰ إن ثبت علىٰ الامتناع من اليمين، فإن حلف بعد أن بين هذا له فقد جاء بما عليه،

وإن امتنع أحلفنا المدعي، ثم ألزمناه جميع ما حلف عليه، فإن أراد اليمين بعد يمين المدعي لم نعطه إياها، فإن جاء ببينة علىٰ أقل مما حلف عليه المدعي، أعطيناه بالبينة، وكانت البينة أولىٰ من اليمين الفاجرة».

وهذا صريح في سماع البينة بعد اليمين المردودة، وعلىٰ هذا سار غير واحد من أئمة المذهب.

قال البغوي في التهذيب (٨/ ٣٢٢): «ولو لم يكن لهما بينة؛ فنكل صاحب اليد عن اليمين، وحلف المدعي، وقضي له، ثم أقام ذو اليد بينته تسمع؛ كما لو أقام البينة بعد إقامة المدعي البينة.

وقيل: إذا قلنا: النكول ورد اليمين بمنزلة إقرار المدعىٰ عليه لا تسمع بينته، كما لو أقام بعد الإقرار والأول أصح؛ لأنه جعل كالإقرار حكما، لا أنه حقيقة إقرار».

وفي فتاوىٰ القاضي حسين التي جمعها البغوي (ص ٤٣٨-٤٣٩ مسألة ٧٧١): «رجل ادعىٰ علىٰ رجل ضيعة، فأنكر المدعىٰ عليه، ونكل عن اليمين، وحلف المدعي، وحكم الحاكم له بالمدعىٰ به، ثم المدعىٰ عليه أقام بينة أن الضيعة ملك له علىٰ الإطلاق، فهل يحكم بهذه البينة أم لا؟.

تفكر ﷺ في هذه المسألة أياما، ثم قال: إن قلنا: النكول ورد اليمين بمنزلة الإقرار، لا تسمع هذه البينة، وإن قلنا: بمنزلة البينة، تسمع عليه.

قلت - يعني البغوي جامع الفتاوىٰ -: والذي عندي أنها تسمع، وإن جعلنا النكول وردّ اليمين بمنزلة الإقرار، لأنه ليس بصريح إقرار، لأن الذي من قِبَله مجرد نكول، فلا يجوز أن يجعل مقرا بيمين المدعي، وبالاتفاق بينته مسموعة قبل يمين المدعي».

وقال الأذرعي في القوت (١٢/ ١٤٢) بعد ذكر فتوىٰ القاضي حسين وتعليق البغوي: «ولعل السماع فيها أظهر من هذه».

وقال البلقيني كما في تحرير العراقي (٣/ ٧٥١): «وهو شيء انفرد به القاضي حسين، وهو ضعيف والأصح: سماعها؛ لأن قولنا: إنه كالإقرار أمر تقديري، والبينة شهدت بأمر تحقيقي، فيعمل بمقتضاها».

وقد رجح الرافعي في الشرح الكبير السماع بعد ما تقدم، فقال في فروع عن ابن سريج (١٣/ ٢٣٨): «ولو لم تكن بينة، ونكل الداخل عن اليمين، فردت علىٰ الخارج، وحكم له، ثم جاء المدعىٰ عليه ببينة، تسمع، كما لو أقامها بعد بينة المدعي.

وفيه وجه: أنها لا تسمع، بناء علىٰ أن النكول ورد اليمين كالإقرار».

وتبعه النووي في الروضة (١٢/ ٦١) في فروع أكثرها عن ابن سريج: «فلو لم تكن بينة، ونكل الداخل عن اليمين، فحلف الخارج، وحكم له، ثم جاء الداخل ببينة، سمعت علىٰ الصحيح، كما لو أقامها بعد بينة الخارج.

وقيل: لا تسمع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار».

قال الأذرعي في القوت (١٢/ ١٤٢): «وظاهر هذا ترجيح القول بأن اليمين المردودة كالبينة لا الإقرار، عكس المرجح هنا، وقال ابن أبي الدم: إنه الصحيح عن الجماعة كلهم».

وقال الدميري في النجم (١٠/ ٤٢٦): «كذا قاله الشيخان هنا، وخالفاه قبيل الركن الثالث فرجحا السماع، وهذا هو الصواب؛ فإنه إقرار تقديري لا تحقيقي، فلم يصدر منه إقرار مكذب لها».

وقال ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (٤/ ٥٣٦): «كذا قالاه هنا، وخالفاه بعد ذلك في أثناء الركن الخامس قبيل المدرك الثالث من مدرك ترجيح البينة فرجحا السماع، قال في «المهمات» هناك: والصحيح: عدم سماعها، وقال البُلْقيني: الأصح: سماعها، وعدم السماع تفرد به القاضي الحسين، وهو

ضعيف، وقال الزركشي: الصواب هو السماع؛ فإنه إقرار تقديري لا تحقيقي، فلم يصدر منه إقرار مكذب لها».

اعتراض وجوابه

فإن قيل: جاء في الأم (٨/ ٢١٤ ط. د. رفعت فوزي): «كل من ادعىٰ علىٰ امرئ شيئا ما كان من مال، وقصاص، وطلاق، وعتق، وغيره، أحلف المدعىٰ عليه، فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين علىٰ المدعي، فإن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعىٰ، ولا يقوم النكول مقام إقرار في شيء حتىٰ يكون مع النكول يمين المدعي».

وهو في مختصر المزني (٢/ ٦٦٧ ط. الداغستاني) ومقتضاه عدم قبول البينة بعد ذلك.

أجيب بأن قوله إنما هو في الحكم بها، والتفريع عليه من اجتهاد بعض الأصحاب، ولا تعارض بين نصيه، لأنه هنا بين أنه يحكم باليمين المردودة كما يحكم بالإقرار، وليس ذلك كالإقرار في القوة، ولا كالبينة، بل ولا كاليمين مع الشاهد عند الشافعي.

قال الشافعي في الرسالة (ص ٦٠٠): «وإقراره أقوىٰ عليه من شاهدين، وأقضي عليه بشاهد ويمين، وهو أضعف من شاهدين، ثم أقضي عليه بنكوله عن

اليمين ويمين صاحبه، وهو أضعف من شاهد ويمين ،لأنه قد ينكل خوف الشهرة، واستصغار ما يحلف عليه، ويكون الحالف لنفسه غير ثقة، وحريصا فاجرا». ونقله المزني في مختصره (٢/ ٦٣٨ ط. الداغستاني) بلفظ: «وهكذا قال في كتاب «الرسالة»: أقضي عليه بعلمي، وهو أقوىٰ من شاهدين، وبشاهدين أو شاهد وامرأتين، وهو أقوىٰ من شاهد ويمين، وبشاهد ويمين، وهو أقوىٰ من النكول ورد اليمين».

ثم لو جاء ببينة بعد اليمين المردودة فهي مسألة أخرىٰ، ونص علىٰ أنها تسمع ويحكم بها، وأنها أولىٰ من اليمين الفاجرة، فيؤخذ بنصه في الموضعين، ويكون هذا التفريع تخريجا، وهو ضعيف مقابل النص الصريح من الإمام.

وأما ما حكاه الأذرعي في القوت (١٢/ ١٣٩) عن البغوي في التعليق أنه خرجهما الأصحاب، وليسا بمنصوصين»، فيرده ما تقدم من النص والله أعلم.

[١٦٢]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٦٦ ط. الحداد): «وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام، وقيل: أبدا».

ما رجحه النووي هنا تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١١٢٣) ولفظه: «وإن ذكر لامتناعه سببا فقال: أريد أن أقيم البينة، أو أنظر في الحساب، ترك ولم يبطل حقه من اليمين، والأظهر: أنه يمهل ثلاثة أيام ولا يزاد».

وهو اختيار الجويني في النهاية، وقال في تعليله (١٨/ ٦٦٤): «والسبب فيه أنا لو لم نفعل هذا، لرفع خصمه كل يوم، والخصم ناكل، وهو لا يحلف يمين الرد، فلا يتفرغ القاضي من خصومته إلىٰ شغل، ولا يجوز أن يفضي القضاء إلىٰ مثل هذا، فيجب إذا قطع الخصومة، ومن ضرورة هذا أن نحكم بنكول المدعي إذا امتنع، ثم إن استمهل أمهلناه ثلاثة أيام بلا مزيد، وهي مدة ثابتة في قواعد من الشريعة، ومدة إمهال المرتد إذا رأينا إمهاله ثلاثة أيام، وهي مدة الخيار، ومقام المسافرين. ولو امتنع»، وتبعه الغزالي في الوسيط (٧/ ٤٢٥).

○ قال أبو عبد الباري:

وهذا الذي ذكروه مخالف لنصّ الشافعي وقول الجمهور.

قال الشافعي في الأم (٨/ ٩٣ ط. د. رفعت فوزي): « وإن نكل عن اليمين قيل للمدعي: ليس النكول بإقرار، فتأخذ منه حقك، كما تأخذه بالإقرار، ولا بينة فتأخذ بها حقك بغير يمين، فاحلف وخذ حقك، فإن أبيت أن تحلف، سألناك عن إبائك، فإن ذكرت أنك تأتي ببينة، أو تذكر معاملة بينك وبينه تركناك، فمتىٰ جئت بشيء تستحق به أعطيناك، وإن لم تأت به حلفت، فإن قلت: لا أؤخر ذلك لشيء غير أني لا أحلف، أبطلت يمينك، فإن طلبتها بعد لم نعطك بها شيئا».

وفي مختصر المزني (٢/ ٦٦٦ ط. الداغستاني): «وإن نكل، قيل للمدعي: احلف واستحق، فإن أبيت سألناك عن إبائك، فإن كان لتأتي ببينة أو تنظر في حسابك تركناك، وإن قلت: لا أؤخر ذلك لشيء غير أني لا أحلف أبطلنا أن تحلف».

وكلام الشافعي ظاهر في أنه لا تحديد للانتظار بثلاثة أيام، وأنه متىٰ جاء بما يستحق به حكم له، وإلا حلف.

وعلىٰ هذا سار الجمهور من العراقيين وغيرهم، أن له التأخير إلىٰ أن يشاء كالبينة.

قال الماوردي في الحاوي (١٧/ ١٣٣): «وإن توقف المدعي عن اليمين لم يحكم بنكوله حتىٰ يسأل عن سبب توقفه، فإن ذكر أنه متوقف عن اليمين، ليرجع إلىٰ حسابه، ويستظهر لنفسه أنظر بها، وكان علىٰ حقه من اليمين، ولم تضيق عليه المدة».

وقال الشيرازي في المهذب (٣/ ٣٩٦): «فإن سئل فذكر أنه امتنع من اليمين لأن له بينة يقيمها وحسابًا ينظر فيه فهو علىٰ حقه من اليمين، ولا يضيق عليه في المدة، ويترك ما ترك المدعىٰ عليه، يتأخر حق المدعي في الحكم له، وبترك المدعي لا يتأخر إلا حقه».

وقال العمراني في البيان (١٣/ ٩٠): «فإن امتنع المدعي عن اليمين.. سئل عن سبب امتناعه، فإن قال: امتنعت؛ لأن لي بينة أقيمها، أو لأنظر في حسابي ثم أحلف ... ترك ما شاء؛ لأن الحق له، ولا تسقط اليمين عن جنبته، بل متىٰ شاء.. حلف واستحق».

قال الأذرعي في القوت (١٢/ ١٤٦): «والذي أورده جمهور العراقيين، ومنهم المحاملي والماوردي وابن الصباغ وصاحب «التنبيه» والعمراني والجرجاني في «تحريره» والروياني في «حليته» وقريبه في «روضته» والهروي في «إشرافه»، وهو قضية ما في تعليقي البغوي(١) وإبراهيم المروزي، و«الكافي»، وعليه اقتصر ابن أبي عصرون، وابن أبي الدم في «أدب القضاء» واقتضىٰ كلام «الذخائر» وغيره أنه المذهب، وهو قضية كلام الفوراني في «العمد».

والظاهر أن مستند الجمهور في عدم التقدير قول الشافعي في المختصر والأم كما قال الأذرعي في القوت (١٢/ ١٤٦).

---

(١) وفي التهذيب للبغوي (٨/ ٢٥٢) أن "المدعىٰ لا تضيق عليه المدة؛ لأن يترك المدعي لا يتأخر إلا حقه».

❐ **تنبيه**: وينبغي التنبيه هنا علىٰ أن ابن الرفعة نقل عن الشافعي قولا غريبا، فقال في الكفاية (١٨/ ١٨٩): «حكىٰ القاضي أبو الطيب وغيره أن الشافعي ﵁ قال في هذه الصورة: «يسأل المدعي عن إبائه، فإن قال: امتنعت لحساب بيني وبينه أريد أن أراجعه، أو أريد أن أستفتي الفقهاء، هل يجوز لي أن أحلف أم لا؟ أجله الحاكم ثلاثاً لا يزيد عليها».

قال الأذرعي في القوت (١٢/ ١٤٦): «إن صحَّ هذا النقل الغريب كان في المسألة قولان منصوصان، لكن يبعد هذا النقل أن صاحبي «التنبيه» و«الشامل» تلميذي القاضي أبي الطيب لم يذكراه».

وهو كما قال الأذرعي غريب، ومع ذلك فهو مخالف لما ثبت عن الشافعي في كتبه المعروفة، فلا يقبل ثبوته عنه إلا ببيان يدل علىٰ ذلك.

[١٦٣] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٦٧ ط. الحداد): «ولو ادعىٰ ولي صبي دينا له، فأنكر ونكل لم يحلف الولي، وقيل: يحلف، وقيل: إن ادعىٰ مباشرة سببه حُلِّف».

رجح النووي هنا عدم تحليف الولي إذا أنكر المدعىٰ عليه، ولم تكن للمدعي بينة، ونكل عن الحلف، وتبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٧٢٤)

ولفظه: «ولو ادعىٰ ولي الصبي دينا له علىٰ إنسان، فأنكر ونكل ، فالذي رَجَح من الوجوه أن اليمين لا ترد عليه، والثاني: أنها ترد، والثالث: إن ادعىٰ ثبوته بسبب باشره ردت، وإلا فلا».

○ قال أبو عبد الباري:

هذه واحدة من مسائل «القيلات المعتمدة»، وذكر النووي أن الأصحاب اختلفوا في المسألة علىٰ ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا تحليف بينهما مطلقا، وهو الذي رجحه النووي في المنهاج، والرافعي في المحرر هنا في المحرر.

القول الثاني: أنهما يتحالفان مطلقا أي سواء ادعىٰ الولي مباشرة السبب أم لا كأن يكون القاضي زوجها، أو وكيل الولي، وهو ظاهر اختيارهما في المنهاج والمحرر والشرح الكبير والروضة في باب الصداق.

قال النووي في الاختلاف في الصداق من المنهاج (٢/ ٤٩٦ ط. الحداد) ولفظه: «ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة، أو مجنونة تحالفا في الأصح».

وتبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٠٢٩) أيضا، ولفظه: «ولو اختلف في قدر المهر الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة، فأظهر الوجهين جريان

التحالف أيضا».

وقال في الصداق من الروضة (٧/ ٣٢٦): «اختلف الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة، فقال الولي: زوجتكها بألفين، فقال: بل بألف. فوجهان. أصحهما عند الأصحاب: يتحالفان».

وكذلك الرافعي في الصداق من الشرح الكبير (٨/ ٣٣٧) ولفظه: «إذا وقع الاختلاف بين ولي الصغيرة والمجنونة، وبين الزوج، فقال الولي: زوجتها بألف، وقال الزوج: بل بخمسمائة فوجهان:

أظهرهما: في المذهب، وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: أنهما يتحالفان».

القول الثالث: التفصيل، فإن ادعىٰ مباشرة سبب الوجوب تحالفا وإلا فلا، وهو ظاهر اختيارهما في باب الدعاوىٰ بحثا في الشرح الكبير والروضة.

قال الرافعي هنا في باب الدعاوىٰ إلىٰ الوجه الثالث القائل بالتفصيل فقال (١٣/ ٢١٨): «ولا بأس بوجه التفصيل، ولقد رجحه أبو الحسن العبادي، وبه أجاب السرخسي في «الأمالي»، وتبعه النووي في الروضة (١٢/ ٥٠).

وعدّ الهيتمي في التحفة (١٠/ ٣٢٥) والخطيب في المغني (٤/ ٤٧٩) الوجه الثالث من «القيلات المعتمدة»، وحمل الإسنوي قول الشافعي عليه فقال في المهمات (٩/ ٤١١): «والفتوىٰ علىٰ ما وقع فيه هذا الاختلاف، وهو الذي

باشره الولي، إنما هو الحلف علىٰ وفق ما بحثه الرافعي، فقد نص عليه الشافعي ﷺ في «الأم» وسبقه إليه البغوي في التهذيب (٥/ ٥١١) وتبعه البلقيني كما في تحرير العراقي (٣/ ٧٥٥).

❐ الترجيح

إذا عرفت ذلك فاعلم أن القول الثالث «وهو التحالف إذا ادعىٰ مباشرة سببه» هو الموافق لظاهر نص الشافعي في «الأم».

قال الشافعي في الأم (٦/ ١٨٤ ط. د. رفعت فوزي): «إذا اختلف الرجل والمرأة في المهر قبل الدخول أو بعده، وقبل الطلاق أو بعده، فقال: نكحتك علىٰ ألف، وقالت: بل نكحتني علىٰ ألفين، أو قال: نكحتك علىٰ عبد، وقالت: بل نكحتني علىٰ دار بعينها، ولا بينة بينهما، تحالفا، وهكذا إذا اختلف الزوج وأبو الصبية البكر أو سيد الأمة».

ويدل علىٰ أن الشافعي أراد هذه الصورة ما ذكره من صيغ الاختلاف بين الطرفين والله أعلم.





كتاب العتق

[١٦٤]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٨٧ ط. الحداد) بعد حكاية قولين في تجزئة العبيد للقرعة: «والقولان في استحباب، وقيل: إيجاب».

رجح النووي هنا أن القولان عن الشافعي إنما هما في الاستحباب، لا في الإيجاب، وعليه فكلاهما يجزئ، وفي وجه ضعيف أنهما في الإيجاب، وعليه فلا يجزئ الآخر.

وهذا الذي قاله النووي تبع فيه المحرر (ص ١٧٥٥) فإنه قال: «والظاهر أن هذا الخلاف في الاستحباب دون الاستحقاق».

ونقله الرافعي في الشرح الكبير (١٣/ ٣٦٢-٣٦٣) عن القاضي حسين واختيار الإمام، وهو كذلك في النهاية (١٩/ ٢٣٣)، ونسب القول بالإيجاب لأبي بكر الصيدلاني، وأنه الموافق لإيراد الأكثرين، وتبعه النووي في الروضة (١٢/ ١٤٩).

فتلخص من ذلك أن الأكثرين يقولون بالإيجاب، وأن القاضي حسين والإمام قالا بالاستحباب، ورجح الرافعي قولهما، وتبعه النووي.

○ قال أبو عبد الباري:

الذي نص عليه الشافعي في الأم هو الإيجاب، فإنه حكىٰ القولين ثم رجح القول بالتجزئة ثلاثا مطلقا، فكان ذلك اختياره.

قال الشافعي في الأم (٩٨/ ٢٨٧ ط. د. رفعت فوزي): «وهذا القول أصح، وأشبه بمعنىٰ السنة؛ لأن رسول الله ﷺ جزأهم ثلاثة أجزاء، وهذا القول موافق للحديث، اختلفت قيمهم أو لم تختلف، وذلك أني جعلت لكل واحد منهم حصة من القرعة، فإذا صارت علىٰ الثلاثة أعدت عليهم القرعة، فإن وقعت علىٰ الاثنين عتقا، واستأنفت القرعة علىٰ الخمسة الباقين من السبعة اختلفت قيمهم أو اتفقت، وكذلك إن كانوا ثمانية أو أكثر، ولا يجوز عندي أبداً أن يقرع بين الرقيق قلوا أو كثروا إلا علىٰ ثلاثة أسهم».

وهذا النص صريح في أن هذا للإيجاب، ولهذا قال الأذرعي في القوت (١٢/ ٤٤٣): «وعجب، كيف لم تأت طريقة قاطعة بذلك مع قول الشافعي: ولا يجوز عندي... إلىٰ آخره».

وقول الشافعي هنا في اختيار القول بالتجزئة ثلاثا : «وهذا القول أصح، وأشبه بمعنىٰ السنة» هو الذي في مختصر المزني (٢/ ٧١٨ ط. الداغستاني) ولفظه:

«ويجزؤون ثلاثة أجزاء أصح عندي من أكثر من ثلاثة»، واقتصر عليه المزني، ولم يذكر تتمة كلام الشافعي المتقدمة، فأوهم أنه للاستحباب.

وصحح ابن الرفعة في الكفاية (١٢/ ١٩٦) ما في الأم، ونقل عن أبي الطيب أنه المذهب الصحيح.

وفي مختصر البويطي (ص ١٠٩٧ ط. القره داغي):" ويجزأ الرقيق ثلاثا، ثم يؤمر برجل لم يحضر الرقاع فيخرج كل رقعة علىٰ كل جزء ويعينه، فإن لم يستووا في القيمةعدلوا، وضم قليل الثمن إلىٰ كثير الثمن، وجعلوا ثلاثة أجزاء قلوا أو كثروا ..." فاقتصر عليه لما أنه اختياره.

وإذا ثبت النص عن الشافعي، ووافقه إيراد الأكثرين واختيارهم، كان هو المعتمد بلا ريب، وكان ما في «المنهاج» ضعيفا خالف فيه نص الشافعي في اختيار الإيجاب.

[١٦٥] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٨٨-٤٨٩ ط. الحداد): «فولاؤه له، ثم لعصبته».

جعل النووي هنا الولاء مرتبا فقال: «ثم لعصبته»، فلا يثبت للعصبة إلا بعد موت المعتق، وهو تبع في ذلك المحرر (ص ١٧٥٨) في قوله: «فإذا مات العتيق ولا وارث له من جهة النسب، ورثه المعتِق، وكذا يأخذ الفاضل عن أصحاب

الفروض، فإن لم يكن المعتِق حيًّا فالمال لعصبات المعتِق، الأقرب فالأقرب».

وهذا كالشرح لكلام المنهاج كما قال الأذرعي في القوت (١٢/ ٤٦٣).

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره من الترتيب، وأن الولاء لا يثبت للعصبة إلا بعد موت المعتِق بطريق الإنتقال بالإرث هو أحد وجهين للأصحاب[(١)].

والثاني: أن الولاء يثبت للعصبة مع المعتِق، وإنما يكون مقدما فيما يمكن تقديمه فيه، وهذا الثاني هو الذي صححه السبكي كما في تحرير العراقي (٣/ ٨١١).

وهو الموافق لظاهر نص الشافعي في المسلم يعتق عبدا نصرانيا، ويموت العتيق في حياة المعتِق، وللمعتق أولاد ذكور نصارىٰ علىٰ دين العتيق أنهم يرثونه، وإن كان أبوهم المعتق حيا.

وقد ذكر الشافعي في الأم (٥/ ٢٧٧ ط. د. رفعت فوزي) هذه المسألة في

---

(١) وفي هذا يقول الجويني بعد أن أطلق عزوه للأصحاب (١٦/ ٥٤٢):« وهذا يمكن تعليله بأن العصبات لا حق لهم في الولاء، ولا حق لهم بالولاء، فيقعون من المعتق في حياة المعتق موقع الأجانب، فإذا مات، ورثوا بالولاء، وصار الولاء لهم لحمة كلحمة النسب، فإذ ذاك نضرب عليهم».

كلام طويل، وجعل الولاء والميراث للعصبة إذا قام بالمعتق مانع من الإرث كاختلاف الدينين، مثل الميراث بالنسب إذا قام المانع بالأب ورثه من علىٰ دين الميت، وهو بحث نفيس أورده علىٰ طريقة المناظرة، وما ذكرنا خلاصته.

وهذا هو الذي عزاه ابن المنذر للشافعي مذهبا له، فقال في الإشراف (٤/ ٣٨٠): «وإذا اشترىٰ النصراني عبدا مسلما، أو كان له عبد نصراني، فأسلم بيع عليه، فإن أعتقه، العتق جائز، وولاءه له لقول النبي ﷺ: «الولاء لمن أعتق»، فإن مات المعتق، ومولاه علىٰ دينه، لم يرثه لقول النبي ﷺ: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر»، وميراثه لجماعة المسلمين، إلا أن يكون لمولاه عصبة مسلمون، فإن أقرب الناس من عصبة مولاه يرثه، ويكون المولىٰ ما دام علىٰ النصرانية في معنىٰ من قد مات، فإن أسلم المولىٰ المعتق، ثم مات المولىٰ المعتق، ورثه بالولاء، هذا قول الشافعي، وأهل العراق».

وذكر التقي السبكي أن ما اختاره الشيخان لم يره لغير القاضي حسين، وأطال في تقرير ما في نص الشافعي في «الأم»، فقال في فتاويه (٢/ ٢٤٢): «إذا خلف المعتَق المسلم ابن معتقه الكافر مسلما، والمعتِق حي لا يرثه المسلم، بل يكون الميراث لبيت المال فلم أره لغير القاضي حسين.

وفي الإشراف لابن المنذر: وإذا اشترىٰ النصراني عبدا مسلما، أو كان له عبد نصراني فأسلم بيع عليه، فإن أعتقه فالعتق جائز وولاؤه له، فإن مات المعتق ومولاه علىٰ دينه لم يرثه، وميراثه لجماعة المسلمين، إلا أن يكون لمولاه عصبة مسلمون، فإن أقرب الناس من عصبة مولاه يرثه، ويكون المولىٰ ما دام علىٰ النصرانية في معنىٰ من قد مات، وإن أسلم المولىٰ المعتق ثم مات المولىٰ المعتق ورثه بالولاء.

هذا قول الشافعي وأهل العراق وكان مالك يقول: إذا أعتق المسلم النصراني يرثه. انتهىٰ.

وهكذا قال أبو عبد الله محمد بن علي القلعي في فرائضه، وإذا أعتق المسلم عبدا نصرانيا ثبت له عليه الولاء، فلو مات العبد ورثه من كان نصرانيا من عصبات المولىٰ، ولا يرثه المولىٰ لاختلاف الدين، وكذلك لو أسلم عبد لذمي فطولب بإزالة الملك عنه فأعتقه، ثبت له عليه الولاء، فإن مات ورثه من كان مسلما من عصبات المولىٰ؛ لأن الولاء بمنزلة النسب، فكما أن النسب يثبت بين المسلم والكافر فكذلك الولاء.

وهكذا لو مات مسلم وخلف أبا ذميا وأخاه مسلما، ورثه الأخ دون الأب،

ولا يكون سقوط ميراث الأب مانعا من ثبوت النسب بينهما وكونه أبا، فكذلك هاهنا لا يكون سقوط الميراث باختلاف الدينين مانعا من ثبوت الولاء عليه. انتهىٰ.

وكذا قاله سعد بن عبد الله ابن علوية أبو القاسم الشافعي في المستعمل قال: إذا أعتق المسلم عبدا ذميا، ومات العبد كان له ولاؤه، ويرثه أقرب عصبة مولاه ممن كان علىٰ دينه، أو مولىٰ مولاه، وكذلك إن كان معاهدا أو مستأمنا ولا يرثه المولىٰ لاختلاف الدينين».

وقال الزركشي في المنثور في القواعد (٣/ ٣٢٦): «ونص في الأم علىٰ أن عصبة المعتق الذين علىٰ دين العتيق يرثون العتيق، وإن كان المعتق حيا، فأثبت الشافعي لهم الولاء والميراث به في حياة المعتق».

وهذا هو الذي اختاره الماوردي في الحاوي (١٨/ ٨٧) فقال: «فإن كان في عصبة مولاه من هو علىٰ ملته ورثه بالولاء، وإن كان المولىٰ غير وارث به كالأخوين إذا كانا علىٰ ملة، وأبوهما علىٰ أخرىٰ توارثا دون الأب، وإن تناسبا بالأب».

وفي تحرير الفتاوىٰ للعراقي (٣/ ٨١١): «قوله في «المنهاج»: «فولاؤُه له ثم

لعصبته» يقتضي أنه لا يثبت الولاء للعصبة إلا بعد موت المعتق، وليس كذلك؛ فالولاء ثابت لهم في حياة المعتق علىٰ المذهب المنصوص في «الأم» في المسلم يعتق عبدًا نصرانيًا ويموت العتيق في حياة المعتق وله أولاد ذكور نصارىٰ علىٰ دين العتيق .. أنهم يرثونه وإن كان أبوهم المعتق حيًا، وهو مذكور في «الروضة» وأصلها في الدوريات في الوصايا، ولو لم يثبت لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثوا، ذكره شيخنا في «تصحيح المنهاج».





كتاب التدبير

[١٦٦]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٩١-٤٩٢ ط. الحداد): «ومقيدا كإن متُّ في ذا الشهر أو المرض فأنت حر».

ما رجحه النووي هنا من أن هذا النوع المقيّد تدبير تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٧٦١) في قوله: «... ومقيدا مثل أن يقول «إن متُّ في هذا الشهر» أو «من مرضي هذا» أو «في هذا البلد» فأنت حرٌّ».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي تبعا للرافعي مخالف لنصوص الشافعي في الأم والبويطي.

قال الشافعي في الأم (٩/ ٣١٠ ط. د. رفعت فوزي): «ولو قال: أنت حرٌّ إن متُّ من مرضي هذا، أو في سفري هذا، أو في عامي هذا، فليس هذا بتدبير، قال الشافعي رضي الله عنه: وإذا صح، ثم مات من غير مرضه ذلك لم يكن حرا، والتدبير ما أثبت السيد التدبير فيه للمدبر».

وقال في البويطي (ص ١١١٥ ط. القره داغي): «وإن قال: أنت حرٌّ إن متُّ من مرضي هذا، أو في سفري هذا، أو في عامي هذا، فهذا وصية وليس بتدبير، وإذا صح ثم مات من غير ذلك المرض لم يكن حرا».

وقال الشافعي في الأم (٥/ ٢٤١ ط. د. رفعت فوزي): «ومن أوصىٰ فقال: إن مت من مرضي هذا ففلان - لعبد له - حر، ولفلان كذا وصية، ويتصدق عني بكذا، ثم صح من مرضه الذي أوصىٰ فيه، ثم مات بعده فجأة، أو من مرض غير ذلك المرض بطلت تلك الوصية؛ لأنه أوصىٰ إلىٰ أجل، ومن أوصىٰ له وأعتق علىٰ شرط لم يكن، وكذلك إذا حد في وصيته حدا فقال: إن مت في عامي هذا، أو في مرضي هذا، فمات من مرض سواه بطل».

فنص في هذه المواضع علىٰ أن هذا النوع، أو هذه الصيغة صيغة وصية، وليست صيغة تدبير، وذكر هذه الصيغ في مواضع أخرىٰ من الأم مثل (٥/ ٢٠٤، ٢٤١) و(٩/ ٣٢٣، ٤٣٤)، وأعطاها أحكام الوصية.

وهذا هو الذي عزاه ابن المنذر في الإشراف (٤/ ٤٣٤) و(٧/ ٥٣) والمروزي في اختلاف الفقهاء (ص ٥٠٥) للشافعي.

قال البلقيني في التدريب (٤/ ٤٤٢): «لو قال: «إذا مت ومضىٰ شهر فأنت حر»، فليس بتدبير، بل هو تعليق عتق بصفة علىٰ الأصح المنصوص فيهما».

وفي تحرير العراقي (٣/ ٨١٥) عن البلقيني: «لم أجد للشافعي نصا يخالفه، وحكاه الرافعي ورجح خلافه، وهو ممنوع؛ فقد ظهر أن مذهب الشافعي: أنه وصية يصح الرجوع فيه، وإن لم نر أحدا من الأصحاب قاله».

وقال العراقي في طرح التثريب (٦/ ٢١٣): «إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا ليس تدبيرا، وإنما هو وصية والرجوع عن الوصية جائز».

واعتمده ورجحه الشيخ زكريا الأنصاري في أسنىٰ المطالب (٤/ ٤٦٥) والغرر البهية (٥/ ٣١٣) وخطأ الشيخين في تسمية العتق المعلق بصفة تدبيرا مقيدا بنص البويطي الذي حكاه الرافعي، وقد علمت أن النص في مواضع من الأم، فليكن المعتمد.

وما ذكره البلقيني عن الرافعي هو قوله في الشرح الكبير (١٣/ ٤٠٩-٤١٠): «المسألة الثانية: يصح التدبير مطلقا، وهو أن يعلق العتق بالموت بلا شرط، ويفيد الشرط في الموت؛ مثل أن يقول: إن قتلت، أو مت حتف أنفي، أو مت من مرضي هذا، أو في سفري هذا، أو في هذا الشهر، أو في هذا البلد، فأنت حر، فإن مات علىٰ الصفة المذكورة، فيعتق، وإلا فلا.

وفي «جمع الجوامع» للروياني: أنه قال في «البويطي»: إذا قال: أنت حر إن مت من مرضي هذا، أو في سفري هذا، فمات من مرضه، أو في سفره، كان حرا، لكنه وصية، وليس بتدبير[(١)].

---

(١) قلت: هو في بحر المذهب أيضا (٨/ ٢٤٠).

ونقل القاضي ابن كج مثله عن النص، ويمكن أن يكون هذا مصيرا إلىٰ أن التدبير هو تعليق العتق بمطلق الموت، وأنه لا ينقسم إلىٰ مطلق ومقيد، والظاهر الأول.

وتظهر فائدة الخلاف في الرجوع علىٰ ما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ».

وحذف من الروضة (١٢/ ١٨٧) ما حكاه الرافعي عن الروياني وابن كج.

وشكك الأذرعي في القوت (١٢/ ٤٧٩) ثبوت ذلك عن الشافعي، فإنه حكىٰ ما في الرافعي عن البويطي ثم قال: «لم يصرح بعزوه إلىٰ الشافعي، بل ذكره بعد قوله: قال أبو يعقوب كذا وكذا بنحو عشرة أسطر، وظاهر العطف والسياق أنه من كلام البويطي نفسه».

وتبعه الزركشي في الخادم (ص ٢٨٢-٢٨٢ تحقيق فارس بن متعب المطيري) فقال: «ونقل ابن كج مثله عن النص، وهذا الذي نقله عن البويطي موجود فيه، لكن سياقه يقتضي أنه من كلام البويطي نفسه، لا من كلام الشافعي، وفيه أشياء كثيرة من هذا الجنس، يظن الواقف عليها أنها من كلام الشافعي، ولا يكون كذلك، فإن كان ابن كج أراد بالنص البويطي ففيه ما ذكرنا، وإن كان المراد غيره ظهور نسبته إلىٰ الشافعي».

والجواب عن هذا من وجهين:

الأول: أن النسخ التي بين أيدينا من البويطي علىٰ خلاف تلك الحكاية، فإن فيها: قال الشافعي: «وإذا أوصىٰ بعتق يعتق عنه بعد موته رجع بالكلام، ولا يكون الرجوع في المدبر إلا بالخروج من ملكه»[(١)] ثم ذكر هذا الكلام بعد نحو عشرة أسطر دون أن يكون لأبي يعقوب البويطي ذكر بينهما، فلعله سقط ذلك من نسخته.

الثاني: أن هذا النص موجود في الأم كما سبق نقله، فتبين بذلك أن هذا قول الشافعي.

[١٦٧] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٩٥ ط. الحداد): «ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير علىٰ المذهب».

أطلق النووي هنا أن للحمل حكم أمه إذا دبرها وهو في بطنه، وهذا يقتضي أنه لا فرق في وقت الولادة، وهو تبع في ذلك الرافعي في المحرر (ص ١٧٦٨) ولفظه: «ولو كانت حاملا يوم التدبير، فالأصح أنه يثبت له حكم التدبير».

---

(١) هو هكذا في تحقيق القره داغي (ص ١١١٥)، وتحقيق أيمن السلايمة (ص ١١٦٠ فقرة ٤٠٧٣) وذكرا أنهما حققاها علىٰ ثلاث نسخ.

○ قال أبو عبد الباري:

هكذا أطلق كثير من الأصحاب، وعللوه بأنه يتبعها في كل عقد، ويعتق بإعتاقها، لكن الذي نص عليه الشافعي هو التفصيل.

قال الشافعي في البويطي (ص ١١٢١ط. القره داغي): «وإن كان دبرها وبها حمل، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر فليس بمدبر، وإن جاءت به لستة أشهر فما زاد فهو مدبر».

وهذا النص من الإمام صريح في أنه متىٰ ثبت العلوق قبل التدبير يقينا لم يكن له حكم أمه في التدبير.

واعتمده البلقيني في التدريب (٤/ ٤٤٣): «ولو دبر حاملا، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر، فليس بمدبر، وإن أتت به لستة أشهر فأكثر، فهو مدبر، هكذا نص عليه البويطي، وهو المعتمد».

وقد نقل الولي العراقي في التحرير (٣/ ٨٢٠) عن شيخه البلقيني أنه قال: «ولا نص للشافعي يخالفه، ووجهه أنها حبلت به في حالة لم يتعلق بها الحرية فيها ولا سببها؛ فكان كولد المستولدة قبل الاستيلاد، وهو الأرجح، ولم يطلع الشيخ أبو حامد ومن تبعه علىٰ النص».

وعلىٰ هذا فالذي ينبغي أن يكون عليه المذهب هو التفصيل كما هو نص الإمام، وهو الموافق لما قدمه من ولد المدبرة قبل التدبير من نكاح أو زنا، فإنه بولادته بأقل من ستة أشهر يتبين أنه قبل التدبير.

[١٦٨]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٩٥ ط. الحداد): «وإن باعها صحّ، وكان رجوعا عنه».

ما ذكر النووي هنا من أن بيع الحامل المدبرة رجوع عن تدبير ما في بطنها، تبع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٧٦٨، ١٧٦٩) ولفظه: «فإن باع الأم صح، وكان رجوعا عن تدبير الحمل».

○ قال أبو عبد الباري:

ما أطلقه النووي هنا تبعا للرافعي، ينبغي أن يكون مقيدا فيما إذا نوىٰ بذلك الرجوع عن تدبير الحمل، وإلا فلو باع بدون ذلك لم يصح البيع، وإن استثنىٰ ما في البطن جاز البيع، ثم ينظر في الحمل، فإن أتت به قبل ستة أشهر كان مدبرا وإلا فلا.

قال الشافعي في الأم (٩/ ٣٣٣ ط. د. رفعت فوزي) فقال: «وإذا دبر الرجل ما في بطن أمته، فليس له بيعها إلا أن يريد ببيعها الرجوع عن التدبير ... ولو باع

الذي دبر ولدها أمه وهي حامل به، فقال: أردت الرجوع في تدبيري الولد، كان البيع جائزا، أو قال: لم أرده كان البيع مردودا».

وقال الشافعي في الأم (٩/ ٣٣٣ ط. د. رفعت فوزي): «ولو باع أمة واستثنىٰ ما في بطنها، لم يجز بيعها، وتوقف الأمة من يوم دبر ما في بطنها، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر، فالولد مدبر إن كان دبره، وحر إن كان أعتقه، وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبير، أو العتق، لم يكن مدبرا، ولا حرا».

وقال في البويطي (ص ١١٢١ط. القره داغي) فقال: «وإن رجع في التدبير، وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم رجع، فهو مدبر، فإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يكن مدبرا».

فهذه نصوص الإمام ظاهرة علىٰ أن قو الشافعي في المسألة التفصيل الذي ذكرناه.

وبهذه النصوص تعقبه الزركشي في الخادم (ص ٣٦٠-٣٦١ تحقيق فارس بن متعب المطيري) فقال: «تصحيحه صحة البيع تابع فيه الإمام، ونسبه في البيان للشيخ أبي حامد وأكثر الأصحاب سواء نوىٰ الرجوع أم لا، لأن البيع لا يفتقر إلىٰ النية، لكن نص الشافعي في «الأم» في باب تدبير ما في البطن علىٰ خلافه،

فقال: «وإذا دبر الرجل ما في بطن أمته، فليس له بيعها إلا أن يريد ببيعها الرجوع عن التدبير»، ولهذا قال الماوردي والبغوي: عليه بطلان البيع، ونقله في البحر وقال: هذا أصح عندي، وكذا قال الشيخ أبو محمد في السلسلة: المنصوص أنه إن لم ينو بهذا العقد رجوعا عن تدبير الحمل فالبيع باطل فيهما جميعا».





كتاب الكتابة

[١٦٩]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٤٩٨ ط. الحداد): «وشرطهما: تكليف وإطلاق».

ما ذكره النووي هنا من اشتراط إطلاق التصرف في المكاتب مخالف لما في المحرر، فإنه اشترط إطلاق التصرف في السيد (ص ١٧٧٤) فقال: «ويشترط في السيد المكاتب التكليف والإطلاق، فلا يكاتب الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه».

وقال في المكاتب (ص ١٧٧٥): «ويشترط في المكاتب التكليف» فلم يذكر شرط إطلاق التصرف فيه.

○ قال أبو عبد الباري:

الصواب المعتمد ما في المحرر، ولا يشترط إطلاق التصرف في المكاتب، بل يصح مكاتبة المحجور عليه بالسفه.

قال الشافعي في الأم (٩/ ٣٥٢-٣٥٣ ط. د. رفعت فوزي): «ولا يجوز أن يكاتب الرجل عبدا له مغلوبا علىٰ عقله، ولا عبدا له غير بالغ، لأنه إذا كان مغلوبا علىٰ عقله، أو غير بالغ، فالكتابة باطلة».

وفي مختصر المزني (٢/ ٧٣٧ ط. الداغستاني): «ولا يكون الابتغاء من المجانين والأطفال، ولا تجوز الكتابة إلا علىٰ بالغ، عاقل».

و في مختصر البويطي (ص ١١٢٢ ط. القره داغي): «ولا يجوز أصل الكتابة حتىٰ يكون السيد والعبد بالغين، غير محجور علىٰ السيد، ولا مغلوب علىٰ عقل العبد».

وهذه النصوص صريحة في أنه لا يشترط في العبد أن يكون مطلق التصرف،

وفي تحرير الولي العراقي (٣/ ٨٢٣): «اشتراط الإطلاق في العبد ليس في «المحرر»، ولم يذكره أحد، وعبارة «التنبيه» (ص ١٤٦): «ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدا بالغا عاقلا»، فاقتصر علىٰ التكليف كما في «المحرر» وغيره، وعبارة «الحاوي» (ص ٧٠٣): «كل ما رق» فلم يعتبر وصفا زائدا علىٰ الرق، وكأن سكوته عن اعتبار التكليف فيه؛ لوضوحه».

وقال الخطيب في المغني (٦/ ٤٨٥): «اشتراط الإطلاق في العبد لم يذكره أحد، والذي نصّ عليه فيه الشافعي والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل لا غير، فلا يضر سفهه؛ لأنه لم ينحصر الأداء من كسبه، فقد يؤدي من الزكاة وغيرها».

وتأول له الأذرعي في القوت (١٢/ ٥٣١) فقال: «الذي نص عليه الشافعي

والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل في العبد لا غير، وحينئذ فقول المصنف «وإطلاق» يجب تأويله وتنزيله علىٰ السيد، وقد يقال: يمكن الاحتراز به عما لو كان مأذونا له في التجارة، وقد ركبته الديون، وحجر الحاكم عليه في اكتتابه ليصرفها في ديونه، فلا يصح كتابته في هذه الحالة، وهذا تكلف لم يمر بباله».

[١٧٠]وقال النووي في المنهاج (٣/ ٥٠٥ ط. الحداد): «ولا يصح بيع النجوم، ولا الاعتياض عنها».

ما ذكره النووي هنا من عدم صحة الاعتياض عن نجوم الكتابة ببدل يتراضيان عليه، تبع فيه المحرر (ص ١٧٨٧) ولفظه: «ولا يجوز للسيد بيع نجوم الكتابة قبل أخذها، ولا الاعتياض عنها».

وهو الذي اعتمده الرافعي في فتح العزيز (١٣/ ٥٣٦) وتبعه في الروضة (١٢/ ٢٧٢)، وهذا المنع هو قول الجويني وتبعه الرافعي والنووي.

قال في نهاية المطلب (١٩/ ٤٥٥): «قال الأئمة: الاستبدال عن النجوم يخرج علىٰ بيع النجوم، فإن جوزنا بيعها، جوزنا الاستبدال عنها، وإن لم نجوز بيعها؛ ففي الاستبدال عنها وجهان، والمذهب الذي عليه التعويل منع ضمان النجوم، وهذا يؤكد منع الاستبدال».

○ قال أبو عبد الباري:

والصحيح المعتمد جواز الاعتياض كما نص عليه الشافعي.

قال الشافعي في الأم (٩/ ٤٠٧-٤٠٨ ط. د. رفعت فوزي): «ولو حلت نجومه كلها وهي دنانير، فأراد أن يأخذ بها منه دراهم، أو عرضا يتراضيان به، ويقبضه السيد قبل أن يتفرقا، كان جائزا، وكان حرا إذا قبضه علىٰ أن المكاتب بريء مما عليه، كما لو كان له علىٰ رجل حر دنانير حالة، فأخذ بها منه عرضا أو دراهم يتراضيان بها، وقبض قبل أن يتفرقا جاز، وعتق المكاتب، ولم يتراجعا بشيء».

وتضمن هذا النص جواز ذلك بثلاثة شروط:

الأول: أن تكون النجوم حالة.

الثاني: أن يتراضيا، فلا يجبر السيد ولا المكاتب علىٰ ذلك.

الثالث: التقابض في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين.

وقال في الأم أيضا (٩/ ٣٤٧ ط. د. رفعت فوزي): «إن كاتبه علىٰ دنانير لم يجبره علىٰ أخذ دراهم، وإن كاتبه علىٰ عرض لم يجبره علىٰ أخذ دراهم، وإن كاتبه علىٰ عوض لم يجبره علىٰ أخذ قيمته».

وقضية عدم الإجبار أنهما إذا تراضيا علىٰ أخذ العوض جاز بالشروط التي المذكورة في النقل المتقدم.

وهذا المعنىٰ هو مقتضىٰ كلام النووي في الشفعة من المنهاج (٢/ ٢٢١ ط. الحداد): «وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع، كمبيع، ومهر، وعوض خلع، وصلح دم، ونجوم، وأجرة، ورأس مال سلم».

وقال في الروضة (٥/ ٧٨): «أو جعله المكاتب عوضا عن النجوم، ثبتت الشفعة في كل ذلك». وهو مأخوذ من الشرح الكبير (٥/ ٤٩٧).

قال الإسنوي في المهمات (٦/ ٨٠) تعقيبا علىٰ الرافعي: «وهذا الكلام يقتضي تجويز الاعتياض عن نجوم الكتابة.

وقد ذكر بعده بأسطر قلائل ما يوافقه أيضـًا، وكذلك في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وهو مخالف لما ذكره في باب الكتابة، لكن المذكور هنا هو الصواب». ونحوه عنده (٩/ ٥٠٦-٥٠٧).

وذكر الأذرعي في القوت (١٢/ ٥٩٥) أن ذلك قضية كلام المحاملي والماوردي وابن الصباغ والدارمي وغيرهم من العراقيين، وقال: «إنه الصحيح المنصوص في «الأم».

وقال البلقيني في التدريب (٤/ ٤٥٢): «ويصح اعتياض الحال عن المؤجل علىٰ النص، وكذلك استبدال العين عن المؤجل».

وفي تحرير العراقي (٣/ ٨٢١): «قال شيخنا: وتبع الرافعي في المنع البغوي، ولم يطلعا علىٰ النص، وذكر الرافعي في الشفعة الاعتياض عن النجوم بشقص وأثبت فيه الشفعة، وقال: يؤخذ مثل النجوم أو قيمتها؛ أي: إن كانت متقومة».

وقال ابن الملقن في العجالة (٤/ ١٨٩٣): «كذا صححه الرافعي في شرحه وفاقا للبغوي، لكن الذي نص عليه الشافعي في الأم، في باب قطاعة المكاتب الجواز».

وعلىٰ هذا جرىٰ زكريا الأنصاري في منهج الطلاب (ص ١٩٨) فقال: «وصح اعتياض عن نجوم لا بيعها».

وقال في فتح الوهاب (٢/ ٣٠٥): «وصح اعتياض عن نجوم «للزومها من جهة السيد مع التشوف للعتق، بهذا جزم في الروضة كأصلها في الشفعة، وصوبه الإسنوي لنص الشافعي عليه في الأم وغيرها، وإن جزم الأصل تبعا لما صححه في الروضة وأصلها هنا بعدم صحته، وعلىٰ الأول جرىٰ البلقيني أيضا، قال:

وتبع الشيخان علىٰ الثاني البغوي، ولم يطلعا علىٰ النص».

وخالفهم الخطيب والرملي فصححا ما في المنهاج من المنع.

قال في المغني (٦/ ٤٩٨): «وهذا ما صححاه هنا تبعا للبغوي، وهذا أوجه مما نقله الرافعي في باب الشفعة عن الأصحاب من الجواز لما مر، وإن صوب الإسنوي ما هناك، وجرىٰ عليه شيخنا هنا في منهجه».

وقال الرملي في النهاية (٨/ ٤١٥): «وهذا هو المعتمد، وإن اعتمد الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة من صحته للزومها من جهة السيد مع تشوف الشارع للعتق».

كذا قالا، وقد علمت أن ذلك هو الذي عليه نص الشافعي في الأم، فهو المعتمد.

[١٧١] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٥٠٦ ط. الحداد): «وإن كان ماله غائبا أمهله إلىٰ الإحضار إن كان دون مرحلتين، وإلا فلا».

تبع النووي فيما ذكره الرافعي في المحرر (ص١٧٨٩) ولفظه: «وإن كان ماله غائبا أمهله إلىٰ الإحضار إن كان علىٰ ما دون مسافة القصر، وإن كان علىٰ مسافة القصر لم يلزمه الإمهال».

وكذلك قال في الشرح الكبير (١٣/ ٥١١): «وإن كان ماله غائبا، فقد أطلق الإمام وصاحب الكتاب: للسيد الفسخ، وليحمل علىٰ تفصيل، ذكره ابن الصباغ، وصاحب «التهذيب» وغيرهما ﷺ وهو أنه إن كان علىٰ مسافة القصر، لم يلزمه التأخير إلىٰ أن يحضره؛ لطول المدة، وإن كان علىٰ ما دون مسافة القصر، لزم التأخير إلىٰ أن يحضره». وتبعه النووي في الروضة (١٢/ ٢٥٥).

○ قال أبو عبد الباري:

ذكر الرافعي أن ما ذكره من التفصيل مأخوذ من ابن الصباغ والبغوي وآخرين، وأن الجويني قال بعدم لزوم الانتظار مطلقا، وتبعه الغزالي في الوجيز.

والصواب المعتمد ما قاله الإمام والغزالي ومن تبعهما، لنص الشافعي عليه.

قال الشافعي في الأم (٩/ ٤٢٧ ط. د. رفعت فوزي): «فإن قال: لي شيء غائب أحضره، لم يكن للسلطان أن ينظره إلىٰ قدوم الغائب، لأنه قد ينظره فيفوت العبد بنفسه، ولا يؤدي إليه ماله، وليس هذا كالحر يسأل النظرة في الدين؛ لأن الدين في ذمته لا سبيل علىٰ رقبته، وهذا عبد، إنما يمنع نفسه بأداء ما عليه».

وقال الإسنوي في المهمات (٩/ ٤٩٦): «وتعليله بالفوات يدل علىٰ أنه لا فرق بين المسافتين، واقتصار الرافعي علىٰ النقل عن هذه الطبقة المتأخرة دليل علىٰ أنه لم يظفر فيها شيء للمتقدمين فضلاً عن إمام المذهب».

ووافقه البلقيني، ففي تحرير العراقي (٣/ ٨٤٠): «قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: والتفرقة بين المسافتين مأخوذة مما إذا سلم المبيع ومال المشتري علىٰ مسافة القصر؛ فللبائع الفسخ، ولا يكلف الصبر إلىٰ إحضاره، وإن كان علىٰ ما دونها، فالأصح: أنه كالذي في البلد، وذلك لا يأتي هنا؛ لأنه يزول ضرر البائع بالحجر علىٰ المشتري، وهو متعذر هنا».

وزاد الأذرعي في القوت (١٢/ ٦١٠) نسبته إلىٰ كثيرين منهم الدارمي والإمام والغزالي، قال: «قالوا: لا يجب الإمهال عند غيبة المال».

[١٧٢] وقال النووي في المنهاج (٣/ ٥٠٨ ط. الحداد) في شراء المكاتب من يعتق عليه: «... أو بإذن، ففيه القولان، فإن صح تكاتب عليه».

ما ذكره النووي من حكاية القولين في صحة شراء المكاتب من يعتق عليه بإذن السيد، تابع فيه الرافعي في المحرر (ص ١٧٩٣) ولفظه: «ولو اشترىٰ من يعتق عليه بغير إذن سيده لم يصح، وبإذنه فيه القولان في تبرعاته، فإن جوزناه يكاتب عليه».

○ قال أبو عبد الباري:

ما ذكره النووي من القولين، فهما منصوص ومخرج.

فأما المنصوص: فلا يصح هذا الشراء

قال الشافعي في الأم (٩٨/ ٣٨٩ ط. د. رفعت فوزي): «وليس للمكاتب أن يشتري أحدا يعتق عليه لو كان حرا ولدا، ولا والدا، ومتىٰ اشتراهم فالشراء فيهم مفسوخ، فإن ماتوا في يديه قبل يردهم ضمن قيمتهم؛ لأنه بسبب الشراء، فإن لم يردهم حتىٰ يعتق فالشراء باطل، ولا يعتقون عليه؛ لأنه لا يملكهم بالشراء الفاسد حتىٰ يجدد لهم شراء بعد العتق، فإذا جدده عتقوا عليه قال: وإنما أبطلت شراءهم؛ لأنه ليس له بيعهم، وإذا اشترىٰ ما ليس له بيعه فليس له بشراء نظرًا، إنما هو إتلاف لأثمانهم».

وقال في مختصر المزني (٢/ ٧٥٥ ط. الداغستاني): «وليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لو كان حرا».

وقال في مختصر البويطي (ص ١١٣٤ ط. القره داغي): «ولا يجوز له أن يشتري أحدا من قرابته، فإن اشتراه فالشراء باطل».

ولم يفرق الإمام في هذه النصوص بين إذن السيد وعدم إذنه، بل قضىٰ بالبطلان مطلقا، ولا تصلح المعارضة بالقول المخرج، والتخصيص به فرع عن المعارضة به.

وهذا هو الذي عزاه ابن المنذر للشافعي، فقال في الإشراف (٧/ ٢٣): «ولا يجوز شراء من ذكرنا في قول الشافعي، فإن فعل: كان مفسوخا».

وكذلك الجصاص في اختلاف العلماء (٤/ ٤٢٢) وذكر فيه نص المزني عن الشافعي.

• وأما المخرج: فهو مأخوذ من صحة التبرع بإذن السيد علىٰ الأظهر[١]، وإذا صح ذلك في التبرعات من الهبة ونحوها، فمن باب أولىٰ أن يصح في شراء من يعتق عليه، لأن الهبة لا منفعة للمكاتب فيها، وهاهنا يحصل له به جمال، ويحصل كسب العبد له وأرش الجناية عليه له. كما في البيان للعمراني (٨/ ٤٣٢) عن أبي إسحاق المروزي.

وهذا هو الذي رجحه النووي تبعا للرافعي، وبنىٰ عليه ما بعده من أنه يكاتب عليه، وقد ذكر ذلك التخريج أيضا الماوردي في الحاوي (١٨/ ٢٤٦).

وقال الروياني في البحر (٨/ ٣٥٣): «وإن كان بإذن سيده، قال عامة

---

(١) قال الشافعي في الأم (٨/ ٦٨): «وما ابتدأ المكاتب بإذن سيده من هبة، أو بيع بما لا يتغابن الناس بمثله، فهو له جائز؛ لأنه إنما يمنع من إتلاف ماله لئلا يعجز فيرجع إلىٰ سيده ذاهب المال، فإذا سلم ذلك سيده قبل يفعله، ثم فعله فما صنع فيه مما يجوز للحر جاز له». وفي مختصر المزني (٢/ ٧٥٣):« ولا يهب إلا بإذن سيده».

أصحابنا: فيه قولان كالتبرعات بإذن سيده، وقال أبو إسحاق: يصح ذلك قولا واحداً.

والفرق بينه وبين التبرعات في أحد القولين، أن التبرعات لا تحصل له عوض بوجه، فهي إتلاف محض فلا يصح العوض، وهو أن هذا العبد يصير ملكه، ويكتسب فيستعين بكسبه، وربما يجنىٰ عليه، فيأخذ هو أرش الجناية، ويؤدي ذلك ويعتق هو معه، فتحصل له المنفعة بذلك، فجاز.

والطريقة الأولىٰ أصح، لأن هذا العوض غير مقصود ولا متحقق، ولو كان كما قال أبو إسحاق: لجاز أن يشتريه بغير إذن السيد، وليس هذا بأكثر من الهبة بشرط الثواب، وقد نص الشافعي أنه لا يجوز ذلك علىٰ القول الذي يقول لا يجوز هبته بإذن السيد».





وبهذا انتهىٰ ما علقناه في هذا الكتاب من مواطن الاختلاف بين نصوص الشافعي والمنهاج علىٰ شرطنا المذكور في مقدمة هذا الكتاب، وقد بلغت اثنين وسبعين ومائة مسألة، وليس هذا استيعابا لما فيه من هذه المسائل، فقد يستدرك عليها مسائل أخرىٰ علىٰ شرط الكتاب.

وكان الانتهاء منه ليلة الخميس، الثامن من شهر جمادىٰ الأولىٰ، لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين للهجرة، والموافق للتاسع والعشرين من شهر أكتوبر، لعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد، وذلك بمدينة نيروبي عاصمة كينيا، إحدىٰ دول شرق أفريقيا.

والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لقارئه وكاتبه، إنه نعم المولىٰ ونعم النصير.

وصلىٰ الله وسلم علىٰ نبينا محمد بن عبد الله، سيد الأولين والآخرين، وعلىٰ آله الغر الميامين، وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي



فهرس الموضوعات

العنوان الصفحة

كتاب الجراح ٤٢٠
باب كيفية القصاص ٤٢٠
كتاب الديات ٤٦٤
كتاب دعوى الدم والقسامة ٥٠٦
كتاب البغاة ٥١٩
كتاب الردة ٥٤٢
كتاب الزنا ٥٤٧
كتاب قطع السرقة ٥٦٧
باب قاطع الطريق ٥٨٨
كتاب الأشربة ٦١٢
كتاب الصيال وضمان الولاة ٦٢١
كتاب السير ٦٤٠
كتاب الصيد والذبائح ٦٨٤
كتاب الأضحية ٦٩٢
كتاب الأطعمة ٧٠٤
كتاب المسابقة والمناضلة ٧١٢

كتاب الأيمان ٧٢٢
كتاب النذر ٧٥٣
كتاب القضاء ٧٦٥
باب القسمة ٧٦٩
كتاب الشهادات ٧٧٦
كتاب الدعوىٰ والبينات ٧٩٢
كتاب العتق ٨١٠
كتاب التدبير ٨١٨
كتاب الكتابة ٨٢٧
فهرس الموضوعات ٨٤٠




بغية المحتاج
إلى مواطن الاختلاف
بين نصوص الشافعي والمنهاج
تأليف
أبي عبد الباري الصومالي
د. محمود بن محمد بن السيلي